OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2020

SIMULATION

GRAND ORAL

Sujet n°1 – Commentaire : TC, 11 mars 2019, *EURL La Joly, M. L. c/ Agent judiciaire de l'Etat*

TC, 11 mars 2019, *EURL La Joly, M. L. c/ Agent judiciaire de l'Etat*

Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 décembre 2018, l'expédition de l'ordonnance du 4 décembre 2018 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, saisi d'une demande de l'E.U.R.L. La Joly, représentée par son liquidateur judiciaire Me B...A..., et de M. C...tendant au paiement de la somme de 5 473 453 euros à la société La Joly et de la somme de 300 000 euros à M. C..., a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 14 novembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est déclaré incompétente pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 11 janvier 2019, le mémoire présenté par le ministre des outre-mer, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que l'opération du 28 juillet 2004, effectué sur réquisitions du procureur de la République sur le fondement de l'article 140 du code minier, n'était pas constitutive d'une voie de fait ;

Vu, enregistré le 14 janvier 2019, le mémoire présenté pour l'agent judiciaire de l'Etat, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que l'opération du 28 juillet 2004 n'a pas été constitutive d'une voie de fait et ne constituait pas essentiellement une opération de police judiciaire, qu'elle n'est pas détachable de l'appréciation de la légalité des titres d'exploitation minière et de leur retrait ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à l'E.U.R.L. La Joly, représentée par son liquidateur judiciaire Me B...A..., à M. C..., au ministre de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code minier ; (...)

Considérant qu'après que le préfet de la Guyane eut retiré, par un arrêté du 14 janvier 2004, les trois autorisations d'exploitation pour or qui avaient été délivrées à la société La Joly pour les sites de la Boue Ouest, la Boue Est et de Wapa, sur le territoire de la commune de Régina, des forces de gendarmerie ont procédé, le 28 juillet 2004, à la destruction de matériels appartenant à la société La Joly découverts sur le site de la Boue ; que la société La Joly et M. C..., son associé unique et gérant, ont demandé l'indemnisation par l'Etat du préjudice résultant de ces destructions ; que, par un arrêt du 14 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande indemnitaire comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par une ordonnance du 4 décembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, ultérieurement saisi de la demande indemnitaire, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;

Mais considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 140 du code minier, applicable à la date des faits en cause : " Le procureur de la République peut ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre la ou les infractions constatées par procès-verbal lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de cette ou de ces infractions " ;

Considérant que si les destructions à raison desquelles a été formée la demande indemnitaire en litige ont abouti à l'extinction d'un droit de propriété de la société La Joly, elles sont intervenues en application des dispositions précitées de l'article 140 du code minier ; qu'elles ne peuvent, par suite, être qualifiées de voie de fait ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que ces destructions ont été ordonnées, sur le fondement de l'article 140 du code minier, par réquisitions du procureur de la République en date du 27 juillet 2004 et sur instructions données sur place par le substitut du procureur de la République le 28 juillet 2004 ; que la demande indemnitaire met ainsi en cause des actes se rattachant directement à une procédure judiciaire et relève, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la demande de la société La Joly et de M.C....

Article 2 : L'ordonnance du 4 décembre 2018 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'E.U.R.L. La Joly, représentée par son liquidateur judiciaire Me B...A..., à M.C..., à l'agent judiciaire de l'Etat, au ministre de l'économie et des finances et au ministre des outre-mer.

PROPOSITION DE CORRIGÉ TC, 11 mars 2019, *EURL La Joly, M. L. c/ Agent judiciaire de l'Etat*

La société La Joly était titulaire de trois autorisations d'exploitation, délivrées le 15 novembre 2000 et le 2 décembre 2002, lui permettant de rechercher de l'or en Guyane. Ces autorisations, qui avaient été délivrées à la société et à son associé unique par le préfet de la Guyane, avaient été retirées quelques mois avant leur terme à la suite à d'un arrêté du 14 janvier 2004. Après ce retrait, la gendarmerie avait conduit une opération sur un des sites d'exploitation anciennement exploités par la société La Joly. Le 28 juillet 2004, les gendarmes participant à cette opération avaient détruit le matériel de la société La Joly qui se trouvait sur le site.

Après une première série de contentieux portant sur la légalité de l'arrêté du 14 janvier 2004, l'associé unique de la société La Joly et le liquidateur judiciaire de celle-ci avaient saisi les juridictions administratives d'une demande indemnitaire en recherchant la responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité du retrait des autorisations minières et des destructions effectuées le 28 juillet 2004. Par un arrêt du 14 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux avait rejeté au fond les conclusions indemnitaires relatives à l'illégalité du retrait des autorisations d'exploitation et a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent les conclusions relatives à l'indemnisation des destructions. Les requérants avaient ensuite saisi le tribunal de grande instance de Paris de leur demande indemnitaire. Par une ordonnance du 4 décembre 2018, le juge de la mise en état a saisi le Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, en prévention d'un conflit négatif de compétence.

La question soumise au Tribunal des conflits portait sur l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande indemnitaire formée par une société qui, après avoir été titulaire d'autorisations d'exploitation de l'or en Guyane, avait vu, après le retrait de ces autorisations, son matériel détruit par les gendarmes agissant sur réquisitions du procureur de la République. Après avoir rappelé les critères de la voie de fait, tels que précisés par le juge des conflits dans sa jurisprudence *Bergoend* (I), le tribunal, tout en constatant son inexistence, admet logiquement la compétence du juge judiciaire dès lors que l'opération se rattachait à une procédure judiciaire (II).

I – Un rappel didactique des critères prétoriens de la voie de fait

Faisant application de sa propre jurisprudence, le Tribunal des conflits rappelle les critères de la voie de fait (A), laquelle s'exonère des règles régissant la répartition des compétences entre juridiction administrative et juridiction judiciaire puisqu'elle constitue, classiquement, un bloc de compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (B).

A – Une application classique de la jurisprudence *Bergoend*

Le Tribunal rappelle qu'il ne peut y avoir voie de fait « que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité

administrative » (TC, 17 juin 2013, *M. Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman*, n° 3911). Le comportement de l'administration ne peut ainsi être qualifié de voie de fait que s'il porte atteinte à la liberté individuelle, entendue au sens de l'article 66 de la Constitution (TC, 12 février 2018, *M. Ndary Gueye c/ Agent judiciaire de l'État*, n° 4110) ou s'il a pour effet une extinction du droit de propriété.

B – Une exception entérinée au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires

Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, proclamé par la loi des 16 et 24 août 1790 relative à l'organisation judiciaire et réaffirmé par la loi du 16 fructidor an III (2 sept. 1795), interdit toute compétence des tribunaux judiciaires pour juger de l'action administrative et des administrateurs en raison de leurs fonctions.

L'application absolutiste du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires (ce qu'Hauriou appelait un « luxe de précautions ») connait toutefois des exceptions. À titre d'exemple, nous savons que le juge pénal bénéficie d'une plénitude de juridiction, d'abord reconnue pour les actes réglementaires et non pour les actes individuels (TC, 5 juillet 1951, *Avranches et Desmarets*, rec., p. 638), et ensuite étendue à l'ensemble des actes administratifs par le législateur dès lors que de l'examen de ces actes *« dépend la solution du procès pénal »* (C. pén., art. 111-5). De même, le juge judiciaire dispose d'une plénitude de compétence pour constater et sanctionner toute voie de fait administrative (TC, 30 octobre 1947, *Barinstein et Lemonnier*, rec., p. 511).

Le Conseil d'État dans son ordonnance du 23 janvier 2013 *Commune de Chirongui,* a certes accepté d'enjoindre à l'administration de faire cesser une atteinte à une liberté fondamentale constitutive d'une voie de fait, consacrant dès lors expressément l'exercice de deux compétences juridictionnelles concurrentes en cette matière qui était supposée être, jusqu'alors, l'apanage du juge judiciaire. L'opération de réduction du champ de la voie de fait à laquelle il a été procédé dans l'arrêt *Bergoend* apparaît, à cet égard, comme un moyen bienvenu de clarifier et de simplifier la répartition des compétences juridictionnelles. La compétence exclusive du juge judiciaire est certes ramenée à la portion congrue mais elle est réaffirmée. L'exception au principe de séparation des autorités perdure, ce que rappelle le juge des conflits dans l'arrêt ici commenté.

II – La reconnaissance par le juge des conflits de la compétence du juge judiciaire

Le Tribunal des conflits, assez logiquement, refuse d'admettre l'existence d'une voie de fait (A). L'opération menée le 28 juillet 2014 par les gendarmes se rattachant toutefois à une procédure judiciaire, il considère que le juge judiciaire doit ici être reconnu compétent (B).

A – L'absence d'identification d'une voie de fait

Le droit de propriété reste invocable, mais c'est uniquement en cas d'« extinction » et non plus d'« atteinte grave » à celui-ci que la théorie de la voie de fait peut être actionnée. Celle-ci suppose donc une dépossession définitive du droit de propriété. Affirmée peu de fois, cette condition a notamment été développée dans l'arrêt *M. et Mme Panizzon* rendu par le Tribunal des conflits le 9 décembre 2013.

La Cour de cassation, dans un arrêt récent (Civ. 3^{e}, 18 janv. 2018, n° 16-21.993), fait directement référence à cette condition de dépossession définitive pour déduire l'existence ou non d'une extinction du droit de propriété. La haute juridiction, après avoir précisé que la remise en état des lieux était

possible, confirme la décision de la cour d'appel, qui en a déduit qu'en l'absence de dépossession définitive, « l'emprise irrégulière n'avait pas pour effet l'extinction du droit de propriété », de sorte que le juge judiciaire était incompétent pour connaître de l'action.

Dans l'arrêt qui nous occupe, le juge des conflits constate que les destructions du matériel de la société La Joly emportaient bien l'extinction de son droit de propriété. Toutefois, le Tribunal juge que ces destructions ne peuvent cependant pas être qualifiées de voie de fait dès lors qu'elles sont intervenues en application du troisième alinéa de l'article 140 du code minier alors en vigueur, qui dispose que « le procureur de la République peut ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre la ou les infractions constatées par procès-verbal lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de cette ou de ces infractions». La restriction de la première condition de la voie de fait, relative à ses effets, n'a pas conduit le Tribunal des conflits à supprimer la seconde, exigeant une illégalité particulièrement grave commise par la puissance publique, laquelle n'est en l'espèce pas constituée. En d'autres termes, les effets de la voie de fait restent liés à « l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière » ou à une décision « manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative » (TC, 3 février 2014, n° 3943, *Mme P. c/ Préfet de police*).

B – Une compétence du juge judiciaire néanmoins consacrée

Alors même que la voie de fait n'est pas reconnue, le Tribunal juge que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire dès lors que l'opération menée le 28 juillet 2014 par les gendarmes se rattachait directement à une procédure judiciaire pour avoir été conduite sur réquisition du procureur de la République et sur instructions données sur place par un de ses substituts.

On sait que le Tribunal des conflits a posé le principe de la distinction entre les actes relatifs à l'organisation même du service public de la justice, qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative, et les actes relatifs à l'exercice de la fonction juridictionnelle et au fonctionnement du service public judiciaire ainsi que les conséquences dommageables pouvant en résulter, qui relèvent de la compétence du juge judiciaire (TC, 27 novembre 1952, *Préfet de la Guyanne*, n° 1420, rec., p. 642 ; TC, 28 avril 2003, *Lavier*, n° 3353). Il a, en outre, énoncé à plusieurs reprises le principe selon lequel « les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire » (TC, 2 juillet 1979, *Agelasto*, n° 02134 ; TC, 19 novembre 2001, *Visconti*, n° 3255 ; TC, 6 juin 2011, *M. B c/ Département de l'Essonne*, n° 3795 ; TC, 15 avril 2013, *M. Imbert c/ Agent judiciaire du Trésor*, n° 3895 ; TC, 8 décembre 2014, *Mme Elsa Djebar*, n° 3981).

Le Conseil d'État (CE, 12 juin 1968, *Préfet de police c/ Sinègre*, n° 71545, s'agissant de la non-restitution d'un permis de conduire à l'issue d'une mesure de suspension ; CE, 6 novembre 1968, *Morel*, n° 70618, s'agissant de la responsabilité de l'État recherchée en raison des circonstances de l'accomplissement, par le service des domaines, de sa mission de séquestre ; CE, 13 janvier 1992, *Grasset*, n° 116218, s'agissant de la disparition de documents comptables placés sous scellés) et la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 18 mai 2005 : pourvoi n° 03-12.746, s'agissant de la disparition de scellés ; Cass. civ. 1ère, 9 juillet 2008 : Bull. civ. I, n° 196, s'agissant de la destruction d'objets saisis) retiennent aussi la compétence des juridictions judiciaires pour connaître des actions en responsabilité en cas de non-

restitution ou de disparition d'objets placés sous-main de justice.

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2020

SIMULATION

GRAND ORAL

Sujet n°2 – Dissertation :
La voie de fait administrative et le juge

Corrigé sujet n° 2 - La voie de fait administrative et le juge

Parce qu'elle ne semble reposer sur aucune justification juridique solide et qu'elle s'exonère des règles régissant la répartition des compétences entre juridiction administrative et juridiction judiciaire, la théorie de la voie de fait a été, depuis sa création, sujette à de fortes critiques. Alors qu'elle constitue, classiquement, un bloc de compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, son champ d'application a été sensiblement restreint. Ce resserrement profite, à l'évidence, au juge administratif en ce qu'il permet de lui transférer le contentieux d'atteinte à certaines libertés dont, jusqu'à présent, la protection était supposée mieux assurée par le juge judiciaire.

Il apparaît donc, au fur et à mesure que se réduit la voie de fait, qu'est altérée corollairement la compétence de principe du juge judiciaire en tant que protecteur des droits et libertés. Une lecture restrictive de la voie de fait a ainsi été consacrée par les différentes juridictions (I). Elle a permis de clarifier la répartition des compétences en matière de protection des libertés, dans un sens incontestablement favorable au juge administratif (II).

I – La redéfinition prétorienne des contours de la voie de fait

La redéfinition de la voie de fait conduit, certes, à une réduction substantielle de son champ d'application (A). Elle permet néanmoins, en renforçant son assise constitutionnelle, de la faire reposer sur un fondement juridique désormais moins incertain (B).

A – La limitation du champ de la voie de fait

Deux conditions ont initialement été identifiées par les tribunaux pour caractériser une voie de fait. La première exigeait que l'administration ait porté une atteinte grave à une liberté fondamentale ou au droit de propriété. La seconde imposait la commission d'une illégalité manifeste par l'administration, au point pour celle-ci de sortir de la voie « de droit », la voie légale, laquelle s'opposait donc à la voie « de fait ».

Selon le juge des conflits, une action administrative ne peut désormais constituer une voie de fait que si elle conduit à « l'extinction du droit de propriété » ou si elle porte atteinte à une « liberté individuelle » (TC, 17 juin 2013, n° 3911, *Bergoend c/ Sté ERDF Annecy Léman*). Sont dès lors exclues du champ de la voie de fait de nombreuses atteintes qui en faisaient préalablement partie. Ainsi, si la notion de liberté fondamentale est d'appréhension large, comme le démontre la jurisprudence issue de l'exercice du référé-liberté, celle de liberté individuelle se veut bien plus exigeante, excluant par définition les libertés dites collectives. C'est ce qu'a clairement jugé la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 19 mars 2015, n° 14-14571) en estimant *« que la liberté syndicale n'entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, l'atteinte qui lui est prétendument portée n'est pas susceptible de caractériser une voie de fait »*. Certes, le droit de propriété reste invocable, mais c'est uniquement en cas d' « extinction » et non plus d'« atteinte grave » à celui-ci que la théorie de la voie de fait pourra être actionnée.

La restriction de la première condition de la voie de fait, relative à ses effets, n'a pas conduit le Tribunal des conflits à supprimer la seconde, exigeant une illégalité particulièrement grave commise par la puissance publique. En d'autres termes, les effets de la voie de fait restent liés à « l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière » ou à une décision « manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative » (TC, 3 février 2014, n° 3943, *Mme P. c/ Préfet de police*).

B – Le renforcement de l'assise constitutionnelle de la voie de fait

La redéfinition de la voie de fait a incontestablement pour effet d'en réduire le champ de manière significative. Toutefois, elle permet d'octroyer au mécanisme une assise constitutionnelle précise qui lui manquait jusqu'à présent et qui faisait dire à de nombreux auteurs que ses soubassements théoriques étaient pour le moins porteurs d'incertitudes.

Le droit de propriété est ainsi toujours concerné mais c'est uniquement en cas d'« extinction » que le juge judicaire sera dorénavant susceptible d'être saisi. L'implantation d'un ouvrage public sur une propriété privée ne provoque dès lors pas une extinction du droit de propriété, et donc une voie de fait, mais seulement une atteinte à celui-ci par l'apparition d'une servitude (Cass. 3e civ., 11 mars 2015, n° 13-24.133). Cette conception stricte du rôle du juge judiciaire en matière de protection de la propriété privée est inspirée de celle défendue par le Conseil constitutionnel qui avait notamment considéré qu'aucun « principe de valeur constitutionnelle n'impose que, en l'absence de dépossession, l'indemnisation des préjudices causés par les travaux ou l'ouvrage public (...) relève de la compétence du juge judiciaire » (CC, 13 décembre 1985, n° 85-198 DC). Quant aux libertés, elles sont dorénavant bornées à la « liberté individuelle » dans son acception singulièrement réductrice issue de l'article 66 de la Constitution tel qu'il est aujourd'hui interprété par le Conseil constitutionnel (CC, 13 mars 2003, n° 2003-467 DC).

La Cour de cassation n'a pas hésité à confirmer ce basculement sémantique et donc le rattachement de la voie de fait au champ de la compétence constitutionnelle des juridictions judiciaires. Se ralliant à la conception restrictive de la voie de fait consacrée par le Tribunal des conflits, elle considère que ne peuvent caractériser une voie de fait ni l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée, car elle ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'Administration (Cass. 3e civ., 11 mars 2015, n° 13-24.133), ni l'atteinte prétendument portée à la liberté syndicale, cette dernière n'entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution (Cass. 1ère civ., 19 mars 2015, n° 14-14571).

II - Une clarification subséquente des compétences juridictionnelles en matière d'atteintes aux libertés et au droit de propriété

La restriction affectant la voie de fait conduit à admettre la compétence exclusive du juge judiciaire en la matière (A). Mais c'est précisément parce que les contours de celle-ci sont considérablement réduits que le juge administratif dispose désormais d'une compétence renforcée pour connaître des hypothèses d'atteintes aux libertés et au droit de propriété maintenant soustraites à la compétence judiciaire (B).

A – Une confirmation ostensible : la compétence exclusive du JJ en matière de voie de fait

Le référé-liberté a été institué par la loi du 30 juin 2000 afin d'offrir au juge administratif des pouvoirs équivalents à ceux conférés depuis longtemps au juge judiciaire. En l'absence d'outil mis à la disposition du juge administratif, les victimes d'une atteinte grave à leur droit de propriété ou à une liberté fondamentale avaient en effet tendance à saisir de manière systématique le juge des référés judiciaire en invoquant la voie de fait. Et les juridictions de l'ordre judiciaire n'hésitaient pas à reconnaître leur propre compétence, au point parfois de semer le trouble en imposant une conception excessivement large de la voie de fait (TC, 9 juin 1986, n° 02434, *Eucat*).

Le Tribunal des conflits a considéré que, contrairement au référé-liberté mis en œuvre lorsque l'administration agit « dans l'exercice d'un de ses pouvoirs », une décision est constitutive d'une voie

de fait « à la condition [...] que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative » (TC, 23 octobre 2000, n° 03227, *Préfet de police c/ Boussadar*). Pourtant, la loi du 30 juin 2000 a été interprétée par le juge administrative de manière fort extensive, au point de s'autoriser à intervenir dans un domaine que le législateur avait souhaité lui interdire de connaître, notamment au titre du référé mesures utiles (CE, 12 mai 2010, n° 333565, *Alberigo*). Cette concurrence fut nettement renforcée par le Conseil d'État dans son ordonnance du 23 janvier 2013 (CE, ord. réf., 23 janvier 2013, n° 365262, *Commune de Chirongui*). À l'occasion de cette affaire, le juge du référé-liberté accepta d'enjoindre à l'administration de faire cesser une atteinte à une liberté fondamentale constitutive d'une voie de fait, consacrant dès lors expressément l'exercice de deux compétences juridictionnelles concurrentes en cette matière qui était supposée être, jusqu'alors, l'apanage du juge judiciaire.

B – Une conséquence discrète : le renforcement du rôle du juge administratif

L'opération de réduction du champ de la voie de fait à laquelle il a été procédé apparaît manifestement comme un moyen bienvenu de clarifier et de simplifier la répartition des compétences juridictionnelles. La compétence exclusive du juge judiciaire est certes ramenée à la portion congrue mais elle est réaffirmée. Elle repose au surplus sur une assise constitutionnelle solide, ce que juge administratif ne saurait ignorer. Le recul du juge administratif n'est toutefois qu'apparent puisqu'il se voit attribuer, du fait de la conception resserrée de la voie de fait, une compétence de principe pour constater, suspendre, annuler et faire cesser les atteintes portées par l'administration au droit de propriété et aux libertés fondamentales exclues du champ de la liberté individuelle. Celles-ci peuvent être sanctionnées d'autant plus aisément par le juge administratif du référé-liberté qu'il a donné de la notion de liberté fondamentale une définition particulièrement large.

La notion d'emprise irrégulière, qui présente des éléments constitutifs partiellement communs avec la voie de fait, en est une illustration éclairante. Le Conseil d'État ayant très tôt jugé que le droit de propriété est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 Code de justice administrative (CE, 29 mars 2002, n° 243338, *SCI Stephaur*), il n'est pas illogique qu'ait été remise en cause la place de la théorie de l'emprise irrégulière en tant que chef de compétence du juge judiciaire. La compétence du juge administratif a ainsi été étendue à la réparation des conséquences dommageables des emprises irrégulières qui ne procèderaient pas à une extinction du droit de propriété (T. confl., 9 décembre 2013, n° 3931, *M. et Mme Panizzon*).

Sans doute faut-il voir dans ces évolutions successives un message adressé aux justiciables selon lequel le juge administratif est désormais définitivement un juge aussi fondé à protéger les droits et libertés que son homologue judiciaire...

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2020

SIMULATION

GRAND ORAL

Sujet n°3 – Argumentation:
Soutenez que la voie de fait est
« présente là où on l'attend le moins, perturbatrice au-delà de l'acceptable ».

Corrigé sujet n°3 - Soutenez que la voie de fait est
« présente là où on l'attend le moins, perturbatrice au-delà de l'acceptable ».

« La Folle du Logis, présente là où on l'attend le moins, perturbatrice au-delà de l'acceptable ».

Cette formule lapidaire du Professeur Chapus (R. Chapus, Droit administratif général, Tome1, Montchrestien, Coll. Domat Droit public, 15ème éd., 2001, p. 533) nous rappelle que la voie de fait a toujours suscité la controverse, de par son existence mais aussi en raison de la singularité de son régime, dérogatoire au principe fondamental de séparation des autorités administratives et judiciaires.

Alors qu'elle constitue, classiquement, un bloc de compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, son champ d'application a été sensiblement restreint. Ce resserrement profite, à l'évidence, au juge administratif en ce qu'il permet de lui transférer le contentieux d'atteinte à certaines libertés dont, jusqu'à présent, la protection était supposée mieux assurée par le juge judiciaire.

Il apparaît donc, au fur et à mesure que se réduit la voie de fait, qu'est altérée corollairement la compétence de principe du juge judiciaire en tant que protecteur des droits et libertés. Une lecture évolutive de la voie de fait a ainsi été consacrée (I), qui a eu pour effet de redéfinir la répartition des compétences en matière de protection des libertés (II).

I – Les contours évolutifs de la voie de fait

La redéfinition de la voie de fait a eu pour conséquence de réduire de façon substantielle son champ d'application (A). Elle a néanmoins eu pour effet de la faire reposer sur un fondement théorique désormais moins fragile (B).

A – Les restrictions affectant le champ de la voie de fait

Deux conditions ont initialement été identifiées par les tribunaux pour caractériser une voie de fait. La première exigeait que l'administration ait porté une atteinte grave à une liberté fondamentale ou au droit de propriété. La seconde imposait la commission d'une illégalité manifeste par l'administration, au point pour celle-ci de sortir de la voie « de droit », la voie légale, laquelle s'opposait donc à la voie « de fait ».

Selon le juge des conflits, une action administrative ne peut désormais constituer une voie de fait que si elle conduit à « l'extinction du droit de propriété » ou si elle porte atteinte à une « liberté individuelle » (TC, 17 juin 2013, n° 3911, *Bergoend c/ Sté ERDF Annecy Léman*). Sont dès lors exclues du champ de la voie de fait de nombreuses atteintes qui en faisaient préalablement partie. Ainsi, si la notion de liberté fondamentale est d'appréhension large, comme le démontre la jurisprudence issue de l'exercice du référé-liberté, celle de liberté individuelle se veut bien plus exigeante, excluant par définition les libertés dites collectives. C'est ce qu'a clairement jugé la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 19 mars 2015, n° 14-14571) en estimant *« que la liberté syndicale n'entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, l'atteinte qui lui est prétendument portée n'est pas susceptible de caractériser une voie de fait »*. Certes, le droit de propriété reste invocable, mais c'est uniquement en cas d' « extinction » et non plus d'« atteinte grave » à celui-ci que la théorie

de la voie de fait pourra être actionnée.

La restriction de la première condition de la voie de fait, relative à ses effets, n'a pas conduit le Tribunal des conflits à supprimer la seconde, exigeant une illégalité particulièrement grave commise par la puissance publique. En d'autres termes, les effets de la voie de fait restent liés à « l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière » ou à une décision « manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative » (TC, 3 février 2014, n° 3943, *Mme P. c/ Préfet de police*).

B – La redéfinition des soubassements théoriques de la voie de fait

La disparition de la voie de fait est depuis longtemps prophétisée, notamment en raison de son soubassement théorique fragile. Il est traditionnellement expliqué que la compétence judiciaire à l'égard des actes ou opérations constitutifs de voie de fait est la conséquence logique de la dénaturation de l'action administrative qu'ils manifestent. En se dénaturant, l'Administration perd le bénéfice du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et donc celui de son juge particulier. Comme l'a expliqué Laferrière, « si l'Administration portait atteinte à l'exercice d'un droit individuel entièrement soustrait à son intervention (...) il n'y aurait pas à proprement parler acte administratif, mais une voie de fait qui ne saurait faire obstacle à la compétence judiciaire » (E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux : Berger-Levrault, 2e éd., t. 1, p. 530).

Mais c'est aussi la panoplie efficace des pouvoirs reconnus au juge judiciaire des référés qui a longtemps conduit les justiciables à préférer le saisir plutôt que son homologue administratif. Hauriou dénonçait déjà la dissymétrie des procédures : « le malheur n'est pas qu'il y ait une juridiction administrative ni qu'elle soit compétente en ces matières ; le malheur est que cette juridiction administrative (...) soit insuffisamment outillée et que, notamment, il n'y ait pas devant elle, pour de semblables occasions, de procédure de référé » (M. Hauriou, note sous T. confl., 2 déc. 1902, Sté immobilière de Saint Just : S. 1904, III, 17).

La redéfinition par le juge des conflits de la voie de fait permet désormais d'octroyer au mécanisme une assise constitutionnelle précise qui lui manquait jusqu'à présent et qui faisait dire à de nombreux auteurs que ses soubassements théoriques étaient pour le moins porteurs d'incertitudes.

Le droit de propriété est ainsi toujours concerné mais c'est uniquement en cas d'« extinction » que le juge judicaire sera dorénavant susceptible d'être saisi. L'implantation d'un ouvrage public sur une propriété privée ne provoque dès lors pas une extinction du droit de propriété, et donc une voie de fait, mais seulement une atteinte à celui-ci par l'apparition d'une servitude (Cass. 3e civ., 11 mars 2015, n° 13-24.133). Cette conception stricte du rôle du juge judiciaire en matière de protection de la propriété privée est inspirée de celle défendue par le Conseil constitutionnel qui avait notamment considéré qu'aucun « principe de valeur constitutionnelle n'impose que, en l'absence de dépossession, l'indemnisation des préjudices causés par les travaux ou l'ouvrage public (...) relève de la compétence du juge judiciaire » (CC, 13 décembre 1985, n° 85-198 DC). Quant aux libertés, elles sont dorénavant bornées à la « liberté individuelle » dans son acception singulièrement réductrice issue de l'article 66 de la Constitution tel qu'il est aujourd'hui interprété par le Conseil constitutionnel (CC, 13 mars 2003,

n° 2003-467 DC).

II - Une réévaluation subséquente des compétences juridictionnelles en matière d'atteintes aux libertés et au droit de propriété

La restriction affectant la voie de fait conduit à admettre la compétence exclusive du juge judiciaire en la matière (A). Mais c'est précisément parce que les contours de celle-ci sont considérablement réduits que le juge administratif dispose désormais d'une compétence renforcée pour connaître des hypothèses d'atteintes aux libertés et au droit de propriété maintenant soustraites à la compétence judiciaire (B).

A – Une confirmation ostensible : la compétence exclusive du JJ en matière de voie de fait

Le référé-liberté a été institué par la loi du 30 juin 2000 afin d'offrir au juge administratif des pouvoirs équivalents à ceux conférés depuis longtemps au juge judiciaire. En l'absence d'outil mis à la disposition du juge administratif, les victimes d'une atteinte grave à leur droit de propriété ou à une liberté fondamentale avaient en effet tendance à saisir de manière systématique le juge des référés judiciaire en invoquant la voie de fait. Et les juridictions de l'ordre judiciaire n'hésitaient pas à reconnaître leur propre compétence, au point parfois de semer le trouble en imposant une conception excessivement large de la voie de fait (TC, 9 juin 1986, n° 02434, *Eucat*).

Le Tribunal des conflits a considéré que, contrairement au référé-liberté mis en œuvre lorsque l'administration agit « dans l'exercice d'un de ses pouvoirs », une décision est constitutive d'une voie de fait « à la condition [...] que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative » (TC, 23 octobre 2000, n° 03227, *Préfet de police c/ Boussadar*). Pourtant, la loi du 30 juin 2000 a été interprétée par le juge administrative de manière fort extensive, au point de s'autoriser à intervenir dans un domaine que le législateur avait souhaité lui interdire de connaître, notamment au titre du référé mesures utiles (CE, 12 mai 2010, n° 333565, *Alberigo*). Cette concurrence fut nettement renforcée par le Conseil d'État dans son ordonnance du 23 janvier 2013 (CE, ord. réf., 23 janvier 2013, n° 365262, *Commune de Chirongui*). À l'occasion de cette affaire, le juge du référé-liberté accepta d'enjoindre à l'administration de faire cesser une atteinte à une liberté fondamentale constitutive d'une voie de fait, consacrant dès lors expressément l'exercice de deux compétences juridictionnelles concurrentes en cette matière qui était supposée être, jusqu'alors, l'apanage du juge judiciaire.

L'opération de réduction du champ de la voie de fait à laquelle il a été procédé par le juge des conflits apparaît manifestement comme un moyen bienvenu de clarifier et de simplifier la répartition des compétences juridictionnelles. La compétence exclusive du juge judiciaire est certes ramenée à la portion congrue mais elle est réaffirmée. Elle repose au surplus sur une assise constitutionnelle solide, ce que juge administratif ne saurait ignorer.

B – Une conséquence discrète : le renforcement du rôle du juge administrative

Le recul du juge administratif n'est toutefois qu'apparent puisqu'il se voit attribuer, du fait de la conception resserrée de la voie de fait, une compétence de principe pour constater, suspendre,

annuler et faire cesser les atteintes portées par l'administration au droit de propriété et aux libertés fondamentales exclues du champ de la liberté individuelle. Celles-ci peuvent être sanctionnées d'autant plus aisément par le juge administratif du référé-liberté qu'il a donné de la notion de liberté fondamentale une définition particulièrement large.

La notion d'emprise irrégulière, qui présente des éléments constitutifs partiellement communs avec la voie de fait, en est une illustration éclairante. Le Conseil d'État ayant très tôt jugé que le droit de propriété est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 Code de justice administrative (CE, 29 mars 2002, n° 243338, *SCI Stephaur*), il n'est pas illogique qu'ait été remise en cause la place de la théorie de l'emprise irrégulière en tant que chef de compétence du juge judiciaire. La compétence du juge administratif a ainsi été étendue à la réparation des conséquences dommageables des emprises irrégulières qui ne procèderaient pas à une extinction du droit de propriété (T. confl., 9 décembre 2013, n° 3931, *M. et Mme Panizzon*).

Sans doute faut-il voir dans ces évolutions successives un message adressé aux justiciables selon lequel le juge administratif est désormais définitivement un juge aussi fondé à protéger les droits et libertés que son homologue judiciaire. S'il reste un rouage du pouvoir, par le lien organique et fonctionnel qu'il entretient avec l'administration, il n'en est pas moins devenu un véritable contre-pouvoir, ostensiblement protecteur des libertés face à cette même administration. A ce titre, les évolutions affectant la voie de fait suggèrent que la juridiction administrative est désormais, au même titre que le juge judiciaire et comme avait pu le constater le Professeur Chapus, une véritable *« juridiction des droits de l'homme ».*

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2020

SIMULATION

GRAND ORAL

<u>Sujet n°4</u> – Commentaire:

CE, 9 novembre 2015,

« Alliance générale contre le racisme et le respect de l'identité française et chrétienne »

CE, 9 novembre 2015, « Alliance générale contre le racisme et le respect de l'identité française et chrétienne »

(...) 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même circulaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que le recours formé à l'encontre des dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;

3. Considérant qu'après avoir rappelé le contexte général dans lequel s'inscrit la représentation du spectacle « Le Mur » de M. M'bala M'bala, la circulaire attaquée du ministre de l'Intérieur prescrit aux préfets l'interprétation qu'il convient de faire des textes et de la jurisprudence relative aux cas dans lesquels la préservation de l'ordre public justifie que soient prises des mesures d'interdiction de certaines représentations, tout en les incitant à faire preuve d'une vigilance particulière à l'égard des représentations des spectacles de M. M'bala M'bala ;

4. Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public ; que l'autorité investie du pouvoir de police peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ;

5. Considérant que l'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; qu'il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion ; que les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales ; que, dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, le ministre de l'Intérieur, qui n'a au demeurant pas édicté de critères contraignants, n'a pas méconnu l'étendue des pouvoirs de police administrative en rappelant que l'autorité qui les détient peut, pour apprécier la nécessité d'interdire la représentation d'un spectacle, tenir compte de l'existence de condamnations pénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceux susceptibles d'être tenus à l'occasion de nouvelles représentations de ce spectacle, de l'importance donnée aux propos incriminés dans la structure même

du spectacle ainsi que des éventuelles atteintes à la dignité de la personne humaine qui pourraient en résulter ; que la circonstance que les propos et gestes en cause sont diffusés sur internet ne fait pas obstacle à l'interdiction de représentation d'un spectacle ; que la circonstance alléguée que les mesures envisagées par la circulaire se révèleraient insuffisantes est sans incidence sur sa légalité ;

7. Considérant que la circulaire attaquée du ministre de l'Intérieur rappelle aux préfets qu'il leur appartient d'informer les maires sur les conditions dans lesquelles ils peuvent légalement interdire la représentation d'un spectacle dans le cas où le risque que soient tenus des propos et gestes de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine est établi avec un degré suffisant de certitude, de les assister dans l'édiction de telles mesures ou, lorsque les conditions de l'interdiction sont réunies, de se substituer à ces derniers ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, ce faisant, le ministre de l'Intérieur n'a pas méconnu l'étendue des pouvoirs de police ni, en tout état de cause, méconnu les principes de nécessité et de proportionnalité auxquels est subordonnée l'édiction de mesures de police ;

8. Considérant, en troisième lieu, que des propos et gestes, notamment ceux à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale, peuvent porter atteinte à la dignité de la personne humaine, alors même qu'ils ne provoqueraient pas de troubles matériels ; qu'ainsi, le ministre de l'Intérieur n'a pas excédé sa compétence en mentionnant, au nombre des éléments permettant de justifier l'interdiction de la représentation d'un spectacle par l'autorité de police, les propos ou scènes qui seraient susceptibles de porter atteinte à la dignité de la personne humaine ;

9. Considérant, enfin, qu'eu égard à l'objet de la circulaire attaquée, l'association requérante ne peut utilement invoquer une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ;

10. Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'Intérieur, l'AGRIF, la SARL Les productions de la Plume et M. M'bala M'bala ne sont pas fondés à demander l'annulation de la circulaire qu'ils attaquent ; (...)

Corrigé sujet n°4 - CE, 9 novembre 2015, « Alliance générale contre le racisme et le respect de l'identité française et chrétienne »

« *Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales* » ; c'est par ce considérant général que le Conseil d'État répond, dans l'arrêt du 9 novembre 2015, aux interrogations qui avaient vu le jour à la suite de l'ordonnance rendue en référé par la Haute Instance, en date du 9 janvier 2014, s'agissant de l'étendue du champ de la police administrative par rapport au champ de la répression pénale.

L'affaire qui a donné lieu à la décision du 9 novembre 2015 était en lien avec les interdictions de spectacles de Dieudonné, fondées, en grande partie, sur la circulaire du ministre de l'Intérieur du 6 janvier 2014. C'est cette dernière qui fait l'objet du recours pour excès de pouvoir dont connaît le juge administratif. Sans s'attarder longtemps sur ce point, le Conseil d'État rappelle que les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire peuvent faire l'objet d'un recours contentieux, dès lors, entre autres, qu'elles prescrivent d'adopter telle interprétation d'un texte. Cette solution classique étant rappelée (CE, sect., 18 décembre 2002, « Duvignères »), elle est appliquée à l'espèce en cause : la circulaire prescrit bien aux préfets *« l'interprétation qu'il convient de faire des textes et de la jurisprudence relative aux cas dans lesquels la préservation de l'ordre public justifie que soient prises des mesures d'interdiction de certaines représentations* » ; les préfets étaient appelés à une vigilance particulière à l'égard des spectacles de Dieudonné.

Le recours est alors recevable à l'encontre de ce texte, ce qui permet au juge de se prononcer sur la légalité de la circulaire. Et il ressort de cet examen, comme le souligne à juste titre Madame Bretonneau, rapporteur public dans cette affaire, que le Conseil d'État se trouve « *dans un cas de figure où l'efficacité chronologique redoutable du référé-liberté fait par contraste ressortir les limites du juge de l'excès de pouvoir, qui intervient après la bataille en terrain largement occupé* ». C'est en son temps le principal reproche qui avait été fait à l'encontre de l'arrêt *Benjamin*, décision de principe en matière d'étendue des pouvoirs de police administrative : l'interdiction de tenue de la réunion publique avait certes été annulée mais plusieurs années après la date à laquelle elle avait été programmée, jetant ainsi le doute sur l'efficacité du contrôle du juge de l'excès de pouvoir... Ce temps est révolu et l'efficacité du juge de l'urgence n'est plus à démontrer, même si certains ont cru bon de dénoncer, au moment du rendu de l'ordonnance du 9 janvier 2014, une trop grande rapidité du juge ; l'urgence justifierait donc de statuer vite, mais pas trop...

Les requérants souhaitaient que soit reconnue l'illégalité de la circulaire du ministre de l'intérieur, ce dernier étant incompétent pour édicter des règles nouvelles. En indiquant aux préfets les cas et modalités permettant d'interdire la tenue d'un spectacle, la circulaire ajouterait au droit existant ou interprèterait mal le droit existant. Plusieurs moyens étaient invoqués : les deux principaux tenaient, d'une part, au fait que la police administrative n'aurait pas à prévenir la commission d'infractions pénales (**I**) ; le second à l'affirmation selon laquelle la prévention des atteintes à la dignité de la personne humaine devrait être liée à des troubles immatériels (**II**).

Si la décision du Conseil d'État confirme la solution rendue par l'ordonnance du 9 janvier 2014, elle a le mérite de clarifier les différentes notions dans un cadre beaucoup plus général, le premier point paraissant particulièrement important.

I - La reconnaissance de la prévention des infractions comme finalité de la police administrative

La circulaire rappelle aux préfets que la police administrative est là pour maintenir l'ordre public ; selon le texte du ministre de l'intérieur, les spectacles de Dieudonné seront placés sous le signe de l'antisémitisme, renforcé par la fameuse gestuelle (« la quenelle ») sur laquelle sa société de production a cru bon de déposer des droits... Le texte est intéressant en ce qu'il précise que le spectacle envisagé va continuer dans cette voie (racisme et antisémitisme) malgré neuf condamnations dont sept définitives. Et, précise la circulaire, « *la réponse à de tels propos doit avant tout être d'ordre pénal (...). Néanmoins l'autorité administrative dispose également de pouvoirs lui permettant de faire cesser les troubles à l'ordre public* » ; l'interdiction d'un spectacle doit revêtir un caractère exceptionnel, mais elle doit être édictée lorsqu'elle apparaît comme la seule solution pour mettre fin au trouble à l'ordre public constitué par la commission répétée d'infractions pénales. Le juge rappelle donc fermement que la police administrative, étant en charge de la prévention des troubles à l'ordre public, doit chercher à empêcher la commission d'infractions pénales (**A**) ; cette activité est néanmoins entourée de garanties (**B**).

A – L'intervention légitime de la police administrative en matière pénale

La formulation de la circulaire posait donc la question de savoir si la police administrative avait pour objet de prévenir la commission d'infractions pénales. Posée ainsi, une telle interrogation ne peut appeler qu'une réponse positive. On sait que la police administrative a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public, ces atteintes pouvant consister ou non en des infractions pénales ; la police judiciaire, elle, a en en charge de les réprimer (T. confl., 17 mai 2010, Violences policières à l'occasion de la commission d'une infraction). Il est donc traditionnel d'opposer les deux, en affirmant que la police administrative a un rôle préventif, la police judiciaire un rôle répressif. Mais il est vrai que, de manière d'ailleurs assez logique, les deux interviennent dans des domaines très voisins, et parfois exactement sur le même objet, ce qui peut justifier les interrogations, qui remontent jusqu'au Tribunal des conflits, pour déterminer si l'opération qui donne lieu au litige relève de la police administrative ou de la police judiciaire, et donc si l'ordre de juridiction compétent est administratif ou judiciaire (T. confl., 12 juin 1978, « Société le profil » : une mission de protection d'un transfert de fonds est bien préventive, mais elle signifie qu'elle vise à empêcher la commission d'un vol). Le fait pour une autorité de police de devoir prendre toutes les mesures pour empêcher la commission de cambriolages et de de vols relève bien d'une mission de police administrative (T. confl., 23 janvier 2006, « Préfet de la région Champagne-Ardenne »), et en l'occurrence, le commerce à protéger avait déjà fait l'objet de 11 cambriolages ; la surveillance avait donc pour objectif de prévenir la commission du douzième...

La police administrative a pour objet d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Elle a pour but d'éviter les troubles à l'ordre public ; il n'est donc pas déraisonnable que le juge considère que l'autorité de police administrative doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir la commission d'infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public, dès lors que l'exercice par les citoyens de leurs droits et libertés n'est pas atteint de manière excessive.

Cette approche est cependant entourée d'un certain nombre de garanties par le juge : les éléments à prendre en compte, et le contrôle exercé sur la mesure.

B – L'intervention néanmoins conditionnée de la police administrative en matière pénale

Le contrôle du juge portera sur les éléments à prendre en compte et s'avèrera minutieux.

S'agissant des éléments à prendre en compte, une mesure de police destinée à prévenir la commission d'infractions pénales doit s'appuyer sur « *le caractère suffisamment certain* » et sur « *l'imminence de la commission de ces infractions* », ainsi que « *sur la nature et la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter* ». Autrement dit, la mesure d'interdiction d'un spectacle ne saurait reposer sur de vagues soupçons liés à d'éventuels propos susceptibles d'être tenus. Dans l'affaire Dieudonné, le prétendu humoriste avait lui-même indiqué dans la présentation de son spectacle qu'il reprendrait les mêmes propos, les mêmes attaques ; le caractère probable du risque de commission d'infractions reposait également sur le fait qu'il avait été condamné pénalement pour des propos identiques antérieurement aux spectacles projetés. La certitude n'était certes pas totale, mais il ne s'agit pas, comme a pu le souligner le Professeur Seiller, d'une *« simple suspicion pesant sur un individu* » qui conduirait à lui « *interdire préventivement de s'exprimer* ». L'imminence était avérée compte tenu de la date des spectacles. Il est vrai que la liberté d'expression nécessite d'être particulièrement attentif aux mesures susceptibles de l'entraver ; pour autant, la probabilité de réitération des propos antisémites était très forte, « *éminemment probable* » selon Mme Bretonneau. Quant à la nature et à la gravité des troubles à l'ordre public susceptibles d'en résulter, elles sont également vérifiables : l'atteinte à la dignité de la personne humaine constitue un trouble à l'ordre public particulièrement grave.

S'agissant du contrôle exercé sur la mesure, il n'est guère nouveau puisqu'il trouve sa source dans l'arrêt « Benjamin » du 9 mai 1933 : la légalité de la mesure de police est subordonnée à sa nécessité ; elle doit être adaptée et strictement proportionnée au risque de trouble à l'ordre public pour que ne soient pas excessivement atteints les droits et libertés. Les maîtres mots du contrôle sont donc adaptation, nécessité et proportionnalité : l'interdiction d'un spectacle doit être la seule mesure permettant d'empêcher que ne soit commise une très probable infraction qui troublerait l'ordre public. Tout l'équilibre repose donc sur la forte probabilité de la commission de l'infraction justifiant l'atteinte majeure à la liberté d'expression ; on comprend bien, dès lors, que la probabilité invoquée doive être dûment vérifiée et étayée pour éviter un risque de censure...

Mais la probabilité de la commission d'une infraction peut-elle résulter d'un risque d'atteinte à la dignité de la personne humaine, alors même qu'aucun trouble matériel à l'ordre public ne serait constaté ? C'est le second argument qu'invoquaient les requérants.

II - L'identification d'une atteinte à la dignité humaine, en l'absence de troubles matériels

Depuis l'arrêt « Commune de Morsang-sur-Orge » (CE, ass., 27 octobre 1995), la dignité de la personne humaine est une composante de l'ordre public ; cette affirmation a été régulièrement reprise par la jurisprudence (CE, ord. réf., 16 avril 2015, « Société Grasse Boulange », à propos de l'exposition de pâtisseries dans une vitrine), l'originalité de la notion résidant dans le fait que, contrairement à ce qui

est traditionnellement retenu en matière de police administrative, un comportement ou un agissement peut être constitutif d'une atteinte à la dignité humaine, donc à l'ordre public, même en l'absence de circonstances locales particulières. La notion de dignité est très vaste : « *la dignité de la personne humaine ne peut qu'être une source perpétuelle de questions, de discussions, parce qu'elle a précisément trait au mystère et à l'indétermination du destin humain* » (P. Frydman).
Mais l'ordonnance du 9 janvier 2014 avait dû franchir deux obstacles supplémentaires : la tenue de propos peut-elle constituer une atteinte à la dignité, et dans l'affirmative, cette atteinte peut-elle constituer un trouble à l'ordre public alors même qu'aucun désordre matériel ne se produit ?

A – Des propos attentatoires à la dignité de la personne humaine

L'ordonnance de 2014 avait ainsi admis que « *des propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale* » seraient probablement tenus et qu'il serait donc de nouveau porté atteinte « *au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine* ». Le Conseil d'État avait, certes, déjà admis que des propos puissent être attentatoires à la dignité de la personne humaine, mais la sanction qui en avait résulté frappait l'association qui avait laissé se tenir de tels propos sur l'antenne de la radio qu'elle gérait et non les personnes qui les avaient directement prononcés (CE, 9 octobre 1996, « Assoc. Ici et maintenant »; de même, CE, 20 mai 1996, « Sté Vortex »).

L'arrêt du 9 novembre 2015 va plus loin en ce qu'il retient une approche très générale : « *des propos et gestes, notamment ceux à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la seconde Guerre Mondiale, peuvent porter atteinte à la dignité de la personne humaine, alors même qu'ils ne provoqueraient pas de troubles matériels* ». Les troubles à l'ordre public seraient ainsi immatériels. Une telle affirmation repose sur deux points : c'est la gravité des propos et gestes, en elle-même, qui doit être appréhendée, donc en dehors de toute circonstance locale particulière, et donc en dehors de tout contexte spécifique ; en soi, la tenue de tels propos ou la commission de tels gestes est contraire à la dignité de la personne humaine et donc à l'ordre public puisqu'elle en est une composante.

Comme l'avait remarqué le Professeur Delvolvé: *« l'ordre public ne se limite pas à la police ; si la police a pour objet l'ordre public, elle s'exerce elle-même dans un ordre public qui la dépasse et dont elle doit assurer le respect. À ce titre, l'arrêt Morsang-sur-Orge n'introduit pas un nouvel objet dans la police générale ; il signifie que la police générale doit garantir un ordre public plus élevé et plus large que celui sur lequel porte son objet habituel »*.

B – Un élargissement entériné de la notion d'ordre public

Au-delà de cette première approche, le juge semble persévérer dans sa volonté de redéfinir l'ordre public. Si la dimension matérielle de l'ordre public se traduit par ses composantes classiques (sécurité, salubrité, tranquillité), une dimension immatérielle existe aussi (dignité humaine). Ce faisant, la Haute juridiction entérine l'élargissement de la notion de dignité de la personne humaine - du reste déjà commencé avant même l'« affaire Dieudonné » (CE, ord., 5 janvier 2007, « Min. Intérieur c/ Assoc. Solidarité des Français » : à propos des « soupes au cochon » distribuées par cette association aux sans-abris et excluant *de facto* ceux d'entre eux qui sont de confession musulmane. - CE, 26 novembre 2008, « Syndicat mixte de la vallée de l'Oise » : à propos de la création d'un centre de stockage de déchets

dans un lieu de mémoire de la Première Guerre mondiale). Si ces effets étaient auparavant limités à la prohibition de comportements visant à la réification de la personne humaine, elle est désormais étendue à une dimension « intellectuelle » visant à interdire les propos contribuant à l'apologie ou à la banalisation des crimes commis contre l'être humain ou, plus largement, les propos ou comportements péjoratifs ou dépréciatifs à l'égard de l'être humain en général ou de certains d'entre eux en particulier. Le champ d'application de la police administrative générale est étendu d'autant, toute injure ou diffamation à caractère racial, et même peut-être toute injure ou diffamation, entrant potentiellement dans le champ des atteintes à la dignité de la personne humaine.

L'ordre public traduit des valeurs communes, une certaine conception du vivre ensemble, évoquées et retenues par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire « SAS c/ France » (CEDH, 1er juillet 2014) : la loi relative à l'interdiction de dissimuler son visage dans la sphère publique repose sur la nécessité d'assurer la sécurité publique, la protection des droits et libertés d'autrui, donc d'assurer le respect du socle minimal des valeurs d'une société démocratique et ouverte (égalité entre hommes et femmes, dignité de la personne humaine). Selon la Cour, le vivre ensemble peut se rattacher au but légitime que constitue la protection des droits et libertés. Cette approche était déjà perceptible dans les années 1930, sous la plume de P.-H. Teitgen (*La police administrative*, 1934 : relève de l'ordre public la prévention des « *atteintes publiques au minimum d'idées morales naturellement admises, à une époque donnée, par la moyenne des individus* »).

Une conception renouvelée de l'ordre public ne doit toutefois pas transformer les atteintes ou les risques d'atteintes en éléments purement virtuels. L'apologie des persécutions antisémites pendant la seconde guerre mondiale constitue en soi des propos portant atteinte à la dignité de la personne humaine, donc à l'ordre public sans qu'aucun désordre matériel et extérieur ne soit constitué. Là sans doute est le point faible de la décision : où se trouve la limite dans les propos tenus ? L'on peut imaginer qu'il est nécessaire que ces assertions constituent des infractions pénales, mais au-delà ?

Ces éléments renvoient en réalité sans doute à l'image que la société souhaite se donner d'elle-même, ce qui incitait le Professeur Truchet a considérer que *« protéger la dignité dans les faits et dans les discours serait protéger l'image que les personnes et la société souhaitent donner d'elles-mêmes et de l'humanité »*. Il n'est toutefois pas anodin de constater, à titre de comparaison, que le juge européen, dans un arrêt de 2012 « Mouvement raëlien suisse c. Suisse », avait posé en principe que la liberté d'expression doit être protégée, y compris lorsque les propos tenus « *heurtent, choquent ou inquiètent* ». Ainsi le veulent le pluralisme des opinions et la tolérance, sans lesquels il n'est pas de « *société démocratique* ». L'ingérence dans la liberté d'expression doit donc répondre, selon une formule désormais classique, à un « *besoin social impérieux* », ce qui a d'ailleurs incité la Cour européenne, dans un arrêt de Grande Chambre du 15 octobre 2015 « Perincek c. Suisse », a sanctionner le droit suisse pour la condamnation pénale infligée à une personne coupable de négation du génocide arménien…

La décision du Conseil d'État ne surprend pas. Elle a le mérite d'expliciter le raisonnement suivi dans l'ordonnance rendue en référé du 9 janvier 2014. La police administrative a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public et englobe donc la prévention de la commission d'infractions pénales. Le contrôle du juge en la matière reste une garantie essentielle pour préserver les droits et libertés, la vérification de l'adaptation, de la nécessité et de la proportionnalité étant minutieuse. Il reste sans doute à peaufiner cette conception renouvelée de l'ordre public…

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2020

SIMULATION

GRAND ORAL

Sujet n°5 – Dissertation:
Le juge administratif, juge pénitentiaire

CORRIGÉ : LE JUGE ADMINISTRATIF, JUGE PÉNITENTIAIRE

Si pendant longtemps le juge administratif s'est refusé à s'immiscer dans l'univers carcéral et à apprécier les conditions matérielles de détention, tel n'est plus le cas désormais. Sous l'impulsion de la jurisprudence européenne, il se place aujourd'hui en garant du respect de la dignité des personnes privées de liberté et oeuvre à l'effectivité de ce droit. Le juge administratif semble aujourd'hui avoir pris la pleine mesure de sa mission en développant depuis quelques années une jurisprudence novatrice qui tend à influer concrètement sur les réalités carcérales.

I – L'intensification avérée du contrôle opéré par le juge administratif en matière pénitentiaire

Si elle est récente, l'implication du juge administratif dans la sphère carcérale était néanmoins inévitable, tant au regard de l'impératif de protection des droits fondamentaux des détenus qu'au regard de la nécessité de contrôler l'activité de service public de l'administration pénitentiaire. Cette immixtion s'est traduite, notamment, par une intensification du contrôle opéré sur les mesures prises à l'égard des détenus.

A – Un élargissement du contrôle opéré sur les mesures prises par l'administration pénitentiaire

1) **Un affaiblissement manifeste de la notion de mesure d'ordre intérieur :** a progressivement été confirmé un véritable reflux de la notion de mesure d'ordre intérieur, lequel induit un assouplissement des conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les mesures prises par l'administration pénitentiaire à l'égard des détenus. Ainsi, dans l'arrêt *« Marie »* du 17 février 1995, le Conseil d'État a admis la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir formé par un détenu contre une sanction disciplinaire prise contre lui, et annulé cette dernière. Les sanctions prononcées en milieu carcéral sont donc devenues des actes faisant grief, à condition néanmoins qu'elles emportent des effets sensibles sur la situation des requérants de par leur *« nature »* et leur *« gravité ».* Par la suite (CE, Ass., 14 décembre 2007), cette solution a été consolidée, le juge administratif dégageant une véritable « grille de lecture » guidant son contrôle lorsqu'il est saisi de décisions prises au sein des établissements pénitentiaires.

2) **Une influence manifeste du juge européen des droits de l'homme :** le changement de posture du juge français s'explique en partie par l'influence du droit européen des droits de l'homme. Celle-ci est manifeste et s'explique par la construction prétorienne remarquable que la Cour de Strasbourg a opérée sur le fondement de l'article 3 de la Convention. En effet, ainsi que l'a écrit le Professeur Sudre, la Cour de Strasbourg a *« ajouté un nouveau droit au catalogue conventionnel, écrivant un article 3 bis de la Convention : "toute personne privée de liberté a droit à des conditions de détention conformes au respect de la dignité humaine" »*. Ainsi, dans l'arrêt « *Riad et Idiab c/ Belgique »* du 24 avril 2008, la Cour européenne a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme « *impose à l'État de s'assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate* ».

B – Un approfondissement du contrôle opéré sur les mesures prises par l'administration pénitentiaire

1) **Un affermissement du contrôle de légalité exercé sur les actes de l'administration pénitentiaire :** dans le prolongement de l'assouplissement des conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir, le juge administratif n'hésite pas à approfondir le contrôle qu'il opère sur les mesures prises par l'administration pénitentiaire. A preuve en ce qui concerne les sanctions disciplinaires infligées aux détenus. Alors qu'il n'opérait qu'un contrôle restreint limité à l'erreur manifeste d'appréciation (CE, n° 326084, 20 mai 2011), le Conseil d'État a considéré dans un arrêt « *M.B.A »* du 1er juin 2015 que le juge de l'excès de pouvoir devait rechercher, dans le cadre d'un recours porté devant lui, si les faits reprochés à un détenu, ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire, constituent des fautes de nature à justifier une sanction, et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le juge administratif exerce donc désormais un contrôle de proportionnalité entre la faute et la sanction.

2) **Un assouplissement des conditions d'engagement de la responsabilité des services pénitentiaires :** au cours des dernières décennies, le droit de la responsabilité de l'État du fait des dommages causés par le service pénitentiaire a profondément évolué. Cela s'est notamment traduit par un recul de l'exigence d'une faute lourde pour engager la responsabilité de l'État (CE, 23 mai 2003, *« Mme Chabba »*; CE, 17 décembre 2008, *« Garde des sceaux, Ministre de la justice c/ M. et Mme Zaouiya »*). La responsabilité sans faute du service public a aussi été admise, lors de dommages causés par des détenus bénéficiaires de permission de sortie (CE, 2 décembre 1981, *« Garde des Sceaux c. Theys »*) ou à propos de personnes bénéficiant de mesures de libération conditionnelle et de semi-liberté (CE 29 avril 1987, *« Garde des Sceaux c. Banque populaire de la région économique de Strasbourg »*). Mais s'il est vrai que l'ouverture de la voie indemnitaire constitue une avancée considérable dans la protection offerte aux détenus, elle reste néanmoins une simple compensation et ne permet aucunement de faire cesser l'atteinte. À cet égard, le développement des procédures d'urgence a signé un renforcement significatif du contrôle des conditions de détention.

II – L'efficacité renforcée du contrôle opéré par le juge administratif en matière pénitentiaire

Le recours au juge administratif des référés a permis de donner toute sa portée à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, qui pose en principe que *« l'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits ».* Le développement des recours préventifs ouvre incontestablement une nouvelle ère contentieuse, susceptible d'inciter l'État à mieux répondre à son obligation positive d'assurer aux détenus des conditions de détention décentes.

A – Le déploiement de l'office du juge administratif par la voie du référé-liberté

1) **L'attractivité du référé-liberté en matière pénitentiaire :** le référé-liberté de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, conçu ex nihilo par la loi du 30 juin 2000, permet d'inscrire le juge administratif dans une logique de la protection des droits fondamentaux. Lorsqu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le juge du référé-liberté, qui statue en quarante-huit heures, prend toutes les mesures provisoires, voire irréversibles, nécessaires à la cessation en urgence de cette atteinte. La volonté d'assurer le respect des libertés par le biais du référé-liberté se manifeste notamment par une interprétation large de la notion de liberté fondamentale à laquelle il doit avoir été porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dans un arrêt du 22 décembre 2012 relatif au centre pénitentiaire des Baumettes, le Conseil d'Etat n'a pas hésité à reconnaitre une nouvelle liberté fondamentale éligible à la procédure de l'article L. 521-2 : le

droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Jusqu'alors, ce droit ne disposait pas d'une reconnaissance autonome dans le cadre du référé-liberté. Désormais, le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants se trouve consacré en tant que liberté fondamentale à part entière. Le manquement à cette obligation conventionnelle peut ainsi être sanctionné par la voie du référé-liberté.

2) **L'utilité du référé-liberté en matière pénitentiaire :** dans son ordonnance *« Section française de l'observatoire international des prisons »* du 22 décembre 2012, le Conseil d'État a considéré que *« lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence »*. En l'espèce, l'administration pénitentiaire, après s'être vue ordonner par le tribunal de Marseille de veiller *« à ce que chaque cellule soit dotée d'un éclairage artificiel et d'une fenêtre en état de fonctionnement »*, de *« procéder à l'enlèvement des détritus dans les parties collective et les cellules »* et de modifier *« la méthode de distribution des plateaux repas jusqu'ici posés à même le sol »*, s'est ainsi vue enjoindre par le Conseil d'État de procéder dans les 10 jours suivant la notification de la décision à l'éradication des espèces nuisibles présentes dans les locaux de l'établissement. Ce recours au juge des référés s'est révélé particulièrement efficace puisque, 5 jours après la décision du Conseil d'État, les opérations de dératisation et de désinsectisation ont effectivement débuté au centre pénitentiaire des Baumettes. De même, en 2015, s'agissant de la maison d'arrêt de Nîmes, le juge des référés du Conseil d'Etat a enjoint à l'administration de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de l'établissement et la prévention des risques d'incendies, pour améliorer, dans l'attente d'une solution pérenne, les conditions matérielles d'installation des détenus durant la nuit et pour assurer l'accès des détenus aux produits d'entretien des cellules et à des draps et couvertures propres (CE, 30 juillet 2015, *« Section française de l'OIP et ordre des avocats au barreau de Nîmes* »).

B – L'action dynamique du juge administratif sur l'administration pénitentiaire

1) **Une influence sensible : l'ajustement de la détention au respect des droits fondamentaux :** une protection de plus en plus dynamique et efficace a progressivement été mise en place par le juge administratif. L'ampleur de cette évolution s'explique principalement par la création du référé-liberté. Ce nouvel outil a permis à des associations d'obtenir du juge administratif des injonctions, visant à faire cesser par tout moyen l'atteinte à une liberté fondamentale, afin que l'administration pénitentiaire agisse sur les conditions de vie effectives des détenus. Le référé-liberté - qui peut se révéler d'autant plus efficace pour remédier à l'inertie de l'administration pénitentiaire qu'il peut être complété par une action en référé mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative - a donc vocation dans ce cadre à agir sur l'environnement pénitentiaire et non simplement sur des mesures individuelles. Le juge administratif se transforme dès lors en véritable prescripteur de l'action publique, assumant pleinement son office de *« juge pénitentiaire »* (Mattias Guyomar, *Mélanges offerts en l'honneur du professeur Jegouzo*).

2) **Une influence néanmoins relative : un rôle mesuré de juge-administrateur :** dans une ordonnance du 28 juillet 2017 *(« Section française de l'Observatoire international des prisons »)*, le Conseil d'Etat, saisi

des conditions de détention à la prison de Fresnes, a néanmoins marqué les limites à son rôle prescripteur en refusant d'enjoindre à l'administration de prendre des mesures structurelles pour améliorer la situation des personnes détenues. Le Conseil d'Etat s'appuie en l'espèce sur une logique procédurale. Le référé-liberté peut être utilisé pour faire cesser un traitement inhumain et dégradant, mais les mesures prises doivent répondre à deux conditions. D'une part, elles doivent reposer sur l'urgence, et le juge intervient pour faire cesser une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale. D'autre part, le référé liberté implique que les mesures imposées par le juge soient provisoires et rapidement mises en œuvre. Il s'agit de mesures de sauvegarde et non pas de réformes systémiques. Le Conseil d'Etat intervient pour faire cesser un traitement inhumain et dégradant, mais son office ne peut le conduire à se substituer à des choix qui relèvent du politique. Ce n'est pas à un juge, non élu et non représentatif, d'opérer de tels choix...

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2020

SIMULATION

GRAND ORAL

Sujet n°6 – Argumentation:
Soutenez que la juridiction administrative est, aujourd'hui, une *« juridiction des droits de l'homme »*

Selon Gaston Jèze, *« le recours pour excès de pouvoir est l'arme la plus efficace, la plus pratique et la plus économique qui existe au monde pour défendre les libertés »*. Le tribunal des conflits n'en a pas moins considéré qu'il *« appartient à l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle de statuer sur les conséquences de tous ordres des atteintes arbitraires à cette liberté »* (TC, 27 mars 1952, *Dame de la Murette*).

S'il reste un rouage du pouvoir, par le lien organique et fonctionnel qu'il entretient avec l'administration, le JA n'en est pas moins devenu un véritable contre-pouvoir, ostensiblement protecteur des libertés face à cette même administration. Une mutation de la conception de son office a pu, à cet égard, être observée, qui a permis le passage d'une « justice objective », uniquement préoccupée de l'assujettissement à la légalité, à une « justice subjective », qui vise à assurer une protection effective des droits et libertés fondamentaux.

Bien que qualifiée de *« juridiction des droits de l'homme »* par le Professeur René Chapus, la juridiction administrative est-elle pleinement, au même titre que le juge judiciaire, un JLD ?

I – La légitimation feutrée du rôle protecteur de la juridiction administrative

A – Des sources privilégiées, dédiées à la protection des libertés

1) L'influence de la source constitutionnelle

ex : CE, 3 juillet 1996, *Koné* : le Conseil d'État érige en PFRLR l'interdiction de faire droit à une demande d'extradition formulée dans un but politique

ex : dans le cadre de la QPC : la protection des droits fondamentaux est au cœur de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité. Si le contrôle de constitutionnalité reste l'apanage du Conseil constitutionnel, il a néanmoins permis de renforcer le Conseil d'État s'agissant des questions de constitutionnalité, au point peut-être de lui octroyer un rôle de juridiction constitutionnelle de droit commun. En opérant le filtrage des QPC, le Conseil d'Etat est en effet appelé à apprécier, selon les termes de la loi organique du 10 décembre 2009, le caractère *« sérieux »* ou *« nouveau »* de la question de constitutionnalité soulevée devant lui. Cette appréciation le conduit à assumer, discrètement mais effectivement, une mission de juge constitutionnel. Le Conseil d'État considère parfois que la question n'est pas jugée sérieuse parce qu'elle peut être réglée sans difficulté ou parce qu'elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits et libertés constitutionnellement garantis.

Dans les deux cas, il tranchera lui-même dans le sens de la conformité ou non de la loi aux droits et libertés constitutionnellement garantis, substituant son appréciation à celle que pourrait faire le Conseil constitutionnel et s'exonérant ainsi d'une « obligation » de renvoi vers le juge constitutionnel. De fait, c'est bien sur le Conseil d'Etat que pèse la mission d'être juge constitutionnel de droit commun. En renvoyant au Conseil constitutionnel les questions de constitutionnalité qui posent une difficulté sérieuse, celui-ci devient une juridiction constitutionnelle d'exception.

2) L'apport de la source conventionnelle

Ex : à propos de « l'intérêt supérieur de l'enfant » : ce principe fait figure de *« formule magique »* selon le doyen Carbonnier. Posé par l'art 3-1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, c'est le CE qui a permis l'intégration en droit positif du principe par l'arrêt *Melle Cinar* du 22 septembre 1997, par lequel le juge administratif a annulé une mesure de reconduite à la frontière prononcée à l'encontre d'un enfant étranger. On observera qu'il a fallu attendre le 18 mai 2005 pour que la Cour de cassation reconnaisse l'applicabilité de l'article 3-1 relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le CE a par ailleurs considéré que l'ISE est une liberté fondamentale invocable dans le cadre du référé liberté de l'article L. 521-2 du CJA (CE, ord, 4 mai 2011, *Ministre des affaires étrangères et européennes c/ Morin)*.

CE, ord, 3 août 2016, *Ministre des affaires étrangères et du développement international c. Mme A* : la circonstance que la conception d'un enfant ait pour origine un contrat entaché de nullité au regard de l'ordre public français est sans incidence sur l'obligation faite à l'Administration par les stipulations de l'art 3-1 de délivrer à un enfant conçu par GPA les documents de voyage lui permettant d'entrer sur le territoire national afin de vivre auprès de sa mère d'intention.

B – Un champ d'intervention progressivement étendu

1) Une redéfinition de la liberté individuelle favorable au juge administratif

TC, 6 septembre 1986, *Eucat* - CE, 8 avril 1987, *Peltier* : ces deux arrêts détachent la liberté d'aller et venir du bloc de l'article 66 pour la rapporter à la DDHC.
CC, 29 décembre 1998, *Loi de finance pour 1999* : le CC distingue le respect de la vie privée de la liberté individuelle pour rattacher explicitement le droit au respect de la vie privée à la « liberté personnelle » garantie à l'article 2 de la DDHC combiné avec l'article 4 de ce même texte
Le CC a ensuite fait de même pour la liberté d'aller et venir, pour l'inviolabilité du domicile privé, le secret des correspondances ou la liberté du mariage... La jurisprudence du CC a donc conduit à une définition plus étroite de la liberté individuelle, en ne se référant à l'article 66 que dans le domaine de privations de liberté.

2) Un élargissement du champ de compétence du juge administratif entériné par le législateur

- loi du 24 juillet 2015 donnant au Conseil d'État compétence directe pour juger des recours concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers informatiques intéressant la sûreté de l'État
- loi du 20 novembre 2015 sur la mise en œuvre de l'état d'urgence confirmant la compétence exclusive de la juridiction administrative pour en connaître
- loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme : de nature exclusivement préventive, les mesures de surveillance ordonnées par le préfet ou le ministre ne devaient pouvoir être contrôlées, dans la première version du texte, que par le juge administratif. L'efficacité d'un tel contrôle ayant été contestée, les services du ministère de l'Intérieur ont repris le projet afin d'introduire un contrôle *a priori* (et minimal) de l'autorité judiciaire.

II – La consécration ostensible du rôle protecteur de la juridiction administrative

A – La mutation de l'office du juge administratif dans le cadre des recours ordinaires

1) Les armes légales octroyées au juge administratif

Il est tout à fait remarquable de constater que, depuis trois décennies, le législateur a élargi les pouvoirs du juge administratif en le dotant, dans son domaine de compétences, d'outils de contrôle et de procédures toujours plus performants :

- loi du 16 juillet 1980 portant sur les pouvoirs d'astreinte du Conseil d'Etat.
- loi du 10 janvier 1990, sur la procédure permettant de contester en urgence des arrêtés de reconduite à la frontière

- loi du 8 février 1995, portant sur les pouvoirs d'injonction et d'astreinte du juge administratif.

2) Une intensification du contrôle opéré par le juge administratif

Cette intensification apparaît notamment dans le domaine pénitentiaire. Le JA se révèle être protecteur des détenus contre l'administration pénitentiaire. Cela se manifeste, notamment, par :

- une recevabilité renforcée des recours (affaiblissement de la notion de mesure d'ordre intérieur...)
- un affermissement du contrôle de légalité (alors qu'il n'opérait qu'un contrôle restreint limité à l'erreur manifeste d'appréciation concernant les sanctions disciplinaires infligées à des détenus, le Conseil d'État a considéré dans un arrêt *M.B.A.* du 1er juin 2015 que le juge de l'excès de pouvoir devait désormais exercer un contrôle de proportionnalité entre la faute et la sanction)
- un assouplissement des conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l'administration pénitentiaire (CE, 23 mai 2003, *Chabba* : abandon de l'exigence de faute lourde pour engager la responsabilité de l'État dans le cadre des activités pénitentiaires

B – Le déploiement de l'office du juge administratif par la voie du référé-liberté

1) L'attractivité du référé-liberté

Le référé-liberté de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, conçu *ex nihilo* par la loi du 30 juin 2000, permet d'inscrire le JA dans une logique de la protection des droits fondamentaux. Dans le sillage de cette loi, s'est développée une véritable culture de l'urgence au sein des juridictions administratives. Lorsqu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le juge du référé-liberté, qui statue en quarante-huit heures, prend toutes les mesures provisoires, voire irréversibles, nécessaires à la cessation en urgence de cette atteinte.

La volonté d'assurer le respect des libertés par le biais du référé-liberté se manifeste de multiples façons :

- Elle se manifeste d'abord au niveau de la recevabilité de la requête, par exemple par le développement par le juge administratif d'une conception souple de la qualité pour agir. Ainsi, dans le cadre du référé-liberté, la recevabilité de la demande relative à un hébergement d'urgence présentée par un mineur isolé non émancipé est admise afin d'assurer la préservation de ses droits fondamentaux ; l'inverse reviendrait à le priver de toute voie de recours (CE, ord, 12 mars 2014, *Kaibo*). Cela fait d'ailleurs écho à une nouvelle ordonnance *Département de l'Isère* du 25 août 2017 par laquelle le CE consacre un droit à l'hébergement d'urgence pour les mineurs isolés étrangers « *dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger* ». Le juge administratif estime que le refus d'hébergement peut constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en « *fonction de la situation sanitaire et morale de l'intéressé* ».

- Elle se manifeste également par une interprétation large de la notion de liberté fondamentale à laquelle il doit avoir été porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dès ses premières décisions, celui-ci a démontré qu'il convenait d'en retenir une conception rigoureusement *sui generis*. Ainsi, il n'est ni nécessaire, ni suffisant que la liberté en cause ait une valeur constitutionnelle, ni même qu'elle soit une liberté au sens strict du terme : certaines d'entre elles sont en effet des droits, tel le droit de propriété ou le droit à la vie. On mesure donc l'ampleur potentielle du champ d'application du référé-liberté, puisqu'il peut être utilisé dans

des contextes aussi différents que la cessation de travaux dangereux, la prise de mesures contre les requins, la poursuite des soins et de l'alimentation à l'égard d'un patient plongé dans un coma irréversible ou l'amélioration des conditions matérielles d'incarcération des détenus...

- Elle se manifeste enfin à travers la condition d'urgence, susceptible de limiter étroitement l'admissibilité du référé-liberté. Toutefois, le juge des référés n'a pas hésité à instaurer une présomption d'urgence à propos des assignations à résidence prononcées dans le cadre de l'état d'urgence (CE, sect., 11 déc. 2015, *Domenjoud*)

2) L'efficacité du référé-liberté

Elle se manifeste aussi par une définition volontairement très large de l'office du juge du référé-liberté. S'il dispose du pouvoir de prendre *« toutes mesures nécessaires »,* le juge prend soin de rappeler que le principe reste celui du caractère provisoire des mesures de référé-liberté. Néanmoins, il a très vite abandonné cette restriction de son office pour se reconnaître le pouvoir de prononcer des mesures de portée concrètement définitive lorsqu'elles sont seules à même de sauvegarder la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte.

- CE, 31 juillet 2017, *Commune de Calais et ministre de l'Intérieur* : dans cette affaire, le CE, rappelant son rôle dans la mise en œuvre du droit humanitaire, et notamment du droit de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant, confirme la mesure d'urgence prise par le tribunal administratif de Lille enjoignant au préfet et à la commune de Calais de prendre diverses mesures destinées à améliorer la situation des migrants : organiser l'assistance aux mineurs isolés, prévoir une distribution d'eau et des services minimums en matière d'hygiène et organiser des départs vers des centres d'accueil mieux équipés.

- CE, 31 mai 2016, *Gonzalez Gomez* : dans cette affaire, la requérante contestait devant le Conseil d'État, dans le cadre du référé-liberté, le refus de l'administration française d'exporter vers l'Espagne les gamètes de son mari défunt afin qu'elle puisse y procéder à une insémination *post-mortem,* que permet la loi de ce pays. En l'espèce, Mme A. soutenait que le refus d'exportation des gamètes était contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le CE a développé un raisonnement en 3 temps :
    - Le Conseil d'État a d'abord précisé l'office du juge administratif. Revenant sur sa jurisprudence, il a admis que le juge des référés puisse, dans le cadre de son office de juge de l'urgence, effectuer un contrôle de la décision ou de l'acte contesté au regard des conventions internationales, en particulier de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
    - Il a, ensuite, jugé que la législation française, prise dans son ensemble, n'était pas contraire à l'article : s'agissant de ces sujets de bioéthique, la marge d'appréciation que la convention laisse aux États est importante et tant l'interdiction de procéder à une insémination *post-mortem* que l'interdiction d'exporter à cette fin des gamètes conservés en France relèvent de cette marge d'appréciation (contrôle *in abstracto*).
    - Le CE a enfin considéré que même si la loi, prise globalement, est compatible avec la convention, son application dans la situation particulière de l'affaire n'aboutit pas à porter une atteinte excessive aux droits fondamentaux en cause (contrôle *in concreto*). Le Conseil d'État en conclut qu'en l'espèce, le refus d'exportation opposé à Mme A. sur le fondement de la loi française porte, au vu de l'ensemble des circonstances particulières de l'affaire,

une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il ordonne donc aux autorités administratives compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l'exportation des gamètes vers l'Espagne.

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2020

SIMULATION AU GRAND ORAL

Sujet n°1 – Dissertation : Faut-il renoncer au principe de dignité ?

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2020

SIMULATION AU GRAND ORAL

Sujet n°1 – Dissertation : Faut-il renoncer au principe de dignité ?

[*Commentaire pour la correction : il n'y a pas une seule manière de répondre à un sujet de dissertation. Chaque étudiant doit pouvoir formuler son propre plan, qui répond à la problématique choisie par lui. L'étudiant doit définir chacun des termes du sujet et le délimiter ; il peut décider de ne traiter qu'un type d'état d'urgence, par exemple, mais doit le préciser en introduction.*
Le plan doit répondre à la problématique, il doit s'articuler en deux parties et deux sous-parties, aux titres dynamiques et sans verbes conjugués.]

La principale interrogation tient à la question elle-même : pourquoi cette question mériterait-elle de se poser ? Est-ce parce que le principe de dignité semble relativement insaisissable, imprécis, trop général, trop présent ? Mais est-ce le cas ? Que recouvre ce principe de dignité ?

Le sujet, tel qu'il est formulé, se veut sans doute provocateur : alors même que l'on considère aujourd'hui que le principe de dignité exprime une exigence normative primordiale, ***intangible***, pourquoi devrait-il être question de son ***abandon*** éventuel, voire souhaitable ?

La dignité, comme principe, revêt un double sens : il s'agit de la qualité intrinsèque d'un être humain en tant qu'être humain – qualité que celui-ci peut revendiquer –, mais aussi l'exigence de respecter sa propre appartenance à l'humanité, qui peut s'opposer aux prétentions d'un individu. La dignité oscille constamment aujourd'hui entre ces deux acceptions.

Or la consécration de la dignité en droit positif paraît dangereuse à plusieurs égards.

Pris dans le sens d'une exigence dont le sujet de droit peut revendiquer le respect pour lui-même, le principe de dignité paraît être omniprésent dans les rapports juridiques. Toute norme juridique, tout droit, toute relation juridique fait appel, d'une façon ou d'une autre, à la dignité du sujet de droit. En ce sens, ériger la dignité en principe normatif peut poser question : la dignité est bien plutôt au fondement de toute norme juridique, laquelle présuppose la dignité du sujet de droit à qui elle s'adresse. Dans ces conditions, la dignité serait à la fois présupposée par la norme et l'objet de certaines normes... De plus, toute prétention d'un sujet de droit doit pouvoir être *relativisée*, dans le cadre des rapports juridiques que ce sujet de droit entretient avec autrui. Pourtant, peut-on relativiser la dignité (comme qualité intrinsèque de l'être humain) sans la remettre en cause ?

Enfin, par son omniprésence, le principe de dignité peut être invoqué dans toute situation, au point de perdre peu à peu sa signification propre et de faire perdre aux autres normes juridiques leurs significations respectives. Ainsi, la portée considérable de la dignité peut être perçue comme une menace pour la clarté et la précision du droit.

Prise dans le sens d'une norme prescrivant le respect de sa propre humanité, la dignité peut aussi devenir un **danger pour la liberté elle-même**, s'il s'agit pour le droit de prescrire sa propre « humanité » à un individu. À cet égard, le principe de dignité comprend potentiellement une dimension liberticide. Néanmoins, ce n'est pas *en soi* que la dignité comme objectivité pose ici problème : la liberté nécessite d'être encadrée objectivement par des bornes pour s'exercer et l'on peut considérer que certaines de ces bornes participent effectivement d'une « commune humanité ». La question majeure consiste plutôt à savoir ***jusqu'où le droit peut aller dans la détermination d'une «dignité» censément objective***, c'est-à-dire jusqu'où il peut aller dans la fixation de bornes extérieures à la liberté de

l'individu, mais qui encadrent celle-ci. Le risque est qu'en raison de ses imprécisions, la dignité ne finisse, en fixant des *bornes* aux libertés, par affecter le *contenu* même de ces libertés.

Pour toutes ces raisons, il existe de nombreuses difficultés tenant à la consécration de la dignité comme principe de droit positif. Autrement dit, le sujet posé devait essentiellement vous amener à **vous interroger sur les limites de la juridicité (ou juridicisation) du principe de dignité.**

Pour autant ce principe de dignité peut ne pas être aussi dangereux qu'il y paraît, pour deux séries de raisons. D'une part, il exprime la **dimension anthropologique du droit**, c'est-à-dire le fait que le droit doit être tourné vers l'Homme et l'humanité. Il peut jouer le rôle, à cet égard, d'une source d'inspiration davantage que celui d'une norme positive. D'autre part, le principe de dignité semble pouvoir être réservé aux **situations les plus difficiles**, aux affaires dans lesquelles les autres normes juridiques ne sont pas suffisantes ou défaillantes. Il jouerait alors le rôle d'une norme ultime face à ce qui serait une véritable réification de l'être humain. A cette condition, il ne semble donc pas nécessaire de renoncer au principe de dignité, mais d'en repenser la place en droit positive, bref de *raisonner* le principe juridique de dignité.

Proposition de plan

En quoi peut-on considérer que le principe de dignité est potentiellement attentatoire au principe de liberté ?

I. Le principe de dignité, véhicule d'une humanité imposée ?

A. Un principe agissant au nom de l'humanité

La dignité est bien aujourd'hui un principe qui s'impose, dans les relations juridiques, comme une limite à l'encontre de tel ou tel liberté ou pouvoir : elle fonde une interdiction de la torture, de l'utilisation d'un individu, de conditions dégradantes de détention, de la commercialisation du corps humain, de l'exposition de cadavres plastinés à des clients, d'une attraction de lancer de nains, de la publication d'images destinées à fasciner les lecteurs-acheteurs... La dignité est bien, dans toutes ces hypothèses, un *principe* au sens plein, fondé sur l'idée qu'il convient *impérativement* de respecter une certaine humanité. Le droit cherche ici à imposer le respect de ce qui peut être conçu *a priori* comme une objectivité s'imposant à tous (et notamment à un éventuel consentement) : l'appartenance de chacun à l'humanité.

B. Un principe à l'objectivité imprécise et discutable

Il n'en reste pas moins que la dignité, même en ce sens censément objectif, n'est pas toujours dépourvue de subjectivité, pas moins d'ailleurs que les normes du droit positif. Un *choix* préside toujours à la considération que la dignité est effectivement violée dans tel ou tel cas concret. Or, par définition, ce choix n'est pas incontestable, ce qui est renforcé par l'imprécision importante du principe de dignité. En raison de cette imprécision, la dignité est assurément une limite potentiellement redoutable pour les libertés, entendues comme pouvoir d'autodétermination de chacun dans le

respect de l'égalité. S'il s'agit en effet de défendre un contenu substantiel de l'humanité, il est difficile d'envisager les limites de ce contenu... L'ampleur de la dignité doit donc demeurer raisonnable si l'on veut préserver le principe de liberté.

II. Le principe de dignité, borne raisonnable à la liberté ?

A. L'ambivalence de la dignité pour le sujet de droit

Néanmoins, si la dignité est une limite pour le sujet de droit, elle apparaît aussi pour lui comme une garantie de sa propre liberté, une borne opposée à un tiers (pouvoir, individu...) qui voudrait lui imposer une certaine façon de conduire sa vie ou de penser, ou qui le réduirait à n'être plus qu'un objet. Cette « borne » paraît salutaire. Le sujet de droit qui revendique le respect de sa propre dignité s'assure, par là, de l'égale dignité de tous. En insistant sur l'humanité de chaque sujet de droit, le droit met à jour une humanité commune. En ce sens, il n'y a pas lieu de s'offusquer d'une opposition entre la dignité « revendiquée » et la dignité « subie » : c'est le principe de dignité lui-même qui contient cette ambivalence. Renoncer au principe serait renoncer à l'une *et* l'autre de ces dimensions.

B. La place raisonnée de la dignité comme principe

Il semble donc qu'une voie d'issue peut être recherchée dans une définition précise de ce qui constitue la « commune humanité », afin de réserver le principe de dignité aux hypothèses les plus graves de réification de l'homme. Une telle définition préserverait le caractère opératoire du principe et, partant, sa crédibilité ; à défaut, le risque est qu'en dépit de sa teneur axiomatique, la dignité en droit soit galvaudée et donc que les véritables atteintes à ce principe ne soient plus perçues par l'ordre juridique – c'est-à-dire aussi par les consciences.

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2020

SIMULATION AU GRAND ORAL

Sujet n°2 – Commentaire : Cour de cassation, Chambre civile 2, Audience publique du jeudi 4 novembre 2004, N° de pourvoi : 03-15397

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 9 et 16 du Code civil ;

Attendu que le magazine Paris-Match a publié dans son numéro 2685 un article intitulé "Routes, la guerre oubliée" où était publiée la photographie d'un jeune homme inanimé, étendu à demi dévêtu sur un brancard, le visage ensanglanté, autour duquel s'affairaient les secouristes du Samu 77, sous-titrée par la légende : "Il faisait la course en scooter. Il avait 16 ans. Les médecins ne pourront le ranimer" ; que les consorts X... estimant que ce cliché, qui représentait Romain X... décédé le 13 juin 2000 à l'âge de 17 ans des suites d'un accident de la circulation alors qu'il pilotait un scooter, portait atteinte à la dignité de la personne représentée, ont attrait en justice la société Hachette Filipacchi associés ;
Attendu que pour condamner la société Hachette Filipacchi associés à payer des dommages-intérêts aux consorts X..., la cour d'appel a notamment énoncé que le droit à la liberté d'informer s'exerçait dans le respect des droits de l'individu et que la nécessité d'une illustration pertinente ne pouvait être valablement invoquée dans un tel contexte où l'article ne relatait pas un fait d'actualité mais était consacré à un phénomène de société et que la photographie publiée sans précaution d'anonymat de l'intéressé, qui représentait le fils et frère des intimés, le visage maculé de sang, inanimé, sur un brancard, portait atteinte à la dignité de la victime et nécessairement à l'intimité de la vie privée de sa famille ;

Qu'en statuant ainsi alors que le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d'un débat général de phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'information des lecteurs justifiait la publication de la photographie litigieuse, ni caractérisé l'atteinte portée par celle-ci à la dignité de la victime, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre ».

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2020

SIMULATION AU GRAND ORAL

Sujet n°2 – Commentaire : Cour de cassation, Chambre civile 2, Audience publique du jeudi 4 novembre 2004, N° de pourvoi : 03-15397

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 9 et 16 du Code civil ;

Attendu que le magazine Paris-Match a publié dans son numéro 2685 un article intitulé "Routes, la guerre oubliée" où était publiée la photographie d'un jeune homme inanimé, étendu à demi dévêtu sur un brancard, le visage ensanglanté, autour duquel s'affairaient les secouristes du Samu 77, sous-titrée par la légende : "Il faisait la course en scooter. Il avait 16 ans. Les médecins ne pourront le ranimer" ; que les consorts X... estimant que ce cliché, qui représentait Romain X... décédé le 13 juin 2000 à l'âge de 17 ans des suites d'un accident de la circulation alors qu'il pilotait un scooter, portait atteinte à la dignité de la personne représentée, ont attrait en justice la société Hachette Filipacchi associés ;
Attendu que pour condamner la société Hachette Filipacchi associés à payer des dommages-intérêts aux consorts X..., la cour d'appel a notamment énoncé que le droit à la liberté d'informer s'exerçait dans le respect des droits de l'individu et que la nécessité d'une illustration pertinente ne pouvait être valablement invoquée dans un tel contexte où l'article ne relatait pas un fait d'actualité mais était consacré à un phénomène de société et que la photographie publiée sans précaution d'anonymat de l'intéressé, qui représentait le fils et frère des intimés, le visage maculé de sang, inanimé, sur un brancard, portait atteinte à la dignité de la victime et nécessairement à l'intimité de la vie privée de sa famille ;

Qu'en statuant ainsi alors que le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d'un débat général de phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'information des lecteurs justifiait la publication de la photographie litigieuse, ni caractérisé l'atteinte portée par celle-ci à la dignité de la victime, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre ».

En quoi la liberté de la presse de publier des photographies doit-elle faire l'objet de limitations ? Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt commenté, un magazine édité par la société Hachette Filipacchi avait publié un article consacré aux accidents de la route, accompagné d'une photographie représentant M. X, un jeune homme décédé au cours d'un accident de scooter et entouré des services de secours. La photographie était complétée d'une courte légende. Les consorts X. (membres de la famille du jeune homme) avaient assigné la société Hachette Filipacchi en réparation, afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts, au motif que la publication portait atteinte à la dignité de ce jeune homme. L'arrêt ne précise pas la solution de première instance, mais la Cour d'appel de Versailles avait fait droit, par un arrêt du 3 avril 2003, à la demande des consorts X., en condamnant la société défenderesse pour deux raisons. D'une part, l'argument tiré d'une illustration pertinente pour un fait d'actualité n'était pas convaincant car l'article en question était au contraire consacré à un phénomène de société. D'autre part, la photographie publiée sans anonymat d'un proche décédé portait ici atteinte à la dignité de la victime et à l'intimité de la vie privée de la famille de celui-ci.

La société Hachette Filipacchi avait formé un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation, afin d'obtenir l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles.

Il se posait la question de savoir dans quelle mesure la presse pouvait librement publier la photographie d'une victime d'un accident de la route sans porter atteinte à la dignité de la personne humaine.

Par son arrêt commenté, rendu par le deuxième chambre civile le 4 novembre 2004, au visa des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des articles 9 et 16 du Code civil, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, puis renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de Paris. Elle formule le principe selon lequel « le principe de liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d'un débat général de phénomène de société », sachant que cette liberté s'exerce « sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine ». En conséquence, elle estime que l'arrêt d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision », car d'une part elle « n'a pas recherché si l'information des lecteurs justifiait la publication de la photographie » et d'autre part n'a pas « caractérisé l'atteinte portée par [cette publication] à la dignité de la victime ».

Plusieurs points méritent ici réflexion. La Cour de cassation fixe d'abord un cadre général par lequel la presse peut choisir librement ses illustrations, dès lors qu'il s'agit d'informer sur un « phénomène de société », sous réserve d'une atteinte à la dignité de la personne humaine (I). Ce principe général n'en pose pas moins question, car si la solution de la Cour est mesurée, elle reste ambivalente tant sur la détermination de la dignité de la personne humaine que sur la question de savoir en quoi consiste un « phénomène de société » (II).

I. L'énoncé d'un principe de liberté de la presse

Le principe que pose la Cour de cassation est un principe de liberté concernant le choix d'une photographie destinée à informer (A), limité par une éventuelle atteinte à la « dignité de la personne humaine » (B).

A. Le contrôle du caractère informatif de la photographie

La Cour de cassation pose tout d'abord « le principe » - formulé comme tel – de « liberté de la presse », dont elle estime qu'il « implique » un élément en matière d'illustrations : un « libre choix des illustrations d'un débat général de phénomène de société ». Le principe de liberté de la presse est fort ancien, le droit français l'ayant consacré dès 1789 (art. 11) et précisé dès la loi du 29 juillet 1881. Cette liberté constitue même aujourd'hui un élément fondamental d'une société démocratique, comme le rappelle constamment la Cour européenne sur le fondement de l'article 10 de la Convention (par ex., CEDH, 7 décembre 1976, *Handyside c. Royaume-Uni*). Il n'y a donc rien d'étonnant à le voir rappeler ici.

Plus spécifique ici est l'implication qu'en tire la Cour concernant la publication par la presse de photographies accompagnant l'information. Telle était la difficulté précise dans cette affaire. Pour censurer l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles, la Cour de cassation sanctionne le fait que la première « n'a pas recherché si l'information des lecteurs justifiait la publication de la photographie litigieuse ». Une telle formulation signifie que la Cour impose au juge un contrôle en la matière : pour qu'une photographie puisse être publiée, il faut d'abord que cette publication soit *justifiée par* l'information des lecteurs, ce qui suppose logiquement un contrôle de cette justification. Cette considération sous-entend qu'une photographie peut par elle-même avoir une valeur informative, et non pas simplement illustrative. En d'autres termes, la censure par la Cour de cassation paraît ici signifier qu'une photographie n'est pas seulement le complément (plus ou moins dispensable) d'une information, mais un élément qui contribue à celle-ci.

De plus, le principe posé par la Cour ne doit pas laisser penser que la liberté ainsi consacrée serait illimitée : elle n'a de sens – du moins dans cet arrêt – que dans le champ défini par la Cour et non pas de manière générale et absolue. Au demeurant, toute liberté suppose juridiquement un *cadre*, un champ dans lequel elle peut s'exercer. Or ce champ comporte ici deux éléments définis par la Cour : le premier est la nécessité du caractère informatif de la photographie ; le second est le rapport de cette publication avec l'illustration d'un « débat général de phénomène de société ».

La liberté de la presse, définie ainsi dans ses contours (sans pouvoir l'être dans son contenu, car le droit ne peut pas définir le *contenu* d'une liberté sans remettre en cause cette dernière), n'en connaît pas moins une limite de taille : la dignité humaine.

B. Les possibilités d'une limitation par la dignité « de la victime »

En effet la liberté de la presse n'est pas plus illimitée qu'une autre liberté : elle ne peut pas ne pas connaître, en droit, des limites. Ici encore, la position de la Cour de cassation n'est guère originale car elle précise justement une limite : le « respect de la dignité *de la personne humaine* ».

D'une part, une telle formulation pose question, car elle n'indique pas précisément dans quelle mesure il serait possible de contester la publication d'une photographie. L'action est-elle réservée aux seules victimes (et donc à ses héritiers) ? Peut-elle être étendue aussi aux proches de la victime photographiée (et donc à la réparation de leur propre préjudice, s'il existe) ? La Cour semble donner un élément de réponse lorsqu'elle censure l'arrêt de la Cour d'appel : elle fait en effet référence à la « dignité *de la victime* ». Si l'on combine les deux formules, la liberté de la presse ne serait donc limitée

que par la dignité humaine *de la victime*, et non pas à proprement parler celle, *a priori* plus générale, *de la dignité humaine*. Cette lecture combinée conduirait à une interprétation restrictive de la limite posée par la dignité à la liberté de la presse. Il faut noter toutefois que la Cour vise dans son arrêt les articles 9 et 16 du Code civil. La vie privée *des proches* serait donc nécessairement liée à la dignité *de la victime* (car le droit à la vie privée s'éteint avec la personne qui en est le titulaire et n'est pas transmissible aux tiers). Il faut constater à cet égard que la Cour d'appel avait explicitement lié la dignité de la victime et les droits de la famille, car elle avait relevé qu'il existait une « atteinte à la dignité de la victime et nécessairement à l'intimité de la vie privée de sa famille », conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation[1].

D'autre part, il convient de noter que seule la dignité peut ici faire obstacle à la liberté de la presse. Une telle restriction peut laisser penser que la Cour de cassation donne un primat à la liberté de la presse, au point d'ériger cette liberté en quasi-absolu. La censure de l'arrêt d'appel quant à la caractérisation de la dignité, pourrait le laisser croire, car la Cour d'appel avait tout de même pris soin de motiver son raisonnement. Autrement dit, la limite de la dignité ne serait plus qu'une exception extrêmement restreinte à une liberté de la presse érigée en principe suprême. Cela dit, l'exception de la dignité n'en existe pas moins et l'on peut considérer qu'elle peut jouer dans beaucoup d'hypothèses.

Singulièrement mesuré, l'arrêt rendu par la Cour de cassation pose donc assez clairement un principe et une exception. Il admet ainsi que la liberté d'informer ne soit pas toute puissante, tout en précisant qu'elle doit demeurer une liberté. Pour autant, cette solution soulève des questions si l'on examine plus précisément ses éléments principaux.

II. L'ambivalence des conditions posées à l'exercice de la liberté de la presse en l'espèce

Deux conditions principales sont posées en l'espèce, qui n'ont certes pas le même sens ni la même portée : la dignité est une *limite* aux dérives de la liberté de la presse (A), cependant que le rattachement au « débat général de phénomène de société » est un *élément constitutif* de l'exercice de cette liberté (B). L'une comme l'autre sont toutefois relativement ambivalentes.

A. La dignité, rempart contre le sensationnalisme ?

Toute la difficulté de l'affaire reposait sur la question de savoir quelles limitations étaient susceptibles d'être opposées à la publication d'une photographie. En imposant à la Cour d'appel de renvoi de vérifier si, en l'espèce, une atteinte portée par la publication à la dignité de la victime était caractérisée, la Cour de cassation ne tranche pas elle-même l'espèce. Elle se contente d'indiquer le raisonnement que devra suivre la Cour. En d'autres termes, l'arrêt commenté ne préjuge en rien de la solution qui sera rendue par la Cour d'appel de renvoi : conformément à son rôle de cassation, la juridiction suprême dit le droit, indépendamment des faits et de leur qualification au regard du droit. Il est bien clair que l'on peut estimer que cette distinction entre fait et droit, caractéristique de la technique de

a)

[1] « si les proches d'une personne peuvent s'opposer à la reproduction de son image après son décès, c'est à la condition d'en éprouver un préjudice personnel établi, déduit le cas échéant d'une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort » (Cass. 1re civ., 22 oct. 2009, n° 08-10.557). On peut considérer que c'est précisément la dignité humaine (en tant qu'elle survit par principe à la mort) qui permet de constituer le lien de rattachement entre la personne décédée et les droits de sa famille.

cassation, est souvent perméable. Mais la Cour ne fait qu'envisager *l'hypothèse* dans laquelle la dignité *pourrait* faire obstacle à la publication d'une photographie, et donc limiter par là même la liberté de la presse.

Il y a lieu, à ce propos, de s'interroger sur le *contenu* exact de la dignité en tant que limite à cette liberté. Premièrement, il faut relever une incertitude tenant à l'ambivalence de la notion même de dignité : celle-ci peut désigner en effet la dignité opposée par une personne (ou ses héritiers) aux tiers, mais aussi la dignité conçue en termes beaucoup plus objectifs, par exemple comme constitutive de l'ordre public. Or l'ordre public permet précisément de limiter la liberté de la presse, notamment pour préserver une certaine morale. La question semble d'autant plus de poser que l'on sait que la dignité n'est pas pure de toute connotation morale.

Deuxièmement, au regard de la jurisprudence tant administrative que judiciaire, il semble que les atteintes à la dignité soient caractérisées lorsque la publication obéit à une logique de sensationnalisme, d'indécence – ou de « choc des photos » comme l'affirme le slogan du magazine qui avait publié la photographie en l'espèce. Dès lors, il conviendrait peut-être de distinguer la publication d'une photographie *choquante du fait de la réalité sociale photographiée*, de la publication d'une photographie *faite pour choquer*, par exemple placée dans un contexte particulier, par exemple de complaisance ou d'insistance morbide. La ligne de partage entre les deux, bien qu'extrêmement poreuse en pratique, permettrait-elle de caractériser l'atteinte à la dignité humaine ? Telle est, semble-t-il, une interprétation que l'on peut faire de l'arrêt commenté, à l'aune notamment de la célèbre jurisprudence sur la publication d'une photographie du préfet Erignac assassiné, plus catégorique mais moins précise sur ce point (Cass. 1ère civ., 20 décembre 2000, n° 98-13.875, qui approuve la Cour d'appel d'avoir considéré que « la photographie publiée représentait distinctement le corps et le visage du préfet assassiné, gisant sur la chaussée d'une rue d'Ajaccio [...] était attentatoire à la dignité de la personne humaine »).

B. Le rattachement à un « phénomène de société », condition vague

L'arrêt cassé par la juridiction suprême considérait que l'argument d'une illustration pertinente accompagnant l'article n'était pas pertinent, car il ne s'agissait justement pas de choisir une illustration pertinente: l'article portait non pas sur tel fait divers, mais sur un «phénomène de société». Autrement dit, la nécessité d'une illustration pertinente n'expliquait (ou n'excusait) en rien le choix de cette photographie précise pour accompagner un dossier d'ordre général. Or la Cour d'appel semble admettre une atteinte à la dignité du fait même de la photographie en cause, et non pas relativement au contexte d'un article portant sur un phénomène de société.

Pour sa part, la Cour de cassation ne reprend pas la distinction entre le fait d'actualité et le phénomène de société. Plus exactement, elle *présuppose* que l'affaire portait sur une photographie illustrant un phénomène de société. En ce sens, l'on peut estimer qu'elle approuve la Cour d'appel. Il est vrai que le « phénomène de société » en cause dans cette affaire portait sur les accidents de la route. Le magazine avait intitulé son article « *Routes, la guerre oubliée* », ce qui laissait bien entrevoir une information de nature générale sur une réalité sociale elle-même suffisamment générale et (malheureusement) répandue. Pour autant, ce présupposé de la part de la Cour indique qu'en dépit de son rôle de juge de cassation, elle qualifie implicitement les faits précis de l'espèce sur ce point.

Quoi qu'il en soit, le juge se montre vigilant quant à la finalité de l'information en cause. Il existerait donc une liberté spécifique de choix des illustrations publiées dès lors qu'il s'agirait d'illustrer un « phénomène de société », de contribuer au « débat général » sur un tel phénomène. Dès lors qu'il s'agirait d'illustrer un « phénomène de société », cette liberté de choix serait plus étendue qu'à l'ordinaire ; tel est l'interprétation que l'on peut faire de la solution. Il n'en demeure pas moins que le critère du « phénomène de société » n'est guère précisé dans cet arrêt, alors qu'il constitue ici le cadre de la liberté de la presse en matière de choix des illustrations. Selon une jurisprudence antérieure et dans une formulation très proche de celle de l'arrêt commenté, « la liberté de communication des informations autorise la publication d'images des personnes *impliquées dans une affaire judiciaire*, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine » (Cass. 1ère civ., 12 juillet 2001, n° 98-21.337) ou « impliquées dans un événement » (Cass., 1ère civ., 20 février 2001). Ces seuls exemples permettent de s'interroger : une « affaire judiciaire » ou un « événement » recouvre-t-il la même chose qu'un « phénomène de société » ?

Enfin, l'ambiguïté est renforcée si l'on admet que le critère du « phénomène de société » sous- entend que la presse se contenterait de *refléter* des événements, alors que le pouvoir médiatique *constitue* toujours (au moins en partie) les événements dont il parle. Il faut sélectionner les faits et les réalités sociales pour pouvoir identifier un « phénomène social », qui n'est pas entièrement donné *a priori* et par lui-même. Cette ambivalence pouvait se retrouver en l'espèce : certes le magazine entendait faire état d'une réalité qu'il se contentait de constater, mais l'article avait aussi et en même temps pour objet de constituer les accidents de la route en « phénomène de société » afin d'attirer l'attention des lecteurs. L'article était d'ailleurs intitulé une « guerre oubliée ». Or un « ennemi » n'est jamais *donné* avant une guerre : il est aussi *crée* par elle.

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2020

SIMULATION AU GRAND ORAL

Sujet n°3 – Argumentation : Soutenez que la peine de mort n'est pas contraire aux libertés fondamentales

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2020

SIMULATION AU GRAND ORAL

Sujet n°3 – Argumentation : Soutenez que la peine de mort n'est pas contraire aux libertés fondamentales

La peine de mort est la punition ultime infligée par la justice d'un État.

Elle interroge la possibilité dudit État, au nom de l'exigence de sécurité due aux citoyens par le contrat social, d'infliger la sanction suprême à un criminel reconnu coupable des pires infractions à la suite à un procès d'assises.

JJ. Rousseau dans son contrat social (1762) prévoit que celui qui viole les termes du contrat social doit être châtié de mort. La théorie de la défense sociale nouvelle insiste particulièrement sur les vertus de rétribution et d'élimination de la société de certains individus dangereux par essence. Le débat intellectuel qui opposa M. Barrès et A. Briand se centra sur les questions d'effectivité de dissuasion et de rétribution de la peine de mort.

En France, la dernière exécution a eu lieu en 1977 et la peine de mort fut abolie à l'initiative de Robert Badiner par la loi L. n°81-908 du 9 octobre 1981.

Aujourd'hui, l'article 66-1 de la Constitution dispose que « nul ne peut être condamné à la peine de mort », et la France est partie au 2ème protocole du PIDCP et au 13ème protocole à la Convention européenne.

Dans quelle mesure la sanction de peine de mort, encadrée, pourrait être compatible avec l'ordonnancement juridique protecteur des libertés fondamentales ?

I. La protection de la vie et la défense de l'intérêt général au cœur du rétablissement de la peine de mort

- La garantie de la sécurité par l'État : L'État droit assurer la sécurité des citoyens pour permettre la garantie des libertés fondamentales, un « droit à la sécurité » justifierait l'existence de la légitimité de la peine de mort
- La protection du droit à la vie d'autrui : Condamner à mort un criminel est une manière de dissuader, et donc de mieux protéger, la vie des concitoyens

II. L'abolition de la peine de mort discutable

L'interdiction de la peine de mort est relativement récente, insérée dans la Constitution française mais pourrait être modifiée, voire retirer du champ de la protection constitutionnelle.

Cette abolition s'est opérée par un débat législatif mais dans lequel le peuple ne fut que trop peu écouté ; une telle question de société devrait relever des processus de démocratie directe.

Au niveau international, même les alinéas 2, 4, 5 et 6 de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne font qu'encadrer la peine de mort, sans l'interdire. Certes, le Protocole numéro 2 du Pacte du 15 décembre 1989 pose l'interdiction de la peine de mort mais tous les États parties au Pacte ne sont pas parties à ce protocole.

Au sein du Conseil de l'Europe, c'est par une interprétation très extensive, voire contra legem que la Cour européenne des droits de l'Homme a interdit la peine de mort :

L'article 2 de la Convention Européenne des droits de l'homme, qui protège le droit à la vie, se lit comme permettant la peine de mort sous certaines conditions : « La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi » . Des protocoles successifs sont venus accompagner le mouvement de condamnation et rejet de la peine de mort exprimé au sein de la population civile. D'abord, le Protocole additionnel n°6 à la Convention Européenne des droits de l'homme du 28 avril 1983 interdisait la peine de mort en temps de paix mais la peine de mort en temps de guerre restait licite. Ensuite, le Protocole additionnel n° 13 à la Convention du 2 mai 2002 étend l'interdiction de la peine capitale « en toutes circonstances ». Tous les États du Conseil de l'Europe ne sont pas parties à ce Protocole numéro 13. Néanmoins, la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'Homme a également évolué sur ce point, et son interprétation lie tous les États membres du Conseil de l'Europe : Dans l'affaire Soering (CEDH, 7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni, n°14038/88), la Cour a affirmé que la peine de mort devait être jugée comme ne cadrant plus « avec mes normes régionales de justice ». Après l'entrée en vigueur du Protocole 6, la Cour s'est fondée sur « *l'accord entre des États contractants pour abroger, ou du moins modifier l'article 2§1 que ce protocole révèle* », et affirme que « *la peine de mort en temps de paix en est venue à être considérée comme une forme de sanction inacceptable (…) qui n'est plus autorisée* » (CEDH, Gr. Ch., 12 mai 2005, Ocalan c. Turquie). C'est en 2010 que l'a Cour pose l'incompatibilité ente la peine de mort et la Convention européenne en toutes circonstances et pour tous les États par son arrêt du 2 mars 2020 : Al Sadoun et Mufdhi c. Royaume-Uni. Il s'agit là d'une volonté de la Cour Européenne plus que d'une application de la lettre de la Convention !

III. Un encadrement de la peine de mort

- Le respect du principe de légalité des délits et des peines
- Une peine de mort dans des conditions respectueuses de la protection du corps humain : utilisation de méthode rapides et indolores
- Le « syndrome du couloir de la mort » peut être proportionné si l'exécution est prompte après le jugement.
- Une atteinte nécessaire, proportionnée à la vie du criminel au nom du droit à la sûreté : Les États-Unis, la plus vielle démocratie, pratiquent la peine de mort qui n'est pas contraire au « substantive due process of law » protégés par les 5ème et 14ème Amendement.
- La peine de mort est alors appliquée après verdict de condamnation devant un jury populaire avec toutes les garanties procédurales :
- interrogatoires croisées (cross-examination),
- interdiction de la preuve par oui-dire (Hearsay)
- surtout un standard de preuve plus élevé que celui de l'intime conviction, la preuve au-delà d'un doute raisonnable (proof beyond a reasonanble doubt).

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2020

SIMULATION AU GRAND ORAL

Sujet n°2 – Commentaire : Décision n° 2020-799 DC du 26 mars 2020 portant examen de la loi organique d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

Décision n° 2020-799 DC du 26 mars 2020 portant examen de la loi organique d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

« *LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 23 mars 2020, par le Premier ministre, sous le n° 2020-799 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.*

Au vu des textes suivants :

- *la Constitution ;*
- *l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;*

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

***1.** La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.*

***2.** Déposé devant le Sénat, première assemblée saisie, le 18 mars 2020, le projet de loi organique, pour lequel le Gouvernement a engagé la procédure accélérée, a été examiné en séance publique le lendemain.*

***3.** Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de juger que cette loi organique a été adoptée en violation des règles de procédure prévues à l'article 46 de la Constitution.*

***4.** Conformément au premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution, les articles 23-4 et 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus fixent à trois mois le délai déterminé dans lequel le Conseil d'État ou la Cour de cassation doit se prononcer sur le renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. L'article 23-10 de la même ordonnance prévoit que le Conseil constitutionnel statue dans un même délai de trois mois après sa saisine.*

***5.** Afin de faire face aux conséquences de l'épidémie du virus covid-19 sur le fonctionnement des juridictions, l'article unique de cette loi organique se borne à suspendre jusqu'au 30 juin 2020 le délai dans lequel le Conseil d'État ou la Cour de cassation doit se prononcer sur le renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et celui dans lequel ce dernier doit statuer sur une telle question. Il ne remet pas en cause l'exercice de ce recours ni n'interdit qu'il soit statué sur une question prioritaire de constitutionnalité durant cette période.*

***6.** Ces dispositions sont conformes à la Constitution.*

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La loi organique d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est conforme à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mars 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 26 mars 2020 »

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2020

SIMULATION AU GRAND ORAL

Sujet n°2 – Commentaire : Décision n° 2020-799 DC du 26 mars 2020 portant examen de la loi organique d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

Décision n° 2020-799 DC du 26 mars 2020 portant examen de la loi organique d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

« *LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 23 mars 2020, par le Premier ministre, sous le n° 2020-799 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.*

Au vu des textes suivants :

- *la Constitution ;*
- *l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;*

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

***1.** La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.*

***2.** Déposé devant le Sénat, première assemblée saisie, le 18 mars 2020, le projet de loi organique, pour lequel le Gouvernement a engagé la procédure accélérée, a été examiné en séance publique le lendemain.*

***3.** Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de juger que cette loi organique a été adoptée en violation des règles de procédure prévues à l'article 46 de la Constitution.*

***4.** Conformément au premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution, les articles 23-4 et 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus fixent à trois mois le délai déterminé dans lequel le Conseil d'État ou la Cour de cassation doit se prononcer sur le renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. L'article 23-10 de la même ordonnance prévoit que le Conseil constitutionnel statue dans un même délai de trois mois après sa saisine.*

***5.** Afin de faire face aux conséquences de l'épidémie du virus covid-19 sur le fonctionnement des juridictions, l'article unique de cette loi organique se borne à suspendre jusqu'au 30 juin 2020 le délai dans lequel le Conseil d'État ou la Cour de cassation doit se prononcer sur le renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et celui dans lequel ce dernier doit statuer sur une telle question. Il ne remet pas en cause l'exercice de ce recours ni n'interdit qu'il soit statué sur une question prioritaire de constitutionnalité durant cette période.*

***6.** Ces dispositions sont conformes à la Constitution.*

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La loi organique d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est conforme à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mars 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 26 mars 2020 »

[*Commentaire pour la correction :*

En commentaire, l'étudiant devra toujours au moins répondre aux 4 questions du QQOPC (Qui ? (CC) Quoi ? (DC) Où ? (publié) Comment ? (décision brève, introduction des circonstances particulières) Pourquoi ? (nécessité d'assurer sa propre efficacité en période de confinement ?)). Une question doit être formulée, le plan doit être découpé en deux parties elles-mêmes subdivisées en deux sous-parties. Il s'agit de souligner les apports de cette décision dans l'ordonnancement jurisprudentiel préexistant.].

Le Conseil constitutionnel, responsable de la constitutionnalité des lois, se prononce ici sur la loi organique d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 qui prévoyait une suspension des délais QPC.

Le 18 mars 2020, le Conseil des ministres adoptait l'article unique d'un projet de loi organique tendant à suspendre pour trois mois (jusqu'à la fin du mois de juin) les délais normalement imposés aux juridictions suprêmes (Cour de Cassation et Conseil d'État) pour examiner les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). Le gouvernement engageait la procédure accélérée. Dès le lendemain, le Sénat vota le texte dans la journée. L'Assemblée nationale fit de même dans les deux jours suivants. L'article 61 de la Constitution impose que les lois organiques soient déférées au Conseil constitutionnel ; c'est à ce titre que le secrétaire général du gouvernement, au nom du Premier ministre, transmet au Conseil constitutionnel la loi adoptée.

Par une brève décision et en créant un nouveau concept juridique (les « circonstances particulières »), le Conseil Constitutionnel valide cette loi en dépit du non-respect des délais imposés par la Constitution en son article 46 alinéa 2.

Dans quelle mesure la légitimité du Conseil constitutionnel peut-elle être discutée face à cet arrêt ?

I. Le Juge constitutionnel statuant *contra-constitutionem*

La loi organique d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (loi n° 2020-799), a été adoptée en méconnaissance des délais imposés par la Constitution pour le vote d'une loi organique, sans pour autant que le Conseil Constitutionnel ne déclare celle-ci inconstitutionnelle pour vice d'adoption : « *Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de juger que cette loi organique a été adoptée en violation des règles de procédure prévues à l'article 46 de la Constitution* » (alinéa 3).

La méconnaissance de la prescription constitutionnelle de l'article 61 n'est pas discuté (A) et pourtant la loi organique est considérée comme conforme à la constitution « compte tenu des circonstances particulières ». Faut-il voir dans cette légitimation a posteriori d'une situation inconstitutionnelle la création d'une exception jurisprudentielle ? (B)

A. Le non-respect évident du délai imposé par la Constitution

Une loi organique fut adoptée le 18 mars 2020 en Conseil des ministres afin de suspendre pour trois mois, les délais normalement imposés aux juridictions suprêmes pour examiner les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). Le gouvernement a engagé la procédure accélérée, et le Sénat et le Parlement ont voté la loi dans les deux jours suivants. Or, l'article 61 de la Constitution impose

que les lois organiques soient déférées au Conseil Constitutionnel, et l'article 46 alinéa 2 impose, lui, un délai d'au moins quinze (15) jours entre le dépôt du texte d'une loi organique relevant de la procédure accélérée et sa délibération parlementaire en séance plénière. La raison d'être de ce délai était d'éviter que les lois organiques, qui influent sur l'équilibre institutionnel en complétant et précisant la Constitution, ne soient modifiées « à la sauvette »[1]. Dès son adoption, des critiques émanaient quant à son inadéquation avec les situations d'urgence. Pour autant, ce délai fut adopté, choisi, et ainsi prévu par la Constitution[2]. Cette règle procédurale n'est pas un principe[3], c'est bien une règle, claire, qui fut plusieurs fois contrôlée par le Conseil Constitutionnel par le passé[4].

Le Conseil constitutionnel en validant la constitutionnalité de la loi semble donc décider *contra-constitutionem*. Qui plus est, sa motivation est d'une concision, d'une avidité argumentaire, soulignée en doctrine : « *compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de juger que cette loi organique a été adoptée en violation des règles de procédure prévues à l'article 46 de la Constitution* ». La crise sanitaire devient une « circonstance particulière » permettant au législateur de s'économiser le respect de la Constitution. Autrement dit, « *l'épidémie de covid-19 justifie, à elle seule, que soit pardonnée l'inconstitutionnalité procédurale commise lors de la préparation de cette loi organique* »[5].

B. La consécration d'une nouvelle exception jurisprudentielle ?

Cette décision fait-elle naitre une « théorie des circonstances particulières » pour le Conseil constitutionnel, en miroir à la théorie des circonstances exceptionnelles du Conseil d'état ?

Pour rappel, la théorie des circonstances exceptionnelles repose sur deux arrêts du Conseil d'État intervenus à l'occasion de la Première Guerre mondiale[6]. Le respect du principe de légalité et de ses composantes, normalement imposables à l'Administration, peut connaître quelques inflexions sous certaines circonstances. Le juge administratif, lorsqu'il considère un acte de l'Administration, peut décider que les règles de droit normalement applicables ne le sont plus, en raison de la nature exceptionnelle des circonstances.

Il semble que l'analogie n'est pas tout à fait possible.
Alors que le Conseil d'État motive très largement et à l'issue d'un raisonnement juridique très précis son recours à la théorie des circonstances exceptionnelles, le Conseil constitutionnel, lui, se montre très avare de précisions et sa formulation semble plus ressortir de la lacune juridique pour justifier le sentiment d'urgence de ces membres et de nécessité de faire avancer la loi organique que d'une volonté de créer un nouveau régime d'exception. Quelques jours après la décision, J-B. Jacquin,

---

[1] J. Solal-Céligny, Co-rapporteur du projet de réforme constitutionnelle, Conseil d'État, 25 août 1958, *in* Comité national chargé de la publication des travaux préparatoires des institutions de la Vème République, *Documents pour servir à l'histoire de l'élaboration de la constitution du 4 octobre 1958, Tome 3 : Du Conseil d'état au référendum*, Paris, Documentation Française, 1991, p. 142 cité par J. Jeanneney, « La non-théorie des "circonstances particulières" », *op. cit.* note 40, p. 845

[2] François Luchaire y voyait un délai « trop lourd pour les cas d'urgence » (Observations sur l'avant-projet, 29 juill. 1958, *in* Comité national chargé de la publication des travaux préparatoires des institutions de la Vème République, *Documents pour servir à l'histoire de l'élaboration de la constitution du 4 octobre 1958. 3*, *op. cit.* note 50, p. 53)

[3] Selon la distinction classique entre règle et principe ; le premier relevant d'une applicabilité claire (la règle s'applique ou ne s'applique pas) ce dont manque le second, dont les contours sont plus vagues ; sur ce point voir R. Dworkin, *Taking rights seriously*, Cambridge, Harvard Univ. Press, 1978, p. 14.

[4] Par exemple : DC, 26 mars 2020, n° 2020-797 DC ; n° 2020-797 DC ; 16 juill. 1996, n° 96-379 DC ; 27 janv. 1994, n° 93-337 DC ;19 nov. 1993, n° 93-327 DC ; 28 déc. 1985, n° 85-205 DC

[5] J. Jeanneney, « La non-théorie des "circonstances particulières" », *op. cit.* note 32, p. 843-848

[6] Conseil d'État, 28 juin 1918, Heyriès, n° 63412 ; Conseil d'État, 28 févr. 1919, n° 61593, *Mmes Dol et Laurent*.

membre du Conseil constitutionnel, reconnaissait dans un article de *Le Monde* que « *cela n'a rien à voir avec la théorie des circonstances exceptionnelles développée par le Conseil d'État, c'est une appréciation au regard de la situation d'espèce* » ((*J.-B. Jacquin, Coronavirus : l'état d'urgence sanitaire ouvre des brèches dans l'État de droit, Le Monde, 28 mars 2020*). Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, a également réfuté une « *quelconque théorie générale des circonstances exceptionnelles* » ((*L. Fabius, Pas d'éclipse des principes fondamentaux du droit, Le Figaro, 18 avr. 2020*)

Bien qu'ayant précisé l'effet limité que les rédacteurs ont souhaité lui donner, la formulation de la justification, et la concision de l'argumentation, ont fait naitre nombre de critiques contre la légitimité du Conseil consitutionnel à se prononcer de manière si laconique contre une prescription explicite de la Constitution ((*P. Cassia, Le Conseil constitutionnel déchire la Constitution, blog Mediapart, 27 mars 2020 ; R. Letteron, Covid-19: le Conseil constitutionnel marche sur la Constitution, Libertescheries.blogspot, 28 mars 2020*). De plus, la légitimité du Conseil Constitutionnel peut également être interrogé en ce que, dans cette discussion, il statuait sur son propre office.

II. Le juge constitutionnel statuant sur son propre office

Le traitement des QPC relevant de son office, le Conseil Constitutionnel devait ici se prononcer sur une loi dont il est le premier bénéficiaire[7]. En effet, l'article 23-7 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 prévoit que le non-respect du délai de 3 mois par une juridiction suprême entraîne le renvoi automatique de la QPC au Conseil Constitutionnel. Il ressort des travaux parlementaires que le Gouvernement s'inquiétait également que les QPC et autres recours juridictionnels puissent entacher son efficacité. En effet, le ministre de l'Intérieur a clairement énoncé qu'il s'opposait à ce que *« l'ensemble de ce qui vient d'être voté puisse faire l'objet de recours et de QPC* » lorsque le député Jean-Christophe Lagarde proposait d'amender la loi organique afin que les délais habituels de QPC soient maintenus pour celles qui toucheraient la loi relative à l'état d'urgence sanitaire, discutée en même temps au Parlement.

A. La suspension des délais QPC

L'ordonnance organique du 7 novembre 1958 soumet l'examen des QPC par les juridictions ordinaires et le Conseil constitutionnel à des délais. L'article 23-2 de l'ordonnance énonce que les juges du fond doivent statuer « sans délai », c'est-à-dire le plus rapidement possible.

Les articles 23-4 et 23-5 imposent à la Cour de cassation et au Conseil d'État de se prononcer dans un délai de trois mois après que la QPC a été transmise par une juridiction du fond ou qu'elle a été soulevée directement devant la juridiction suprême.

Enfin, l'article 23-10 dispose que le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Ces délais ont pour objet d'assurer que les QPC sont examinées rapidement par les juridictions et qu'elles ne retardent pas substantiellement le traitement des affaires.

L'article 23-7 de l'ordonnance organique de 1958 énonce que si le Conseil d'État ou la Cour de cassation ne se prononce pas dans un délai de trois mois sur la QPC qui leur a été transmise ou qui a

[7] Il ressort des travaux parlementaire préalables à l'adoption de cette loi organique que le président de la Commission des lois du Sénat a présenté le texte comme le fruit d'une « préoccupation très vive » et d'une « attente pressante » du Conseil Constitutionnel redoutant alors « d'être rapidement encombré » par les QPC (Sénat, commission des lois, Rapport n° 381, 19 mars 2020).

été soulevée devant eux, celle-ci est transmise de plein droit au Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que la juridiction suprême doit transmettre la QPC au Conseil constitutionnel, sans s'être assurée qu'elle remplit les conditions de renvoi prévues par les articles 23-4 et 23-5. Dans une telle hypothèse, la QPC n'aura fait l'objet soit que du seul filtre de la juridiction du fond, soit d'aucun filtre si elle a été soulevée pour la première fois devant la juridiction suprême.

Au regard de la crise sanitaire, le législateur a souhaité suspendre les délais d'examen des QPC devant les juridictions suprêmes et le Conseil constitutionnel jusqu'au 30 juin 2020. Il résulte de cette loi que les délais d'examen des QPC sont suspendus, compte tenu de l'urgence, dès la promulgation de la loi (le 30 mars 2020). Ensuite à partir du 30 juin 2020, les délais de procédure qui auront commencé à courir avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique reprendront leur cours.

La loi ne touche pas aux délais d'examen des QPC par les juridictions du fond, surement parce qu'il ne s'agit pas d'un délai fixe qui serait sanctionné par un dessaisissement de la juridiction en cas de méconnaissance de celui-ci. La loi procède à la suspension des délais trimestriels d'examen des QPC devant les juridictions suprêmes comme devant le Conseil constitutionnel. Le législateur s'appuie sur la forte probabilité, compte tenu de la difficulté pour ces juridictions de statuer durant la période de confinement, que certaines QPC pendantes devant les deux juridictions suprêmes devront être transmises de plein droit du fait de l'expiration du délai de trois mois.

D'après le Gouvernement et le Parlement, une transmission de plein droit des QPC conduirait le Conseil à être « *menacé d'engorgement par des affaires ne présentant aucun intérêt et que, dans des circonstances normales, les juridictions faîtières auraient refusé de lui soumettre* »[8], ce « *qui nuirait à la bonne administration de la justice* »[9]. Il nous semble pourtant que les arguments avancés par le législateur au soutien de l'adoption de la loi organique suspendant le délai d'examen QPC sont très fragiles. En d'autres termes, la crainte de l'engorgement du Conseil constitutionnel n'est pas réellement fondée.

B. La justification lacunaire

1) Un délai indicatif

Le délai de trois mois prévu dans l'article 23-10 de l'ordonnance (prévoyant que le Conseil doit statuer dans un délai de trois mois) n'ouvre pas une voie de recours en cas de non-respect.

2) Un délai gérable

Le Conseil constitutionnel ne semble pas déborder par les QPC et a plutôt tendance à statuer sur les QPC dans un délai inférieur à trois mois. La seule instance dans laquelle il a mis plus de trois mois à répondre à une QPC fut dans l'affaire relative au mandat d'arrêt européen impliquant le renvoi d'une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE)[10] (le dépassement du délai n'avait eu aucune incidence sur la validité de la procédure ou celle de la décision du Conseil).

[8] Rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale, 20 mars 2020

[9] Étude d'impact sur le projet de loi organique d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid – 19

[10] CC, n° 2013-314 QPC du 14 juin 2013, *Jeremy F. [Absence de recours en cas d'extension des effets du mandat d'arrêt européen]*. Décision rendue plus de quatre mois après la saisine.

Les équivalents du Conseil Constitutionnel dans d'autres pays européens ont généralement moins de trois mois pour statuer[11].

Conclusion :

L'absence de nécessité et d'urgence à suspendre les délais d'examen des QPC contraste avec le choix du législateur de se précipiter à suspendre ces délais en violation des dispositions de la Constitution.

On comprend mal que le Conseil constitutionnel soit tellement préoccupé par l'augmentation de sa charge de travail et la préservation du double filtre, qu'il en arrive à couvrir ce qui peut apparaître comme une violation de la Constitution qu'il est censé garantir même en période de circonstances exceptionnelles.

Il faudra raison garder un certain temps avant de constater l'étendue de cette nouvelle théorie, et les implications en termes de pouvoirs exceptionnels qu'elle pourrait entraîner. Certains auteurs dès aujourd'hui posent une distinction très nette entre la théorie des circonstances particulières du Conseil Constitutionnel, qui ne serait que révélatrice d'un manque d'inventivité et d'une volonté de ne pas rendre une règle de procédure « responsable » d'un délai dans l'adoption d'une loi organique d'urgence, et la théorie des circonstances exceptionnelles du Conseil d'État.

[11] La Cour constitutionnelle allemande n'est soumise à aucun délai et la Cour constitutionnelle belge dispose d'un délai de six mois renouvelable (Article 109 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle).

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2020

SIMULATION AU GRAND ORAL

Sujet n°3 – Argumentation : <u>Soutenez que les états d'urgence ne portent pas atteinte aux libertés fondamentales</u>

Soutenez que les états d'urgence ne portent pas atteinte aux libertés fondamentales

Deux types d'état d'urgence coexistent aujourd'hui en France ; l'état d'urgence mis en place de 2015 à 2017 pour répondre à la menace terroriste en France et basé sur la loi de 1955 ; et l'état d'urgence sanitaire créé en mars 2020. Il est nécessaire de les distinguer.

L'état d'urgence est un régime restrictif des libertés publiques créé par la loi n°55-385 du 3 avril, pouvant être appliqué sur tout ou partie du territoire national, se caractérisant surtout par l'extension des pouvoirs ordinaires de police des autorités civiles[1]. L'état d'urgence a été mis en place en France suite aux attentats du 13 novembre 2015 et fut prolongé sans cesse jusqu'au 1er novembre 2017, l'essentiel des dispositions qui le caractérisaient ayant été incorporé dans le droit commun par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

L'état d'urgence sanitaire est un nouveau régime juridique restrictif des libertés publiques mis en place pour répondre à la pandémie internationale de COVID-19. Suite à une étude d'impact demandée par le Sénat, il a été décidé de créer un nouveau régime d'exception plutôt que d'utiliser ceux existants (la théorie des circonstances exceptionnelles, l'article 16 ou 36 de la Constitution, l'état d'urgence de 1955). La loi d'urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 met donc en place un nouveau régime restrictif des libertés publiques : l'état d'urgence sanitaire. Il peut être déclaré en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. Il octroie de larges pouvoirs au premier ministre et aux préfets, notamment ceux de pouvoir confiner la population, contrôler les prix de certaines marchandises, fermes les lieux publics et de culte[2].

Parmi les droits et libertés fondamentaux, le droit à la vie tient une place toute particulière. Les mesures d'urgence, sécuritaire et sanitaire, n'ont-elles pas été mises en place afin notamment de protéger ce droit à la vie ?

Les libertés fondamentales ne pourraient plus se développer dans un état en situation de guerre, ni *a forciori* dans un État décimé par une pandémie internationale. La protection de l'individu doit être placée au centre des mesures étatiques car il est l'objet premier, le bénéficiaire principal, des libertés fondamentales.

I. Les états d'urgence protecteurs des libertés fondamentales

Les états d'urgence ont pour première fonction de doter l'administration de pouvoirs exceptionnels afin de répondre à une menace qu'elle ne peut gérer par le droit ordinaire. La mise en place de l'état d'urgence sécuritaire pour répondre à la menace terroriste a permis d'assurer la sécurité des citoyens dans l'État français, sécurité sans laquelle l'État ne pourrait garantir les droits et libertés fondamentaux (A). L'état d'urgence sanitaire fut quant à lui nécessaire pour protéger le droit à la vie (B).

[1] « État d'urgence » Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2020-2021
[2] « État d'urgence sanitaire » Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2020-2021

A. Pas de liberté sans sécurité

L'état d'urgence sécuritaire a permis de renforcer la sécurité au sein de l'État au pic de la menace terroriste en France. Assurer la sécurité au sein de l'État est une fonction primaire de l'État (Max Weber, le monopole de la violence légitime). Il doit assurer une vie en sécurité à ses citoyens pour pouvoir leur garantir les droits et libertés fondamentaux.

Machiavel déjà énonçait l'impérative nécessité « *pour maintenir l'État* » qu'avait le prince « *d'agir contre l'humanité, contre la charité, contre la religion même* »[3]. John Locke défend la théorie d'un souverain qui détient une habilitation *a priori* d'agir « *pour le bien public, en dehors des prescriptions de la loi, et parfois contre elle* ». Michel Foucault, considère que l'État, en charge d'un « pacte de sécurité » doit par moment s'écarter des prescriptions légales pour répondre à une situation exceptionnelle susceptible de mettre à mal l'assurance de la sécurité [4]

L'État, l'ordre mis en péril, est une condition à la mise en œuvre de la protection des droits fondamentaux. Pour assurer une protection pérenne et sereine des droits fondamentaux, il faut accepter, un temps, de s'en écarter.

L'état d'urgence sécuritaire a été mis en place sur la rhétorique que l'ordonnancement pénal de l'époque ne permettait pas de répondre de manière adéquate à l'amplitude de la menace terroriste qui pesait sur la France.

B. Le droit à la vie comme droit essentiel

L'état d'urgence sanitaire s'est basé sur l'idée que le Code de la Santé publique ne permettait pas de répondre de manière efficace à la pandémie. Sans ces mesures, préconisées par ailleurs par un Conseil scientifique et par l'Organisation Mondiale de la Santé, les hôpitaux n'auraient plus été en mesure de traiter les malades et le nombre de morts aurait pu exploser, comme nous l'ont enseigné les pandémies historiques. À l'heure de la grippe espagnole par exemple, l'État n'avait pas les mêmes fonctions ni mêmes obligations (positives) en matière de protection de la vie.

Le droit à la vie se trouve au sommet de l'échelle des droits fondamentaux. Pour la Cour Européenne des droits de l'homme le droit à la vie dispose d'une « *valeur suprême dans l'échelle des droits de l'homme au plan international* » (CEDH 22 mars 2001, Streletz, Kessler et Krenz c/ Allemagne, req. n° 34044/96)) et qu'il est un attribut inaliénable de la personne humaine qui jouit alors d'une « prééminence » parmi les stipulations de la Convention (CEDH 29 avril 2002 Pretty c/ Royuame-Uni). Pour le Comité des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies le droit à la vie est « *le droit suprême de l'être humain* » (Décis. CDH n° 146/1983, 4 avr. 1985, Baboeram c /Surinam, A/40/40, § 697).

En France, à la différence de la Loi Fondamentale allemande (Article 2, alinéa 2d : « *Chacun a droit à la vie et à l'intégrité physique* » ; Article 79 al. 3 : protège le droit à la vie en tant que droit indérogeable), ou de

[3] Machiavel, *Le Prince*, chapitre XVIII

[4] Ibidem - *« L'État qui garantit la sécurité est un État qui est obligé d'intervenir dans tous les cas où la trame de la vie quotidienne est trouée par un événement singulier, exceptionnel. Du coup, la loi n'est plus adaptée ; du coup, il faut bien ces espèces d'interventions, dont le caractère exceptionnel, extra-légal, ne devra pas apparaître du tout comme signe de l'arbitraire ni d'un excès de pouvoir, mais au contraire d'une sollicitude »*

la Constitution Portugaise du 2 avril 1976 (Article 24 : « *la vie humaine est inviolable* »), la Constitution française reste muette sur le droit à la vie. C'est le Conseil constitutionnel qui reconnaît ce droit comme faisant partie des corollaires du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine par sa décision *Bioéthique* de 1994 (Décision n°94-343/344 du 27 juillet 1994).

C'est pour protéger ce droit fondamental et essentiel que fut mis en place l'état d'urgence sanitaire.

II. Le juge comme garant du respect des libertés fondamentales dans le contrôle des mesures d'urgence

Toutes les mesures prises sous l'état d'urgence doivent répondre aux conditions de validité de toute restriction des libertés fondamentales : une finalité légitime, et le respect de la proportionnalité entre l'atteinte à la liberté fondamentale et la finalité poursuivie. Celle-ci sera vérifiée par l'application du triple test de proportionnalité qui doit normalement conduire le juge à vérifier que la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée (stricto sensu)[5].

Le juge est vu comme un garant des libertés fondamentales (« droit au juge » souvent considéré comme une garantie des libertés fondamentales ; Art. 66 Constitution ; le Conseil constitutionnel déduit de l'article 16 DHDHC le droit à un recours juridictionnel effectif (CC, DC 17 juin 2011 Recours des Associations)). Son contrôle des mesures d'urgence sécuritaires ou sanitaires, s'inscrit comme une garantie supplémentaire au fait que l'état d'urgence ne viole pas les libertés fondamentales.

A. Le juge protecteur des libertés fondamentales dans la mise en œuvre des mesures d'urgence sécuritaire

1. L'intervention du juge constitutionnel

En décembre 2015 pour la première fois le Conseil Constitutionnel a pu se prononcer sur la constitutionnalité des mesures prises au titre de l'état d'urgence par voie de la QPC (question prioritaire de constitutionnalité – art. 61-1 de la Constitution) - aucune des lois de prorogations ne lui avait été soumise au titre du contrôle de constitutionnalité a priori. L'apport du Conseil constitutionnel au régime de l'état d'urgence fut essentiel. Il a rappelé aux pouvoirs publics que si la Constitution n'interdit pas au législateur d'instituer une législation d'exception telle l'état d'urgence, c'est à la condition qu'il opère une conciliation entre la prévention des atteintes à l'ordre public et le respect des droits et libertés reconnus par la Constitution (**Cons. const. 1er déc. 2017, no 2017-677 QPC**).

2. Le juge administratif au cœur du contrôle des mesures de l'état d'urgence

- Référé-liberté

La loi du 20 novembre 2015 a inséré un **article 14-1** dans la loi du 3 avril 1955 faisant du juge administratif le juge de droit commun des mesures prises sur le fondement de l'état d'urgence – à l'exception notable des peines prévues à l'article 13. Le juge administratif peut contrôler ces mesures au titre du livre V du

[5] Voy.la thèse du Professeur X. Philippe sur le contrôle de proportionnalité : X. Philippe, Le contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences constitutionnelle et administrative françaises, 1989, Aix-Marseille 3. Pour une application voir. Conseil d'État, 26 octobre 2011, n°317827.

Code de justice administrative, prévoyant les référés. Aussi, très rapidement après l'instauration de l'état d'urgence en 2015, le juge administratif du référé-liberté fut très largement sollicité pour examiner si les premières assignations à résidence ordonnées par les autorités de police portaient une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier à la liberté d'aller et venir des assignés, et d'en prononcer la suspension (par ex., TA de Paris, 27 nov. 2015, M. A., req. N° 1519030).

Par la mesure du référé-liberté, il s'agit de s'assurer que l'autorité administrative opère une conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de la personne assignée à résidence compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence ou dans la détermination des modalités de l'assignation. Le juge des référés peut suspendre l'exécution de l'assignation à résidence lorsqu'il constate que les motifs pour lesquelles l'assignation a été ordonnée étaient infondés (CE 22 janv. 2016, M. B., req. no 396116) ou lorsque l'administration refuse de lui fournir « sans motif » une pièce dont elle se prévaut à l'audience et sur laquelle elle s'est fondée pour ordonner l'assignation (CE 9 févr. 2016, M. C., req. no 396570).

Par sept décisions de novembre 2015, le Conseil d'État a jugé que les décisions d'assignation à résidence portent en principe et par elle-même une atteinte grave et immédiate à la situation des assignés de nature à créer une situation d'urgence justifiant que des mesures provisoires et conservatoires de sauvegarde soient prises si les autres conditions posées par **l'article L. 521-2 du code de justice administrative** sont remplies (CE, sect., 11 déc. 2015, M. J. Domenjoud, req. no 394989). Il y a dès lors une « présomption » que la condition d'urgence, requise pour permettre l'application du référé-liberté, est remplie en matière d'assignations à résidence prises dans le cadre de l'état d'urgence.

- Référé-suspension

La procédure de référé suspension, prévue à l'article L 521-1 du Code de justice administrative a permis au juge d'ordonner la suspension d'une décision d'un proviseur de permettre aux élèves d'un lycée de fumer dans la cour de l'établissement qui invoquait la nécessité de renforcer la sécurité des élèves aux abords de l'établissement en limitant leurs regroupements extérieurs lors des récréations (TA Cergy-Pontoise, 21 avr. 2016, Assoc. Comité national contre le Tabagisme et autres).

- Recours pour excès de pouvoir

À la différence du déclenchement de l'article 16 de la constitution qui est un acte de gouvernement insusceptible de faire l'objet d'un recours juridictionnel (CE, ass., 2 mars 1962, Rubin de Servens), la Décision par laquelle est institué l'état d'urgence peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir sous réserve que le requérant réside habituellement à l'intérieur de la zone géographique d'application des mesures prises dans le cadre du décret déclarant l'état d'urgence (CE, ass., 24 mars 2006, req. nos 286834 et 287218, MM. Rolin et Boisvert). Néanmoins, si l'état d'urgence a déjà fait l'objet d'une prorogation au moment du dépôt du recours, le Conseil d'État estime que la légalité du décret n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse (CE 23 déc. 2016, Ligue des droits de l'homme, req. no 395091). De la même manière, les décisions ordonnant les perquisitions sont qualifiées de mesures de police administrative, elles sont donc susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (CE, avis, 6 juill. 2017, Napol et autres, req. no 398234,

3. La place du juge judiciaire

Le juge judiciaire est compétent lorsque les mesures prises dans le cadre l'état d'urgence conduisent à une **privation de liberté**. Or, le Conseil d'État a considéré que cela n'était le cas que pour les **assignations à résidence dépassant douze heures par jour** (**Cons. const. 22 déc. 2015, no 2015-527 QPC**).

La compétence du juge judiciaire s'étend également aux assignations à résidence lorsqu'il est constaté la violation de l'obligation de résidence (Crim. 3 mai 2017, no 16-86.155).

Sur le fondement de l'article 111-5 du code pénal qui prévoit que « les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès qui leur est soumis », le juge judiciaire, en l'occurrence le juge pénal, peut exercer un contrôle, par la voie de l'exception d'illégalité, **de l'ordre de perquisition**. Si ces dernières ne fondent pas les poursuites pénales elles déterminent néanmoins la régularité de la procédure (Crim. 13 déc. 2016, no 16-84.794). C'est ainsi le cas lorsque, à l'occasion d'une perquisition, sont découverts des armes de catégorie C non déclarées et plusieurs grammes de résine de cannabis (Crim. 28 mars 2017, no 16-85.073). S'il les estime insuffisamment motivées, plutôt que d'annuler les perquisitions, le juge pénal doit solliciter le ministère public afin qu'il obtienne de l'autorité de police les éléments factuels les justifiant (Crim. 28 mars 2017.).

B. Le juge protecteur des libertés fondamentales dans la mise en œuvre des mesures d'urgence sanitaires

[La loi prévoit 3 catégories de mesures relevant de trois autorités différentes. Malgré la nature sanitaire de ce régime d'exception, les pouvoirs prévus par celui-ci ne relèvent pas des organismes de référence en matière sanitaire. Au niveau national, les pouvoirs relèvent essentiellement du Premier

ministre[6] (et non du ministre de la Santé)[7], et au plan local, des préfets ou des maires[8] (et non de l'agence régionale de la santé, qui n'a qu'un rôle consultatif). Cela s'explique par le fait qu'il s'agit de pouvoirs de police et donc de restrictions des libertés au nom de la santé publique (un élément de l'ordre public général[9], dont le chef du gouvernement et le préfet ont, avec le maire, la charge). La police de l'urgence sanitaire est une police spéciale que les autorités cumulent avec leur pouvoir de police générale. Le maire peut aggraver les mesures nationales, de manière proportionnelle aux nécessités locales.]

Le Conseil Constitutionnel ne s'est pas prononcé sur l'état d'urgence sanitaire, mais a simplement validé la loi organique qui suspend les délais d'examen des questions prioritaires de constitutionnalité (Décision n° 2020-799 DC du 26 mars 2020 portant examen de la loi organique d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19)

a) Le juge administratif

Le contrôle de la mise en place de l'état d'urgence : En 2005 et en 2016, le Conseil d'État a admis la recevabilité des recours dirigés contre le décret déclarant l'état d'urgence, qu'il a donc écarté du champ des actes de gouvernement. Il y a tout lieu de croire que la même position serait prise pour la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. Cette recevabilité est toutefois limitée dans le temps, les recours ne pouvant plus prospérer dès lors que l'état d'urgence a été confirmé la loi (CE ord. réf. 14 novembre 2005, *Rolin* ; CE, ord., 27 janv. 2016, *Ligue des droits de l'homme*, n° 396220).

[6] L'article L. 3131-15 du Code de la Santé Publique prévoit que le premier ministre peut, sur rapport du ministre chargé de la santé et « *aux seules fins de garantir la santé publique* » :
« 1° restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;
2° interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
3° ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d'être affectées ;
4° ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ;
5° ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité
6° limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;
7° ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l'usage de ces biens […] ;
8° prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits […] ;
9° en tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ».
Le 21 mars, l'Assemblée nationale a voté un amendement créant un dixième point : le Premier ministre peut « en tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12 ». Il s'ensuit que, s'il l'estime nécessaire, le Gouvernement pourra interdire des « déplacements à des fins professionnelles, […] fermer tous les établissements recevant du public, […] interdire certaines importations ou exportations » (Amendement n°184 présenté à l'Assemblée nationale par le Gouvernement)

[7] Le ministre de la santé dispose du pouvoir de prescrire toute autre mesure réglementaire relative à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de santé ainsi que toute mesure individuelle nécessaire à l'application des règlements adoptés par le Premier ministre (CSP, art. L. 3131-16).

[8] Les autorités déconcentrées peuvent être habilitées, soit par le Premier ministre, soit par le ministre chargé de la Santé, à prendre toutes les mesures générales ou individuelles utiles à l'application des décisions nationales (CSP, art. L. 3131-17).

[9] S. Renard, *Ordre public sanitaire (Etude de droit public interne)*, Theses, Université de Rennes I, 2007, en ligne https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01525379 (consulté le 28 août 2020)

Le contrôle des mesures prises au titre de l'état d'urgence : La loi du 23 mars 2020, prenant exemple sur le régime de l'état d'urgence (art. 14-1 de la loi du 3 avr. 1955), a rappelé que les mesures prises au titre de l'état d'urgence sanitaire peuvent faire l'objet, devant le juge administratif, d'un référé-suspension et d'un référé-liberté.

Quelques exemples :

- Une quatorzaine stricte avait été mise en place à l'arrivée dans les territoires ultramarins – une mesure censurée par le Conseil constitutionnel le 11 mai comme privative de liberté ;
- Sans qu'un texte spécifique ait été publié, le service de l'asile a fermé par la force des choses ; cette situation a été critiquée par le Conseil d'État qui a demandé la réouverture du service (30 avril 2020)
- Le conseil d'État a toutefois rétabli le 13 juin 2020 la liberté de manifester, avec une déclaration préalable et en respectant les gestes barrières. (Conseil d'État, 13 juin 2020, Manifestations sur la voie publique)
- Liberté de culte : Le Conseil d'État a ordonné au gouvernement le 18 mai 2020 de revenir sur cette interdiction et d'édicter des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires (Conseil d'État, 18 mai 2020, Rassemblement dans les lieux de culte.)

b) Le juge judiciaire

Les mesures de quarantaine individuelle peuvent être contestées à tout moment devant le Juge des Libertés et de la Détention qui statue dans 72h. La mise en quarantaine dure 14 jours, et sa prolongation doit intervenir après saisie du juge des libertés et de la détention par le préfet, avec une limite totale d'un mois. (Art. 3131-17 du CSP, modifié suite à une décision n°2020-800 DC du Conseil Constitutionnel le 11 mai 2020).

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2020

SIMULATION AU GRAND ORAL

Sujet n°1 – Dissertation : L'influence du dialogue des juges sur la protection des droits fondamentaux

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2021

SIMULATION AU GRAND ORAL

LE DROIT AU PROCES EQUITABLE

Sujet 1 : Dissertation

La publicité des débats comme garantie du procès équitable

Sujet 2 : Argumentation

Soutenez que la prescription est un fondement nécessaire de l'Etat de droit.

Sujet 3 : Commentaire

Commentaire d'arrêt : CEDH, Affaire GOLDER c. ROYAUME-UNI, arrêt du 21 février 1975, req. n°4451/70

« 28. D'autre part, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne proclame pas en termes exprès un droit d'accès aux tribunaux. Il énonce des droits distincts mais dérivant de la même idée fondamentale et qui, réunis, constituent un droit unique dont il ne donne pas la définition précise, au sens étroit de ces mots. Il incombe à la Cour de rechercher, par voie d'interprétation, si l'accès aux tribunaux constitue un élément ou aspect de ce droit.

29. Les thèses présentées à la Cour ont porté d'abord sur la méthode à suivre pour l'interprétation de la Convention et en particulier de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). La Cour est disposée à considérer, avec le gouvernement et la Commission, qu'il y a lieu pour elle de s'inspirer des articles 31 à 33 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. Cette convention n'est pas encore en vigueur et elle précise, en son article 4, qu'elle ne rétroagira pas, mais ses articles 31 à 33 énoncent pour l'essentiel des règles de droit international communément admises et auxquelles la Cour a déjà recouru. A ce titre, ils entrent en ligne de compte pour l'interprétation de la Convention européenne sous réserve, le cas échéant, de "toute règle pertinente de l'organisation" au sein de laquelle elle a été adoptée, le Conseil de l'Europe (article 5 de la Convention de Vienne).

30. Tel que le prévoit la "règle générale" de l'article 31 de la Convention de Vienne, le processus d'interprétation d'un traité forme un tout, une seule opération complexe ; ladite règle, étroitement intégrée, place sur le même pied les divers éléments qu'énumèrent les quatre paragraphes de l'article.

31. Les termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention européenne, lus dans leur contexte, donnent à penser que ce droit figure parmi les garanties reconnues.

32. Les indications les plus nettes se dégagent du texte français de la première phrase. Dans le domaine des contestations civiles, chacun a droit à ce que l'instance entamée par ou contre lui se déroule d'une certaine manière - "équitablement", "publiquement", "dans un délai raisonnable", etc. -, mais aussi, et d'abord, "à ce que sa cause soit entendue" non par n'importe quelle autorité, mais "par un tribunal", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 39, par. 95). Le gouvernement a souligné avec raison que "cause" peut signifier "procès qui se plaide" (Littré, Dictionnaire de la langue française, tome I, p. 509, 5o). Telle n'est cependant pas l'unique acception ordinaire de ce vocable: il sert également à désigner, par extension, "l'ensemble des intérêts à soutenir, à faire prévaloir" (Paul Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, tome I, p. 666, II-2o). De même, la "contestation" préexiste en général au procès et se conçoit sans lui. Quant à l'expression "tribunal indépendant et impartial établi par la loi", elle évoque l'idée d'organisation plutôt que de fonctionnement, d'institution plutôt que de procédure.

De son côté, le texte anglais parle d'un "independent and impartial tribunal established by law". En outre, le membre de phrase "in the determination of his civil rights and obligations", que le gouvernement a cité à l'appui de sa thèse, ne vise pas nécessairement le seul cas d'une instance judiciaire déjà pendante: ainsi que

l'a noté la Commission, il peut passer pour synonyme de "wherever his civil rights and obligations are being determined" (paragraphe 52 du rapport). Il impliquerait alors, lui aussi, le droit à ce qu'une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil trouve sa solution (determination) devant un "tribunal".

Le gouvernement a soutenu que les adverbes "équitablement" et "publiquement", l'expression "dans un délai raisonnable", la seconde phrase du paragraphe 1 (art. 6-1) ("jugement", "procès") et le paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) présupposent à l'évidence une procédure en cours devant un tribunal.

Si le droit à l'équité, la publicité et la célérité de la procédure judiciaire ne peut, à coup sûr, s'appliquer qu'à une procédure engagée, il ne s'ensuit pourtant pas forcément qu'il exclue un droit à l'ouverture même de celle-ci; les délégués de la Commission ont eu raison de le souligner au paragraphe 21 de leur mémoire. En matière pénale, le "délai raisonnable" peut d'ailleurs avoir pour point de départ une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, du "tribunal" compétent pour décider "du bien-fondé de (l')accusation" (arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A no 7, pp. 26-27, par. 19; arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A no 8, p. 41, par. 18; arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 45, par. 110); on conçoit aussi qu'en matière civile il puisse commencer à courir, dans certaines hypothèses, avant même le dépôt de l'acte introduisant l'instance devant le "tribunal" que le demandeur invite à trancher la "contestation".

[…]

34. Ainsi que le précise l'article 31 par. 2 de la Convention de Vienne, le préambule d'un traité forme partie intégrante du contexte. En outre, il offre d'ordinaire une grande utilité pour la détermination de l'"objet" et du "but" de l'instrument à interpréter.

En l'espèce, le passage le plus significatif du préambule de la Convention européenne est celui où les gouvernements signataires s'affirment "résolus, en tant que gouvernements d'États européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration Universelle" du 10 décembre 1948.

Pour le gouvernement, cet alinéa illustre le "processus sélectif" suivi par les rédacteurs: la Convention ne chercherait pas à protéger les Droits de l'Homme en général, mais uniquement "certains des droits énoncés dans la Déclaration Universelle". Les articles 1 et 19 (art. 1, art. 19) iraient dans le même sens.

Quant à elle, la Commission attribue beaucoup d'importance aux mots "prééminence du droit"; d'après elle, ils éclairent l'article 6 par. 1 (art. 6-1).

Le caractère "sélectif" de la Convention ne saurait prêter à contestation. On peut aussi admettre, avec le gouvernement, que le préambule n'inclut par la prééminence du droit dans l'objet et le but de la Convention, mais la désigne comme l'un des éléments du patrimoine spirituel commun aux Etats membres du Conseil de l'Europe. La Cour estime pourtant, avec la Commission, que l'on aurait tort de voir dans cette mention un simple "rappel plus ou moins rhétorique", dépourvu d'intérêt pour l'interprète de la Convention. Si les gouvernements signataires ont décidé de "prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration Universelle", c'est en raison notamment de leur attachement sincère à la prééminence du droit. Il paraît à la fois naturel et conforme au principe de la bonne foi (article 31 par. 1 de la Convention de Vienne) d'avoir égard à ce motif, hautement proclamé, en interprétant les termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but de la Convention.

Il en est d'autant plus ainsi que le Statut du Conseil de l'Europe, organisation dont est membre chacun des États parties à la Convention (article 66 de celle-ci) (art. 66), se réfère à deux reprises à la prééminence du droit: une première fois dans le préambule, où les gouvernements signataires proclament leur

inébranlable attachement à ce principe, et une seconde fois dans l'article 3, aux termes duquel "tout Membre du Conseil (...) reconnaît le principe de la prééminence du droit (...)".

Or en matière civile la prééminence du droit ne se conçoit guère sans la possibilité d'accéder aux tribunaux.

35. En son paragraphe 3 c), l'article 31 de la Convention de Vienne invite à tenir compte, en même temps que du contexte, "de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties". Parmi ces règles figurent des principes généraux de droit, notamment des "principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées" (article 38 par. 1 c) du Statut de la Cour internationale de Justice); la Commission juridique de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe a d'ailleurs prévu, en août 1950, "que la Commission et la Cour (devraient) nécessairement appliquer de tels principes" dans l'accomplissement de leurs tâches; en conséquence, elle a "jugé inutile" de le spécifier par une clause de la Convention (Assemblée consultative, document de séance de la session de 1950, tome III, no 93, p. 982, par. 5).

Le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge compte au nombre des principes fondamentaux de droit universellement reconnus; il en va de même du principe de droit international qui prohibe le déni de justice. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) doit se lire à leur lumière.

Si ce texte passait pour concerner exclusivement le déroulement d'une instance déjà engagée devant un tribunal, un État contractant pourrait, sans l'enfreindre, supprimer ses juridictions ou soustraire à leur compétence le règlement de certaines catégories de différends de caractère civil pour le confier à des organes dépendant du gouvernement. Pareilles hypothèses, inséparables d'un risque d'arbitraire, conduiraient à de graves conséquences contraires auxdits principes et que la Cour ne saurait perdre de vue (arrêt Lawless du 1er juillet 1961, série A no 3, p. 52, et arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A no 11, p. 14, dernier alinéa).

Aux yeux de la Cour, on ne comprendrait pas que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) décrive en détail les garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours et qu'il ne protège pas d'abord ce qui seul permet d'en bénéficier en réalité: l'accès au juge. Équité, publicité et célérité du procès n'offrent point d'intérêt en l'absence de procès.

36. De l'ensemble des considérations qui précèdent, il ressort que le droit d'accès constitue un élément inhérent au droit qu'énonce l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Il ne s'agit pas là d'une interprétation extensive de nature à imposer aux États contractants de nouvelles obligations: elle se fonde sur les termes mêmes de la première phrase de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), lue dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de ce traité normatif qu'est la Convention (arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A no 7, p. 23, par. 8), ainsi que de principes généraux de droit.

La Cour arrive ainsi, sans devoir recourir à des "moyens complémentaires d'interprétation" au sens de l'article 32 de la Convention de Vienne, à la conclusion que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il consacre de la sorte le "droit à un tribunal", dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un aspect. A cela s'ajoutent les garanties prescrites par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) quant à l'organisation et à la composition du tribunal et quant au déroulement de l'instance. Le tout forme en bref le droit à un procès équitable; la Cour n'a pas à rechercher en l'espèce si et dans quelle mesure l'article 6 par. 1 (art. 6-1) exige en outre une décision sur le fond même de la contestation ("décidera", "determination").

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2021

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 1 : LE DROIT AU PROCES EQUITABLE

Corrigés

Sujet 1 : Dissertation

La publicité des débats comme garantie du procès équitable

Corrigé : Auditionné en juillet 2021 par la Commission des lois, Monsieur Eric DUPOND-MORETTI, Garde des Sceaux, défendait son projet de loi pour la confiance en l'institution judiciaire, et notamment l'une de ses mesures phare : l'enregistrement et la diffusion du procès. Il déclarait avoir « *souhaité ouvrir les prétoires aux caméras dans un double souci de transparence et de pédagogie* ».

Aux termes de l'article 6§1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la publicité des débats constitue en elle-même un droit substantiel, mais pas absolu :

> « ***Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement*** *et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.* ***Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public*** *pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent,* ***ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice****. »*

Il ressort de ces dispositions que le droit au procès équitable comprend à la fois la publicité des débats et la publicité du prononcé des jugements.

Il convient de rappeler que la publicité des débats judiciaires a de longue date été au centre de notre organisation judiciaire, le Conseil d'Etat ayant jugé, dans un arrêt en date du 4 octobre 1974, que :

> « *La publicité des débats judiciaires est un principe général du droit* ».

CE, Ass., 4 octobre 1974, n°88930 (*Dame David*)

Cette publicité, garantie de longue date et ramenée sur le devant de la scène par le Garde des sceaux, apparaît aujourd'hui susciter un intérêt particulier.

Concernant la publicité des jugements, on pense à la progression de l'open data, notamment à travers l'ouverture de la nouvelle base de données JUDILIBRE par la Cour de cassation, qui met à la disposition du public, gratuitement, toutes les décisions rendues publiquement par la plus haute juridiction judiciaire.

Concernant la publicité des débats, qui nous intéressera ici, on pense particulièrement au procès des attentats du 13 novembre, entièrement filmé à l'attention des archives audiovisuelles de la justice.

Dans ce contexte, il est **nécessaire de s'interroger sur les garanties qu'offre la publicité des débats pour le respect du droit au procès équitable (I.) mais aussi quant aux inévitables limites de cette publicité (II.).**

I. Les garanties offertes par la publicité pour le respect du droit au procès équitable

Dans l'arrêt phare *DELCOURT c. Belgique*, la Cour européenne a rappelé l'importance des apparences en matière de pratique judiciaire, citant expressément l'adage « *justice must not only be done, it must seem to be done* » (CEDH, Affaire DELCOURT c. BELGIQUE, arrêt du 17 janvier 1970, req. n°2689/65, §31). Dans des arrêts plus récents, la Cour a encore affirmé l'importance des apparences, notamment dans l'affaire KRESS c. FRANCE :

« Enfin, la théorie des apparences doit aussi entrer en jeu : en s'exprimant publiquement sur le rejet ou l'acceptation des moyens présentés par l'une des parties, le commissaire du gouvernement pourrait être légitimement considéré par les parties comme prenant fait et cause pour l'une d'entre elles.

Pour la Cour, un justiciable non rompu aux arcanes de la justice administrative peut assez naturellement avoir tendance à considérer comme un adversaire un commissaire du gouvernement qui se prononce pour le rejet de son pourvoi. A l'inverse, il est vrai, un justiciable qui verrait sa thèse appuyée par le commissaire le percevrait comme son allié. »

CEDH, Affaire KRESS c. FRANCE, arrêt du 7 juin 2001, req. n°39594/98, §81

La théorie des apparences est intimement connectée avec la publicité des débats judiciaires : offerte au regard du « *justiciable non rompu aux arcanes de la justice* », les tribunaux, sous le contrôle du public, doivent **visiblement et manifestement** offrir toutes les garanties du procès équitable.

La publicité des débats garantit effectivement le respect du droit au procès équitable à plusieurs niveaux :

- **Droits de la défense :** la publicité garantit que la défense des parties soit assurée sans influence extérieure, la justice étant rendue « *sous le contrôle de l'opinion* » (CORNU et FOYER, 1996, n°105 ; Dalloz Action, Droit et pratique de la procédure civile, n°332.71) ;

- **Impartialité des juges :** la publicité permet aux justiciables de constater par eux-mêmes l'impartialité des juges, qu'elle soit subjective (*propre au for intérieur du juge et donc à sa conduite personnelle*) ou objective (*relative aux fonctions exercées par le passé du juge – concerne notamment la question de savoir si le juge a déjà siégé dans la même affaire*). Cela implique que les justiciables connaissent l'identité des juges saisis de leur affaire : à défaut, il y aurait violation de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, Affaire VERNES c. FRANCE, arrêt du 20 janvier 2011, req. n°20/01/2011, §44).

II. Les limites de la publicité comme garantie du droit au procès équitable

On l'a vu, aux termes de l'article 6§1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la publicité des débats judiciaires n'est pas un droit absolu, c'est-à-dire qu'il connaît des limites. De même, selon l'article 306, alinéa 1er du code de procédure pénale :

*« Les débats sont publics, **à moins que** la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou pour les mœurs ».*

Il appartient aux juges répressifs d'évaluer les circonstances qui justifieraient ainsi le recours à une audience en huis clos, ainsi que l'étendue d'une telle mesure (Crim., 11 décembre 1968, n°69-92.858). Le huis clos peut être prononcé d'office par le juge répressif, sur les réquisitions du ministère public, à la demande de la victime constituée partie civile ou encore de l'accusé.

De manière plus générale, la publicité des débats doit être mise en balance avec la protection d'autres intérêts, et notamment la protection du droit au respect de la vie privée, garantie par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Ainsi, en matière de procédure civile, le respect de la vie privée pourra justifier que l'accès à la salle d'audience soit restreint dans différentes hypothèses (*cf.* article 435 code de procédure civile). Il est également intéressant de relever que les débats relatifs au divorce ne sont jamais publics (*cf.* article 248 code civil).

Sujet 2 : Argumentation

Soutenez que la prescription est un fondement nécessaire de l'Etat de droit

Corrigé : Avec la parution en janvier 2021 de *La Familia Grande*, ouvrage de Camille KOUCHNER, est revenue sur le devant de la scène la question de la prescription, notamment en matière de violences sexuelles sur mineurs, et des justifications de cette règle procédurale.

Aux termes de Gérard CORNU, la prescription se définit comme un « *mode d'acquisition ou d'extinction d'un droit, par l'écoulement d'un certain laps de temps (d'un délai) et sous les conditions déterminées par la loi* » (CORNU Gérard, *Vocabulaire juridique,* 10ème édition, p. 792).

Aux termes de Gérard CORNU encore, l'Etat de droit peut être défini comme l' « *ordre juridique dans lequel le respect du Droit est réellement garanti aux sujets de droit, notamment contre l'arbitraire* » (CORNU Gérard, *Vocabulaire juridique,* 10ème édition, p.419).

Dans le contexte de cet Etat de droit, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, dans le célèbre arrêt de principe AIREY c. IRLANDE que l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissait le droit d'accès à un tribunal (CEDH, Affaire AIREY c. IRLANDE, arrêt du 9 octobre 1979, req. n°6289/73).

Pour autant, ce droit peut connaître des restrictions, notamment à travers l'existence d'un délai de prescription au terme duquel l'action judiciaire sera éteinte. Ces restrictions procédurales sont admises par la Cour européenne des droits de l'homme lorsque leur objectif est de préserver la sécurité juridique et qu'elles sont proportionnées à cet objectif (CEDH, Affaire HOWALD MOORE et autres c. SUISSE, arrêt du 11 mars 2014, req. n°°52067 et 41072/11).

Il sera soutenu ici que, en droit français, la prescription extinctive est un fondement nécessaire de l'Etat de droit, en ce qu'elle **constitue un instrument de sauvegarde de la sécurité juridique (I.) et en ce qu'elle est intimement liée à la présomption d'innocence et offre par là-même un rempart contre l'arbitraire (II.)**.

I. Un instrument de sauvegarde de la sécurité juridique

En matière civile comme en matière pénale, la prescription extinctive est intimement liée à la sauvegarde de la sécurité juridique.

- **En matière civile** : aux termes de l'article 2219 du code civil, « *la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de* ***l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps*** ». Ainsi, le mécanisme de prescription extinctive a pour visée de pérenniser des situations de fait déjà établies de longue date.

- **En matière pénale** : la prescription extinctive en procédure pénale répond du même esprit. Les articles 7 à 9 du code de procédure pénale prévoient les délais de prescription extinctive respectivement applicables aux crimes, aux délits et aux contraventions. L'article 9-1 du code de procédure pénale prévoit **des régimes dérogatoires pour les cas où l'infraction aurait été soit occulte, soit dissimulée**, la situation de fait n'étant donc pas établie. Il convient toutefois de souligner que la loi instaure alors **des délais butoirs** au terme desquels l'action publique peut être mise en œuvre.

Dans son traité de procédure pénale, la Professeure Michèle-Laure RASSAT allègue de différents arguments en faveur de cette sanction de l'écoulement du temps, dont on relève qu'ils sont très liés à la sauvegarde de la sécurité juridique (RASSAT Michèle-Laure, *Traité de procédure pénale*, 3ème édition, 2001, n°297).

Ainsi, selon la Professeure Michèle-Laure RASSAT, il est :

- **Inutile** « *d'agiter l'opinion publique en lui rappelant des infractions anciennes et qu'elle a oubliées* » ;
- **Inopportun** de « *manifester aussi spectaculairement l'inefficacité d'un système pénal qui met des années avant de se saisir des délinquants* » ;
- **Légitime** « *que la négligence des autorités publiques chargées de la lutte contre la délinquance soit sanctionnée* ».

II. Un rempart contre l'arbitraire

Dans le fameux ouvrage « *Des délits et des peines* », Cesare BECCARIA adoptait déjà une approche très pragmatique de la question. Il soulignait qu'il fallait éviter de tomber dans l'écueil qui consisterait à « *prétendre établir une proportion exacte entre l'atrocité des délits* » et le délai de la prescription.

Dans une décision très récente, le Conseil constitutionnel a jugé :

> *« Il résulte du principe de nécessité des peines, protégé par l'article 8 de la Déclaration de 1789, et de la garantie des droits, proclamée par l'article 16 de la même déclaration, un principe selon lequel, en matière pénale, il appartient au législateur,* ***afin de tenir compte des conséquences attachées à l'écoulement du temps****, de fixer des règles relatives à la prescription de l'action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions. »*
>
> **DC n°2019-785 QPC du 24 mai 2019**

Au terme d'un délai important, il devient matériellement difficile d'apporter les preuves des faits poursuivis. Ce dépérissement des preuves est une importante justification de la prescription extinctive.

L'exercice de nouvelles poursuites en dépit de cette situation de fait risquerait d'aboutir à une décision arbitraire, c'est-à-dire injuste.

Sujet 3 : Commentaire

Commentaire d'arrêt : CEDH, Affaire GOLDER c. ROYAUME-UNI, arrêt du 21 février 1975, req. n°4451/70

« 28. D'autre part, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne proclame pas en termes exprès un droit d'accès aux tribunaux. Il énonce des droits distincts mais dérivant de la même idée fondamentale et qui, réunis, constituent un droit unique dont il ne donne pas la définition précise, au sens étroit de ces mots. Il incombe à la Cour de rechercher, par voie d'interprétation, si l'accès aux tribunaux constitue un élément ou aspect de ce droit.

29. Les thèses présentées à la Cour ont porté d'abord sur la méthode à suivre pour l'interprétation de la Convention et en particulier de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). La Cour est disposée à considérer, avec le gouvernement et la Commission, qu'il y a lieu pour elle de s'inspirer des articles 31 à 33 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. Cette convention n'est pas encore en vigueur et elle précise, en son article 4, qu'elle ne rétroagira pas, mais ses articles 31 à 33 énoncent pour l'essentiel des règles de droit international communément admises et auxquelles la Cour a déjà recouru. A ce titre, ils entrent en ligne de compte pour l'interprétation de la Convention européenne sous réserve, le cas échéant, de "toute règle pertinente de l'organisation" au sein de laquelle elle a été adoptée, le Conseil de l'Europe (article 5 de la Convention de Vienne).

30. Tel que le prévoit la "règle générale" de l'article 31 de la Convention de Vienne, le processus d'interprétation d'un traité forme un tout, une seule opération complexe; ladite règle, étroitement intégrée, place sur le même pied les divers éléments qu'énumèrent les quatre paragraphes de l'article.

31. Les termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention européenne, lus dans leur contexte, donnent à penser que ce droit figure parmi les garanties reconnues.

32. Les indications les plus nettes se dégagent du texte français de la première phrase. Dans le domaine des contestations civiles, chacun a droit à ce que l'instance entamée par ou contre lui se déroule d'une certaine manière - "équitablement", "publiquement", "dans un délai raisonnable", etc. -, mais aussi, et d'abord, "à ce que sa cause soit entendue" non par n'importe quelle autorité, mais "par un tribunal", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 39, par. 95). Le gouvernement a souligné avec raison que "cause" peut signifier "procès qui se plaide" (Littré, Dictionnaire de la langue française, tome I, p. 509, 5o). Telle n'est cependant pas l'unique acception ordinaire de ce vocable: il sert également à désigner, par extension, "l'ensemble des intérêts à soutenir, à faire prévaloir" (Paul Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, tome I, p. 666, II-2o). De même, la "contestation" préexiste en général au procès et se conçoit sans lui. Quant à l'expression "tribunal indépendant et impartial établi par la loi", elle évoque l'idée d'organisation plutôt que de fonctionnement, d'institution plutôt que de procédure.

De son côté, le texte anglais parle d'un "independent and impartial tribunal established by law". En outre, le membre de phrase "in the determination of his civil rights and obligations", que le gouvernement a cité à l'appui de sa thèse, ne vise pas nécessairement le seul cas d'une instance judiciaire déjà pendante: ainsi que l'a noté la Commission, il peut passer pour synonyme de "wherever his civil rights and obligations are being determined" (paragraphe 52 du rapport). Il impliquerait alors, lui aussi, le droit à ce qu'une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil trouve sa solution (determination) devant un "tribunal".

Le gouvernement a soutenu que les adverbes "équitablement" et "publiquement", l'expression "dans un délai raisonnable", la seconde phrase du paragraphe 1 (art. 6-1) ("jugement", "procès")

et le paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) présupposent à l'évidence une procédure en cours devant un tribunal.

Si le droit à l'équité, la publicité et la célérité de la procédure judiciaire ne peut, à coup sûr, s'appliquer qu'à une procédure engagée, il ne s'ensuit pourtant pas forcément qu'il exclue un droit à l'ouverture même de celle-ci; les délégués de la Commission ont eu raison de le souligner au paragraphe 21 de leur mémoire. En matière pénale, le "délai raisonnable" peut d'ailleurs avoir pour point de départ une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, du "tribunal" compétent pour décider "du bien-fondé de (l')accusation" (arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A no 7, pp. 26-27, par. 19; arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A no 8, p. 41, par. 18; arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 45, par. 110); on conçoit aussi qu'en matière civile il puisse commencer à courir, dans certaines hypothèses, avant même le dépôt de l'acte introduisant l'instance devant le "tribunal" que le demandeur invite à trancher la "contestation".

[…]

34. Ainsi que le précise l'article 31 par. 2 de la Convention de Vienne, le préambule d'un traité forme partie intégrante du contexte. En outre, il offre d'ordinaire une grande utilité pour la détermination de l'"objet" et du "but" de l'instrument à interpréter.

En l'espèce, le passage le plus significatif du préambule de la Convention européenne est celui où les gouvernements signataires s'affirment "résolus, en tant que gouvernements d'États européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration Universelle" du 10 décembre 1948.

Pour le gouvernement, cet alinéa illustre le "processus sélectif" suivi par les rédacteurs: la Convention ne chercherait pas à protéger les Droits de l'Homme en général, mais uniquement "certains des droits énoncés dans la Déclaration Universelle". Les articles 1 et 19 (art. 1, art. 19) iraient dans le même sens.

Quant à elle, la Commission attribue beaucoup d'importance aux mots "prééminence du droit"; d'après elle, ils éclairent l'article 6 par. 1 (art. 6-1).

Le caractère "sélectif" de la Convention ne saurait prêter à contestation. On peut aussi admettre, avec le gouvernement, que le préambule n'inclut par la prééminence du droit dans l'objet et le but de la Convention, mais la désigne comme l'un des éléments du patrimoine spirituel commun aux Etats membres du Conseil de l'Europe. La Cour estime pourtant, avec la Commission, que l'on aurait tort de voir dans cette mention un simple "rappel plus ou moins rhétorique", dépourvu d'intérêt pour l'interprète de la Convention. Si les gouvernements signataires ont décidé de "prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration Universelle", c'est en raison notamment de leur attachement sincère à la prééminence du droit. Il paraît à la fois naturel et conforme au principe de la bonne foi (article 31 par. 1 de la Convention de Vienne) d'avoir égard à ce motif, hautement proclamé, en interprétant les termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but de la Convention.

Il en est d'autant plus ainsi que le Statut du Conseil de l'Europe, organisation dont est membre chacun des États parties à la Convention (article 66 de celle-ci) (art. 66), se réfère à deux reprises à la prééminence du droit: une première fois dans le préambule, où les gouvernements signataires proclament leur inébranlable attachement à ce principe, et une seconde fois dans l'article 3, aux termes duquel "tout Membre du Conseil (...) reconnaît le principe de la prééminence du droit (...)".

Or en matière civile la prééminence du droit ne se conçoit guère sans la possibilité d'accéder aux tribunaux.

35. En son paragraphe 3 c), l'article 31 de la Convention de Vienne invite à tenir compte, en même temps que du contexte, "de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties". Parmi ces règles figurent des principes généraux de droit, notamment des "principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées" (article 38 par. 1 c) du Statut de la Cour internationale de Justice); la Commission juridique de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe a d'ailleurs prévu, en août 1950, "que la Commission et la Cour (devraient) nécessairement appliquer de tels principes" dans l'accomplissement de leurs tâches; en conséquence, elle a "jugé inutile" de le spécifier par une clause de la Convention (Assemblée consultative, document de séance de la session de 1950, tome III, no 93, p. 982, par. 5).

Le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge compte au nombre des principes fondamentaux de droit universellement reconnus; il en va de même du principe de droit international qui prohibe le déni de justice. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) doit se lire à leur lumière.

Si ce texte passait pour concerner exclusivement le déroulement d'une instance déjà engagée devant un tribunal, un État contractant pourrait, sans l'enfreindre, supprimer ses juridictions ou soustraire à leur compétence le règlement de certaines catégories de différends de caractère civil pour le confier à des organes dépendant du gouvernement. Pareilles hypothèses, inséparables d'un risque d'arbitraire, conduiraient à de graves conséquences contraires auxdits principes et que la Cour ne saurait perdre de vue (arrêt Lawless du 1er juillet 1961, série A no 3, p. 52, et arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A no 11, p. 14, dernier alinéa).

Aux yeux de la Cour, on ne comprendrait pas que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) décrive en détail les garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours et qu'il ne protège pas d'abord ce qui seul permet d'en bénéficier en réalité: l'accès au juge. Équité, publicité et célérité du procès n'offrent point d'intérêt en l'absence de procès.

36. De l'ensemble des considérations qui précèdent, il ressort que le droit d'accès constitue un élément inhérent au droit qu'énonce l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Il ne s'agit pas là d'une interprétation extensive de nature à imposer aux États contractants de nouvelles obligations: elle se fonde sur les termes mêmes de la première phrase de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), lue dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de ce traité normatif qu'est la Convention (arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A no 7, p. 23, par. 8), ainsi que de principes généraux de droit.

La Cour arrive ainsi, sans devoir recourir à des "moyens complémentaires d'interprétation" au sens de l'article 32 de la Convention de Vienne, à la conclusion que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il consacre de la sorte le "droit à un tribunal", dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un aspect. A cela s'ajoutent les garanties prescrites par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) quant à l'organisation et à la composition du tribunal et quant au déroulement de l'instance. Le tout forme en bref le droit à un procès équitable; la Cour n'a pas à rechercher en l'espèce si et dans quelle mesure l'article 6 par. 1 (art. 6-1) exige en outre une décision sur le fond même de la contestation ("décidera", "determination").

Corrigé : Ainsi que le souligne la Cour européenne par une formule sibylline issue de l'arrêt GOLDER c. ROYAUME-UNI, « *équité, publicité et célérité des parties n'offrent point d'intérêt en l'absence de procès* ».

La question du droit à un tribunal, et par là-même du droit **d'accès** à un tribunal, se trouve au cœur de l'arrêt GOLDER c. ROYAUME-UNI, rendu le 21 février 1975.

A l'origine de cette affaire, un détenu britannique avait été empêché de prendre contact avec son avocat. Cet empêchement avait causé pour le détenu un obstacle de fait à l'exercice d'un quelconque recours.

C'est dans ce contexte que les juges de STRASBOURG ont eu à déterminer si l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissait ou non le droit d'accès à un tribunal.

Au terme de l'arrêt GOLDER c. ROYAUME-UNI, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les droits garantis par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme impliquent qu'il existe en amont un droit d'accès au juge, bien que celui-ci ne soit pas explicitement reconnu par la Convention.

Cette interprétation pourrait sembler enrichir la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et donc alourdir indûment les engagements des Etats parties. Rappelons que les Etats ne devraient en effet être redevables que des obligations auxquelles ils ont consenti, conformément à une approche très contractualiste des conventions internationales.

Au terme d'une analyse méthodique, la Cour européenne des droits de l'homme, qui met en œuvre plusieurs instruments d'interprétation, démontre toutefois que le droit d'accès à un tribunal **est compris dans les termes mêmes de la Convention**.

Les instruments d'interprétation mis en œuvre par la Cour européenne des droits de l'homme, pour lesquels elle s'inspire de la Convention de VIENNE sur le droit des traités du 23 mai 1969, sont les suivants :

- Interprétation littérale de la Convention (*i.e.* interprétation du sens littéral des termes de la Convention) ;
- Interprétation du contexte interne de la Convention (*i.e.* interprétation de la Convention à la lumière de son propre préambule) ;
- Interprétation téléologique de la Convention (*i.e.* à la lumière de la visée et des objectifs de la Convention).

Afin d'éclairer cette consécration prétorienne du droit d'accès à un tribunal, **il sera fait état de la nature du droit d'accès au tribunal (I.) et des incidences durables de cette décision (II.)**.

I. La nature du droit d'accès au tribunal garanti par la Cour européenne des droits de l'homme

A. Un droit inhérent aux garanties de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- La **théorie de l'inhérence** : le droit d'accès à un tribunal ne résulte pas d'une extension des termes de la Convention. Au contraire, il est **compris dans les termes de l'article 6§1 de la Convention**.
- Le raisonnement par l'absurde utilisé pour arriver à ce constat : sans droit d'accès à un tribunal, les garanties offertes par l'article 6§1 de la Convention pour le déroulement de la procédure devant un tribunal se trouvent totalement vidées de leur substance.

B. Un droit intimement lié à la prééminence du droit, principe clé du système de la Convention

- La **prééminence du droit est visée par le préambule de la Convention** parmi les idéaux animant les Etats parties.
- La prééminence du droit ne se conçoit pas sans droit d'accès aux tribunaux, puisque celui-ci permet aux citoyens des Etats parties **d'actionner les droits** qui leur sont garantis par la Convention (c'est-à-dire d'intenter les recours nécessaires à ce que leur violation soit condamnée).

II. Les incidences durables de l'arrêt GOLDER c. Royaume-Uni

A. Obligations positives des Etats parties en matière de droit au procès équitable

- CEDH, arrêt du 6 février 1981, Affaire AIREY c. IRLANDE, req. n°6289/73 : il ne suffit pas que l'accès à un tribunal soit ouvert, il faut également que les justiciables bénéficient des ressources pour y accéder.
    - Célèbre maxime : « *La Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs* ».
    - Consécration de **l'obligation positive** des Etats parties de garantir **un droit d'accès effectif au tribunal, ici au travers de l'octroi de l'aide juridictionnelle** (*faire un lien avec la notion de droits économiques, sociaux et culturels*).

B. Procéduralisation des droits substantiels garantis par la Convention

- La Cour européenne des droits de l'homme tend désormais à dégager de tous les droits substantiels énoncés par la Convention **une obligation positive procédurale implicite** de « *mettre en place et de rendre effective des procédures permettant de revendiquer au niveau national le droit en cause* » (SUDRE François et SURREL Hélène, *Répertoire de droit international*, DALLOZ, n°82).
- Cela signifie que la Cour ne déduit plus l'obligation positive de mettre en place des procédures effectives de l'article 6§1 de la Convention, mais directement des dispositions garantissant des droits substantielles.
- Voir notamment les arrêts :
    - CEDH, arrêt du 16 mars 2000, Affaire OZGÜR GUNDEM c. TURQUIE, req. n° 23144/93 : procéduralisation du droit à la liberté d'expression ;
    - CEDH, arrêt du 26 juillet 2005, Affaire SILIADIN c. France, req. n°73316/01 : obligation pour les Etats parties d'adopter une législation pénale permettant de sanctionner effectivement des pratiques contraires à l'article 4 de la Convention.

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2021

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 2 : LA LIBERTE RELATIONNELLE

Sujets

Sujet 1 : Dissertation

Le droit reconnu aux enfants de développer des relations avec leurs parents

Sujet 2 : Argumentation

Soutenez que l'intervention de l'Etat en matière de relations sexuelles peut être légitime

Sujet 3 : Commentaire

Commentaire d'arrêt : CEDH, Affaire MENNESSON c. FRANCE, avis consultatif du 10 avril 2019, Demande n°P16-2018-001

« II.SUR LE PREMIER POINT

35. Il résulte de la jurisprudence de la Cour que l'article 8 de la Convention demande que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et le père d'intention lorsqu'il est le père biologique. Comme indiqué précédemment, la Cour a en effet expressément conclu dans l'arrêt Mennesson précité que l'absence d'une telle possibilité emportait violation du droit de l'enfant au respect de sa vie privée, tel qu'il se trouve garanti par cette disposition (Mennesson, précité, §§ 100-101; voir aussi Labassee c. France, no 65941/11, 26 juin 2014, ainsi que Foulon et Bouvet c. France, nos 9063/14 et 10410/14, 21 juillet 2016, et Laborie c. France, no 44024/13, 19 janvier 2017).

36. En rapport avec ce qui précède, la Cour relève qu'à ce jour, sa jurisprudence met un certain accent sur l'existence d'un lien biologique entre l'enfant et au moins l'un des parents d'intention (voir les arrêts cités ci-dessus, ainsi que l'arrêt Paradiso et Campanelli c. Italie [GC] (no 25358/12, § 195, 24 janvier 2017). Elle rappelle à cet égard que la question à examiner en l'espèce inclut explicitement un élément factuel selon lequel le père d'intention a un lien biologique avec l'enfant concerné. La Cour va circonscrire sa réponse en conséquence. Elle précise toutefois qu'elle pourrait être appelée à l'avenir à développer sa jurisprudence dans ce domaine, étant donné en particulier l'évolution de la question de la gestation pour autrui.

37. Pour se prononcer dans le cadre de la présente demande d'avis consultatif (paragraphes 32, 34 et 36 ci-dessus) sur la ***question de savoir si l'article 8 de la Convention requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention*** *deux facteurs ont un poids particulier : l'intérêt supérieur de l'enfant et l'étendue de la marge d'appréciation dont disposent les États parties.*

38. S'agissant du premier facteur, la Cour se réfère au principe essentiel selon lequel, chaque fois que la situation d'un enfant est en cause, l'intérêt supérieur de celui-ci doit primer (voir, en particulier, Paradiso et Campanelli, précité, § 208, X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 95, CEDH 2013, Mennesson, précité, §§ 81 et 99, Labassee, précité, §§ 60 et 78, et Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 133, 28 juin 2007).

39. La Cour a admis dans les arrêts Mennesson (précité, § 99) et Labassee (précité, § 78) qu'il était « concevable que la France puisse souhaiter décourager ses ressortissants de recourir à l'étranger à une méthode de procréation qu'elle prohibe sur son territoire ». Elle a toutefois relevé que les effets de la non-reconnaissance en droit français du lien de filiation entre les enfants ainsi conçus et les parents d'intention ne se limitaient pas à la situation de ces derniers, qui seuls ont fait le choix des modalités de procréation que leur reprochent les autorités françaises : ils portent aussi sur celle des enfants eux-mêmes, dont le droit au respect de la vie privée se trouve significativement affecté.

40. L'absence de reconnaissance d'un lien de filiation entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention a ainsi des conséquences négatives sur plusieurs aspects du droit de l'enfant au respect de la vie privée. D'un point de vue général, comme la Cour l'a relevé dans les arrêts Mennesson et Labassee précités, l'absence de reconnaissance en droit interne du lien entre l'enfant et la mère d'intention défavorise l'enfant dès lors qu'il le place dans une forme d'incertitude juridique quant à son identité dans la société (§§ 96 et 75 respectivement). Il y a notamment un risque qu'il n'ait pas l'accès à la nationalité de la mère d'intention dans les conditions que garantit la filiation, cela peut compliquer son maintien sur le territoire du pays de résidence de la mère d'intention (même si ce risque n'existe pas dans le cas soumis à l'examen de la Cour de cassation, le père d'intention, qui est aussi le père biologique, ayant la nationalité française), ses droits successoraux à l'égard de celle-ci peuvent être amoindris, il se trouve fragilisé dans le maintien de sa relation avec la mère d'intention en cas de séparation des parents d'intention ou de décès du père d'intention, et il n'est pas protégé contre un refus ou une renonciation de la mère d'intention de le prendre en charge.

41. La Cour est consciente de ce que, dans le contexte de la gestation pour autrui, l'intérêt supérieur de l'enfant ne se résume pas au respect de ces aspects de son droit à la vie privée. Il inclut d'autres éléments fondamentaux, qui ne plaident pas nécessairement en faveur de la reconnaissance d'un lien de filiation avec la mère d'intention, tels que la protection contre les risques d'abus que comporte la gestation pour autrui (voir Paradiso et Campanelli, précité, § 202) et la possibilité de connaitre ses origines (voir, par exemple, Mikulić c. Croatie, no 53176/99, §§ 54-55, CEDH 2002-I).

42. Au vu des éléments indiqués au paragraphe 40 ci-dessus et du fait que l'intérêt supérieur de l'enfant comprend aussi l'identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l'élever, de satisfaire à ses besoins et d'assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d'évoluer dans un milieu stable, la Cour considère toutefois que l'impossibilité générale et absolue d'obtenir la reconnaissance du lien entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention n'est pas conciliable avec l'intérêt supérieur de l'enfant, qui exige pour le moins un examen de chaque situation au regard des circonstances particulières qui la caractérise.

43. S'agissant du second facteur, comme la Cour l'a rappelé dans les arrêts Mennesson (précité, § 77) et Labassee (précité, § 57), l'étendue de la marge d'appréciation dont disposent les États varie selon les circonstances, les domaines et le contexte ; la présence ou l'absence d'un dénominateur commun aux systèmes juridiques des États contractants peut constituer un élément pertinent à cet égard. Ainsi, lorsqu'il n'y a pas de consensus au sein des États membres du Conseil de l'Europe, que ce soit sur l'importance relative de l'intérêt en jeu ou sur les meilleurs moyens de le protéger, en particulier lorsque l'affaire soulève des questions morales ou éthiques délicates, la marge d'appréciation est large. Or il ressort de l'étude de droit comparé susmentionnée que, malgré une certaine évolution vers la possibilité d'une reconnaissance juridique du lien de filiation entre les enfants nés d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et les parents d'intention, il n'y a pas consensus en Europe sur cette question (paragraphe 23 ci-dessus).

44. La Cour a toutefois également rappelé dans ces mêmes arrêts (§§ 77 et 80, et §§ 56 et 59 respectivement) que, lorsqu'un aspect particulièrement important de l'identité d'un individu se trouve en jeu, comme lorsque l'on touche à la filiation, la marge laissée à l'État est d'ordinaire restreinte. Elle en a déduit qu'il convenait d'atténuer la marge d'appréciation dont disposait l'État défendeur (ibidem).

45. Ce qui est en jeu dans le contexte de la reconnaissance d'un lien de filiation entre des enfants nés à l'issue d'une gestation pour autrui et les parents d'intention dépasse en réalité la question de l'identité de ces enfants. D'autres aspects essentiels de leur vie privée sont concernés dès lors que sont en question l'environnement dans lequel ils vivent et se développent et les personnes qui ont la responsabilité de satisfaire à leurs besoins et d'assurer leur bien-être (voir aussi les paragraphes 40-42 ci-dessus). Ceci conforte le constat de la Cour quant à la réduction de la marge d'appréciation.

46. En somme, vu les exigences de l'intérêt supérieur de l'enfant et la réduction de la marge d'appréciation, la Cour est d'avis que, dans une situation telle que celle visée par la Cour de cassation

dans ses questions (paragraphes 9 et 32 ci-dessus) et délimitée par la Cour au paragraphe 36 ci-dessus, le droit au respect de la vie privée, au sens de l'article 8 de la Convention, d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une gestation pour autrui, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation entre cet enfant et la mère d'intention, désignée dans l'acte de naissance légalement établi à l'étranger comme étant la « mère légale ».

47. Bien que le litige interne ne concerne pas le cas d'un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et conçu avec les gamètes de la mère d'intention, la Cour juge important de préciser que, lorsque la situation est par ailleurs similaire à celle dont il est question dans ce litige, la nécessité d'offrir une possibilité de reconnaissance du lien entre l'enfant et la mère d'intention vaut a fortiori dans un tel cas.

III.SUR LE SECOND POINT

48. Le second point concerne la question de savoir si le droit au respect de la vie privée de l'enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger, dans la situation où l'enfant a été conçu avec les gamètes d'une tierce donneuse, requiert que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de naissance légalement établi à l'étranger, ou s'il admet qu'elle puisse se faire par d'autres moyens, tels que l'adoption de l'enfant par la mère d'intention.

49. Il est dans l'intérêt de l'enfant qui est dans cette situation que la durée de l'incertitude dans laquelle il se trouve quant à sa filiation à l'égard de la mère d'intention soit aussi brève que possible. Comme indiqué précédemment, tant que le lien entre lui et celle-ci n'est pas reconnu en droit interne sa situation se trouve fragilisée s'agissant de plusieurs aspects de son droit au respect de la vie privée (paragraphe 40 ci-dessus).

50. On ne saurait toutefois en déduire que les États parties soient tenus d'opter pour la transcription des actes de naissance légalement établis à l'étranger.

51. La Cour constate en effet qu'il n'y a pas de consensus européen sur cette question : lorsque l'établissement ou la reconnaissance du lien entre l'enfant et le parent d'intention est possible, leurs modalités varient d'un État à l'autre (paragraphe 24 ci-dessus). Elle observe ensuite que l'identité de l'individu est moins directement en jeu lorsqu'il s'agit non du principe même de l'établissement ou de la reconnaissance de sa filiation mais des moyens à mettre en œuvre à cette fin. La Cour estime en conséquence que le choix des moyens à mettre en œuvre pour permettre la reconnaissance du lien enfant-parents d'intention tombe dans la marge d'appréciation des États.

52. Outre ce constat relatif à la marge d'appréciation, la Cour considère que l'article 8 de la Convention n'impose pas une obligation générale pour les États de reconnaître ab initio un lien de filiation entre l'enfant et la mère d'intention. Ce que requiert l'intérêt supérieur de l'enfant – qui s'apprécie avant tout in concreto plutôt qu'in abstracto – c'est que ce lien, légalement établi à l'étranger, puisse être reconnu au plus tard lorsqu'il s'est concrétisé. Il appartient en principe non pas à la Cour mais en premier lieu aux autorités nationales d'évaluer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, si et quand ce lien s'est concrétisé.

53. On ne saurait déduire de l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi compris que la reconnaissance du lien de filiation entre l'enfant et la mère d'intention que requiert le droit de l'enfant au respect de la vie privée, au sens l'article 8 de la Convention, impose aux États de procéder à la transcription de l'acte de naissance étranger en ce qu'il désigne la mère d'intention comme étant la mère légale. Selon les circonstances de chaque cause, d'autres modalités peuvent également servir convenablement cet intérêt supérieur, dont l'adoption, qui, s'agissant de la reconnaissance de ce lien, produit des effets de même nature que la transcription de l'acte de naissance étranger.

54. Ce qui compte c'est qu'au plus tard lorsque, selon l'appréciation des circonstances de chaque cas, le lien entre l'enfant et la mère d'intention s'est concrétisé (paragraphe 52 ci-dessus), il y ait un mécanisme effectif permettant la reconnaissance de ce lien. Une procédure d'adoption peut répondre à cette

nécessité dès lors que ses conditions sont adaptées et que ses modalités permettent une décision rapide, de manière à éviter que l'enfant soit maintenu longtemps dans l'incertitude juridique quant à ce lien. Il va de soi que ces conditions doivent inclure une appréciation par le juge de l'intérêt supérieur de l'enfant à la lumière des circonstances de la cause.

55. En somme, vu la marge d'appréciation dont disposent les États s'agissant du choix des moyens, d'autres voies que la transcription, notamment l'adoption par la mère d'intention, peuvent être acceptables dans la mesure où les modalités prévues par le droit interne garantissent l'effectivité et la célérité de leur mise en œuvre, conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant.

56. La Cour de cassation indique dans sa demande d'avis que la loi française facilite l'adoption de l'enfant du conjoint (paragraphe 14 ci-dessus). Il peut s'agir d'une adoption plénière ou d'une adoption simple.

57. Le gouvernement français fait ainsi valoir qu'entre le 5 juillet 2017 et le 2 mai 2018 la quasi-totalité des demandes d'adoption entre conjoints concernant des enfants nés à l'étranger d'une gestation pour autrui ont été satisfaites. La Cour relève cependant que cette procédure n'est ouverte qu'aux parents d'intention mariés. De plus, il ressort notamment des observations en intervention du Défenseur des droits que des incertitudes persistent quant aux modalités de l'adoption de l'enfant du conjoint dans ce contexte, s'agissant par exemple de la nécessité d'obtenir le consentement préalable de la mère porteuse.

58. Ceci étant, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer dans le cadre de son avis consultatif sur l'adéquation du droit français de l'adoption avec les critères énoncés aux paragraphes 54-55 ci-dessus. Il revient au juge interne de le faire (paragraphe 25 ci-dessus), en tenant compte de la situation fragilisée dans laquelle se trouvent les enfants tant que la procédure d'adoption est pendante. ».

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2021

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 2 : LA LIBERTE RELATIONNELLE

Corrigés

Sujet 1 : Dissertation

Le droit reconnu aux enfants de développer des relations avec leurs parents

Corrigé :

Aux termes de l'article 8 al. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après, « *la CESDH* ») :

> « *Toute personne a droit* ***au respect de sa vie privée et familiale****, de son domicile et de sa correspondance* ».

Il est important de souligner que l'article 8 consacre le droit au « *respect »* de la vie familiale : en cela, l'application de ce texte présuppose l'existence d'une famille (CEDH arrêt du 13 juin 1979, *affaire Marckx c. Belgique*, req. n°6833/74).

Il n'en demeure pas moins que **le champ d'application de ce texte est large**, dès lors que la notion de famille est une **notion autonome** en droit de la CESDH, c'est-à-dire qu'elle ne peut être interprétée par simple référence au droit interne, mais est revêtu d'une étendue européenne.

Ainsi, dans l'important arrêt *Marck c. Belgique* (préc.), la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, « *la CEDH* ») a jugé que la notion de « *vie familiale* » englobait les rapports entre proches parents, et comprenait par là-même la famille « naturelle » comme la famille « légitime », indépendamment des qualifications de droit interne.

De même, l'existence d'une vie familiale n'est pas subordonnée à l'existence de liens maritaux (CEDH, arrêt du 26 mai 1994, affaire Keegan c. Irlande, req. n°16969/90).

En matière de liens entre les parents et leurs enfants, la Cour a adopté la même logique tendant à une application large de l'article 8 :

> « *La notion de famille sur laquelle repose l'article 8 inclut,* ***même en l'absence de cohabitation****, le lien entre un individu et son enfant, que ce dernier soit légitime ou naturel*. »
>
> **CEDH, arrêt du 24 avril 1996, affaire Boughanemi c. France, req. n°22070/93, §35**

On le voit, le champ d'application de l'article 8 de la CESDH est délibérément large, ce qui garantit une vaste étendue à l'application de ce droit, notamment en faveur du droit des enfants à entretenir des relations avec leurs parents.

Cette volonté d'une protection forte du droit au respect de la vie familiale se matérialise par le soin apporté par la jurisprudence à l'**effectivité de ce droit (I).** Toutefois, il conviendra d'exposer les **limites du droit des enfants à développer des relations avec leurs parents (II).**

I. Le droit de nouer des relations effectives avec ses parents

Le droit de nouer des relations effectives avec ses parents implique leur développement normal (**A.**) mais aussi, comme préalable nécessaire, le droit à la connaissance de ses origines (**B.**).

A. Le droit à un développement normal des relations familiales

- Est garanti le droit pour un enfant **d'avoir des liens** avec ses parents (CEDH, arrêt du 26 mai 1994, affaire Keegan c. Irlande, req. n°16969/90), mais cela n'est pas suffisant.
- Le droit de l'enfant au respect de sa vie privée et familiale doit être concret et effectif, et non théorique et illusoire (*sur ce point, rapprocher de l'arrêt-phare* : CEDH, arrêt du 9 octobre 1979, affaire Airey c. Irlande, req. n°6289/73).
- Afin que la protection des relations de l'enfant avec ses parents soit **effective**, il est nécessaire :
    - Qu'ils puissent être ensemble (CEDH, arrêt du 28 juin 2006, affaire Fourchon c. France, req. n°60145/00) ;
    - Et donc de tenter de réunir parents et enfants (CEDH, arrêt du 26 février 2004, affaire Görgülü c. Allemagne, req. n°74969/01).
- Sans cela, enfants et parents ne pourront ***développer*** leur relation.

B. Le prolongement de ce droit : le droit à la connaissance de ses origines

- Il apparaît dans les arrêts susvisés que la protection effective du droit des enfants de développer des liens avec leurs parents implique pour les Etats parties des **obligations positives** : il ne suffit pas pour les Etats parties de s'abstenir de s'ingérer dans ces relations, il faut également qu'ils mettent en œuvre les mesures nécessaires, notamment procédurales, à ce qu'elles puissent prospérer.
- Cela implique également pour l'Etat de **garantir aux enfants le droit d'accès à leurs origines**, et, par là-même, **à l'identité de leurs parents** :

> *« La Cour rappelle à cet égard que « l'article 8 protège un droit à l'identité et à l'épanouissement personnel et celui de nouer et de développer des relations avec ses semblables et le monde extérieur. (...) La sauvegarde de la stabilité mentale est à cet égard un préalable inéluctable à la jouissance effective du droit au respect de la vie privée » (arrêt Bensaid c. Royaume-Uni, no 44599/98, § 47, CEDH 2001-I). A cet épanouissement contribuent **l'établissement des détails de son identité d'être humain et l'intérêt vital, protégé par la Convention, à obtenir des informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un aspect important de son identité personnelle, par exemple l'identité de ses géniteurs** (Mikulić c. Croatie, no 53176/99, §§ 54 et 64, CEDH 2002-I). »*

CEDH, arrêt de Grande Chambre du 13 février 2003, affaire Odièvre c. France, req. n°42326/98

II. Les limites au droit de nouer des relations effectives avec ses parents

Le droit au respect de la vie privée et familiale admet l'existence de certaines ingérences étatiques (**A.**) et doit, en tout état de cause, nécessairement coexister avec d'autres libertés fondamentales (**B.**).

A. L'admission d'ingérences étatiques strictement justifiées

- Le droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas un droit absolu mais un droit relatif (*cf.* Art. 8 al.2 de la CESDH), c'est-à-dire qu'il est **susceptible de restrictions**.
- Ainsi, en matière de relations des enfants avec leurs parents, la séparation des enfants de leurs parents peut être justifiée lorsqu'elle est rendue nécessaire par la protection de **l'intérêt supérieur de l'enfant**, lequel doit primer sur toute autre considération (CEDH, arrêt de Grande Chambre du 6 juillet 2010, affaire Neulinger c. Suisse, req. n°41615/07).

- Ex : une rupture du lien familial peut notamment être justifiée par l'existence de maltraitances physiques ou psychologiques (CEDH, affaire Dewinne c. Belgique, décision du 10 mars 2005, req. n°56024/00).

B. La prise en compte des libertés fondamentales des parents

- Le droit à la vie privée et familiale des enfants peut se heurter avec celui de leurs parents. C'est notamment le cas **lorsqu'une mère biologique souhaite conserver l'anonymat**, puisque :

> *« L'expression « toute personne » de l'article 8 de la Convention **s'applique à l'enfant comme à la mère**. D'un côté, il y a le droit à la connaissance de ses origines qui trouve son fondement dans l'interprétation extensive du champ d'application de la notion de vie privée. L'intérêt vital de l'enfant dans son épanouissement est également largement reconnu dans l'économie générale de la Convention* […]. *De l'autre, **on ne saurait dénier l'intérêt d'une femme à conserver l'anonymat pour sauvegarder sa santé en accouchant dans des conditions médicales appropriées**.* […] *La Cour se trouve en l'espèce en présence de **deux intérêts privés difficilement conciliables** ».*
>
> **CEDH, arrêt de Grande Chambre du 13 février 2003, affaire Odièvre c. France, req. n°42326/98**

- Dans cette affaire, la CEDH a validé la conformité du système français (*cf.* article 326 et L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles) à l'article 8 de la CESDH, en constatant que les enfants nés sous X avaient « *accès à des informations non identifiantes »* sur leur famille biologique, qui leur permettaient « *d'établir quelques racines de* [leur] *histoire **dans le respect de la préservation des intérêts des tiers*** » (§48).

Sujet 2 : Argumentation

Soutenez que l'intervention de l'Etat en matière de relations sexuelles peut être légitime

Corrigé : La vie sexuelle, et notamment la détermination de l'identité sexuelle, constitue **l'un des aspects les plus intimes de la vie privée de l'individu** (CEDH, arrêt de Grande Chambre du 11 juillet 2002, affaire Christine Goodwin c. Royaume-Uni, req. n°28957/95).

Par principe, l'Etat ne saurait intervenir dans les relations sexuelles des individus. Sur ce point, la jurisprudence européenne a joué un rôle précurseur, puisque la CEDH jugeait dès 1981 que **les relations sexuelles entre « *adultes consentants* » ne sauraient être pénalisées** (CEDH, arrêt du 22 oct. 1981, affaire Dudgeon c. Royaume-Uni).

Par là-même, la Cour retenait que **l'intervention de l'Etat dans les relations sexuelles entre adultes consentants était injustifiée**.

De même, il a été jugé que les pratiques sadomasochistes dans lesquelles le respect du consentement des participants était sauvegardé ne sauraient justifier une intervention de l'Etat (CEDH, arrêt du 17 février 2005, affaire KA et AD c. Belgique, req. n°42758/98).

La clé de voûte de cette solution étant le **consentement**, **l'intervention de l'Etat pourra toutefois être justifiable** quant le consentement était impossible ou a été ravi, bien que la marge d'appréciation reconnue aux Etats-parties en la matière soit étroite (CEDH, arrêt du 31 juillet 2000, affaire ADT c. Royaume-Uni, req. n°35735/97).

Il sera donc ici soutenu que l'intervention de l'Etat en matière de relations sexuelles est légitime lorsque le consentement était impossible (**I.**) ou qu'il a été ravi (**II.**), ce qui sera illustré par le droit en vigueur.

I. Le consentement impossible

Le consentement des majeurs protégés (**A.**) comme des mineurs (**B.**) est impossible et justifie donc l'intervention de l'Etat.

A. Les majeurs protégés

- CEDH, arrêt du 22 octobre 1996, affaire Stubbings et autres c. Royaume-Uni, req. n°22083/93 : les personnes vulnérables ont droit à une protection de l'Etat contre les sévices sexuels, sous la forme d'une **prévention efficace**.
- Il doit toutefois être noté que cette protection **ne peut justifier l'interdiction pure et simple des activités sexuelles** pour les majeurs protégés, toute restriction devant être justifiée et proportionnée. La clause du règlement d'un établissement psychiatrique qui interdit, de façon absolue, toute activité sexuelle est illicite (CAA Bordeaux, 6 novembre 2012, *cf. notes de jurisprudence sous article 415 du code civil*).
- L'intervention de l'Etat est donc justifiée dès lors qu'elle est restreinte à une stricte proportionnalité.

B. Les mineurs

- Le droit pénal **déclare imposées** les relations sexuelles entre un majeur et un mineur ; on parle alors d'***atteintes sexuelles***.
- Ces infractions spécifiques aux mineurs se superposent aux ***agressions sexuelles*** (*cf. infra*), qui peuvent être commises à la fois sur des mineurs et des majeurs (voir article 227-1-1 du code pénal).

- Ainsi, l'article 227-25 du code pénal prévoit que « *hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, le fait, pour un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un **mineur de quinze ans**[1] est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende* ».
- Pour les **mineurs de plus de quinze ans**, la qualification d'atteinte sexuelle est subordonnée à l'établissement d'une certaine qualité chez le majeur (*cf.* article 227-27 du code pénal : autorité de droit ou de fait ; abus de l'autorité résultant de ses fonctions).
- Ces interventions de l'Etat sont **légitimes dès lors que les mineurs ainsi protégés ne disposent pas de la maturité nécessaire** pour consentir à l'accomplissement d'un acte sexuel. Elles se justifient par là-même par la protection de l'**intérêt supérieur de l'enfant**.

II. Le consentement ravi

Les pratiques sexuelles non-consenties, qu'elles concernent des mineurs ou des majeurs, font l'objet d'une répression pénale à travers les textes relatifs au viol (**B.**) et aux autres agressions sexuelles (**A.**). L'intervention de l'Etat dans ces relations sexuelles est ici justifiée dès lors que le consentement y est, par nature, inexistant.

A. Les autres agressions sexuelles que le viol

- L'article 222-22 du code pénal définit l'agression sexuelle comme « *toute atteinte sexuelle commise avec **violence, contrainte, menace ou surprise*** ». Comme pour le viol, la violence, contrainte, menace ou surprise constituent les moyens par lesquels le consentement est ravi.
- L'article 222-22-1 al. 1er du code pénal précise que la contrainte peut être « *physique ou morale* ».
- Il s'agit donc d'hypothèses où les personnes impliquées dans une relation sexuelle n'auront **pas consenti**, de telle sorte que l'intervention de l'Etat à travers le droit pénal est justifiée.

B. Le viol

- Aux termes de l'article 222-23 al. 1er du code pénal, « *Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur **par violence, contrainte, menace ou surprise** est un viol*. »
- Il est à noter que **la pénalisation du viol a été renforcée à travers une extension de sa définition** : préalablement à la loi du 3 août 2018, le viol était défini comme « *tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis **sur la personne d'autrui** par violence, contrainte, menace ou surprise* ». Ainsi, quand l'acte sexuel contraint était commis sur la personne de l'auteur, il ne pouvait être qualifié de viol (Crim. 22 août 2001).
- Cette extension illustre l'important renforcement de la protection des valeurs protégées par les crimes et délits sexuels. Ce renforcement matérialise une prise de conscience très prégnante en la matière (*à relier dans l'actualité très récente à la publication du rapport de la Commission indépendant sur les abus sexuels dans l'Eglise, dit « rapport Sauvé »*). Cette prise de conscience peut également justifier une certaine intervention de l'Etat.

[1] Attention : l'expression « *mineur de quinze ans* » signifie **mineur de moins de quinze ans**.

Sujet 3 : Commentaire

Commentaire d'arrêt : CEDH, Affaire MENNESSON c. FRANCE, avis consultatif du 10 avril 2019, Demande n°P16-2018-001

« II.SUR LE PREMIER POINT

35. Il résulte de la jurisprudence de la Cour que l'article 8 de la Convention demande que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et le père d'intention lorsqu'il est le père biologique. Comme indiqué précédemment, la Cour a en effet expressément conclu dans l'arrêt Mennesson précité que l'absence d'une telle possibilité emportait violation du droit de l'enfant au respect de sa vie privée, tel qu'il se trouve garanti par cette disposition (Mennesson, précité, §§ 100-101; voir aussi Labassee c. France, no 65941/11, 26 juin 2014, ainsi que Foulon et Bouvet c. France, nos 9063/14 et 10410/14, 21 juillet 2016, et Laborie c. France, no 44024/13, 19 janvier 2017).

36. En rapport avec ce qui précède, la Cour relève qu'à ce jour, sa jurisprudence met un certain accent sur l'existence d'un lien biologique entre l'enfant et au moins l'un des parents d'intention (voir les arrêts cités ci-dessus, ainsi que l'arrêt Paradiso et Campanelli c. Italie [GC] (no 25358/12, § 195, 24 janvier 2017). Elle rappelle à cet égard que la question à examiner en l'espèce inclut explicitement un élément factuel selon lequel le père d'intention a un lien biologique avec l'enfant concerné. La Cour va circonscrire sa réponse en conséquence. Elle précise toutefois qu'elle pourrait être appelée à l'avenir à développer sa jurisprudence dans ce domaine, étant donné en particulier l'évolution de la question de la gestation pour autrui.

*37. Pour se prononcer dans le cadre de la présente demande d'avis consultatif (paragraphes 32, 34 et 36 ci-dessus) sur la **question de savoir si l'article 8 de la Convention requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention** deux facteurs ont un poids particulier : l'intérêt supérieur de l'enfant et l'étendue de la marge d'appréciation dont disposent les États parties.*

38. S'agissant du premier facteur, la Cour se réfère au principe essentiel selon lequel, chaque fois que la situation d'un enfant est en cause, l'intérêt supérieur de celui-ci doit primer (voir, en particulier, Paradiso et Campanelli, précité, § 208, X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 95, CEDH 2013, Mennesson, précité, §§ 81 et 99, Labassee, précité, §§ 60 et 78, et Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 133, 28 juin 2007).

39. La Cour a admis dans les arrêts Mennesson (précité, § 99) et Labassee (précité, § 78) qu'il était « concevable que la France puisse souhaiter décourager ses ressortissants de recourir à l'étranger à une méthode de procréation qu'elle prohibe sur son territoire ». Elle a toutefois relevé que les effets de la non-reconnaissance en droit français du lien de filiation entre les enfants ainsi conçus et les parents d'intention ne se limitaient pas à la situation de ces derniers, qui seuls ont fait le choix des modalités de procréation que leur reprochent les autorités françaises : ils portent aussi sur celle des enfants eux-mêmes, dont le droit au respect de la vie privée se trouve significativement affecté.

40. L'absence de reconnaissance d'un lien de filiation entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention a ainsi des conséquences négatives sur plusieurs aspects du droit de l'enfant au respect de la vie privée. D'un point de vue général, comme la Cour l'a relevé dans les arrêts Mennesson et Labassee précités, l'absence de reconnaissance en droit interne du lien entre l'enfant et la mère d'intention défavorise l'enfant dès lors qu'il le place dans une forme d'incertitude juridique quant à son identité dans la société (§§ 96 et 75 respectivement). Il y a notamment un risque qu'il n'ait pas l'accès à la nationalité de la mère d'intention dans les conditions que garantit la filiation, cela peut compliquer son maintien sur le territoire du pays de résidence de la mère d'intention (même si ce risque n'existe pas dans le cas soumis à l'examen de la Cour de cassation, le père d'intention, qui est aussi le père biologique, ayant la nationalité française), ses droits successoraux à l'égard de celle-

ci peuvent être amoindris, il se trouve fragilisé dans le maintien de sa relation avec la mère d'intention en cas de séparation des parents d'intention ou de décès du père d'intention, et il n'est pas protégé contre un refus ou une renonciation de la mère d'intention de le prendre en charge.

41. La Cour est consciente de ce que, dans le contexte de la gestation pour autrui, l'intérêt supérieur de l'enfant ne se résume pas au respect de ces aspects de son droit à la vie privée. Il inclut d'autres éléments fondamentaux, qui ne plaident pas nécessairement en faveur de la reconnaissance d'un lien de filiation avec la mère d'intention, tels que la protection contre les risques d'abus que comporte la gestation pour autrui (voir Paradiso et Campanelli, précité, § 202) et la possibilité de connaitre ses origines (voir, par exemple, Mikulić c. Croatie, no 53176/99, §§ 54-55, CEDH 2002-I).

42. Au vu des éléments indiqués au paragraphe 40 ci-dessus et du fait que l'intérêt supérieur de l'enfant comprend aussi l'identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l'élever, de satisfaire à ses besoins et d'assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d'évoluer dans un milieu stable, la Cour considère toutefois que l'impossibilité générale et absolue d'obtenir la reconnaissance du lien entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention n'est pas conciliable avec l'intérêt supérieur de l'enfant, qui exige pour le moins un examen de chaque situation au regard des circonstances particulières qui la caractérise.

43. S'agissant du second facteur, comme la Cour l'a rappelé dans les arrêts Mennesson (précité, § 77) et Labassee (précité, § 57), l'étendue de la marge d'appréciation dont disposent les États varie selon les circonstances, les domaines et le contexte ; la présence ou l'absence d'un dénominateur commun aux systèmes juridiques des États contractants peut constituer un élément pertinent à cet égard. Ainsi, lorsqu'il n'y a pas de consensus au sein des États membres du Conseil de l'Europe, que ce soit sur l'importance relative de l'intérêt en jeu ou sur les meilleurs moyens de le protéger, en particulier lorsque l'affaire soulève des questions morales ou éthiques délicates, la marge d'appréciation est large. Or il ressort de l'étude de droit comparé susmentionnée que, malgré une certaine évolution vers la possibilité d'une reconnaissance juridique du lien de filiation entre les enfants nés d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et les parents d'intention, il n'y a pas consensus en Europe sur cette question (paragraphe 23 ci-dessus).

44. La Cour a toutefois également rappelé dans ces mêmes arrêts (§§ 77 et 80, et §§ 56 et 59 respectivement) que, lorsqu'un aspect particulièrement important de l'identité d'un individu se trouve en jeu, comme lorsque l'on touche à la filiation, la marge laissée à l'État est d'ordinaire restreinte. Elle en a déduit qu'il convenait d'atténuer la marge d'appréciation dont disposait l'État défendeur (ibidem).

45. Ce qui est en jeu dans le contexte de la reconnaissance d'un lien de filiation entre des enfants nés à l'issue d'une gestation pour autrui et les parents d'intention dépasse en réalité la question de l'identité de ces enfants. D'autres aspects essentiels de leur vie privée sont concernés dès lors que sont en question l'environnement dans lequel ils vivent et se développent et les personnes qui ont la responsabilité de satisfaire à leurs besoins et d'assurer leur bien-être (voir aussi les paragraphes 40-42 ci-dessus). Ceci conforte le constat de la Cour quant à la réduction de la marge d'appréciation.

46. En somme, vu les exigences de l'intérêt supérieur de l'enfant et la réduction de la marge d'appréciation, la Cour est d'avis que, dans une situation telle que celle visée par la Cour de cassation dans ses questions (paragraphes 9 et 32 ci-dessus) et délimitée par la Cour au paragraphe 36 ci-dessus, le droit au respect de la vie privée, au sens de l'article 8 de la Convention, d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une gestation pour autrui, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation entre cet enfant et la mère d'intention, désignée dans l'acte de naissance légalement établi à l'étranger comme étant la « mère légale ».

47. Bien que le litige interne ne concerne pas le cas d'un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et conçu avec les gamètes de la mère d'intention, la Cour juge important de préciser que, lorsque la situation est par ailleurs similaire à celle dont il est question dans ce litige, la nécessité d'offrir

une possibilité de reconnaissance du lien entre l'enfant et la mère d'intention vaut a fortiori dans un tel cas.

III.SUR LE SECOND POINT

48. Le second point concerne la question de savoir si le droit au respect de la vie privée de l'enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger, dans la situation où l'enfant a été conçu avec les gamètes d'une tierce donneuse, requiert que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de naissance légalement établi à l'étranger, ou s'il admet qu'elle puisse se faire par d'autres moyens, tels que l'adoption de l'enfant par la mère d'intention.

49. Il est dans l'intérêt de l'enfant qui est dans cette situation que la durée de l'incertitude dans laquelle il se trouve quant à sa filiation à l'égard de la mère d'intention soit aussi brève que possible. Comme indiqué précédemment, tant que le lien entre lui et celle-ci n'est pas reconnu en droit interne sa situation se trouve fragilisée s'agissant de plusieurs aspects de son droit au respect de la vie privée (paragraphe 40 ci-dessus).

50. On ne saurait toutefois en déduire que les États parties soient tenus d'opter pour la transcription des actes de naissance légalement établis à l'étranger.

51. La Cour constate en effet qu'il n'y a pas de consensus européen sur cette question : lorsque l'établissement ou la reconnaissance du lien entre l'enfant et le parent d'intention est possible, leurs modalités varient d'un État à l'autre (paragraphe 24 ci-dessus). Elle observe ensuite que l'identité de l'individu est moins directement en jeu lorsqu'il s'agit non du principe même de l'établissement ou de la reconnaissance de sa filiation mais des moyens à mettre en œuvre à cette fin. La Cour estime en conséquence que le choix des moyens à mettre en œuvre pour permettre la reconnaissance du lien enfant-parents d'intention tombe dans la marge d'appréciation des États.

52. Outre ce constat relatif à la marge d'appréciation, la Cour considère que l'article 8 de la Convention n'impose pas une obligation générale pour les États de reconnaître ab initio un lien de filiation entre l'enfant et la mère d'intention. Ce que requiert l'intérêt supérieur de l'enfant – qui s'apprécie avant tout in concreto plutôt qu'in abstracto – c'est que ce lien, légalement établi à l'étranger, puisse être reconnu au plus tard lorsqu'il s'est concrétisé. Il appartient en principe non pas à la Cour mais en premier lieu aux autorités nationales d'évaluer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, si et quand ce lien s'est concrétisé.

53. On ne saurait déduire de l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi compris que la reconnaissance du lien de filiation entre l'enfant et la mère d'intention que requiert le droit de l'enfant au respect de la vie privée, au sens l'article 8 de la Convention, impose aux États de procéder à la transcription de l'acte de naissance étranger en ce qu'il désigne la mère d'intention comme étant la mère légale. Selon les circonstances de chaque cause, d'autres modalités peuvent également servir convenablement cet intérêt supérieur, dont l'adoption, qui, s'agissant de la reconnaissance de ce lien, produit des effets de même nature que la transcription de l'acte de naissance étranger.

54. Ce qui compte c'est qu'au plus tard lorsque, selon l'appréciation des circonstances de chaque cas, le lien entre l'enfant et la mère d'intention s'est concrétisé (paragraphe 52 ci-dessus), il y ait un mécanisme effectif permettant la reconnaissance de ce lien. Une procédure d'adoption peut répondre à cette nécessité dès lors que ses conditions sont adaptées et que ses modalités permettent une décision rapide, de manière à éviter que l'enfant soit maintenu longtemps dans l'incertitude juridique quant à ce lien. Il va de soi que ces conditions doivent inclure une appréciation par le juge de l'intérêt supérieur de l'enfant à la lumière des circonstances de la cause.

55. En somme, vu la marge d'appréciation dont disposent les États s'agissant du choix des moyens, d'autres voies que la transcription, notamment l'adoption par la mère d'intention, peuvent être acceptables dans la mesure où les modalités prévues par le droit interne garantissent l'effectivité et la célérité de leur mise en œuvre, conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant.

56. La Cour de cassation indique dans sa demande d'avis que la loi française facilite l'adoption de l'enfant du conjoint (paragraphe 14 ci-dessus). Il peut s'agir d'une adoption plénière ou d'une adoption simple.

57. Le gouvernement français fait ainsi valoir qu'entre le 5 juillet 2017 et le 2 mai 2018 la quasi-totalité des demandes d'adoption entre conjoints concernant des enfants nés à l'étranger d'une gestation pour autrui ont été satisfaites. La Cour relève cependant que cette procédure n'est ouverte qu'aux parents d'intention mariés. De plus, il ressort notamment des observations en intervention du Défenseur des droits que des incertitudes persistent quant aux modalités de l'adoption de l'enfant du conjoint dans ce contexte, s'agissant par exemple de la nécessité d'obtenir le consentement préalable de la mère porteuse.

58. Ceci étant, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer dans le cadre de son avis consultatif sur l'adéquation du droit français de l'adoption avec les critères énoncés aux paragraphes 54-55 ci-dessus. Il revient au juge interne de le faire (paragraphe 25 ci-dessus), en tenant compte de la situation fragilisée dans laquelle se trouvent les enfants tant que la procédure d'adoption est pendante. ».

Corrigé :

L'affaire Mennesson a longtemps agité l'actualité judiciaire française, **trois premiers arrêts** ayant été rendus par la Cour de cassation le 6 avril 2011, puis **deux seconds**, cette fois par l'Assemblée plénière, le 3 juillet 2015, puis enfin un **troisième**, le 4 octobre 2019.

A l'origine de cette affaire se trouve le couple Mennesson, un homme et une femme mariés, qui avaient eu recours au procédé de gestation pour autrui (ci-après, « *la GPA* ») aux Etats-Unis (Californie) en raison de leur infertilité. Deux jumelles étaient nées le 25 octobre 2000 en Californie. Leur acte de naissance avait été enregistré à l'état civil américain, mais sa transcription avait été refusée sur les registres de l'état civil français.

Par trois arrêts du 6 janvier 2011, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation jugeait que **la demande de transcription des actes étrangers des enfants MENNESSON ne pouvait pas en soi être accueillie, puisqu'ils étaient issus de GPA, un acte contraire au principe de l'indisponibilité des personnes** (Civ. 1, 6 avril 2011, pourvois n° 09-66.486, n° 10-19.053 et n° 09-17.130).

Saisie de l'affaire, la CEDH jugeait qu'il y avait là une violation du droit à la vie privée garanti par l'article 8 de la CESDH, dès lors que le droit au respect de la vie privée des enfants « *implique que chacun puisse établir la substance de son identité, y compris sa filiation* » (CEDH, arrêt du 26 septembre 2014, Affaire Mennesson c. France, req. n°65192/11, §102).

Statuant à nouveau dans la même affaire, la Cour de cassation a jugé, par les arrêts du 3 juillet 2015, que l'existence d'une convention de GPA ne **faisait pas en soi obstacle à la transcription d'un acte de naissance établi à l'étranger** (Ass. plén., 3 juillet 2015, pourvois n° 14-21.323 et 15-50.002).

Cette solution permettait à Monsieur MENNESSON, père biologique, de voir son lien de filiation inscrit aux registres de l'état civil français. **Le problème du lien de filiation de Madame MENNESSON, mère dite « d'intention », avec ses deux filles demeurait toutefois entier**. C'est la question qui se trouve au cœur de la demande d'avis consultatif adressé par la Cour de cassation à la CEDH

Avant d'entrer dans le fond de l'analyse de cet avis, il convient de relever que celui-ci constitue une avancée procédurale importante : en effet, c'est le premier avis consultatif rendu par la CEDH sur le fondement du Protocole n°16 à la CESDH, entré en vigueur le 1er août 2018. Cette disposition permet aux « *plus hautes juridictions d'une Haute Partie Contractante, telles que désignées conformément à l'article 10, d'adresser à*

la CEDH des demandes d'avis consultatifs sur des questions relatives à l'interprétation ou l'application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles ».

Au cas présent, la CEDH était donc consultée sur la « *question de savoir si l'article 8 de la Convention requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention* » (§37).

Au terme de cet avis, la CEDH a énoncé que le droit interne devait offrir la « *possibilité* » de voir reconnaître le lien de filiation entre l'enfant issu d'une GPA réalisée à l'étranger, les moyens de cette reconnaissance restant à l'appréciation des Etats parties.

A la suite de cet avis, la Cour de cassation a finalement jugé que la GPA réalisée à l'étranger ne faisait pas davantage obstacle à la reconnaissance d'un lien de filiation avec la mère d'intention (Cass. Ass. plén. 4 octobre 2019, n°10-19.053).

Il conviendra ici d'analyser le raisonnement retenu par la CEDH dans cet avis consultatif. La CEDH procède ici en deux temps très clairement identifiés, qu'il conviendra de respecter pour la clarté de l'exposé : si l'intérêt supérieur de l'enfant justifie que le lien avec sa mère d'intention soit reconnu (**I.**), il n'en demeure pas moins que les Etats parties conservent une marge d'appréciation quant aux modalités de cette reconnaissance (**II.**).

I. La nécessaire reconnaissance d'un lien entre la mère d'intention et l'enfant issu d'une GPA réalisée à l'étranger

Après avoir fait le rappel de la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant (**A.**), la CEDH explicite la nécessité de prévenir les conséquences négatives d'une absence de lien (**B.**).

A. La primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant

- *Cf. §§38 à 42*
    - A relier à : Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 et signée par la France le 26 janvier 1990.

- *42. Au vu des éléments indiqués au paragraphe 40 ci-dessus et du fait que l'intérêt supérieur de l'enfant comprend aussi l'identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l'élever, de satisfaire à ses besoins et d'assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d'évoluer dans un milieu stable, la Cour considère toutefois que **l'impossibilité générale et absolue d'obtenir la reconnaissance du lien entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention n'est pas conciliable avec l'intérêt supérieur de l'enfant**, qui exige pour le moins un examen de chaque situation au regard des circonstances particulières qui la caractérise.*
    - Par là-même, la CEDH invalide la solution retenue par la Cour de cassation par ses arrêts de 2015, qui se limitaient à reconnaître la possibilité d'une reconnaissance du lien de filiation pour le père biologique et non la mère d'intention.
    - La CEDH déduit donc d'importantes conséquences de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'elle justifie, comme on va le voir, par une multiplicité de considérations très pratiques.

B. La nécessité de prévenir les conséquences négatives d'une l'absence de lien

*- « 40. L'absence de reconnaissance d'un lien de filiation entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention a ainsi des conséquences négatives sur plusieurs aspects du droit de l'enfant au respect de la vie privée. D'un point de vue général, comme la Cour l'a relevé dans les arrêts Mennesson et Labassee précités, l'absence de reconnaissance en droit interne du lien entre l'enfant et la mère d'intention défavorise l'enfant dès lors qu'il le place dans **une forme d'incertitude juridique** quant à son identité dans la société (§§ 96 et 75 respectivement). Il y a*

*notamment un **risque qu'il n'ait pas l'accès à la nationalité de la mère d'intention dans les conditions que garantit la filiation, cela peut compliquer son maintien sur le territoire du pays de résidence de la mère d'intention** (même si ce risque n'existe pas dans le cas soumis à l'examen de la Cour de cassation, le père d'intention, qui est aussi le père biologique, ayant la nationalité française), **ses droits successoraux** à l'égard de celle-ci peuvent être amoindris, il se trouve frag**ilisé dans le maintien de sa relation avec la mère d'intention en cas de séparation des parents d'intention ou de décès du père d'intention**, et il n'est **pas protégé contre un refus ou une renonciation de la mère d'intention de le prendre en charge**.»*

- Il est intéressant de constater que la CEDH va au-delà du cas d'espèce qui lui est soumis, afin d'envisager l'ensemble des justifications éventuelles de la reconnaissance d'un lien entre la mère d'intention et l'enfant issu d'une GPA.

II. La marge d'appréciation reconnue aux Etats pour les modalités de la reconnaissance du lien

Il convient de relever que la CEDH distingue bien, quant à l'étendue de la marge d'appréciation reconnue aux Etats, entre *principe* et *modalités* de la reconnaissance du lien litigieux (**A.**). L'incidence de la liberté reconnue pour les *modalités* de la reconnaissance du lien consiste en la possibilité d'une adoption en droit français (**B.**).

A. La distinction de la marge reconnue aux Etats pour le principe et pour les modalités

- Sur le principe de la reconnaissance du lien :
  - La Cour reconnaît qu'il n'existe pas de consensus entre les Etats parties quant à la question de la reconnaissance du lien. Ceci étant considéré, la marge d'appréciation reconnue aux Etats devrait être large.

  Toutefois, dès lors qu'il s'agit d'un **aspect important de l'identité** (« *44. La Cour a toutefois également rappelé dans ces mêmes arrêts (§§ 77 et 80, et §§ 56 et 59 respectivement) que, lorsqu'un aspect particulièrement important de l'identité d'un individu se trouve en jeu, comme lorsque l'on touche à la filiation, la marge laissée à l'État est d'ordinaire restreinte. Elle en a déduit qu'il convenait d'atténuer la marge d'appréciation dont disposait l'État défendeur (ibidem).* »), **la marge d'appréciation des Etats se trouver restreinte**.

  - Il incombe donc aux Etats de reconnaître le principe d'une reconnaissance de la filiation de la mère d'intention avec l'enfant issu d'une GPA, sans quoi le droit interne ne saurait être conforme avec l'article 8 de la CESDH.
- Sur les modalités de la reconnaissance du lien :
  - *« 51. La Cour constate en effet qu'il n'y a **pas de consensus européen sur cette question** : lorsque l'établissement ou la reconnaissance du lien entre l'enfant et le parent d'intention est possible, leurs modalités varient d'un État à l'autre (paragraphe 24 ci-dessus). Elle observe ensuite que **l'identité de l'individu est moins directement en jeu lorsqu'il s'agit non du principe même de l'établissement ou de la reconnaissance de sa filiation mais des moyens à mettre en œuvre à cette fin**. La Cour estime en conséquence que le choix des moyens à mettre en œuvre pour permettre la reconnaissance du lien enfant-parents d'intention tombe dans la marge d'appréciation des États. »*
  - La CEDH reconnaît une réelle marge d'appréciation aux Etats parties quant à la détermination des modalités de reconnaissance du lien de filiation.

B. L'incidence de la liberté reconnue aux Etats parties pour les modalités

- *« 55. En somme, vu la marge d'appréciation dont disposent les États s'agissant du choix des moyens, **d'autres voies que la transcription, notamment l'adoption par la mère d'intention, peuvent être acceptables** dans la mesure où les modalités prévues par le droit interne garantissent **l'effectivité et la célérité de leur mise en œuvre**, conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant. »*

- En l'espèce, la Cour de cassation statuant après cet avis a finalement retenu que **seule la transcription** permettrait la protection des droits garantis par l'article 8 de la CESDH (Ass. plén., 4 octobre 2019, pourvoi n°10-19.053) :

> *« en l'espèce, s'agissant d'un **contentieux qui perdure depuis plus de quinze ans**, en l'absence d'autre voie permettant de reconnaître la filiation dans des conditions qui ne porteraient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mmes E... et J... D... consacré par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et alors qu'il y a lieu de mettre fin à cette atteinte, **la transcription sur les registres de l'état civil de Nantes des actes de naissance établis à l'étranger de E... et J... D... ne saurait être annulée** ».*

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2022

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 1 – La crise sanitaire

1. Dissertation
2. Commentaire
3. Argumentation

1. **Sujet – Dissertation**

L'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.

2. **Sujet – Commentaire**

Commentaire d'arrêt (extraits) : Conseil constitutionnel, décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021, Loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire

« **30.** L'article 9 permet aux directeurs des établissements d'enseignement scolaire d'accéder à des informations médicales relatives aux élèves et de procéder à leur traitement.

(…)

32. Les députés et sénateurs requérants estiment par ailleurs que ces dispositions méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée. Ils considèrent que la dérogation au secret médical qu'elles instaurent et l'autorisation de traitement qu'elles accordent ne sont pas entourées de garanties suffisantes quant à la détermination des personnes susceptibles d'accéder à ces données à caractère personnel, à la protection desdites données et aux finalités poursuivies, alors même qu'il s'agit de données particulièrement sensibles relatives à des personnes pour la plupart mineures.

(…)

34. Enfin, selon les députés auteurs de la première saisine, ces dispositions seraient de nature à entraîner une rupture d'égalité entre les élèves dans l'accès à l'instruction, selon leur statut vaccinal.

35. La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Il résulte de ce droit que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. Lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale, une particulière vigilance doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités.

36. Le premier alinéa de l'article 9 prévoit que, par dérogation à l'exigence fixée à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les directeurs des établissements d'enseignement scolaire des premier et second degrés peuvent avoir accès aux informations médicales relatives aux élèves, pour une durée ne pouvant excéder la fin de l'année scolaire en cours. Son second alinéa les autorise à procéder au traitement des données ainsi recueillies, aux fins de faciliter l'organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d'organiser des conditions d'enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus.

37. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu lutter contre l'épidémie de covid-19 par la mise en œuvre des protocoles sanitaires au sein des établissements d'enseignement scolaire. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.

38. Toutefois, en premier lieu, les dispositions contestées permettent d'accéder non seulement au statut virologique et vaccinal des élèves, mais également à l'existence de contacts avec des personnes contaminées, ainsi que de procéder au traitement de ces données, sans que soit préalablement recueilli le consentement des élèves intéressés ou, s'ils sont mineurs, de leurs représentants légaux.

39. En deuxième lieu, ces dispositions autorisent l'accès à ces données et leur traitement tant par les directeurs des établissements d'enseignement scolaire des premier et second degrés que par « les personnes qu'ils habilitent spécialement à cet effet ». Les informations médicales en cause sont donc susceptibles d'être communiquées à un grand nombre de personnes, dont l'habilitation n'est subordonnée à aucun critère ni assortie d'aucune garantie relative à la protection du secret médical.

40. En dernier lieu, en se bornant à prévoir que le traitement de ces données permet d'organiser les conditions d'enseignement pour prévenir les risques de propagation du virus, le législateur n'a pas défini avec une précision suffisante les finalités poursuivies par ces dispositions.

41. Il résulte de ce qui précède que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

42. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 9 doit être déclaré contraire à la Constitution. »

3. Sujets – Argumentation

Soutenez que l'état d'urgence sanitaire est une atteinte justifiée aux libertés fondamentales.

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2022

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 1 – La crise sanitaire

Corrigés

1. Dissertation
2. Commentaire
3. Argumentation

1. Dissertation

L'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé

Dès 1944, le programme du Conseil national de la Résistance prévoyait, entre bien d'autres idées, d'instaurer un pouvoir devant « combattre pour la vie et la santé des Français ».

La protection de la santé demeurera un souci du constituant français lors de l'érection de la IVe République. En effet, son préambule, qui appartient aujourd'hui encore au bloc de constitutionnalité, dispose que la Nation :

« 10. assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

11. garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, **la protection de la santé**, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. »

Au surplus, l'instauration de la santé au sein du bloc de constitutionnalité ne s'arrête pas là. Ainsi, la Charte de l'environnement de 2004 dispose en son article premier que :

« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et **respectueux de la santé.** »

Le bloc de constitutionnalité comprend donc deux sources textuelles mentionnant explicitement la protection de la santé. Elle est clairement consacrée dans l'ordre juridique français. Le Conseil constitutionnel consacre aujourd'hui la protection de la santé comme un objectif de valeur constitutionnel **(I).** Il s'applique de manière très large au sein de l'ordre juridique français **(II).**

I. La nature du principe de la protection de la santé

Le Conseil constitutionnel a consacré la protection de la santé comme objectif de valeur constitutionnelle **(A)**. Cette position jurisprudentielle possède aujourd'hui un fondement jurisprudentiel clair **(B)**.

A. La consécration de l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé

Cela a été vu, la protection de la santé possède plusieurs sources textuelles dans l'ordre juridique français.

Par suite, le Conseil constitutionnel prend en compte la protection de la santé dans sa jurisprudence depuis longtemps. Dès 1980, il a soutenu que le droit de grève pouvait être obéré, notamment dans le but de protéger la santé ; faisant par-là de la protection de la santé un principe de valeur constitutionnelle **(Conseil constitutionnel, décision n° 80-117 du 22 juillet 1980, Loi sur la protection et le contrôle des matières nucléaires**). Très récemment, le Conseil d'État a considéré que l'article 1er de la Charte de l'environnement (précité) constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de Justice administrative (20 septembre 2022, M. et Mme C., n° 451129)

Le Professeur Pierre de Montalivet explique que, malgré des formulations peu explicites, le Conseil de Montpensier a reconnu la protection de la santé publique tel un objectif de valeur constitutionnelle dans les décisions :

- **Conseil constitutionnel, décision n° 89-269 DC du 22 janvier 1990, Égalité entre Français et étrangers**
- **<u>Et surtout,</u> Conseil constitutionnel, décision n° 90-287 DC du 16 janvier 1991, Santé publique et assurance sociale**

B. Le fondement de l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé

Le Conseil constitutionnel a tout d'abord déduit l'existence de l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé publique de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de la IVe République (Décision n° 90-287 DC précitée).

Il a plus récemment considéré très explicitement qu' : « aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous… la protection de la santé ». Il en découle un objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. »

(Conseil constitutionnel, décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, Union des industries de protection des plantes).

En ce qui concerne la Charte de l'environnement, le Conseil constitutionnel déduit un objectif de valeur de « protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains » (Décision n° 2019-823 QPC précitée). L'article 1er de la Charte, qui a déjà été vu, a une valeur constitutionnelle, mais il n'est pas le fondement textuel de l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé **(Conseil constitutionnel, décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010)**.

I. La large application de l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé

L'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé s'applique en période ordinaire **(A)** et se renforce considérablement en période extraordinaire, lors de l'état d'urgence sanitaire **(B)**.

A. L'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé en période ordinaire

Le Conseil constitutionnel a peu excipé de l'argument que constitue l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé dans sa jurisprudence en période ordinaire. Il l'utilise en différentes occasions pour rappeler que le législateur ne peut pas priver « de garanties légales des exigences constitutionnelles » **(Conseil constitutionnel, décision 2010-605 DC du 12 mai 2010, Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)**.

Sur un sujet plus précis, le Conseil constitutionnel a considéré qu'« il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective. Il lui est également loisible de modifier les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l'évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques. Toutefois, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de mettre en cause, au regard de l'état des connaissances scientifiques, les dispositions prises par le législateur ni de rechercher si l'objectif de protection de la santé que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. » **(Conseil constitutionnel, décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015, Époux L.)**.

Le Conseil constitutionnel adopte donc une politique jurisprudentielle à la fois large mesurée en matière de protection de la santé en période ordinaire.

B. L'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé en état d'urgence sanitaire

Le Conseil constitutionnel affirme clairement que : « La Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence sanitaire. Il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. » **(Conseil constitutionnel, décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, Loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions)**.

Le Conseil constitutionnel a donc considéré, de manière générale, que les législations sur l'état d'urgence, ou celles prises dans le but de protéger la santé pendant l'état d'urgence sanitaire, étaient valides. Il faut considérer que certaines dispositions ont été considérées comme anticonstitutionnelles en ce qu'elles n'assuraient pas une juste conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et d'autres libertés et droits garantis par la Constitution. Par exemple, le Conseil constitutionnel a estimé qu'il n'était pas valide de conditionner l'entrée à une réunion politique à la présentation d'un passe vaccinale **(Conseil constitutionnel, décision n° 2022-835 DC, Loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)**.

* *

*

2. Commentaire

Commentaire d'arrêt (extraits) : **Conseil constitutionnel, décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021, Loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire**

Le Professeur Paul Cassia soutient dans sa contribution extérieure à cette décision du Conseil constitutionnel que cette loi, et plus généralement toutes celles portant sur l'état d'urgence sanitaire et les politiques de luttes contre l'épidémie de covid « méconnaissent de manière substantielle la garantie des droits et la séparation des pouvoirs consacrées par l'article 16 de la Déclaration de 1789. » Il explique que : « pour l'application de l'article 16 de la Déclaration de 1789, la mise en place d'un régime législatif exceptionnel et temporaire d'une durée d'application de quelques mois ne saurait être conforme à la Constitution si, parallèlement à l'augmentation considérable des pouvoirs de police administrative spéciale, le Parlement n'institue pas une ou des voies de recours contentieux spécifiques de nature à permettre en pratique, concrètement, un contrôle non seulement rapide, mais également complet et efficace y compris sur le plan des injonctions de faire susceptibles d'être ordonnées à l'encontre du pouvoir exécutif national ou local tant que ce régime est en vigueur. »

Le secret de l'instruction et des délibérations des décisions du Conseil constitutionnel ainsi que l'obligation de réserve de ses membres rendent impossible la connaissance des opinions personnelles de ceux-ci. Peut-être que certains, minoritaires, rejoignaient Paul Cassia lorsque cette décision a été prise. Pour autant, en tant qu'institution, en tant que juridiction, le Conseil constitutionnel a considéré que cette loi était globalement valide. Cet extrait invite à s'attarder sur une exception notable. Le juge constitutionnel considère en effet que l'article de la loi soumise à son contrôle « relatif à l'accès des directeurs d'établissements scolaires à des données de santé concernant les élèves » n'est pas conforme à la Constitution.

I. La défense du droit à la vie privée opérée par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel effectue une défense générale du droit à la vie privée **(A)**, tout en précisant l'application de ce droit fondamental en ce qui concerne le droit des données **(B)**.

A. La défense générale du droit à la vie privée

Le Conseil constitutionnel estime que la mesure attaquée est susceptible de porter atteinte à l'égalité d'accès à l'instruction de tous les usagers du service public de l'éducation (Considérant 34). Néanmoins, ce n'est pas sur ce fondement qu'il s'appuie le plus. En effet, il considère que l'article 9 de la loi attaquée est contraire à la Constitution en ce qu'il ne respecte pas le droit à la vie privée tel qu'il est protégé par la Constitution.

Après avoir constaté la présence de l'argument de l'irrespect du droit à la vie privée dans la saisine des députés comme celle des sénateurs requérants, le Conseil constitutionnel rappelle que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen « implique le droit au respect de la vie privée. » Cette disposition prévoit plus précisément que : « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. »

Si le Conseil constitutionnel a d'abord considéré que le droit à la vie privée constituait une liberté individuelle, le rattachant *ipso facto* à l'article 66 de la Constitution **(décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité)**, il a ensuite rattaché ce droit cardinal à l'article 2 de la Constitution **(décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, loi portant création d'une couverture maladie universelle)**. Ce raisonnement se retrouve depuis lors dans la jurisprudence constante du Conseil de Montpensier.

B. La défense du droit à la vie en ce qui concerne le droit des données

Le juge constitutionnel français a, en ce qui concerne la protection des données, émis quelques précisions. Il estime que : « la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif » **(décision n° 2012-652 DC du 22 mars 201, loi relative à la protection de l'identité)**.

La décision ici étudiée se place donc dans le droit fil de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en ce qui concerne le droit à la vie privée dans le domaine de l'utilisation des données (considérant 35). Il précise que cette question concernant des données médicales d'individus le plus souvent mineurs, une attention doit être portée

à la proportionnalité des mesures soumises à son contrôle (considérants 32 et 35). Cette protection particulière se place également dans la continuité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel **(décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, loi portant création d'une couverture maladie universelle)**.

II. L'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée de l'article 9

Le Conseil constitutionnel estime que le but de l'atteinte à la vie privée n'est pas assez précisément défini **(A)**. Au surplus, la loi contrôlée ne prévoit pas suffisamment de garanties pour limiter l'atteinte à la vie privée **(B)**. Le Conseil de Montpensier estime par conséquent que l'atteinte au droit à la vie privée qu'il constate n'est pas proportionnée ; et que par suite, la loi est invalide.

A. La trop faible précision du but recherché par l'atteinte au droit à la vie privée

Le Conseil constitutionnel considère que le but recherché par cette loi est légitime (considérant 36). Son objectif est en effet de concilier le droit à la vie privée avec l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, le second réduisant le premier pour lutter contre l'épidémie de covid (considérant 37).

Aussi, le Gouvernement estime dans ses observations sur la loi auprès du Conseil constitutionnel, que ; « il a en outre entendu favoriser le maintien de l'ouverture des établissements scolaires des premier et second degrés et des classes qu'ils comportent. »

Toutefois, le Conseil constitutionnel considère que le but recherché n'est pas assez précisément défini (considérant 40).

De plus, le Conseil constitutionnel constate que la collecte des données vaccinales par les directeurs d'établissements scolaires n'est pas conditionnée à l'accord des élèves s'ils sont majeurs ou de leurs représentants légaux s'ils sont mineurs (considérant 38). Il considère, dans le droit fil de sa jurisprudence constante sur ce sujet, que cette disposition est donc anticonstitutionnelle **(décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, précitée)**.

B. L'insuffisance des garanties prévues par la loi pour limiter l'atteinte au droit à la vie privée

Au surplus, la collecte des données n'est pas encadrée par des garanties suffisantes pour la limiter aux directeurs d'établissements. Autrement dit, elle n'est pas limitée à ce que le législateur estime utile pour lutter efficacement l'épidémie de covid-19, à ce que le législateur considère comme nécessaire pour atteindre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé (considérant 39). Le juge constitutionnel fait donc ici application d'un principe, celui de proportionnalité, très important en droit public français, qui se répète très souvent, en de multiples lieux de sa jurisprudence.

Après avoir examiné la loi n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021, le Conseil constitutionnel estime que son article 9 n'est pas conforme à la Constitution, car il constitue une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée (considérants 41 et 42).

Le Conseil constitutionnel effectue ici, classiquement, un contrôle de proportionnalité, soit un contrôle très approfondi. Il ne considère pas que les libertés existent chacune en vase clos. Il ne fait pas montre de considérer que chaque liberté est infinie. Il accepte que des atteintes à ces libertés puissent intervenir puissent exister si elles sont justifiées. Il met en balance toutes les normes de référence du contrôle de constitutionnalité des lois afin de proposer la meilleure et la plus effective protection aux citoyens. Ici, bien qu'il ait souvent considéré que les législations adoptées pour lutter contre l'épidémie de covid-19 soient constitutionnelles, il fixe une limite claire. Il défend le droit à la vie privé dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire.

Sujet 3 : Argumentation

Soutenez que l'état d'urgence sanitaire est une atteinte justifiée aux libertés fondamentales

La crise sanitaire causée par l'épidémie de covid-19 a engendré l'adoption d'une série de politiques publiques de santé très importantes. La plus marquante est l'adoption d'un état exorbitant du droit commun inédit : **l'état d'urgence sanitaire.**

Celui-ci, et plus généralement, toutes les mesures prises dans son cadre ont été très souvent très critiqués au sein de la société française. Les uns dénonçant la verticalité du pouvoir exécutif, qui prenait dans les faits des décisions importantes en Conseil de défense, organe irresponsable devant la représentation nationale. Les autres vilipendant, entre autres choses et à la suite du philosophe Michel Foucault, la mise en place d'un biopouvoir visant à contrôler les corps des citoyens. Ce mécontentement s'est caractérisé très concrètement en matière juridictionnelle. Le **juge des référés du Conseil d'État n'avait jamais reçu autant de demandes** de suspensions d'actes juridiques avant l'adoption des protocoles sanitaires qui se sont succédés en 2022.

La prolifération de critiques ne doit pas empêcher de voir les attraits de l'état d'urgence sanitaire pour préserver les libertés. En effet, cet état exceptionnel du droit a été adopté pour préserver la santé des Français, pour se rapprocher de l'objectif de valeur constitutionnelle de préservation de la santé (**Conseil constitutionnel, décision n° 90-287 DC du 16 janvier 1991, Santé publique et assurance sociale)**.

La défense et la promotion des libertés fondamentales incitent à une critique constante du droit positif afin que celui-ci s'améliore continuellement ; et l'état d'urgence sanitaire peut faire l'objet de critiques. Néanmoins, il a aussi des vertus. Il est possible de dire que les atteintes à certaines libertés, celle d'aller et venir par exemple, étaient justifiées pour préserver les libertés de manière générale. En effet, la logique de conciliation propre aux libertés fondamentales ne peut pas s'appliquer de la même manière en tout temps. Il était nécessaire de la transformer face à un évènement aussi imprévisible et important que l'épidémie de covid-19 **(I)**. C'est pour cette raison que les limitations à l'exercice de certaines libertés dues à l'application de l'état d'urgence sanitaire ont globalement été considérées comme valides par toutes les institutions ayant une compétence en France **(II)**.

I. La nécessaire évolution du régime d'application des libertés fondamentales pour préserver le droit à la vie face à l'épidémie de covid

Les libertés fondamentales reposent sur une logique de conciliation qui évolue avec le temps et les conditions que celui-ci porte avec lui **(A)**. L'état d'urgence sanitaire se justifie en faisant primer le droit à la vie, principe de valeur constitutionnelle, et l'objectif de valeur constitutionnelle de préservation de la santé dans les conditions particulières de l'épidémie de covid **(B)**.

A. L'état d'urgence sanitaire comme une reconfiguration de la logique de conciliation des libertés fondamentales

Le principe de conciliation de différentes libertés fondamentales apparaît dans la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel.

Cette logique n'est pas universelle, elle est située. Elle l'est dans l'espace puisque chaque État opère celle qu'il estime juste. Elle l'est également dans le temps. En effet, les libertés fondamentales évoluent. Leurs conceptions, les modalités de leur mise en place évoluent en fonction des époques. Parler de liberté d'expression à la Révolution française n'implique pas la même chose qu'aujourd'hui, à l'heure de la radio, de la télévision et des réseaux sociaux... Dans le même sens, face à un péril très grand, l'état du droit passe parfois dans une phase exceptionnelle ; une parenthèse s'ouvre alors, l'exercice des droits fondamentaux se réduit pour un moment afin de surmonter le péril. Montesquieu expliquait qu'il valait mieux, parfois, mettre « un voile » sur les libertés, pour un moment, afin de les préserver plus tard, lorsqu'un péril peut les abattre, les mettre à mal définitivement.

Pendant ces périodes extraordinaires, la conciliation entre les droits est complètement transformée. Par exemple, lors de l'application de l'état d'urgence, la sécurité prime sur tout autre droit ou liberté fondamentale (V. par exemple sur sujet : **Conseil constitutionnel, décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985, loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances**).

De manière analogue, face à un péril sanitaire, lorsque la santé publique est menacée, que la vie de chacun, surtout celle des plus fragiles, est en proie à une épidémie, le droit change, il évolue. Il fait primer le droit à la vie et l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé (V. par exemple sur ce sujet : **Conseil constitutionnel, décision n° 2021-828 du 9 novembre 2021, loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire**).

B. La primauté du droit à la vie et de l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé

Le droit à la vie de manière générale, et très souvent, de manière plus précise, l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, ont primé dans leur conciliation avec les autres libertés et droits garantis par la Constitution.

On peut observer cela à travers une multitude d'exemples. Le plus éloquent, le plus évident est la liberté d'aller et venir ; et ce, dès l'adoption de la **loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19**. La liberté de circulation a été considérablement obérée pendant les confinements. Elle était en pratique presque inexistante pendant les périodes de confinement. Il s'agissait d'un cas parmi d'autres. Par exemple, la **Commission nationale consultative des droits de l'homme** a considéré que l'état d'urgence sanitaire avait causé une interruption presque totale de l'activité de l'institution judiciaire (V. par exemple la **Déclaration sur l'état d'urgence sanitaire [D-2020-7] du 26 novembre 2020**).

L'état d'urgence sanitaire, de par sa matière, son contenu, est donc une atteinte justifiée aux libertés fondamentales. Il demeure critiquable à propos de son opportunité, des modalités parfois jugées excessives de son application. À ce sujet le Conseil constitutionnel a plusieurs fois rappelé l'obligatoire proportionnalité des mesures adoptées sur le fondement de l'état d'urgence sanitaire (V. par exemple sur ce sujet : **Conseil constitutionnel, décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, loi relative à la gestion de la crise sanitaire)**. Néanmoins, l'état d'urgence sanitaire n'est pas infondé, totalement irrationnel. Il est bel et bien justifié. C'est sans doute pour cela qu'il a été validé par les institutions tant politiques que juridictionnelles ayant une compétence en France.

II. La validité de l'état d'urgence sanitaire du point de vue des juridictions

Les institutions politiques **(A)** et juridictionnelles **(B)** ont considéré que l'état d'urgence et les mesures prises sur son fondement sont valides.

A. La validité de l'état d'urgence sanitaire pour les institutions politiques

Les institutions politiques ont décidé de mettre en place l'état d'urgence, de le proroger, de l'appliquer d'une façon et non point d'une autre. Elles considèrent que cet état du droit est une atteinte justifiée aux libertés fondamentales, telles qu'elles s'appliquent en période ordinaire.

On peut observer cette chronologie :

- du 22 mars 2020 au 10 juillet 2020 : État d'urgence sanitaire
- du 11 juillet 2020 au 16 octobre 2020 : Régime transitoire de « sortie de l'état d'urgence sanitaire »
- du 17 octobre 2020 au 1er juin 2021 : État d'urgence sanitaire
- du 2 juin 2021 au 31 juillet 2022 : Régime transitoire (plus ou moins restrictif avec possibilité pour le Gouvernement d'activer des mesures de restrictions des libertés pour lutter contre l'épidémie)

Aussi, l'appréciation de l'opportunité d'une telle mesure est considérée comme le monopole des institutions politiques. Le Conseil constitutionnel a considéré en ce sens qu'il ne « dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement » et qu'il ne pouvait donc pas « remettre en cause l'appréciation par le législateur » sur le risque de propagation de l'épidémie de covid, la situation de fait justifiant l'application de l'état d'urgence sanitaire (**Conseil constitutionnel, décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021, loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire)**. Il avait déjà expliqué auparavant qu'en ce qui concerne le jugement de l'opportunité d'une mesure liée à des connaissances scientifiques, « il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature

que celui du Parlement de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances, les dispositions prises par le législateur » (Conseil constitutionnel, décision n° 2015-480 QPC du 17 septembre 2015, Association Plastics Europe).

Au-delà de son opportunité, la validité de l'état d'urgence sanitaire a de plus été reconnue par les juridictions ayant une compétence en France.

B. La validité de l'état d'urgence sanitaire pour les juridictions

Des juridictions supranationales, européennes pour être plus précis, ont considéré que l'état d'urgence sanitaire était valide par rapport aux normes de référence contenues dans leur office. C'est également le cas des juridictions françaises.

1. La validité de l'état d'urgence du point de vue des juridictions supranationales

L'Union européenne a joué un rôle de coordination des mesures, prises par les États membres, équivalentes à l'état d'urgence sanitaire (V. sur ce sujet : **Règlement 2021/953 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2021)**. Aucune de ces institutions n'a considéré que cet état du droit particulier était inconventionnelle. Elles ont donc considéré que cet état du droit était une atteinte justifiée aux libertés fondamentales.

Par exemple, le Tribunal de première instance de l'Union européenne a de plus considéré que ce texte était valide **(affaire T-710/21 Roos c/Parlement, 27 avril 2022)**.

Par ailleurs, les organes du Conseil de l'Europe ont accepté que **l'article 15 de la CEDH** s'applique pendant l'état d'urgence sanitaire (V. par exemple sur ce sujet : **CEDH, 13 avril 2021, Terheş contre Roumanie, n° 49333/20**). Cet article dispose que :

« En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. »

2. La validité de l'état d'urgence du point de vue des juridictions nationales

Les juridictions françaises, sauf quelques dispositions particulières, ont globalement considéré que l'état d'urgence sanitaire était valide. Elles ont donc considéré que cet état du droit était une atteinte justifiée aux libertés fondamentales.

On peut l'observer dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel (V. décisions précitées). On peut également le voir dans celle du Conseil d'État. Par exemple, dans le refus de suspendre l'écrasante majorité des mesures prises sur le fondement de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre des procédures de référés (V. par exemple sur ce sujet : Conseil d'État, 4 mars 2022, *[11 requêtes jointes] Mme V. G. et autres*). Cette acceptation de l'état d'urgence sanitaire peut également se lire dans les arrêts rendus par la Cour de cassation (V. pour un panorama général de cette question le discours de Madame la Première présidente de la Cour de cassation Chantal Arens, lors du colloque « La justice face à la crise sanitaire » du 3 mai 2021).

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2022

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 2 – Le droit au respect de la vie privée

1. Dissertation
2. Commentaire
3. Argumentation

1. DISSERTATION

La protection du droit à la vie privée

2. Commentaire

CEDH, 20 janvier 2020, Breyer c/Allemagne (extraits)

73. La Cour rappelle que la vie privée est un terme large non susceptible d'être défini de manière exhaustive.

(…)

79. La Cour reconnaît que, lorsqu'elle met en balance l'intérêt de l'État défendeur à protéger sa sécurité nationale par des mesures de surveillance secrète et la gravité de l'ingérence dans le droit d'un requérant au respect de sa vie privée, les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation dans le choix des moyens pour atteindre l'objectif légitime de protection de la sécurité nationale.

(…)

81. [...] la Cour réaffirme que le simple stockage de données relatives à la vie privée d'un individu constitue une ingérence au sens de l'article 8 de la Convention (Leander c. Suède, 26 mars 1987, § 48)

(…)

86. (…) la Cour accepte l'argument du gouvernement selon lequel l'ingérence poursuivait les objectifs légitimes de sécurité publique, de prévention des troubles ou de la criminalité et de la protection des droits et libertés (…)

88. Une ingérence sera considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » pour un objectif légitime si elle répond à un « besoin social impérieux » et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi. La Cour constate que la lutte contre la criminalité, et en notamment contre la criminalité organisée et le terrorisme [...], le maintien de la sécurité publique et la protection des citoyens constituent des « besoins sociaux impérieux » [...]. Elle reconnaît également que les moyens modernes de télécommunications et les changements dans la manière de communiquer exigent que les outils d'investigation des services de police et les organes de sécurité nationale soient adaptés.

(…)

92. que seul un ensemble limité de données a été stocké. Ces données ne comprenaient pas d'informations très personnelles ou permettant la création de profils de personnalité ou le suivi des mouvements des abonnés à la téléphonie mobile. En outre, aucune donnée concernant des événements de communication individuels n'a été stockée. (...)

95. En résumé, la Cour conclut que l'ingérence était, sans être insignifiante, d'une nature plutôt limitée. (...)

108. (...) les États membres disposent d'une certaine marge d'appréciation dans le choix des moyens d'atteindre les objectifs légitimes de protection de la sécurité nationale et de lutte contre la criminalité, que l'Allemagne n'a pas dépassée dans le cas présent.

109. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que le stockage des données à caractère personnel des requérants par leurs fournisseurs de services respectifs en vertu de l'article 111 de la loi sur les télécommunications (...) était proportionné et donc « nécessaire dans une société démocratique. »

110. Il n'y a donc pas eu de violation de l'article 8 de la Convention

3. ARGUMENTATION

Soutenez que la protection des données est aujourd'hui capitale pour assurer le droit au respect de la vie privée

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2022

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 2 – Le droit au respect de la vie privée
Corrigés

1. Dissertation
2. Commentaire
3. Argumentation

Sujet 1. Dissertation

La protection du droit à la vie privée

La vie privée fait partie des droits fondamentaux les plus importants. Que seraient en effet les autres libertés, les autres droits de l'homme sans celui-ci ? Sans vie privée, exposés à une transparence absolue de tous les aspects de leur vie, les individus sont épiés sans cesse, surveillés sans fin. Ils agissent et exercent tous leurs autres droits en sachant qu'ils ne sont jamais tout à fait seuls ; autant dire qu'ils ne les exercent plus effectivement, voire plus du tout. Affirmer un droit à la vie privée revient à affirmer qu'il existe toujours un espace préservé, libre de toute incursion extérieure pour chaque homme, pour toutes les femmes, un lieu où tout un chacun peut se développer comme l'entend, loin du fracas et du bruit de la vie publique. Le Doyen Jean Carbonnier expliquait que protéger le droit à la vie privée, revient à protéger la « sphère secrète de vie d'où [une personne] aura le pouvoir d'écarter les tiers. »

Ce principe fondamental est une constante de l'histoire des droits fondamentaux. Au cours des dernières décennies, le développement des nouvelles technologies de télécommunication a placé de nouveaux périls pour le respect du droit à la vie privée. Les révélations de lanceurs d'alerte tels que Julian Assange ou Edward Snowden ont en effet montré comment le développement de ces technologies, le développement de géants du numérique aux moyens colossaux, et les velléités de services secrets de nombreux États, ont permis la mise en place de systèmes de surveillance généralisée des individus.

Les conditions d'application du droit au respect à la vie privée ont donc changé. Il est intéressant de les observer en se demandant si la protection actuelle du droit à la vie privée permet son application effective ?

Le droit à la vie privée cherche à protéger la vie intime. Il est difficile à définir précisément, car sa matière est en constante expansion, face aux évolutions du temps présent, elle ne peut être circonscrite par quelques bornes définitivement énoncées **(I)**. Cette dimension de la vie privée bénéficie d'une forte protection juridique **(II)**.

I. L'expansion continuelle de la matière du droit à la vie privée pour protéger l'intimité

Il apparaît que le droit à la vie privée est un principe intrinsèquement en extension **(A)**. Cela l'a logiquement fait croître au fur et à mesure du temps **(B)**.

A. Un principe intrinsèquement en extension

Dans son arrêt **du 29 avril 2022, Pretty contre Royaume-Uni, la CEDH** considère que le droit à la vie privée n'est pas enfermable dans une décision arrêtée. En effet, la notion de vie privée, laquelle même

est l'objet du droit ici étudié, est selon le juge de Strasbourg « large, non susceptible d'une définition exhaustive. »

Dès lors que la définition de la vie privée n'est pas exhaustive, le droit qui la protège peut s'étendre à l'infini. S'il peut se définir comme celui qui préserve la sphère intime de chacun, tant son rapport à lui-même que dans ses relations avec autrui, le droit à la vie privée est toujours susceptible d'évoluer, de s'étendre continuellement.

En ce sens également, la CEDH interprète la CESDH « à la lumière des conditions de vie actuelles » (**CEDH, 25 avril 1978, Tyrer contre Royaume-Uni**). Les conditions de vie actuelles différant de celle du passé, l'interprétation de l'étendue du droit à la vie privée change. De nouveaux espaces jusqu'alors inconnus, par exemple les espaces déterritorialisés d'internet, sont découverts et exposent de nouveaux risques contre le respect du droit à la vie privée. Celui-ci s'étend alors par les réformes normatives ainsi que par les interprétations évolutives de la jurisprudence.

B. L'extension de la vie privée

Le droit à la vie privée s'est continuellement étendu.

Parmi d'autres éléments de protection de la vie privée, le Code pénal protège le droit à l'image (**Code pénal, article 226–1**). On ne peut donc pas jeter en pâture l'image d'un individu, révélant tel ou tel aspect de sa vie privée au grand jour. Un grand nombre d'arrêts condamne des titres de la presse dite *people* pour ce genre de révélations (V. sur la publication d'images des compagnes d'un président de la République : **TGI Paris, 4 septembre 2012, Valérie Trierweiler contre VSD ; V. aussi Trib. Corr. Nanterre, 2 septembre 2014, J Gayet c/Closer**).

Très récemment, le Conseil constitutionnel a estimé qu'à tout dispositif de surveillance policière, doit être associé des garanties nécessaires pour assurer qu'il n'y ait pas d'atteintes à la vie privée, disproportionnées par rapport aux buts, s'ils sont légitimes et nécessaires, poursuivis par cette surveillance (**Conseil constitutionnel, décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, Loi pour une sécurité globale***)*.

La jurisprudence de la CEDH est particulièrement éclairante sur l'extension du droit à la vie privée. On peut citer, parmi d'autres, quelques aspects de la défense du droit à la vie privée assurée par la Cour de Strasbourg :

- La protection des correspondances **(2 août 1984, Malone c/Royaume-Uni)**
- L'intégrité physique et morale de la personne **(26 mars 1985, X et Y c/Pays-Bas)**
- La liberté de la vie sexuelle **(26 mars 1985, X et Y c/Pays-Bas)** dans les limites de la loi
- La protection du **domicile (24 novembre 1986, Gillow contre Royaume-Uni)**

- Le droit à l'identité en général **(2 février 1994 Burghartz c/Suisse)** (incluant notamment un droit à l'identité sexuelle **(11 juillet 2002 Christine Goodwin c/Royaume-Uni)**

On peut ajouter, parmi les grandes évolutions du droit à la vie privée, que le développement du numérique a fait grandir le domaine du droit à la vie privée. Tant le **RGPD** que la loi **informatique et liberté du 6 janvier 1978** énoncent clairement que la réglementation du numérique qu'ils assurent est faite pour protéger les droits fondamentaux, et particulièrement le droit à la vie privée.

II. La forte protection juridique du droit à la vie privée pour protéger l'intimité

La protection du droit à la vie privée est forte juridiquement, en plus d'être particulièrement étendue. En effet, il s'agit d'un principe *erga omnes* **(A)** qui s'appuie sur des sources placées haut dans la hiérarchie des normes **(B)**.

A. Un principe *erga omnes*

La Cour de cassation énonce très clairement que : « [T]oute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée » (**Cass. Civ. 1, 23 octobre 1990, numéro 89–13.163**). Il est donc clair que le droit à la vie privée n'est pas le privilège de quelques-uns. Il constitue un principe *erga omnes*. Toute personne a le droit de voir sa vie privée respecter et de demander réparation des préjudices subis si ce n'est pas le cas.

Ce droit est intimement lié à la personne qui en jouit. Aussi, il s'éteint avec le décès de celle-ci (V. sur ce sujet : **Cour de cassation, Première chambre civile, 14 décembre 1999 ;** V. aussi : **CEDH, 15 mai 2006, Mortensen contre Danemark**). Le droit à la vie privée apparaît ainsi comme un principe universel en ce qu'il est rattaché intrinsèquement à chaque personne vivante.

B. La place importante des sources du droit à la vie privée dans la hiérarchie des normes

La protection de la vie privée est possible, car le droit qui la porte possède des sources à tous les niveaux de l'ordre juridique.

- Au niveau constitutionnel : le Conseil constitutionnel estime que le droit à la vie privée se déduit de l'**article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, loi portant création d'une couverture maladie universelle)**
- Au niveau conventionnel, le droit à la vie privée est consacré :
    - à l'**article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme**,
    - à l'**article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques**,

- à l'**article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme**,
- à l'**article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne**

- Au niveau législatif : **l'article 9 du Code civi**l prévoit que « *chacun a droit au respect de sa vie privée* ».

L'ensemble de ces dispositions participe d'une protection effective du droit à la vie privée. Si elle n'est pas parfaite, étant parfois battue en brèche devant la puissance de certains faits, elle n'est pas pour autant inexistante, ni même ineffective.

SUJET 2. COMMENTAIRE

CEDH, 20 janvier 2020, Breyer c/Allemagne (extraits)

Le droit à la vie privée est principe fondamental et très ancien. Il est en France déduit de **l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (Conseil constitutionnel, décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, loi portant création d'une couverture maladie universelle)**. Si le principe de ce droit a une force constante, les conceptions qui rendent son exercice effectif évoluent nécessairement avec le temps ; les conceptions et l'effectivité de la vie privée au XVIIIe siècle ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui.

Pareillement, bien que cela soit dans une moindre mesure, **l'article 8 de la CEDH** dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Néanmoins, entre 1950, date de l'adoption de la convention, et aujourd'hui, les conditions de vie ont changé. Le développement des technologies de communications moderne a radicalement changé les conditions d'exercice effectif du droit à la vie privée.

De plus, aujourd'hui comme hier, et ce dans tous les États membres du Conseil de l'Europe et parties à la CESDH, le droit à la vie privée, comme tous les autres droits fondamentaux, n'est pas absolu. Il doit justement se concilier avec les autres droits fondamentaux, notamment avec le droit à la sécurité avec les objectifs de préservation de l'ordre public et des infractions pénales, particulièrement les actes terroristes.

Dans le cas ici étudié, il faut constater que l'Allemagne possède une législation sur les télécommunications, adoptée en 2004 et réformée substantiellement en 2007. Elle permet d'exiger des opérateurs de téléphonie mobile de collecter et de conserver des données personnelles d'utilisateurs de carte sim prépayées dans le but de protéger la sécurité nationale allemande et de prévenir des infractions pénales, des troubles à l'ordre public et des actes de terrorisme. Cette législation a été considérée comme conforme à la loi fondamentale allemande par la Cour

constitutionnelle allemande dans un arrêt du 24 janvier 2012. La juridiction de Karlsruhe estime que cette mesure est une atteinte justifiée au droit à la vie privée. En effet, elle poursuit un but légitime et est proportionnée pour y arriver.

La même question arrive devant le juge de Strasbourg. Les juges européens doivent répondre à la question de savoir si l'obligation allemande de collecter et conserver les données des utilisateurs de cartes sim prépayées est valide par rapport à la CESDH ?

I. La défense du droit à la vie privée opérée par la Cour

La CEDH opère une défense du droit à la vie privée en adoptant une définition large de celle-ci **(A)** ainsi qu'en définissant de manière large, également, des atteintes au droit à la vie privée **(B)**.

A. Une définition large de la vie privée

La CEDH adopte une définition qu'elle dit « non-exhaustive » de la vie privée (§73). Elle réitère ici sa jurisprudence constante. Les juges de Strasbourg avaient déjà considéré que la vie privée était une notion « large » qui ne peut pas être définitivement circonscrite dans leur jurisprudence **du 29 avril 2002, Pretty contre Royaume-Uni**.

Il faut aussi constater que la Cour européenne des droits de l'homme estime que, si le droit à la vie privée repose sur l'article 8 de la CESDH pour tous les États membres, en l'absence d'évidence interprétative ou de consensus parmi ces derniers, chaque État membre possède des marges d'interprétation (§§79 et 108). La définition du droit à la vie privée est donc labile, elle fluctue pour partie au gré des changements de territoire, n'est pas exactement la même à Paris, Berlin, Rome ou Budapest. Le droit à la vie privée s'applique de manière spécifique à chaque État. Cette adaptation permet, au moins en théorie, une effectivité plus grande de ce droit.

B. Une définition large des atteintes à la vie privée

En plus de définir le droit à la vie privée de manière large, la CEDH définit les atteintes à celui-ci de manière large ; sa conception n'en est que plus étendue. En effet, elle n'est « que le simple stockage de données relatives à la vie privée d'un individu constitue une ingérence au sens de l'article 8 de la Convention. » (§81). Ce principe est bien installé dans la jurisprudence de la CEDH. En effet, elle l'avait déjà affirmé dans son arrêt **Leander contre Suède (26 mars 1987**). Elle montre que la CEDH adopte une vision large de ce qu'est une atteinte au droit à la vie privée.

Dans la conception de la CEDH, l'intention pour laquelle une altération au droit à la vie privée n'importe donc pas. Une atteinte est toujours considérée comme une atteinte. Pour autant, elle n'est

pas toujours considérée comme une inconventionnalité. En effet, pour savoir si une atteinte est conforme à la CESDH ou non, la CEDH vérifie que le but que cette même atteinte poursuit soit justifiée et que l'atteinte en question soit proportionnée.

II. La validité des atteintes justifiées et proportionnées au droit à la vie privée

Les atteintes au droit à la vie privée sont conformes à la CEDH si elles sont justifiées **(A)** et proportionnées **(B)**.

A. La validité des atteintes justifiées au droit à la vie privée

La CEDH cherche si l'atteinte qu'elle constate est justifiée ou non afin de pouvoir trancher sur la licéité des législations allemandes sur les télécommunications. Elle considère que la collecte de données ici observée est réalisée pour des objectifs légitimes, à savoir les objectifs de « sécurité publique, de prévention des troubles ou de la criminalité et de la protection des droits et libertés » (§86).

La Cour reprend ici un principe très classique en droit des libertés fondamentales. Elle applique la première étape de tout contrôle de proportionnalité : la mesure était-elle nécessaire. Il s'agit d'un principe très ancré dans la jurisprudence de la CEDH (V. sur ce sujet : **CEDH, 23 juillet 1968, Affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique c. Belgique**).

Plus précisément, la CEDH considère que l'atteinte au droit à la vie privée doit être « nécessaire dans une société démocratique » en ce qu'elle répond à un « besoin social impérieux, » ce qui est le cas de la collecte et de la préservation de données personnelles que le juge strasbourgeois analyse (§88).

Elle applique en cela clairement **l'article 8.2 de la CESDH**, qui dispose que : « il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

Le juge européen ne s'arrête pas là dans son contrôle de proportionnalité.

B. La validité des atteintes proportionnées à la vie privée

Le juge européen constate que les atteintes au droit à la vie privée sont « limitées » et qu'elles ne contenaient pas « d'informations très personnelles. » Il estime aussi que le stockage et l'utilisation des données de communication étaient très limités (§92). « La Cour conclut [donc] que l'ingérence était,

sans être insignifiante, d'une nature plutôt limitée. » Par conséquent, elle conclut que la législation allemande sur les télécommunications est conforme à l'article 8 de la CESDH (§110).

Si elle constitue une atteinte au droit à la vie privée, elle poursuit de manière proportionnée un but légitime et « nécessaire dans une société démocratique » (§109). Il faut d'ailleurs remarquer que la CEDH protège les conditions nécessaires à la préservation d'une société démocratique dans sa jurisprudence constante (V. une affaire marquante sur ce sujet : **Handsyde contre Royaume-Uni, 7 décembre 1976**). L'arrêt ici présenté montre que la limitation des atteintes au droit à la vie privée rendue possible par le contrôle de proportionnalité participe de la défense de cette société.

SUJET 3. ARGUMENTATION

Soutenez que la protection des données est aujourd'hui capitale pour assurer le droit au respect de la vie privée

L'importance des données dans la préservation du droit à la vie est très vite apparue en France, avec le développement des technologies numériques. En effet, le scandale qui fit suite au projet Safari (Système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus) – qui prévoyait le regroupement des fichiers administratifs de chacun des Français, a eu une conséquence politique importante : l'adoption de **la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés**, qui protège notamment la vie privée.

Plusieurs révolutions du numérique ont eu lieu depuis lors. La loi de 1978 est toujours en vigueur, et a été réformée, plusieurs fois, pour continuer d'être pertinente face aux évolutions constantes de la technologie, bien que cela soit difficile et que d'aucuns considèrent qu'elle est en permanence « en retard ». Cette loi a inspiré de nombreux autres pays, notamment en ce qui concerne l'apport le plus célèbre de la loi de 1978 : la création de la **CNIL**. EN effet, il existe des organes équivalents dans tous les États de l'Union européenne. Aussi, le **règlement européen du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel** a créé le Contrôleur européen de la protection des données. Celui-ci coordonne les différentes CNIL européennes grâce à des lignes directrices.

Le droit des données personnelles, comme tous les pans du droit du numérique, tombent vite en désuétude, car le législateur éprouve des difficultés à faire évoluer les lois aussi rapidement que l'innovation technologique avance. Le Doyen Jean Carbonnier expliquait d'ailleurs « il se peut qu'être en retard pour retarder l'inévitable soit une fonction instinctive du droit ». La loi de 1978 le montre assez bien.

Le droit des données ne se limite pour autant pas à elle. Il est très dynamique et comprend d'autres normes tant au niveau national qu'européen. La protection du droit à la vie privée dans l'utilisation des données est importante tant au niveau normatif (**I**) qu'au niveau organique (**II**).

I. La protection normative du droit à la vie privée dans l'utilisation des données

La protection normative du droit à la vie privée dans l'utilisation des données s'observe tant au niveau de la France **(A)** que de l'Union européenne **(B)**.

A. La protection normative française

La principale norme française protégeant les libertés fondamentales est **la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés**.

En effet, le premier article de cette législation dispose que : « **l'informatique** doit être mis au service du citoyen. » Il ajoute que, par voie de conséquence, il **ne doit pas « porter atteinte** ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, **ni à leur vie privée**, ni aux libertés individuelles ou publiques. »

On peut aussi lire parmi les dispositions de cette loi, à l'article 68 que : « le responsable d'un traitement [de données] ne peut transférer des données à caractère personnel vers un État n'appartenant pas à l [« Union européenne] que si cet État assure un **niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes** à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet. »

Il est donc possible d'observer de manière claire que la protection des données, au sein de la loi de 1978, participe de la protection du droit à la vie privée.

B. La protection normative européenne

Le niveau européen est souvent considéré comme le plus pertinent pour édicter des normes en matière numérique. En effet, les géants du secteur sont plus facilement à la force mise en commun des États membres de l'Union européenne plutôt qu'à leurs diligences dispersées. L'Union européenne a ainsi produit une série d'outils normatifs très importants pour protéger les droits fondamentaux dans le domaine numérique.

Le plus important de tous les textes européens pour faire respecter le droit à la vie privée dans l'utilisation des données est le RGPD.

Le § 4 de son exposé des motifs dispose que : « le traitement des données à caractère personnel devrait être conçu pour servir l'humanité. Le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu ; il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en

balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les traités, **en particulier le respect de la vie privée** et familiale, du domicile et des communications, la protection des données à caractère personnel, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'expression et d'information, la liberté d'entreprise, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et la diversité culturelle, religieuse et linguistique. »

Plus généralement, le RGPD repose tout entier sur une logique de *compliance*. Il fixe un but à tous les opérateurs, quels qu'ils soient, effectuant un traitement des données personnelles : respecter les droits fondamentaux, et notamment le droit à la vie privée. Tous ces opérateurs doivent se mettre en conformité, adopter tous les mécanismes nécessaires pour prévenir une atteinte à ces droits.

II. La protection organique du droit à la vie privée dans l'utilisation des données

La protection organique existe tant au niveau juridictionnel **(A)** qu'au niveau administratif **(B)**.

A. La protection juridictionnelle

La CEDH protège la vie privée en vertu de l'article 8 de la CESDH, qui dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » La Cour de Strasbourg reconnaît dans un arrêt ***Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande*** **(27 juin 2017)** que la protection des données personnelles joue un rôle important dans la protection des données.

La Cour de Justice de l'Union européenne s'inspire souvent de la jurisprudence de la CEDH. Par exemple, l'arrêt du **6 octobre 2020 (Quadrature du Net**), la CJUE s'inspire de l'arrêt de la **CEDH du 13 septembre 2018 (Big Brother Watch et autres c/Royaume-Uni**). Il en résulte que les dispositifs de surveillance des individus sur internet, qui capte leurs données personnelles pour parvenir à leur but, ne sont ni valides ni invalides en soi par rapport au droit de l'Union européenne. Ils sont valides s'ils sont assortis de garanties objectives et effectives pour éviter les abus attentatoires aux libertés fondamentales, notamment au droit à la vie privée, et qu'ils sont présents pour assurer un but licite, légitime et proportionné par rapport à cet objectif.

Au niveau national, le Conseil d'État vérifie que les actes de transpositions du droit de l'Union assurent un niveau de protection des libertés fondamentales équivalent à celui existant dans l'ordre interne français. Ce principe s'applique notamment en droit du numérique et en ce qui concerne la protection des données (**CE, 21 avril 2021, n° 393099, French Data Network**). Le Conseil d'État vérifie donc que le plus haut niveau de protection du droit à la vie privée soit assuré en France.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel est particulièrement attentif à la protection des données numériques. En ce sens, il a jugé que la plupart des dispositions de la loi de 1955 sur l'état d'urgence étaient conformes à la Constitution, sauf celles relatives aux données informatiques copiées à l'occasion d'une perquisition réalisée au cours de l'état d'urgence sans autorisation spécifique (**Conseil constitutionnel, décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, *Ligue des droits de l'homme***).

B. La protection administrative

Le Défenseur des droits, de par sa large compétence, protège le droit à la vie privée, et notamment en ce qui concerne l'utilisation des données personnelles.

Néanmoins, la principale autorité administrative pour protéger les données personnelles, et par-là le droit à la vie privée, est la CNIL. Elle a été instituée par la loi du 6 janvier 1978 précitée.

Plus précisément, **l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978** de cette loi prévoit que la CNIL est une autorité publique indépendante. Le même article dispose que la CNIL « promeut, dans le cadre de ses missions, l'utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données. »

Elle informe les particuliers et les opérateurs du numérique sur les façons d'utiliser des données dans le respect du droit à la vie privée. Elle émet des avis, publie des rapports informatifs, mène des contrôles pour vérifier la conformité aux règles ; et peut ensuite, émettre des recommandations, mettre en garde et user d'un pouvoir de sanctionner les opérateurs du numérique en infraction par rapport aux normes qu'elles protègent. C'est le principal organe d'application de la loi de 1978 et du RGPD. Elle joue un rôle important dans la protection du droit à la vie privée dans l'utilisation des données.

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2022

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 3 : La présomption d'innocence

1. Dissertation
2. Commentaire
3. Argumentation

SUJET 1. DISSERTATION

La présomption d'innocence comme principe structurant du procès en France

SUJET 2. COMMENTAIRE

Cass Civ 1, 6 janvier 2021, 19-21.718 (extraits)

5. Selon l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à un procès équitable et toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

6. Selon l'article 10 de cette Convention, toute personne a droit à la liberté d'expression, mais son exercice peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d'autrui pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

7. En vertu de l'article 9-1 du Code civil, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence. Une telle atteinte est constituée à condition que l'expression litigieuse soit exprimée publiquement et contienne des conclusions définitives tenant pour acquise la culpabilité d'une personne pouvant être identifiée relativement à des faits qui font l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, ou d'une condamnation pénale non encore irrévocable (1re Civ., 10 avril 2013, pourvoi n° 11-28.406, Bull. 2013, I, n° 77).

8. Le droit à la présomption d'innocence et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.

9. Cette mise en balance doit être effectuée en considération, notamment, de la teneur de l'expression litigieuse, sa contribution à un débat d'intérêt général, l'influence qu'elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et la proportionnalité de la mesure demandée (CEDH, arrêt du 29 mars 2016, Bédat c. Suisse [GC], n° 56925/08).

10. L'arrêt retient, d'abord, que, si le film retrace le parcours de trois personnes qui se disent victimes d'actes à caractère sexuel infligés par le prêtre en cause lorsqu'ils étaient scouts, fait état de la dénonciation de ces faits auprès des services de police et de la création d'une association rassemblant d'autres personnes se déclarant victimes de faits similaires et si, à la suite de plusieurs plaintes dont celles émanant des personnages principaux du film, M. X... fait l'objet d'une information judiciaire en cours au jour de sa diffusion en salles, ce film n'est cependant pas un documentaire sur le procès à venir et que, présenté par son auteur comme une œuvre sur la libération de la parole de victimes de pédophilie au sein de l'Église catholique, il s'inscrit dans une actualité portant sur la dénonciation de tels actes au sein de

celle-ci et dans un débat d'intérêt général qui justifie que la liberté d'expression soit respectée et que l'atteinte susceptible de lui être portée pour assurer le droit à la présomption d'innocence soit limitée.

11. L'arrêt précise, ensuite, que le film débute sur un carton indiquant « Ce film est une fiction, basée sur des faits réels », informant le public qu'il s'agit d'une œuvre de l'esprit et s'achève par un autre carton mentionnant « Le père X... bénéficie de la présomption d'innocence. Aucune date de procès n'a été fixée », que cette information à l'issue du film venant avant le générique, tous les spectateurs sont ainsi informés de cette présomption au jour de la sortie du film. Il constate, par motifs adoptés, que les éléments exposés dans le film étaient déjà connus du public. Il ajoute que l'éventuel procès de M. X... n'est pas même prévu à une date proche et qu'il n'est pas porté atteinte au droit de l'intéressé à un procès équitable.

12. Il énonce, enfin, que la suspension de la sortie du film jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale mettant en cause M. X... pourrait à l'évidence ne permettre sa sortie que dans plusieurs années, dans des conditions telles qu'il en résulterait une atteinte grave et disproportionnée à la liberté d'expression.

13. De ces constatations et énonciations, desquelles il résulte qu'elle a procédé à la mise en balance des intérêts en présence et apprécié l'impact du film et des avertissements donnés aux spectateurs au regard de la procédure pénale en cours, sans retenir que la culpabilité de l'intéressé aurait été tenue pour acquise avant qu'il ne soit jugé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux constatations invoquées par les première et quatrième branches et à la recherche visée par la septième branche qui ne lui avait pas été demandée, a déduit, à bon droit, que la suspension de la diffusion de l'œuvre audiovisuelle « Grâce à Dieu » jusqu'à ce qu'une décision définitive sur la culpabilité de celui-ci soit rendue constituerait une mesure disproportionnée aux intérêts en jeu.

14. Il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche et est inopérant en ses cinquième et sixième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi

SUJET 3. ARGUMENTATION

Soutenez que la présomption d'innocence est toujours d'actualité à l'ère du numérique

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2022

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 3 : La présomption d'innocence
Corrigés

1. Dissertation
2. Commentaire
3. Argumentation

Sujet 1. Dissertation

La présomption d'innocence comme principe structurant du procès en France

La présomption est une garantie procédurale. Elle apparaît au sein des procès en France. En effet, en principe, la personne demanderesse doit prouver ses dires afin de faire, si elle y parvient, condamner la personne défenderesse.

La présomption d'innocence était déjà défendue par la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle, notamment par Cesare Beccaria. Elle a été consacrée dès 1789 avec **l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen**, qui dispose que : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. »

La présomption d'innocence est aujourd'hui répandue partout dans le monde. Parmi d'autres exemples, on peut l'observer en Amérique du Nord (article 11 de la Charte des droits et libertés du Canada) et en Amérique du Sud (article 17 de la Constitution du Paraguay). On peut aussi le voir en Afrique (article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme) ou en Asie (article 27 de la Constitution coréenne).

La présomption d'innocence est aujourd'hui encore bien présente en France. Elle est capitale pour préserver l'État de droit en ce qu'elle empêche que la simple allégation d'un demandeur puisse priver de sa liberté une personne, puisse condamner une personne à une peine sans apporter de preuve. Elle apporte une rationalité et une justice à tout procès puisqu'à chaque fois qu'une condamnation, de la même manière qu'un acquittement, est prononcée, ce n'est pas au nom du qu'en-dira-t-on, de l'arbitraire, mais au nom d'une logique, d'un raisonnement reposant sur des preuves dûment présentées. La présomption constitue donc un principe structurant du procès en France.
La présomption d'innocence s'est érigée comme un guide structurant du procès en France, particulièrement du procès pénal, du fait de l'enjeu de privation de liberté qu'il peut entraîner avec lui. Il est reconnu au sein d'une multitude de sources, tant supranationales **(I)** que nationales **(II)**. Cette reconnaissance impose ce principe de manière forte et pérenne, fait de la présomption d'innocence un fil conducteur du procès en France.

I. Un principe structurant imposé par les sources supranationales

Tant au niveau mondial **(A)** qu'au niveau européen **(B)**, la présomption d'innocence est un principe structurant du procès.

A. Un principe structurant imposé au niveau mondial

La présomption d'innocence est imposée par des sources au niveau international. Bien qu'il ne soit pas contraignant juridiquement, **l'article 11.1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme** dispose que : « Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » Cela montre l'importance de ce principe au niveau mondial.

L'article 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui lui est contraignant au sein de l'ordre juridique français, dispose que : « Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »

On voit donc que les normes internationales font de la présomption d'innocence un principe structurant tous les procès, qui s'applique en principe dans chaque procédure juridictionnelle.

B. Un principe structurant imposé au niveau européen

La présomption d'innocence est protégée par la CESDH et par le droit de l'Union européenne. Tous les États membres du Conseil de l'Europe et à l'Union européenne doivent le respecter.
En effet, **l'article 6.2 de la CESDH** dispose que : « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » La **CEDH** (**6 décembre 1988, Barberà, Messegué et Jabardo c/Espagne)** a précisé que la présomption implique que :

- les juges n'aient pas d'idée « préconçue » quant à l'accusé,
- la charge de la preuve porte sur l'accusation
- le doute profite à l'accusé

Il apparaît donc que les préceptes de la CEDH quant à la présomption d'innocence contribuent à structure le procès au sein de tous les États parties à la CESDH, dont la France fait partie. Par exemple, si un individu est présumé innocent, il ne peut pas être obligé de s'accuser lui-même ; le droit de se taire se déduit donc de la présomption d'innocence (**CEDH, 17 décembre 1996, Saunders c/Royaume-Uni)**. Aussi, au sein de la CEDH, la présomption d'innocence s'applique de manière absolue en matière pénale, mais peut potentiellement accepter des exceptions dans d'autres matières, bien qu'elle demeure le principe applicable *ab initio* (**CEDH, 30 mars 2010, Poncelet c/France**)

De manière semblable, **l'article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne** dispose que : « 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. » La CJUE peut se fonder autant sur cet article que sur l'article 6.2 de la CESDH pour rendre ses décisions (V. par exemple : **CJUE, 13 juillet 2021, Romana Tabacchi c/Commission).**

En tant que principe miliaire des droits de la défense, la présomption d'innocence, telle qu'elle est protégée au sein de l'Union européenne, structure le procès dans tous les États membres, dont la France fait partie.

II. Un principe structurant imposé par les sources nationales

Bien qu'elle soit largement reconnue par les sources nationales **(A)**, en plus des sources supranationales, la présomption d'innocence connaît des limites **(B)**. Elle structure le procès en France de manière générale, mais pas de manière absolue.

A. La large étendue de la présomption d'innocence en France

Au niveau constitutionnel, **l'article 9 de la DDHC** consacre la présomption d'innocence (précitée). Le Conseil constitutionnel l'accepte parmi les normes de références du contrôle de constitutionnalité des lois **(décision n° 20-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes)**. De la même manière que la CEDH, il estime que la présomption d'innocence implique le droit de se taire **(décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016, Mme Sylvie T.)**.

Au niveau législatif, l'**article 9-1 du Code civil** dispose en ce sens que : « Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. — Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. »

Comme au niveau de la CEDH, le droit français concentre la protection de la présomption d'innocence sur l'ensemble des procès existants. En plus du volet civil, le Conseil d'État considère que la présomption d'innocence est une liberté fondamentale (**CE, ord. 14 mars 2005**, B. *Gollnisch*). Elle s'applique donc au sein du procès administratif. Cependant, la présomption d'innocence est plus importante dans la matière pénale. On peut le voir à **l'article 11 du Code de procédure pénale** et à **l'article 434-7-2 du Code pénal**. Néanmoins, il existe des limitations à la présomption d'innocence en France.

B. Les limites à la présomption d'innocence en France

Tout d'abord, la présomption d'innocence doit être conciliée avec d'autres principes. C'est souvent le cas avec les principes de liberté de presse et de liberté de diffusion publique d'informations. Ainsi, **la loi du 29 juillet 1881** sur la liberté de la presse encadre les publications pour assurer le respect de la présomption d'innocence. Par exemple, il est interdit de diffuser des informations donnant accès à un sondage d'opinion à propos de la culpabilité d'un accusé mise en cause « à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre ». Pour autant, la presse a le droit de mener des enquêtes. La présomption d'innocence est donc conciliée avec la liberté de la presse.

Dans un sens voisin, le Conseil constitutionnel estime que la présomption d'innocence doit être conciliée avec d'autres principes constitutionnels, par exemple avec l'objectif de valeur constitutionnelle « de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle » (**Conseil constitutionnel, décision n° 2 ° 1 °-25 QPC du 16 septembre 2010, M. Jean-Victor C**.).

Enfin, il existe quelques exceptions à la présomption d'innocence, en dehors du champ pénal. Ces présomptions de culpabilité ne doivent jamais porter sur des enjeux importants, sont réfragables, préservent les droits de la défense et portent sur des faits qui imputent très vraisemblablement la culpabilité à l'auteur des faits. Dans ces conditions la **CEDH** considère que ce dispositif est en accord avec la CESDH (**Salabiaku contre France, 7 octobre 1998).** Il en va par exemple ainsi des présomptions légales de culpabilité en matière de circulation.

SUJET 2. COMMENTAIRE

Cass Civ 1, 6 janvier 2021, 19-21.718 (extraits)

Les libertés fondamentales ne descendent pas du ciel, elles sont situées dans le temps et l'espace. Aussi, elles doivent constamment être mises en balance les unes par rapport aux autres afin de s'adapter aux conditions de vie d'une époque. Par exemple, l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé a plus pesé dans cette balance pendant l'état d'urgence sanitaire que pendant les périodes ordinaires. La présomption d'innocence ne fait pas exception à ce principe. Elle doit être conciliée avec d'autres principes. C'est ce à quoi s'applique la Cour de cassation dans l'arrêt ici étudié.

La Cour de cassation a en effet été saisie de l'affaire du film *Grâce à Dieu* de François Ozon. Ce film relate les révélations, l'action et l'association des victimes d'actes pédophiles de Bernard Preynat, lorsque ce dernier était prêtre dans la région lyonnaise. Puisqu'il est sorti avant que l'action pénale contre Bernard Preynat s'achève, le film arborait des avertissements aux spectateurs rappelant la présomption d'innocence de celui-ci et le caractère fictionnel du film. Néanmoins, le film raconte une histoire du point de vue des parties demanderesses d'une condamnation contre Bernard Preynat. Il expose donc ce dernier comme coupable des faits qui lui ont été reprochés, à travers les yeux de ceux qui seront reconnus plus tard comme ses victimes par le **Tribunal correctionnel de Lyon dans un jugement du 16 mars 2020**.

L'ancien prêtre a saisi le juge des référés du **Tribunal de grande instance de Paris** afin de suspendre la diffusion du film au motif du respect de sa présomption d'innocence. Le Tribunal n'a pas accédé à sa demande (**18 févr. 2019, n° 19/14/499**). La **Cour d'appel de Paris** a suivi le même chemin suite au recours de Bernard Preynat devant elle (**26 juin 2019, n° 19/03880**). Bernard Preynat s'est ensuite pourvu en cassation. La Cour du Palais a alors dû se demander quelle est la juste balance entre le respect du droit à la présomption d'innocence de Bernard Preynat et la liberté de diffusion d'une œuvre artistique, la liberté d'expression de son auteur ? Les juges de cassation ont estimé que la suspension de l'œuvre cinématographique serait disproportionnée par rapport aux intérêts en jeu. Ils rejettent donc le pourvoi. Il apparaît à la lecture de l'arrêt que la conciliation entre présomption d'innocence et liberté d'expression est *in abstracto* nécessaire, tout en étant impossible (I). Par voie de conséquence, la Cour de cassation indique que cette conciliation doit nécessairement être effectuée *in concreto* **(II)**.

I. Une impossible et pourtant nécessaire conciliation *in abstracto* entre présomption d'innocence et liberté d'expression

L'arrêt de la Cour de cassation montre que la conciliation entre la liberté d'expression et la présomption d'innocence est nécessaire **(A)**. Pour autant, la Cour montre aussi qu'en soi, *in abstracto*, cette conciliation est impossible **(B)**.

A. Une conciliation nécessaire *in abstracto* entre la liberté d'expression et la présomption d'innocence

La Cour de cassation ne fait pas un choix exclusif. D'une part, elle reconnaît l'importance de la présomption d'innocence (§5) en rappelant les principes contenus à l'**article 6.2 de la CESDH**, qui dispose que « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie », et de **l'article 9-1 du Code civil**, qui prévoit que « Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. — Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte ». La Cour rappelle aussi que la présomption d'innocence ne s'éteint que lorsque toute action juridictionnelle s'est éteinte (§6). Elle se place dans le droit fil de sa jurisprudence antérieure en affirmant que la présomption d'innocence s'appliquait de plein droit pour Bernard Preynat au moment des faits (§7) (**Cass Civ 10 avril 2013, n° 11-28.406**). Elle ne voit donc aucune erreur de droit dans l'ordonnance de la Cour d'appel de Paris.

D'autre part, la Cour de cassation affirme l'importance de la liberté d'expression en se fondant sur **l'article 10.1 de la CESDH**, qui dispose que : « toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. » (§6). En se fondant principalement sur les dispositions de la CESDH, la Cour de cassation se place dans le cadre d'un contrôle de conventionnalité qui porte sur les libertés fondamentales. Elle montre que dans une telle situation plusieurs droits et libertés fondamentaux apparaissent ; et que, rien ne permet de dire qu'un devrait s'appliquer tout entier plus qu'un autre. La liberté d'expression et la présomption d'innocence devant s'appliquer concomitamment, en soi, elles doivent *in abstracto* être conciliées.

B. Une conciliation impossible *in abstracto* entre la liberté d'expression et la présomption d'innocence

La conciliation entre la présomption d'innocence et la liberté d'expression doit être effectuée. Pour cela, il faut répondre à cette question : comment ? Avec quelles modalités cette conciliation doit-elle être conduite ?
La Cour de cassation note, en se fondant sur la CSDH, que la liberté d'expression et la présomption d'innocence ont la même valeur normative (§8). Elle réitère ici sa jurisprudence antérieure en la matière (**Cass Civ 1, 30 septembre 2015, n° 14-16.273**).

Dès lors que deux énoncés normatifs possèdent la même valeur, l'une ne s'impose pas par sa force prescriptive sur l'autre (et vice versa). Il n'est en soi pas possible de dire que la présomption d'innocence doit davantage s'appliquer que la liberté d'expression, totalement ou partiellement, et inversement. *In abstracto*, il n'est pas possible de mener de concilier la liberté d'expression et la présomption d'innocence. À l'inverse, la mise en balance de ces deux principes juridiques doit nécessairement s'opérer *in concreto*.

II. Une conciliation nécessairement *in concreto* entre la liberté d'expression et la présomption d'innocence

La mise en balance de la présomption d'innocence et de la liberté d'expression s'effectue *in concreto*. En ce sens, le juge de cassation proclame dans son arrêt que la juste application du droit implique pour les juges du fond de : « privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime » (§8). C'est ce qu'a fait la Cour d'appel de Paris. Apparaissent ainsi de la lecture de cet arrêt une voie, des critères pour concilier la liberté d'expression et la présomption d'innocence. Certains éléments apparaissent comme favorables à la liberté d'expression **(A),** alors que d'autres sont plus favorables à la présomption d'innocence **(B)**.

A. Les éléments favorables à la liberté d'expression

La liberté d'expression vaudra d'autant plus que :

- Le litige en question est important, qu'il contribue à l'intérêt général, par exemple par le débat et l'information qu'il apporte au public (§ 9). Cela rejoint la jurisprudence de la CEDH et la CESDH sur laquelle se fonde la Cour de cassation dans son arrêt (§10) **(CEDH, 29 mars 2016, Bédat c/Suisse)**.
- Que l'information diffusée est une fiction, qu'elle ne constitue pas une œuvre de reproduction de la réalité, comme un reportage ou un documentaire (§ 11). À nouveau, cet attendu du juge de cassation rejoint la jurisprudence de la **CEDH (24 mai 1988, Müller et a. c/Suisse)**.

C'est au nom de ces arguments que la Cour de cassation estime que l'ordonnance du juge d'appel n'est pas entachée d'erreur de droit. Elle note cependant que les éléments favorables à la liberté d'expression ne sont pas les seuls existants, ne sont pas les seuls à prendre en compte pour les juridictions de fond.

B. Les éléments favorables à la présomption d'innocence

La liberté d'expression est d'autant moins prise en compte que :

- les critères précédents ne sont pas remplis.
- qu'elle affecte substantiellement la procédure en cours (§ 12). La Cour de cassation se place ici encore dans la continuité de la CEDH **(29 mars 2016, Bédat c/Suisse)**.
- que la mesure demandée pour faire respecter la présomption d'innocence en réduisant la liberté d'expression soit proportionnée (§ 12 et §13). À nouveau, la Cour de cassation se place à la suite de la CEDH (29 mars 2016, Bédat c/Suisse) et d'un raisonnement très classique, celui de la proportionnalité, en matière de droits et libertés fondamentales.

SUJET 3. ARGUMENTATION

Soutenez que la présomption d'innocence est toujours d'actualité à l'ère du numérique

Les principes importants perdurent, sont fixes dans le temps, mais leurs conceptions évoluent avec le temps. Sans cette flexibilité, les principes s'éteignent, car ils ne réussissent pas à s'appliquer au bout d'un certain temps. En effet, un principe juridique existe véritablement uniquement lorsqu'il s'applique effectivement. Il prend véritablement corps à travers un régime juridique qui est adapté aux conditions de vie d'une époque.

La présomption d'innocence a été consacrée dès la Révolution française, à **l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen**, qui dispose que : « tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il appartient dorénavant aux normes de référence du contrôle de constitutionnalité.

La présomption d'innocence est donc consacrée par les normes les plus importantes au sein de la hiérarchie des normes en France. S'il s'agit d'un vieux principe, d'un principe séculaire, il est toujours d'actualité puisqu'il est toujours consacré. Néanmoins, est-il effectif ? Les conditions de vie actuelles ne sont plus les mêmes que lors de la Révolution française. La révolution des technologies de télécommunications, d'internet, des réseaux sociaux les a profondément transformées. Aussi, les conciliations nécessaires entre la présomption d'innocence et la liberté de diffusion des informations, notamment dans la presse, n'ont plus les mêmes conditions d'application sous l'ère du numérique qu'auparavant. Les conditions d'application actuelles de la présomption d'innocence soulèvent des enjeux neufs et très importants. Il est intéressant de montrer que la présomption d'innocence est donc toujours d'actualité, peut-être plus que jamais, à l'heure du numérique. Si elle est pertinente **(I)**, elle doit évoluer du fait de la révolution numérique **(II)**.

I. La pertinence de la présomption d'innocence à l'ère numérique

La pertinence de la présomption d'innocence demeure **(B)** malgré l'apparition de nouveaux enjeux du fait de la révolution numérique **(A)**.

A. Les enjeux nouveaux du numérique pour la présomption d'innocence

Le numérique soulève une multitude d'enjeux, parfois nouveaux, parfois anciens, pour la présomption d'innocence. Il n'est pas matière, ici, à les développer tous, pour peu qu'une telle démarche soit réalisable, mais de se concentrer sur deux qui retiennent particulièrement l'attention.

D'abord, la collecte ainsi que la conservation des données ont été considérablement accrues de par les technologies de télécommunications. Cette masse colossale de données associée à des technologies d'intelligence artificielle a rendu possible le développement de procédés de justice prédictive, qui n'existaient jusqu'alors qu'à l'état embryonnaire dans la réalité, reléguant les mécanismes développés aux œuvres de science-fiction. Néanmoins, l'existence d'une justice prédictive n'est plus uniquement l'objet des livres de Philip K. Dick. Elle est possible dans la réalité. Par essence, prévoir les comportements d'un individu a pour vocation de parvenir à savoir

s'il est resté dans le droit chemin ou s'il s'est rendu coupable d'une infraction. Comment affirmer encore la présomption d'innocence d'une personne si les algorithmes qui aident la Justice à décider montraient qu'elle a 99,99 % de chances d'avoir commis un méfait ?

La Justice française n'est pas parvenue à une telle extrémité. Néanmoins, elle adopte déjà quelques points d'aide à la décision de ce type (d'aucuns pensent que la mise à disposition de toutes les dispositions de Justice prévue par la **loi 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique** est une première vers la voie d'une justice prédictive en France). Elle doit et devra sans cesse concilier cette possibilité de prédiction avec le principe de la présomption d'innocence.

Par ailleurs, le numérique a donné une force phénoménale aux logiques d'accusation publique. Si la vindicte populaire n'a rien de neuf, le fait que tout un chacun puisse diffuser son opinion publiquement sur les réseaux sociaux a changé considérablement ce phénomène. Si quelques-uns ont été condamnés pour atteinte à la présomption d'innocence (par exemple **Cass Civ 1, 10 avril 2013, n° 11-28-406**), cette dénonciation en ligne n'est que peu réprimandée en pratique. Comment préserver la présomption d'innocence lorsque des masses colossales d'individus diffusent une opinion sur la supposée culpabilité d'un individu sont l'action juridictionnelle n'est pas éteinte ? Le numérique, par un autre biais, pose de nouveaux enjeux pour préserver la présomption d'innocence.

B. La pertinence actuelle de la présomption d'innocence

La pertinence de la présomption demeure face à la révolution numérique. En effet, un individu n'a pas moins le droit à un procès équitable, rendu selon des principes justes et rationnels qu'auparavant. En effet, la nature humaine, la dignité de chacun et les droits fondamentaux en général, n'ont pas dévié sous la pression du développement des nouvelles technologies de télécommunication. Il est possible de vérifier cette constatation en remarquant que la présomption d'innocence bénéficie d'une protection particulièrement solide parmi toutes les normes applicables en France.

En plus, de **l'article 9 de la DDHC** déjà cité, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, on peut observer que la présomption d'innocence est globalement reconnue au sein de tous les procès nationaux :

- Procès administratif : **Conseil d'État, ord. 14 mars 2005, B. Gollnisch**
- Procès civil : **article 9-1 du Code civil**
- Procès pénal :
    - **Article 11 du Code de procédure pénale**
    - **Article 434-7-2 du Code pénal**.

Il est également possible d'observer une protection de la présomption d'innocence à des niveaux supranationaux :

- Au niveau international : **article 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques**
- Au niveau européen :
    - **Article 6§2 de la CEDH.**
    - **Article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne**.

Pour autant que la présomption d'innocence demeure pertinente aujourd'hui, elle doit évoluer afin de s'appliquer effectivement à l'ère du numérique.

II. La nécessaire évolution de la présomption d'innocence à l'ère numérique

La présomption d'innocence est toujours pertinente a l'heure du numérique ; toutefois, elle doit nécessairement évoluer pour demeurer effective. Si les enjeux nouveaux du numérique pour la présomption d'innocence sont difficiles à saisir juridiquement **(A)**, des évolutions et des pistes d'évolution de la présomption d'innocence sont déjà intervenues dans le droit positif **(B)**.

A. Les difficultés pour saisir juridiquement les enjeux nouveaux du numérique pour la présomption d'innocence

Les grands enjeux du numérique pour la présomption d'innocence sont difficiles à saisir juridiquement.

Tout d'abord, la régulation de l'intelligence est difficile à régir. En plus d'être propre à des sauts technologiques fréquents, en rupture avec les précédents, l'intelligence artificielle pose de nombreuses questions éthiques. Elles sont abondamment étudiées, mais elles ne sont pas parfaitement résolues. Dès lors, il est difficile d'établir une législation à ce propos. Le **Conseil d'État** a remarqué cela dans **l'étude qu'il a rendue au Premier ministre** en mars 2022, intitulée : **Intelligence artificielle et action publique : construire la confiance, servir la performance.**

Il apparaît donc qu'il est difficile de se saisir juridiquement de cet enjeu du numérique, notamment pour préserver la présomption d'innocence.

Par ailleurs, il est difficile de déterminer les responsables, de qualifier leurs infractions puis de condamner les individus participant à des phénomènes de vindicte publique atteignant la présomption d'innocence. **La loi dite Avia n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur interne**t a essayé de parvenir à cela. Néanmoins, elle a été considérée comme attentatoire à des libertés et droits garantis par la Constitution, notamment à **l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen**, qui dispose que : « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi », par le **Conseil constitutionnel (décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020)**.

Une nouvelle fois, il apparaît que le saisissement des enjeux nouveaux du numérique pour la présomption d'innocence est difficile.

B. Les évolutions de la présomption d'innocence pour saisir les enjeux nouveaux du numérique pour la présomption d'innocence

Récemment, l'Union européenne est en train d'adopter un ***Artificial Intelligence Act,*** qui vise à réguler l'intelligence artificielle parmi tous les États membres sans éteindre les possibilités d'innovation en ce domaine ; au contraire, en les promouvant. Cette norme européenne offre un cadre permettant de s'appuyer sur le numérique pour décider de manière plus juste, avec plus de rationalité, mais ne remet pas en cause la présomption d'innocence. De plus, le **RGPD** ainsi que la loi **informatique et liberté du 6 janvier 1978** disposent

que la régulation du numérique qu'ils assurent est faite pour protéger les droits fondamentaux, dont fait partie le droit à la présomption d'innocence.

Il apparaît donc que le droit positif a évolué pour faire face à un enjeu nouveau du numérique pour la présomption d'innocence.

Par ailleurs, l'Union européenne adoptera d'ici la fin de l'année 2022 (en octobre normalement) le ***Digital Services Act*** (DSA) et a déjà adopté (en juillet 2022) le ***Digital Market Act*** (DMA). Ce dernier a pour objectif de réduire la domination des grands acteurs du numérique comme les GAFAM. Il vise à éviter qu'ils puissent réguler internet à leur guise, sans rendre de compte à aucune autorité publique. Le DMA rend plus effectif le DSA à la vue de l'objectif de ce dernier : éviter les phénomènes de harcèlement, de haine, de meutes en ligne ; autrement dit, empêcher les atteintes à la présomption d'innocence en ligne.

Il apparaît donc que le droit positif a évolué et est encore en train de ce faire, afin de répondre à un enjeu nouveau du numérique pour la présomption d'innocence.

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2022

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 4 – La sécurité

1. Dissertation
2. Commentaire
3. Argumentation

SUJET 1. DISSERTATION

La force du droit à la sécurité en France

SUJET 2. COMMENTAIRE

CJUE, 15 juillet 2021, contre Slovénie (extraits)

(…) 19 Au cours de la période allant du mois de février 2014 au mois de juillet 2015, B. K. a effectué, en sa qualité de sous-officier de l'armée slovène, un « service de garde » ininterrompu de sept jours par mois au cours duquel il devait être joignable et présent en permanence au sein de la caserne où il était affecté. Ce « service de garde » comprenait à la fois des périodes au cours desquelles B. K. devait exercer une activité de surveillance effective et des périodes durant lesquelles ce dernier n'était tenu que de demeurer à la disposition de ses supérieurs. En cas de venue inopinée de la police militaire, d'un groupe d'inspection ou d'un groupe d'intervention, il devait en faire mention sur le formulaire d'enregistrement et remplir les missions que lui imposaient ses supérieurs. (…)

32 (…), il y a lieu de relever, d'une part, que, afin de déterminer si, comme le demande la juridiction de renvoi, l'article 2 de la directive 2003/88 est applicable à une activité de garde assurée par un militaire en temps de paix, telle que le « service de garde » effectué par B. K. dans les conditions mentionnées au point 19 du présent arrêt, il convient d'examiner si une telle activité relève du champ d'application de cette directive, lequel est fixé non par son article 2 mais par son article 1er, paragraphe 3.

33 D'autre part, la juridiction de renvoi part de la prémisse selon laquelle le litige au principal relève du champ d'application du droit de l'Union. Néanmoins, dans la mesure où ce litige concerne un militaire, il convient d'examiner, au préalable, si, comme l'ont soutenu les gouvernements français et espagnol, le droit de l'Union n'a pas vocation à régir l'aménagement du temps de travail des militaires au motif que cet aménagement relèverait des modalités d'organisation des forces armées des États membres, lesquelles seraient, par leur nature même, exclues du champ d'application de ce droit, conformément à l'article 4, paragraphe 2, TUE. (…)

35 En premier lieu, il convient de vérifier si l'article 4, paragraphe 2, TUE impose d'exclure l'intégralité des membres des forces armées du champ d'application du droit de l'Union et notamment des règles sur l'aménagement du temps de travail.

36 Aux termes de cet article 4, paragraphe 2, l'Union respecte, d'une part, l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles et, d'autre part, les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. Cette même disposition précise que la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre.

37 À cet égard, il y a lieu de relever que les missions principales des forces armées des États membres, que sont la préservation de l'intégrité territoriale et la sauvegarde de la sécurité nationale, figurent

explicitement parmi les fonctions essentielles de l'État que l'Union doit respecter, en vertu de l'article 4, paragraphe 2, TUE. (…)

39 Cela étant, il ne découle pas du respect dû par l'Union aux fonctions essentielles de l'État, consacré à l'article 4, paragraphe 2, TUE, que les décisions des États membres relatives à l'organisation de leurs forces armées échapperaient au champ d'application du droit de l'Union, en particulier lorsque sont en cause des règles relatives à l'aménagement du temps de travail. (…)

43 (…) si le respect dû par l'Union aux fonctions essentielles de l'État n'implique pas de soustraire intégralement l'aménagement du temps de travail des militaires au champ d'application du droit de l'Union, il n'en demeure pas moins que l'article 4, paragraphe 2, TUE requiert que l'application aux militaires des règles du droit de l'Union relatives à cet aménagement ne soit pas de nature à entraver le bon accomplissement de ces fonctions essentielles. Dès lors, ces règles ne sauraient être interprétées d'une manière telle qu'elles empêcheraient les forces armées d'accomplir leurs missions et qu'elles porteraient atteinte, par voie de conséquence, aux fonctions essentielles de l'État que sont la préservation de son intégrité territoriale et la sauvegarde de la sécurité nationale. (…)

46 Il découle de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'article 4, paragraphe 2, TUE n'a pas pour effet d'exclure l'aménagement du temps de travail de l'ensemble des militaires du champ d'application du droit de l'Union.

47 En deuxième lieu, il convient de rappeler que la directive 2003/88 a pour objet de fixer des prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs par un rapprochement des réglementations nationales concernant, notamment, la durée du temps de travail. Cette harmonisation au niveau de l'Union européenne en matière d'aménagement du temps de travail vise à garantir une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, en faisant bénéficier ceux–ci de périodes minimales de repos – notamment journalier et hebdomadaire – ainsi que de périodes de pause adéquates, et en prévoyant une limite maximale à la durée hebdomadaire de travail [arrêt du 9 mars 2021, Radiotelevizija Slovenija (Période d'astreinte dans un lieu reculé), C-344/19, EU:C:2021:182, point 25 et jurisprudence citée].

48 Par ailleurs, les dispositions de la directive 2003/88 précisent le droit fondamental à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire expressément consacré à l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte ») et doivent, dès lors, être interprétées à la lumière de ce dernier (arrêt du 17 mars 2021, Academia de Studii Economice din Bucureşti, C-585/19, EU:C:2021:210, point 37 et jurisprudence citée). Il s'ensuit notamment que ces dispositions ne sauraient faire l'objet d'une interprétation restrictive au détriment des droits que le travailleur tire de cette directive [arrêt du 9 mars 2021, Radiotelevizija Slovenija (Période d'astreinte dans un lieu reculé), C-344/19, EU:C:2021:182, point 27 et jurisprudence citée].

49 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, aux fins de l'application de la directive 2003/88, la notion de « travailleur » doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et des devoirs des personnes concernées. Or, la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en

contrepartie desquelles elle reçoit une rémunération. Il s'ensuit qu'une relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination entre le travailleur et son employeur. L'existence d'un tel lien doit être appréciée dans chaque cas particulier en fonction de tous les éléments et de toutes les circonstances caractérisant les relations entre les parties (arrêt du 20 novembre 2018, Sindicatul Familia Constanţa e.a., C-147/17, EU:C:2018:926, points 41 et 42 ainsi que jurisprudence citée).

50 En l'occurrence, il est constant que, au cours de la période en cause au principal, B. K. percevait une rémunération et se trouvait, en sa qualité de sous-officier de l'armée slovène, dans un lien de subordination par rapport à son employeur, au sens du point précédent. Il s'ensuit que la directive 2003/88 a, a priori, vocation à s'appliquer à sa situation. (…)

68 il ne saurait être considéré que l'intégralité des activités exercées par les militaires présentent des particularités telles que celles-ci s'opposent à toute planification du temps de travail respectueuse des exigences imposées par la directive 2003/88.

69 Au contraire, certaines activités susceptibles d'être exercées par les membres des forces armées, comme celles liées notamment à des services d'administration, d'entretien, de réparation, de santé, de maintien de l'ordre ou de poursuite des infractions, ne sauraient être exclues, dans leur intégralité, du champ d'application de la directive 2003/88.

70 En effet, il est constant que de telles activités relèvent, en principe, du champ d'application de cette directive lorsqu'elles sont exercées, dans des conditions similaires, par des travailleurs de la fonction publique n'ayant pas le statut de militaire. (…)

73 Cela étant, (…) lorsque les membres des forces armées sont confrontés à des circonstances d'une gravité et d'une ampleur exceptionnelles, au sens de cette jurisprudence, les activités de ceux-ci sont exclues du champ d'application de la directive 2003/88, en vertu de son article 1er, paragraphe 3, lu en combinaison avec l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/391. (…)

76 Tel est le cas des activités exercées par des membres des forces armées qui, en raison de leurs hautes qualifications ou du caractère extrêmement sensible des tâches qui leur sont assignées, ne peuvent que très difficilement être remplacés par d'autres membres des forces armées, au moyen d'un système de rotation permettant de garantir tout à la fois le respect des périodes maximales de travail et des périodes de repos prévues par la directive 2003/88 et le bon accomplissement des missions essentielles qui leur sont imparties.

77 Troisièmement, il importe de relever que tous les militaires appelés à prêter leur concours aux opérations impliquant un engagement militaire des forces armées d'un État membre, que celles-ci se déploient, de façon permanente ou occasionnelle, à l'intérieur de ses frontières ou à l'extérieur de celles-ci, exercent une activité qui, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/88, lu en combinaison avec l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/391, et à la lumière de l'article 4, paragraphe 2, TUE, doit, par sa nature même, être exclue, dans son intégralité, du champ d'application de la directive 2003/88.

78 En effet, le respect des exigences imposées par la directive 2003/88 au cours de ces opérations ferait peser un risque considérable sur le succès de celles-ci, succès qui suppose de pouvoir exiger un

engagement total, au cours de longues périodes, des membres des forces armées impliqués, et, par voie de conséquence, sur le bon accomplissement des fonctions essentielles de sauvegarde de la sécurité nationale ou de préservation de l'intégrité territoriale des États membres. (…)

83 La circonstance que la formation initiale, les entraînements opérationnels et les opérations militaires proprement dites ont lieu en temps de paix n'est pas de nature à infirmer la conclusion selon laquelle ces activités doivent être intégralement exclues du champ d'application de la directive 2003/88. En effet, les missions qui sont assumées par les forces armées afin d'assurer la préservation de la sécurité nationale et de l'intégrité du territoire doivent pouvoir être pleinement réalisées, même en temps de paix. (…)

88 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/88, lu à la lumière de l'article 4, paragraphe 2, TUE, doit être interprété en ce sens qu'une activité de garde exercée par un militaire est exclue du champ d'application de cette directive :

– soit lorsque cette activité intervient dans le cadre de sa formation initiale, d'un entraînement opérationnel ou d'une opération militaire proprement dite,
– soit lorsqu'elle constitue une activité à ce point particulière qu'elle ne se prête pas à un système de rotation des effectifs permettant d'assurer le respect des exigences de ladite directive,
– soit lorsqu'il apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances pertinentes, que cette activité est exécutée dans le cadre d'événements exceptionnels, dont la gravité et l'ampleur nécessitent l'adoption de mesures indispensables à la protection de la vie, de la santé ainsi que de la sécurité de la collectivité et dont la bonne exécution serait compromise si l'ensemble des règles énoncées par ladite directive devaient être respectées,
– soit lorsque l'application de ladite directive à une telle activité, en imposant aux autorités concernées de mettre en place un système de rotation ou de planification du temps de travail, ne pourrait se faire qu'au détriment du bon accomplissement des opérations militaires proprement dites.

SUJET 3. ARGUMENTATION

Soutenez que l'état d'urgence existe pour préserver l'État de droit

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2022

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 4 – La sécurité

Corrigés

1. Dissertation
2. Commentaire
3. Argumentation

SUJET 1. DISSERTATION

La force du droit à la sécurité en France

Que n'a-t-on pas fait au nom du droit à la sécurité ? Des atteintes à l'État de droit et aux droits fondamentaux ont souvent été commises par la justification d'assurer la sécurité. Pour autant, la sécurité ne vaut pas rien. Freud explique qu'il s'agit du premier et plus important besoin social, du plus profond désir des individus dans leurs psychés. Aussi, les comportements électoraux, dans les démocraties, révèlent souvent que la promesse d'assurer une sécurité forte est payante pour être élu, même si les autres droits fondamentaux risquent d'être profondément atteints. Par exemple, d'éminents analystes politiques considèrent que l'élection de Jair Bolsonaro à la présidence du Brésil a répondu à cette logique.

Certes, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 considère que parmi les droits naturels imprescriptibles de l'homme figure la sûreté. Néanmoins, il ne faut pas confondre cette dernière avec la sécurité. La sûreté se définit, à la suite de Montesquieu, comme la protection contre les mesures privatives de liberté, arbitraires. La sécurité n'a pendant longtemps pas été définie précisément.

En France, il a fallu attendre **la loi n° 85-73 du 21 janvier 1973 d'orientation et de programmation relative à la sécurité** pour que la sécurité soit clairement définie dans l'ordre juridique français. Son article premier dispose que : « – La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. – L'État a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens. » Cette loi a été abrogée en 2012, mais désormais, la sécurité se retrouve de manière diffuse dans tout l'ordre juridique. On retrouve de plus la disposition de la loi de 1995 à **l'article L111-1 du Code de la sécurité intérieure**, qui prévoit que : « – La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. – L'État a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens. – Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par voie réglementaire, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou œuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion ou de l'aide aux victimes. »

Le droit à la sécurité est animé par des logiques politiques, est souvent résumé à cette réalité. Toutefois, il a pris une force normative importante, qui a une importance cardinale pour comprendre les libertés fondamentales.

Il est intéressant d'observer la haute valeur normative du droit à la sécurité en France **(I)** ainsi que l'élasticité de son régime juridique **(II)**.

I. La haute valeur normative du droit à la sécurité en France

La force du droit à la sécurité dans l'ordre juridique français se constate d'abord par la place particulière qu'il occupe au sein du bloc de constitutionnalité **(A)**, et ensuite par son assise normative très large **(B)**.

A. Une place particulière au sein du bloc de constitutionnalité

Il existe, tout d'abord, un droit à une sécurité sociale dans l'ordre constitutionnel. En ce sens, le préambule de la Constitution de la IVe République compte parmi les principes particulièrement nécessaires à notre temps, celui proclamant que la Nation : « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. »

La sécurité, au sens strict du terme, est avant tout reconnue comme une conséquence de l'objectif de valeur constitutionnel de préservation de l'ordre public et de prévention des infractions pénales. En effet, le **Conseil constitutionnel** estime que cet objectif de valeur constitutionnel comprend « notamment (…) la sécurité des personnes et des biens » (**décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, loi sécurité et liberté**). Aussi, la sécurité est en France une des composantes de l'ordre public (V. **articles L211-1 et suivants du Code de la sécurité).**

Aussi, l'utilisation de la force est une dimension importante, parmi d'autres, de réalisation de ce même objectif de valeur constitutionnelle. Comment juguler la violence qui peut troubler l'ordre public et la sécurité sans cela ? L'utilisation de la force est dès lors une des modalités pour rendre effectif le droit à la sécurité.

À ce sujet, **l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme** et du citoyen dispose que : « la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » Le Conseil constitutionnel considère depuis peu qu'il découle de cette disposition que « l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la "force publique" nécessaire à la garantie des droits » est un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France **(Conseil constitutionnel, décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, société Air France)**.

B. L'assise normative très large du droit à la sécurité

L'assise normative de la sécurité est très large en France.

En effet, la sécurité trouve une assise supranationale :

- Au niveau de la CEDH, la sécurité est avant tout conçue comme une justification légitime pour restreindre d'autres droits (le procès équitable [**art. 6 CESDH**], la vie privée et familiale [art. 8 CEDH], liberté de pensée, de conscience et de religion [**art. 9 CESDH**], liberté d'expression [**art. 10 CESDH**], liberté de réunion et d'association [**art. 11 CESDH**]). En limitant l'expression du droit à la sécurité, la CEDH le consacre d'une certaine manière. En effet, elle indique clairement que la sécurité doit être mise en balance avec d'autres droits pour que la convention soit pleinement applicable. De plus, la CEDH considère que la sécurité impose des obligations positives pour les États, de l'assurer afin de rendre les autres droits effectifs pour les individus (V. par exemple sur ce sujet : **CEDH, 14 juin 2011, Ciechońska/Pologne**).
- Au niveau de l'Union européenne, la **Charte européenne des droits fondamentaux** ne comporte pas de mention explicite du droit à la sécurité. Néanmoins, **l'article 6** de cette charte dispose que : « toute personne a le droit à la liberté et à la sûreté. » Aussi, la Cour de Justice

de l'Union européenne a considéré en 2020 que : « le droit à la sécurité, garanti par l'article 6 de la Charte (**CJUE, 6 octobre 2020, *La Quadrature du Net et autres***). Il faut relativiser cette affirmation, car la Cour a considéré dans le même arrêt que l'article 6 de la charte des droits fondamentaux ne créait pas « une obligation d'adopter des mesures spécifiques en vue de réprimer certaines infractions pénales. »

Par ailleurs, le droit à la sécurité se repose aussi sur des fondements nationaux. On peut observer cela dans l'instauration d'une série de mécanismes et de régimes juridiques spéciaux, tous adoptés pour assurer une sécurité aux personnes résidant en France.

II. Le régime juridique élastique pour faire respecter le droit à la sécurité

Le régime juridique qui met en place le droit à la sécurité en France est élastique. En temps ordinaire, il est mis en balance avec les autres droits fondamentaux, ce qui constitue une opération complexe **(A)**. Lors d'une période extraordinaire, d'un temps exceptionnel, le droit à la sécurité prime sur les autres libertés et droits fondamentaux, sans pour autant les effacer complètement **(B)**.

A. La complexité de la balance entre le droit à la sécurité et les autres droits fondamentaux en temps ordinaire

La sécurité est une des composantes de l'ordre public français, avec la tranquillité, la salubrité et la dignité de la personne humaine (**Conseil d'État, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge**). **Les articles L211-1 et suivants du Code de la sécurité** intérieure prévoient une série de dispositions pour préserver l'ordre public. En période ordinaire, la sécurité contribue, en tant que composante de l'ordre public, à préserver ce qui permet un plein exercice des libertés fondamentales.

Il faut à ce sujet constater que le commissaire du Gouvernement Corneille expliquait très tôt que : « la liberté est la règle et la restriction de police l'exception. » (Conclusions sous l'arrêt **: Conseil d'État, 10 août 1917, Baldy**). Aussi, le juge administratif effectue un contrôle de proportionnalité de toute mesure de police (**Conseil d'État, 19 mai 1933, Benjamin**). En temps normal, la sécurité, en tant que composante de l'ordre public, est toujours mise en balance avec les autres libertés fondamentales.

B. La primauté donnée au droit à la sécurité en période extraordinaire

Tout d'abord, le **Conseil d'État** a considéré dans son **Heyriès (28 juin 1918**) que les administrations peuvent agir de manière plus lâche par rapport aux obligations qui s'imposent à elles, donc par rapport aux libertés fondamentales, si des circonstances exceptionnelles le justifient (par exemple, une catastrophe naturelle, une insurrection ou une guerre). En entrant dans une période anormale, la sécurité peut donc primer.

Ensuite, la Constitution prévoit deux états exceptionnels du droit. En premier lieu, **l'article 16 de la Constitution** dispose que : « lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. » En second lieu, **l'article 36 de la Constitution** prévoit la possible mise en place d'un état de siège. Dans les deux cas, on peut constater que l'entrée en une période extraordinaire justifie,

pendant un temps restreint, des états exceptionnels du droit, où la sécurité prime sur les autres aspects des libertés fondamentales.

Enfin, **la loi n° 55-385 du 3 avril 1955** relative à l'état d'urgence dispose en son **article premier** que celui-ci peut être déclaré : « soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. Il a assez récemment été activité, le 14 novembre 2015, à la suite des attentats commis le 13 novembre 2015 à Paris. Il a ensuite été prorogé à six reprises par les **lois du 20 novembre 2015, du 19 février 2016, du 20 mai 2016, du 21 juillet 2016, du 19 décembre 2016 et du 11 juillet 2017**.

SUJET 2. COMMENTAIRE

CJUE, 15 juillet 2021, contre Slovénie (extraits)

Un militaire slovène considérant que ses conditions de travail ne respectent pas ses droits a réclamé devant les juridictions slovènes que les heures qu'il a passées en « service de garde » lui soient payées en heures supplémentaires. Le militaire a interjeté appel suite à ce que la juridiction de première instance n'accède pas à sa demande. La juridiction d'appel sursoit à statuer et demande à la Cour de Justice de l'Union européenne d'éclairer l'interprétation de la directive 2002/88/CE.

Cet arrêt met donc en avant un thème d'une brûlante actualité au sein des libertés fondamentales depuis quelques années : la sécurité. En ce sens, la France a vécu sous l'état d'urgence entre 2015 et 2017. De plus, l'irruption de la guerre en Ukraine pose des questions à la politique de défense nationale. Elle apparaît d'autant plus importante aujourd'hui par rapport au moment où aucune guerre conventionnelle ne se déroulait en Europe.

Au regard de cette situation, certains thuriféraires du droit à la sécurité, mus par une logique strictement politique, estiment que ce droit pèse davantage que les autres dans la balance des libertés fondamentales que toutes les autorités publiques doivent effectuer pour assurer leurs missions. Ce n'est pas le cas, le droit à la sécurité, et les politiques sécuritaires ne justifient pas tout. Le juge de l'Union européenne le rappelle à propos des droits sociaux dans cet arrêt. Il défend le droit fondamental à une limitation de la durée du travail **(I)** tout en reconnaissant que ce droit fondamental doit être mis en balance avec d'autres libertés et droits fondamentaux, avec le droit des activités militaires, lui-même inspiré (notamment) par le droit à la sécurité **(II)**.

I. La défense du droit fondamental à une limitation de la durée de travail

La Cour de Justice de l'Union européenne considère que la directive 2003/88/CE s'applique en principe aux activités militaires (**A)**, bien que le régime juridique issu de l'application de cette directive aux militaires soit complexe **(B)**.

A. L'applicabilité de la directive européenne 2003/88/CE aux activités militaires

La **directive européenne 2003/88/CE** dispose en son **article 6** que : « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : — a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus

entre partenaires sociaux ; — b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. »

Il faut noter que la directive 2003/88/CE renvoie à la **directive 89/391/CE**, qui prévoit une exception importante. En effet, **l'article 2** de celle-ci dispose que : « la présente directive n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de manière contraignante. »

Si la Slovénie a considéré que toutes les activités militaires entraient dans l'exception prévue à la directive 89/391/CE, comme la France, la Cour de Justice de l'Union européenne a considéré qu'en principe, les activités militaires, comme toute activité professionnelle, entrent dans le domaine d'application de la directive 2003/88/CE.

La Cour défend donc ici, en confrontation claire avec les dires des exécutifs slovènes et français, que la sécurité et la défense nationale n'écartent pas l'application des droits sociaux des militaires. Elle défend, plus que toute autre chose, le droit fondamental contenu à **l'article 31.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne**, qui dispose que : « tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. » En ce sens, la Cour de Justice soutient dans l'arrêt que la directive de 2003 contient des « prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs. »

B. Le régime juridique complexe de la directive 2003/88/CE en ce qui concerne les militaires

La Cour de Justice de l'Union européenne considère qu'en principe la directive 2003/88/CE s'applique à tous les travailleurs des États membres de l'Union. Néanmoins, elle ne considère pas qu'elle s'applique de manière univoque, de la même manière, quelles que soient les fonctions, quel que soit le domaine d'activité des travailleurs.

La Cour de Justice considère plutôt qu'il faut sérier les choses, qu'il faut faire preuve de plus de précision. Si les fonctions militaires entrent dans le champ d'application de la directive de 2003, certaines sont manifestement incompatibles avec la règle des 48 heures hebdomadaires maximum fixée par la même directive.

La défense du droit fondamental à une durée maximale du travail hebdomadaire se met donc en place de manière complexe. À chaque fois qu'un État cherche à savoir s'il s'applique ou non pour ses militaires, il doit se demander si leurs fonctions réelles, leur activité effective, rendent l'application de la directive impossible. Autrement dit, ils doivent mettre en balance le droit fondamental à la limitation de la durée de travail avec le droit à la sécurité.

II. La mise en balance du droit fondamental à la limitation de la durée de travail avec le droit des activités militaires

La mise en balance du droit fondamental à la limitation de la durée de travail avec le droit à la sécurité est nécessaire ; elle s'opère à travers le droit des activités militaires dans le présent arrêt **(A)**. Il faut constater qu'au cours de cette conciliation, ce droit fondamental conserve une force importante **(B)**.

A. La nécessaire mise en balance du droit fondamental à la limitation de la durée de travail avec le droit des activités militaires

La Cour de Justice de l'Union européenne considère à plusieurs reprises que la défense de l'intégrité territoriale et la défense nationale sont des activités militaires extrêmement complexes et qu'elles pouvaient justifier la non-applicabilité de la directive de 2003 ici étudiée. Qui aurait l'idée, par exemple, d'interdire de poursuivre une opération complexe, un combat de haute intensité, si la durée de 48 heures était dépassée ? En revanche, d'autres activités des personnels des armées n'empêchent nullement de respecter cette prescription.

La solution trouvée par la Cour de Justice de l'Union européenne implique une casuistique permanente. À chaque cas, chaque type d'activité militaire, il faut se demander si la directive de 2003 peut s'appliquer ou non. La mise en balance du droit fondamental à la limitation de la durée de travail avec le droit des activités militaires est donc nécessaire.

Les militaires sont des travailleurs au sens de la Cour de Justice de l'Union européenne puisqu'ils exercent des fonctions en échange d'une rémunération et qu'il existe un lien de subordination entre eux et leurs chefs, soit une relation de travail **(CJUE, 20 novembre 2018, Sindicatul Familia Constanţa)**. L'interprétation large que la **Cour de Justice** adopte de la directive, dans la continuité de sa jurisprudence antérieure (**9 mars 2021, Radiotelevizija Slovenija)**, accepte donc des exceptions si elles sont justifiées. Cela entraîne une fragilité de la mise en balance du droit fondamental à la limitation de la durée de travail avec le droit des activités militaires.

B. La fragilité du droit fondamental à la limitation de la durée de travail avec le droit à la sécurité

Les législations slovènes, dans le cas d'espèce, et Françaises, ne reposent pas sur cette logique. L'article **L4121-5 du Code de la défense** français dispose par exemple que : « les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. » Dans la logique juridique de ces deux États membres, les activités militaires ne sont pas dissociables les unes des autres ; par conséquent, la règle des 48 heures ne peut pas s'appliquer. De prime abord, la casuistique décrite précédemment ne peut pas s'appliquer non plus dans cette logique.

L'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne pose donc la question de savoir comment les États membres peuvent l'appliquer. En France, le **Conseil d'État** s'est déjà prononcé sur la question du temps maximum de travail des gendarmes départementaux dans un **arrêt M. G. Q du 17 décembre 2021**. La Haute juridiction française a alors observé, non pas l'activité de tous les personnels ayant un statut militaire, mais l'activité spécifique de tous les gendarmes départementaux. Plus précisément, le Conseil d'État a constaté que les astreintes de ces gendarmes ont lieu sans éloignement de domicile puisqu'ils habitent en caserne. Par conséquent, le juge du Palais-Royal estime que lors de leurs astreintes, les gendarmes départementaux ne dépassent pas la durée maximale de 48 heures de travail hebdomadaire prévue par la directive de 2003 ici étudiée.

Si la juridiction française a suivi la logique juridique de la Cour de Justice de l'Union européenne, elle a dans le même temps réussi à justifier le droit positif de la France. Cela montre qu'en excipant du droit à la sécurité ou de la défense nationale, ainsi qu'en maniant l'argumentation juridique et le décompte des heures avec la finesse dont le Conseil d'État a le secret, la balance entre le droit fondamental à la limitation de la durée du travail hebdomadaire et le droit des activités militaires penche en ce

deuxième versant. Il apparaît donc que la balance entre ce droit social et le droit à la sécurité peut facilement tourner à l'avantage du second, malgré la défense du premier par la Cour de Justice de l'Union européenne.

SUJET 3. ARGUMENTATION

Soutenez que l'état d'urgence existe pour préserver l'État de droit

Cela pourrait paraître surprenant. L'état d'urgence, cette période exceptionnelle du droit, qui ne respecte par définition pas toutes les garanties présentes dans le droit commun, existe pour préserver l'État de droit. Adopté par la **loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence**, à côté d'autres régimes extraordinaires du droit créés par la jurisprudence (**CE, 28 juin 1918, Heyriès**) et prévus par la Constitution (**articles 16 sur les pouvoirs étendus au président de la République et 36 sur l'état de siège**), l'état d'urgence peut se comprendre comme un mal nécessaire, une période provisoire où les libertés doivent baisser leur voix afin de parler à nouveau au plus fort plus tard.

Certains considèrent qu'il est fallacieux de suspendre un grand nombre de libertés, ou tout du moins de restreindre considérablement leur exercice, au nom du seul droit à la sécurité, qu'il n'est ni acceptable politiquement ni valide juridiquement d'instaurer une telle loi exceptionnelle. D'autres estiment que la loi d'urgence, tel qu'elle a récemment été appliquée en France, était inopportune.

Sans être un analyste béat, aveugle à toute critique, il est possible d'affirmer qu'à défaut d'être une solution parfaite et à défaut de parvenir toujours à cet objectif, très exigeant, l'état d'urgence existe pour préserver l'État de droit.

De telles législations semblables existent dans d'autres États (par exemple avec les articles 116 et 155 de la Constitution espagnole) et souffrent des mêmes critiques. Néanmoins, il faut remarquer que, si l'état d'urgence existe pour préserver l'État de droit **(I)**, il existe de manière imparfaite et ne parvient pas toujours parfaitement à ce but **(II)**.

I. Une existence pour préserver l'État de droit

En luttant contre les périls qui menacent l'État de droit **(A)**, l'état d'urgence préserve ce dernier **(B)** ; c'est là sa raison d'être.

A. La lutte contre les périls menaçant l'État de droit par des moyens exceptionnels

L'état d'urgence a un but très clair, lutter contre des menaces, des menaces contre la sécurité de tous. En ce sens, **l'article premier de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955** relative à l'état d'urgence dispose que celui-ci peut être déclaré : « soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. »

L'état d'urgence a été appliqué en France à ces périodes :

- En 1955 et en 1958, suite à des évènements liés à la guerre d'Algérie. Plus particulièrement, en 1961, après le putsch des généraux à Alger. L'état d'urgence a été renouvelé jusqu'au 31 mai 1963 sur la totalité du territoire métropolitain ;
- En 1984, en Nouvelle-Calédonie lors des violences opposant indépendantistes et partisans du maintien de l'île au sein de la République française ;
- En 2005, à l'occasion des émeutes dans les banlieues dans 25 départements, incluant l'Île-de-France. L'état d'urgence a pris fin le 4 janvier 2006 ;
- Le 14 novembre 2015, à la suite des attentats commis le 13 novembre 2015 à Paris. L'état d'urgence a été déclaré sur tout le territoire métropolitain et une partie de l'outremer et a été prorogé à six reprises par les lois du 20 novembre 2015, du 19 février 2016, du 20 mai 2016, du 21 juillet 2016, du 19 décembre 2016 et du 11 juillet 2017.

  À chaque fois, l'état d'urgence a été contesté par certains. À chaque fois cependant, il a été adopté avec l'intention de lutter contre ce que les Gouvernements qui l'ont mis en place considéraient comme des périls contre l'État et l'ordre public qu'il assure. Comment considérer que l'État de droit existe seul, sans puissance publique pour le mettre en place ? Avant d'être « de droit », une entité politique est nécessairement un « État ». Aussi, préserver l'État revient à protéger les conditions d'existence même de l'État de droit.

B. La préservation de l'État de droit par l'état d'urgence

Il faut remarquer que, certes, l'état d'urgence réduit fortement l'exercice des libertés fondamentales. Cependant, il faut tout d'abord noter que toutes les libertés ne sont pas suspendues pendant l'état d'urgence. Cet état du droit donne des pouvoirs exceptionnels à différentes institutions et agents de l'État ; néanmoins, ils ne sont pas dans l'obligation de les utiliser. Une action ciblée est donc prévue par la loi de 1955 (**articles 5 et suivants de la loi de 1955**). La liberté d'expression n'a, par exemple, nullement été obérée lors de l'état d'urgence de 2015. Les critiques acerbes dont il a été l'objet le montrent bien. Aussi, l'état d'urgence est délimité dans l'espace. Il ne concerne pas nécessairement tout le territoire. L'article 2 de la loi de 1955 précise en effet que le décret de déclaration de l'état d'urgence : « détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur. » Cette territorialisation s'est vérifiée dans l'Histoire.

Ensuite, l'état d'urgence est par définition provisoire. Il est mis en place jusqu'à ce que la situation pour laquelle il a été proclamé soit résolue. En effet, l'état d'urgence est déclaré pour 12 jours maximum par décret en Conseil des ministres (**article 2 de la loi de 1955**). Au-delà, l'état d'urgence est prorogé par le biais de lois, qui doivent fixer une durée limite (**article 3 de la loi de 1955**).

De plus, l'état d'urgence est assorti de garanties pour voir son application limitée. Par exemple, **l'article 11 de la loi de 1955** facilite les perquisitions ordonnées par le ministre de l'Intérieur ou du préfet dans son ressort territorial si et seulement si le décret de proclamation de l'état d'urgence dispose de ce pouvoir exceptionnel explicitement.

Enfin, quelques contrôles juridictionnels existent pour vérifier la licéité des mesures prises sur le fondement de l'état d'urgence. Par exemple, **l'article 14-1 de la loi de 1955** dispose que : « – (…) les mesures prises sur le fondement [de l'état d'urgence] sont soumises au contrôle du juge administratif

dans les conditions fixées par le code de justice administrative – La condition d'urgence est présumée satisfaite pour le recours juridictionnel en référé formé contre une mesure d'assignation à résidence. »

II. Une existence imparfaite pour préserver l'État de droit

Pour autant qu'il existe pour préserver l'État de droit, l'état d'urgence n'est pas parfait. Il ne parvient pas nécessairement à ce but. Tout d'abord, il est toujours difficile, épineux de savoir si l'État d'urgence est opportun ou pas **(A)**. Ensuite, l'état d'urgence porte en lui les germes de la destruction, en même temps que ceux de la protection de l'État de droit; des dérives peuvent l'éloigner de son but **(B)**.

A. L'épineuse question de l'opportunité de l'état d'urgence et des mesures prises dans son cadre

La question de l'opportunité de l'état d'urgence et des mesures prises dans son cadre est épineuse. Comment juger rationnellement d'une telle question de fait ?

Le jugement d'une telle chose est nécessairement laissé à l'appréciation, large, de l'organe qui détient une compétence pour cela. En effet, les conditions de déclaration de l'état d'urgence ne sont pas extrêmement précises**. L'article premier de la loi de 1955** dispose que :

« soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. »

Néanmoins, comment savoir si le péril est véritablement imminent ? Comment savoir si une atteinte à l'ordre public est grave ou non ? Comment qualifier avec exactitude un évènement de calamité publique ? L'appréciation de la situation qui ouvre l'état d'urgence soufre nécessairement de quelques équivoques. Face à un même fait, un pouvoir exécutif de telle couleur politique déclarera l'état d'urgence, un pouvoir exécutif de telle autre couleur politique ne le fera pas.

Aussi, cette question relève de la compétence des pouvoirs politiques (l'exécutif en premier lieu ; et, si l'état d'urgence doit perdurer au-delà de 12 jours, le législatif [**article 3 de la loi 1955**]). En ce sens, le Conseil constitutionnel considère qu' : « il appartient au législateur d'opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public sans lequel l'exercice des libertés ne saurait être assuré. » (**Conseil constitutionnel, décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985, loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances** ; Position réitérée après à la réforme de la loi de 1955 en 2015 [loi adoptée à la suite de l'état d'urgence de 2015] à propos des mesures de perquisitions ordonnées dans le cadre de l'état d'urgence : **Conseil constitutionnel, décision n° 2016-600 QPC du 2 décembre 2016**

M. Raïme A.).

Il apparaît donc que l'opportunité de l'état d'urgence, et de toutes les mesures adoptées dans son cadre, est une question équivoque qui doit être tranchée par les pouvoirs politiques, et qui est relativement peu contrôlée par des juridictions dans son opportunité. La logique est de dire que face à un péril pour la Nation, dans son être, son existence même, c'est à la représentation nationale et au Gouvernement responsable devant elle, de prendre des décisions existentielles. En ce sens, **l'article 4 de la loi de 1955** prévoit que : « la loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un

délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale. » Autrement dit, dès qu'un changement politique majeur intervient, l'état d'urgence n'est plus applicable : c'est un choix politique. L'état d'urgence étant par essence une décision politique, elle est tout autant par essence propre à l'opposition, au débat d'idées. Il est donc critiquable, toujours. Ces critiques ne doivent pas faire oublier ce pour quoi il existe : préserver d'un grand péril, et par-là, préserver l'État de droit. En ce sens, **l'étude annuelle du Conseil d'État de 2021**, consacrée aux états d'urgence, est sous-titrée « la démocratie sous contraintes. »

B. Les risques de dérives propres à l'état d'urgence

Éloigné d'une pure logique juridique, l'état d'urgence porte en lui des risques contre l'État de droit.

D'abord, l'état d'urgence est assorti de quelques garanties pour protéger l'État de droit. Néanmoins, reposant sur une logique essentiellement politique, elles n'empêchent pas des renouvellements successifs de l'état d'urgence, tant que l'exécutif et le législatif estiment que cela est nécessaire. L'état d'urgence a par exemple plusieurs fois été prorogé à partir de 2015. À mesure que les prorogations se succèdent, il apparaît que la situation périlleuse justifiant l'application de l'état d'urgence ne constitue pas véritablement une crise. En effet, dès lors qu'elle dure, elle est pérenne, structurelle. Par conséquent, l'état d'urgence n'est en théorie plus pertinent. S'il continue d'être appliqué, il n'est pas *contra legem* si les procédures de prorogation sont respectées dûment. Néanmoins, sa prolongation est contraire à l'esprit de la loi de 1955. Il peut alors s'agir d'exercer une gouvernance coercitive alors qu'un mode de gouvernement normal devrait en principe s'exercer ; ceci s'oppose bien évidemment à l'État de droit. Certains ont considéré que l'application de l'état d'urgence en 2015 a constitué une telle atteinte contre l'État de droit.

Il apparaît donc que, si l'état d'urgence existe en théorie pour protéger l'État de droit, il comporte en pratique des risques contre celui-ci. À l'étranger, dans un cas extrême, le Paraguay a vécu sous un état d'urgence de 1954 à 1988, ce qui a permis à Alfredo Stroesnner de diriger ce pays de manière dictatoriale.

D'autre part, l'état d'urgence, lorsqu'il perdure longtemps, entraîne souvent une transformation du droit commun, plus coercitive. Dans un tel cas, l'État de droit comporte moins de garanties pour les personnes à la suite de l'application de l'État d'urgence. Cela a été le cas États-Unis à la suite de l'adoption du *Patriot Act* suite aux attentats du 11 septembre 2001. Notamment en ce qui concerne la question des perquisitions, **la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015**, réformant la loi de 1955 sur l'état d'urgence, a rendu plus intenses les pouvoirs de police administrative existant dans le cadre de l'état d'urgence. Cette réforme a ôté quelques garanties de respect des libertés fondamentales pour mieux atteindre l'objectif de valeur constitutionnelle de préservation de l'ordre public et de prévention des infractions pénales (V. par exemple sur ce sujet : **Conseil constitutionnel, décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, M. Roushdi B.**).

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2022

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 5 – Liberté d'association

1. Dissertation
2. Commentaire
3. Argumentation

***SUJET* 1. DISSERTATION**

La protection de la liberté d'association

SUJET 2 – COMMENTAIRE

Conseil d'État, ordonnance du 29 avril 2022, Association comité action Palestine, n° 462736 (extraits)

(…) 2. L'association « Comité Action Palestine », déclarée le 23 juillet 2004 à la préfecture de la Gironde, compte une trentaine de membres et s'est donnée pour objet d'apporter un soutien à la cause palestinienne, notamment par l'organisation de conférences et manifestations, par la diffusion et la publication de prises de position et d'informations par voie de tracts ou sur son site internet. Elle a été dissoute par un décret du 9 mars 2022 pris sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, l'association a saisi le juge des référés du Conseil d'État d'une demande, fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de ce décret.

3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : /(...) 6 ° (...) qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ; /7 ° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger ». Selon l'article L. 212-1-1 du même code : « Pour l'application de l'article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient ».

4. En premier lieu, le décret contesté fait grief à l'association requérante d'avoir, sous couvert d'un antisionisme radical, diffusé de nombreuses publications présentées comme provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une nation ou une religion déterminée et retient que de tels faits sont de nature à justifier la dissolution de l'association sur le fondement du 6 ° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, il résulte des pièces versées au dossier dans le cadre de l'instruction contradictoire de la procédure de référé et des éléments exposés au cours de l'audience que les prises de position énoncées par les publications de l'association requérante ainsi mises en cause, dont une bonne part est déjà ancienne, si elles expriment des opinions tranchées et parfois virulentes sur la situation au Proche-Orient, sur le conflit israélo-palestinien, sur la politique menée et les actions conduites par les autorités israéliennes et sur le soutien que l'association entend apporter à la cause palestinienne, ne peuvent, en l'état de l'instruction, être regardées comme provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes, au sens du 6 ° de l'article

L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Il n'est, par ailleurs, pas établi que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'association aurait diffusé sur son site internet des publications présentant un caractère antisémite.

5. En deuxième lieu, si le décret retient aussi, pour justifier la mesure de dissolution, que des membres actifs de l'association requérante ont été impliqués dans des actes à caractère antisémite, il ne résulte d'aucun élément versé au dossier dans le cadre de l'instruction de la procédure de référé que les personnes mises en cause à raison de tels actes seraient ou auraient été membres de l'association.

6. En troisième lieu, les informations diffusées ou les prises de position exprimées par l'association quant à l'action d'organisations implantées au Proche-Orient ou à la situation de personnes condamnées pour des faits de terrorisme ne peuvent, eu égard à la teneur de ces publications, être qualifiées d'agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger, au sens du 7 ° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.

7. Il résulte de ce qui précède que, en l'état de l'instruction menée en référé, l'association requérante est fondée à soutenir que la mesure de dissolution prononcée par le décret contesté, à raison des faits qu'il relève à son encontre, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'association et à la liberté d'expression, qui présentent le caractère de libertés fondamentales.

8. Par ailleurs, eu égard aux conséquences qui découlent d'une mesure de dissolution prise sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure et à l'atteinte qui en résulte pour la liberté d'association, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'elle soulève, l'association requérante est fondée à demander la suspension de l'exécution du décret qu'elle conteste.

SUJET 3. ARGUMENTATION

Soutenez que la liberté d'association est nécessaire à une société démocratique

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2022

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 5 – Liberté d'association

Corrigés

1. Dissertation
2. Commentaire
3. Argumentation

SUJET 1. DISSERTATION

La protection de la liberté d'association

La **loi du 1er juillet 1901** dispose en son **article premier** que : « l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. »

La liberté d'association est une des libertés les plus importantes dans l'ordre constitutionnel français. En effet, c'est lorsque le Conseil constitutionnel a considéré que la liberté d'association est un **principe fondamental reconnu par les lois de la République** que le bloc de constitutionnalité a été créé **(Conseil constitutionnel, décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi de 1901 relative au contrat d'association)**. En effet, le Conseil du Palais-Royal a par-là considéré que le préambule de la Constitution de la Ve République, ainsi que tous les textes mentionnés par celui-ci ont une valeur constitutionnelle.

Aussi, **l'article 11 de la CESDH** dispose que : « toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. » La CEDH considère que cette liberté est « fondamentale » au sein d'une « société démocratique », que celle-ci ne peut pas exister véritablement sans elle (V. par exemple sur ce sujet : **CEDH, 20 février 2003, Djavit An contre Turquie).**

La liberté d'association a également une valeur politique très forte. D'abord, d'un point de vue historique, il faut remarquer que c'est à la suite d'une limitation drastique du droit de s'associer et ce celui de se réunir, plus précisément de l'interdiction de la tenue des ateliers nationaux à Paris, que la révolution de 1848 s'est animée. Autrement dit, c'est lorsque la Monarchie de Juillet réduisit la liberté d'association, notamment, qu'une révolution aboutit à l'instauration de la Seconde République.

L'importance juridique, politique et historique de la liberté d'association rend très intéressant de s'interroger sur la protection de cette liberté fondamentale aujourd'hui. La multiplicité des sources sur lesquelles elle s'appuie **(I)** lui permet de protéger la multiplicité des associations, au sens large du terme, qui existent **(II)**.

I. La multiplicité des fondements de la protection de la liberté d'association

Les fondements de la liberté d'association sont multiples et se complètent les uns par rapport aux autres afin d'offrir à la liberté d'association une assise solide et protectrice. En effet, cette liberté fondamentale connaît des sources supranationales **(A)** ainsi que nationales **(B)**.

A. Les fondements supranationaux de la protection de la liberté d'association

Bien qu'elle n'ait pas de valeur juridiquement contraignante en France, la **Déclaration universelle des droits de l'homme** est une source d'inspiration pour tous les textes qui lui ont succédé. Son **article 20** dispose que : « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. – 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. » Toujours au niveau international, **l'article 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques** dispose que « toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit

de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts. » Apparaît ainsi que la liberté d'association est universellement reconnue. Les juridictions françaises se fondent parfois sur ce fondement pour protéger la liberté syndicale (V. par exemple sur ce sujet : **Conseil d'État, 15 mars 2002, FNSA PTT**).

Il faut noter qu'aucun soubresaut de la politique française ou européenne ne remettrait en cause ces dispositions. Les fondements internationaux de la liberté d'association lui assurent donc une grande pérennité.

Par ailleurs, la liberté d'association possède aussi des fondements européens. D'abord, la **CESDH** dispose en son **article 11** que : « toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. » Ensuite, **l'article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne** prévoit que : « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politiques, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts – 2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens ou citoyennes de l'Union. »

Les sources européennes de la liberté d'expression permettent à celle-ci d'acquérir une grande effectivité grâce au travail juridictionnel intense de la CEDH, et dans une moindre mesure de la CJUE, pour faire appliquer ces dispositions.

B. Les fondements nationaux de la protection de la liberté d'association

La protection nationale de la liberté d'association est particulièrement forte : elle existe à tous les niveaux de la hiérarchie des normes.

Au niveau constitutionnel, la liberté d'association a une valeur constitutionnelle. En effet, le Conseil constitutionnel considère qu'il s'agit d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République (**Conseil constitutionnel, décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi de 1901 relative au contrat d'association)**. Il faut noter que la protection constitutionnelle de la liberté d'association est particulièrement importante. En effet, c'est à partir de la décision du 16 juillet 1971 que le Conseil constitutionnel a construit le bloc de constitutionnalité. C'est par la liberté d'association que le plus large édifice national de protection des droits fondamentaux a commencé son édification.

Le niveau de protection législatif de la liberté d'association est lié au niveau constitutionnel. En effet, le Conseil constitutionnel a reconnu la liberté d'association comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République en observant la **loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association**. Celle-ci compte parmi les grandes législations libérales de la IIIe République. Elle est enracinée dans l'histoire de France. Ce caractère historique montre que la protection de la liberté d'association est adaptée à la situation française, elle en épouse les réalités, les concepts et les singularités.

Enfin, des règlements et des jurisprudences précisent le régime juridique précis de la liberté d'association. Ils déterminent avec exactitude les modalités d'exercice de cette liberté et lui donnent par suite une effectivité forte.

II. La multiplicité des types d'association protégés

La multiplicité des sources de la liberté d'association permet de ne pas l'enfermer dans une conception étriquée, qui risquerait de limiter le phénomène associatif dans toute sa diversité. En effet, la liberté d'association concerne plusieurs sortes d'association. Il existe une liberté d'association générale **(A)** autant qu'une liberté syndicale en France **(B)**.

A. La protection de la liberté d'association générale

La liberté d'association vaut pour toutes les associations et groupements de fait. La protection de cette liberté est générale. Comme toutes les libertés fondamentales, elle doit être mise en balance avec d'autres principes, d'autres droits pour être appliquée de manière effective. Le Conseil constitutionnel a clairement estimé que toute atteinte à la liberté d'association doit être justifiée par la volonté de poursuivre un but légitime avec des moyens nécessaires, adaptés et proportionnés **(Conseil constitutionnel, décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, loi confortant le respect des principes de la République)**.

La CEDH accorde une protection particulière à cette liberté, car elle considère qu'elle est nécessaire au développement du pluralisme au sein d'une société, qu'elle est par suite nécessaire à la société démocratique **(CEDH, 17 février 2004, Gorzelick et autres contre Pologne)**. La promotion du pluralisme est d'autant plus importante en ce qui concerne les partis politiques afin d'assurer le bien-être de la démocratie. Les États parties à la CESDH doivent y prêter une atteinte particulière **(CEDH, 25 octobre 2005, Ouranio Toxo contre Grèce)**. Aussi, le pluralisme des courants d'opinions et de pensées constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Le pluralisme des partis politiques fait l'objet d'une attention toute particulière du Conseil constitutionnel **(Conseil constitutionnel, décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003, Loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques)**.

B. La protection de la liberté syndicale

La liberté syndicale est distincte de la liberté d'association dans l'ordre juridique français. Néanmoins, elle est présentée ici à plusieurs titres. D'abord, ces deux libertés protègent une chose commune : le droit de s'unir afin de défendre quelque chose. Théoriquement, une association promouvra des idées, des causes, alors qu'un syndicat défendra des intérêts. Néanmoins, la défense des intérêts, celle des idées et celle des causes s'entrecroisent constamment dans la réalité. Ensuite et surtout, les sources supranationales de la liberté d'association mentionnent aussi la liberté syndicale, incitant par-là à les présenter ensemble.

En France, le Conseil constitutionnel a tout d'abord protégé le droit syndical **(décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes)**. Il s'éloignait par-là de l'esprit du Préambule de la Constitution de la IVe République, qui constitue le principal socle des droits sociaux en France. C'est pour cela qu'il a effectué un revirement de jurisprudence. En effet, le Conseil constitutionnel considère qu'il existe une liberté syndicale ayant une valeur constitutionnelle **(décision n° 22 octobre 1982 DC du 22 octobre 1982, loi relative au développement des institutions représentatives du personnel).** Le Conseil constitutionnel déduit cette liberté du **principe particulièrement nécessaire à notre temps** écrit au **8e alinéa du Préambule de**

1946, disposant que : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. »

SUJET 2. COMMENTAIRE

Conseil d'État, ordonnance du 29 avril 2022, Association comité action Palestine, n° 462736 (extraits)

L'article L 212-1 du Code de la sécurité intérieure prévoit qu'il soit possible de dissoudre une association si elle ne respecte pas des principes fondamentaux, si elle défend des positions qui vont contre la République et les droits fondamentaux.

Le président de la République a adopté un décret de dissolution de l'association comité action Palestine, sur le fondement de cette disposition législative le 9 mars 2022. Le décret fait en effet grief à l'association de promouvoir des propos et mener des actions antisémites par le biais d'un antisionisme radical, et de défendre des idées antirépublicaines par le biais d'une conception radicale de l'islam et d'une « légitimation » d'entreprises terroristes.

Considérant cette décision contraire aux droits fondamentaux, cette association saisit le juge des référés du Conseil d'État. Celui-ci considère les arguments de la partie demanderesse valable et suspend le décret. Il apparaît ainsi que la limite à la liberté d'association prévue à l'article du Code de la défense nationale précédemment citée n'est pas appréciée de manière large par le juge administratif. Comme le disait déjà le commissaire du Gouvernement Corneille dans son arrêt Baldy, « la liberté est la règle et la restriction de police l'exception. » (Conclusions sous l'arrêt : **Conseil d'État, 10 août 1917, Baldy**).

Après avoir constaté la recevabilité du référé– liberté **(I)**, le Conseil d'État suspend le décret de suspension de l'association requérante **(II)**.

I. La recevabilité du référé-liberté contre le décret de dissolution de l'association

L'association comité action Palestine est fondée à saisir le juge des référés. En effet, sa requête concerne les droits fondamentaux reconnus dans le cadre de **l'article L521-2 du Code de Justice administrative.**

Celui-ci dispose que : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »

Le décret attaqué est recevable tant du point de vue de l'urgence de la situation **(A)**, que de l'atteinte à une liberté fondamentale par une autorité publique **(B)**.

A. L'urgence de l'atteinte à la liberté d'association

Tout d'abord, le Conseil d'État considère que la demande de l'association est urgente « eu égard aux conséquences qui découlent d'une mesure de dissolution prise sur le fondement de l'article L 212-1 du code de la sécurité intérieure » (considérant 8). L'appréciation de l'urgence, dans le cadre du référé-liberté est particulière **(Conseil d'État, 4 février 2004, Commune d'Yvrac contre Gueguen)**. En effet, le délai de traitement d'un référé-liberté est très court : il est de 48 heures. Par conséquent, le juge du Palais-Royal estime que la condition d'urgence exigée à l'article L521-2 du Code de justice administrative est remplie s'il est impératif que la situation soit résolue en 48 heures (**Conseil d'État, 28 février 2003, Commune de Pertuis contre Pellenc**).

Le Conseil d'État estime donc qu'en l'espèce la dissolution d'une association est une problématique très urgente, qui doit être résolue dans les 2 jours suivant la demande en référé-liberté. L'étude de la recevabilité de ce référé-liberté montre donc l'importance de la liberté d'association pour le juge administratif français. Cela s'observe également en ce qui concerne le critère de l'atteinte à une liberté fondamentale par une autorité publique.

B. L'a**tteinte à une liberté fondamentale par une autorité publique**

Le décret de dissolution de l'association a été édicté par le président de la République et contresigné par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Il s'agit donc, pour le juge administratif, de préserver une liberté fondamentale par rapport à une personne morale de droit public dans l'exercice de ses prérogatives.

Aussi, la liberté entre bien dans le domaine protégé par l'article L521-2 du Code de justice administrative. Il n'y rien d'étonnant à cela lorsque l'on connaît l'histoire des libertés fondamentales en France. En effet, celles-ci sont protégées par une multitude de sources ; néanmoins, au niveau interne, c'est le bloc de constitutionnalité qui constitue le plus important corpus protecteur pour les libertés. Ce bloc, parfois également appelé normes de référence du contrôle de constitutionnalité, ne s'est pas créé *ex nihilo*. Il a été élaboré par le Conseil constitutionnel. À quelle occasion ? Pour protéger la liberté d'association d'une loi qui allait en limiter l'exercice ; c'est là la portée de la très célèbre décision « liberté d'association » (**Conseil constitutionnel, décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi de 1901 relative au contrat d'association)**.

Au surplus, l'emploi du vocable « liberté fondamentale » indique que ces dispositions sont réputées fonder l'ordre juridique français. Cette expression fait aujourd'hui florès dans la pratique. Elle s'est répandue dans plusieurs textes législatifs. Il faut remarquer que l'article L521-2 du Code de Justice administrative, lorsqu'il a été adopté par la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, a été sa première occurrence dans une législation française. En faisant entrer la liberté d'association, dans une conception large, au sein de la matière défendue sur le fondement de l'article L521-2 du Code de Justice administrative, le juge administratif manifeste donc également une définition de la liberté d'association. Il s'agit d'une liberté qui, parmi d'autres, fonde l'ordre juridique en ce qu'elle inspire toute sa matière.

La suspension du décret s'explique enfin par l'appréciation du Conseil d'État, qui constate une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'association engendrée par le décret. Cela s'observe bien à travers l'étude des fondements de la suspension du décret présidentiel.

II. Les fondements de la suspension du décret de dissolution de l'association

Les motifs avancés par l'exécutif français dans son décret sont insuffisants pour dissoudre l'association **(A)**. La suspension du décret qui en suit se place dans la continuité directe d'une longue histoire cherchant à encadrer le phénomène associatif tout en affirmant sa liberté **(B)**.

A. L'insuffisante motivation du décret de dissolution de l'association

Les motifs du décret de dissolution sont multiples. En effet, il y est soutenu que, tant par ses propres positions publiques (propos et messages diffusés sur internet, notamment) que celles de ses membres, l'association comité action Palestine enfreint des droits fondamentaux importants et de manière continue. Par voie conséquente, l'exécutif s'estime fondé à dissoudre cette association sur le fondement de l'article **L212-1 du Code de la sécurité intérieure**, qui dispose que :

« Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : (…)

6 ° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;

7 ° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.

Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application du présent article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l'organisation d'un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du Code pénal. »

Le Conseil d'État, sans remettre en cause la véracité des faits avancés comme motifs du décret, considère que les preuves sont insuffisantes pour justifier la dissolution de l'association, ou que ces mêmes faits n'entrent pas dans une catégorie juridique énoncée à l'article L221-1 du Code de la sécurité intérieure. Faute de motivation adéquate, la dissolution de l'association n'est pas fondée ; il s'agit d'une atteinte « grave et manifestement illégale » par rapport à la liberté d'association.

B. La conciliation historique entre encadrement et liberté des associations

La disposition législative du Code de la sécurité intérieure précédemment citée a été introduite par la **loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées**, qui visait à lutter contre les partis d'extrême-droite cherchant à mettre à bas le régime parlementaire de la IIIe République. Elle fût en effet adoptée en réaction aux émeutes du 6 février 1934. Cela montre une volonté politique précoce d'encadrer la liberté d'association, de la mettre en balance avec un principe sécuritaire.

Pour autant, le Conseil d'État, et plus généralement, tous les juges administratifs, effectuent un contrôle des actes de dissolution des associations afin de vérifier que la liberté d'association ne soit pas excessivement obérée. Il annule parfois les décrets de dissolution, comme dans le cas présent. Il confirme dans d'autres cas la dissolution (V. par exemple sur ce sujet : **Conseil d'État, ordonnance du 25 novembre 2020, Barakacity** ; V. aussi **Conseil d'État, ordonnance du 3 mai 2021, Génération identitaire**). Le Conseil d'État fait ainsi respecter la liberté d'association, protégée tant par la CESDH **(article 11)** que le bloc de constitutionnalité **(Conseil constitutionnel, décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi de 1901 relative au contrat d'association)**, dans le cadre du régime juridique qui la met en place.

SUJET 3. ARGUMENTATION

Soutenez que la liberté d'association est nécessaire à une société démocratique

L'article 11 de la CESDH dispose que : « toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. » Est-ce une liberté parmi d'autres ? Oui, il y en a d'autres ; mais non, pas tout à fait, c'est une liberté très particulière. En ce sens, la CEDH considère que cette liberté est « fondamentale » au sein d'une « société démocratique », que celle-ci ne peut pas exister véritablement sans elle (V. par exemple sur ce sujet : **CEDH, 20 février 2003, Djavit An contre Turquie**).

La liberté d'association est donc multiforme. Elle est une liberté individuelle puisqu'elle assure à chacun le droit de s'unir avec d'autres pour la réalisation d'un dessein partagé. Elle constitue aussi une liberté collective, car c'est elle qui donne le droit de se défendre à des groupes d'hommes et de femmes, à toutes les associations auxquelles ils ou elles participent. La liberté d'association est de surcroît une des conditions d'existence, pour tous les individus qui forment une société, de la démocratie (V. sur la nature de la liberté d'association : **CEDH, 17 février 2004, Gorzelick et autres contre Pologne).**

C'est ce dernier point qui la singularise. Il fait facilement sens. En effet, comment imaginer une élection sans qu'il y ait plusieurs partis politiques ? Comment imaginer une société libre et pluraliste, c'est-à-dire une société démocratique, sans que les personnes aient le droit d'affirmer, de promouvoir et défendre leurs idées et leurs intérêts ? La douceur de vie d'une société démocratique laisse parfois oublier l'importance de ces droits. La guerre d'Ukraine et le durcissement du régime politique russe peuvent nous rappeler qu'avant cela, face au régime totalitaire soviétique, des dissidents ont résisté à cette négation des droits fondamentaux. Que réclamaient-ils ? Les droits de l'homme et la possibilité de défendre leurs idées librement. Comment s'y prenaient-ils ? En s'associant clandestinement pour parvenir à leur but. On peut penser à ce sujet au groupe de la Charte 77, qui prit comme porte-parole Vlacav Havel, Jan Patočka et Jiří Hájek, et qui revendiqua l'application des droits de l'homme en Tchécoslovaquie face au régime soviétique de Brejnev.

Soutenir que la liberté d'association est nécessaire à une société démocratique est donc salutaire et utile, en plus d'être intéressant. Si elle est une condition d'existence d'une société démocratique **(I),** elle n'est pas pour autant infinie, elle doit être mise en balance avec d'autres libertés et d'autres doits fondamentaux, elle comporte des limites **(II).**

I. La liberté d'association comme condition nécessaire à une société démocratique

En ce qu'elle permet l'existence effective d'une société pluraliste, la liberté d'association est une condition nécessaire à l'existence d'une société démocratique **(A)** ; elle l'est d'autant plus en ce qui concerne les partis politiques **(B)**.

A. L'affirmation du pluralisme nécessaire à la société démocratique

Qui dit démocratie est obligé de dire pluralisme. En effet, un régime démocratique suppose qu'une population choisisse son avenir politique, détermine les règles qu'elle devra respecter. Si un Peuple n'a pas plusieurs choix lorsqu'il détermine sa politique, il est difficile de soutenir qu'il profite véritablement d'un régime démocratique. La démocratie en tant que régime politique implique en effet un pluralisme dans la société, suppose une ouverture sociétale. Une société démocratique est nécessairement traversée par différents courants de pensée, tel que chacun peut choisir entre l'un ou l'autre lorsqu'il est appelé aux urnes. La liberté d'association est un principe cardinal pour parvenir à la diffusion de plusieurs courants de pensée dans une société. Elle est protégée à **l'article 11 de la CESDH.** Aussi, depuis sa proclamation par le biais de la loi du 1er juillet 1901, elle a été élevée au rang constitutionnel, en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République, par le **Conseil constitutionnel (décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi de 1901 relative au contrat d'association).**

La **CEDH** affirme très clairement le lien entre la liberté d'association et la société démocratique. Elle l'a rappelé sans ambages à l'occasion de son **arrêt Gorzelik (et autres) contre Pologne du 17 février 2004**. Elle proclame ainsi que : « l'état de la démocratie (…) peut se mesurer à la manière dont la législation nationale consacre [la liberté d'association] et dont les autorités l'appliquent dans la pratique (…). Dans sa jurisprudence, la Cour a confirmé à de nombreuses reprises la relation directe entre la démocratie, le pluralisme et la liberté d'association et a établi le principe selon lequel seules des raisons convaincantes et impératives peuvent justifier des restrictions à cette liberté. L'ensemble de ces restrictions sont soumises à un contrôle rigoureux de la Cour. »

B. Le cas particulier des partis politiques

L'évidence invite à parler de la spécificité de la liberté d'association des partis politiques pour soutenir qu'il s'agit d'une liberté essentielle à la démocratie. Certes, les citoyens peuvent s'exprimer directement par la voie de référendums ou grâce à d'autres moyens de démocratie directe. Néanmoins, une démocratie parfaitement directe n'est qu'œuvre théorique dans un État aussi étendu que la France. La France, comme les autres États membres du Conseil de l'Europe, est avant tout une démocratie représentative. Par conséquent, elle organise des élections à l'occasion desquelles les citoyens ont le choix entre diverses voies politiques. Par exemple, lors des dernières élections présidentielles, les Français ont pu choisir entre des courants politiques aussi divers que le trotskisme de Nathalie Arthaud, la social-démocratie d'Anne Hidalgo, la gauche plus radicale de Jean-Luc Mélenchon, le libéralisme progressiste d'Emmanuel Macron ou le nationalisme d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen. Cette pluralité des partis permet à chaque individu de déterminer librement, en ayant un véritable choix, l'avenir politique de la nation dont il est le citoyen. À l'inverse, les régimes totalitaires marxistes et fascistes reposent sur l'idée d'un parti unique représentant le peuple à lui seul. La démocratie, si elle est proclamée, n'est alors qu'un leurre.

La CEDH considère donc, de manière générale, que les États parties à la CESDH ont une obligation positive de « garantir le bon fonctionnement d'une association ou d'un parti politique. » (**CEDH, 25 octobre 2005, Ouranio Toxo contre Grèce)**. Plus précisément, la CEDH considère que le pluralisme des partis doit particulièrement être protégé (**CEDH, 13 février 2003 Refah Partisi**).

II. Les limites de la liberté d'association utile à la société démocratique

La liberté d'association n'est pas illimitée. Il faut remarquer que ses limites sont conçues pour préserver une société démocratique, tant en période ordinaire **(A)** qu'en période extraordinaire **(B).**

A. Les limites à la liberté d'association en période ordinaire

En période ordinaire, de manière générale, la liberté d'association, comme toutes les libertés, doit être mise en balance avec les autres libertés. Il s'agit là d'une première limite à la liberté d'association.

Il est possible de retenir deux limites plus spécifiques.

En premier lieu, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant des principes de la République soumet l'obtention de financement public à la signature d'un contrat d'engagement républicain pour une association. Le Conseil constitutionnel estime que cela ne limite pas indûment la liberté d'association, car, les associations qui ne souhaitent pas signer ce contrat n'ont qu'à fonctionner de manière autonome, en dehors de tout financement public **(Conseil constitutionnel, décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, loi confortant le respect des principes de la République**). À défaut d'être une limite à la liberté d'association, il s'agit d'une contrainte à son plein exercice. Bien que cela soit critiquable, l'intention du législateur, en instaurant cette contrainte, est de limiter l'expansion d'associations qui pourraient contester l'ordre républicain et la société démocratique qu'il suppose autant qu'il permet.

En second lieu, **l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure** dispose qu'il est possible de dissoudre une association qui provoque des manifestations armées ou violentes (1 °), qui se constituent en une milice paramilitaire (2 °), qui vise à contester l'intégrité du territoire ou la forme républicaine du gouvernement (3 °) ainsi que la légalité républicaine (4 °). Une association, sur le fondement de ce même article du Code de la Sécurité intérieure, peut être dissoute si elle rassemble ou célèbre des individus ayant été condamnés pour collaboration avec l'ennemi (5 °). Enfin, toutes les associations qui incitent à la haine ou à la violence envers une catégorie déterminée de population (6 °), ou qui promeuvent une action terroriste (7 °) peuvent être dissoutes.

À nouveau, on observe que les limites au principe ou à l'exercice de la liberté d'association sont mises en place avec le but de protéger la société d'atteintes graves aux libertés fondamentales et à l'ordre public. Autrement dit, elle protège la société de ce qui pourrait l'éloigner de la démocratie et du pluralisme qu'elle suppose. Même lorsqu'on observe les limites à la liberté d'association, elles sont encore utiles, si ce n'est nécessaire à l'existence d'une société démocratique.

B. Les limites à la liberté d'expression en période extraordinaire

Au cours d'une période extraordinaire, la mise en balance des libertés les unes par rapport aux autres est transformée. La lutte contre le péril qui appelle l'état exceptionnel du droit fait primer un droit, souvent la sécurité, sur les autres. La liberté d'association ne s'efface pas, mais voit son exercice réduit parfois considérablement.

Plusieurs périodes extraordinaires, avec des régimes juridiques distincts, impliquent en effet des limitations à la liberté d'association. Cette limitation peut être critiquée, et l'est souvent ; néanmoins l'esprit de ces mécanismes juridiques est bien de préserver l'État de droit et, plus généralement, les conditions d'existence de la société démocratique, dont la liberté d'association est un des éléments clefs.

Il existe des périodes extraordinaires d'origine jurisprudentielle (**Conseil d'État, 28 juin 1918, Heyriès)**, législative (**l'état d'urgence et l'état d'urgence sanitaire)** ainsi que constitutionnelle (**articles 16 sur les pouvoirs présidentiels et 36 sur l'état de siège**).

À chaque fois qu'un de ces états exceptionnels du droit s'ouvre, la liberté d'association peut être réduite. Par exemple, **l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril du 1955 sur l'état d'urgence** dispose que : « sont dissous par décret en conseil des ministres les associations ou groupements de faits qui participent à la commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent. » Dans le même sens, les limitations drastiques à la liberté d'aller et venir potentiellement imposées pendant un état d'urgence sanitaire réduisent *de facto* l'exercice de la liberté d'association. Comment observer une vie associative active lorsque personne n'est en droit de sortir de chez soi –ou si peu ?

Il apparaît donc une nouvelle fois que la liberté d'association partage une caractéristique avec ses limites. Les limitations au principe ou à l'exercice de la liberté d'association sont mises en place avec le but de protéger la société d'atteintes graves aux libertés fondamentales et à l'ordre public. Bien que toute période extraordinaire comporte des risques pouvant compromettre la protection des libertés fondamentales, son but premier est de protéger la société de ce qui pourrait l'éloigner de l'État de droit, de la démocratie et du pluralisme.

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2023

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 1 – La liberté d'expression

1. Dissertation
2. Commentaire
3. Argumentation

1. Sujet – Dissertation

Les limites de la liberté d'expression

Présentation du sujet

- la liberté est une absence de contrainte.
- L'expression est l'action d'exprimer quelque chose (opinion, etc) par le langage oral ou écrit, par le corps, l'art…
- La liberté d'opinion et d'expression implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
- La liberté d'expression est protégée au ttire de DLF **(droits et libertés fondamentaux)**. Ces derniers correspondent à un ensemble de prérogatives personnelles qu'une société donnée estime être fondamentales. À ce titre, elles leur confèrent la place la plus élevée dans la hiérarchie des normes. C'est un ensemble de droits considérés comme fondamentaux, proclamés comme tels dans les sources juridiques, et opposables à l'État et aux personnes publiques.

I. La nécessaire liberté d'expression

La liberté d'expression est reconnue depuis la Révolution française en droit français et connaître les fondements textuels :

- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789) :
  - Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ».
  - Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi
- Déclaration universelle des Droits de l'Homme :
  - « Article 18 - Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. »
  - « Article 10 - Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. »
- Chartes des droits fondamentaux de l'Union européenne :
  - Article 1 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
- Convention européenne des droits de l'homme :
  - Article 10. 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».

La liberté d'expression est une une condition de la liberté de la pensée et qu'elle exprime l'identité et l'autonomie intellectuelles des individus. Par là, elle conditionne leurs relations aux autres individus et à la société. La liberté d'expression est une manifestation de la liberté de la pensée.

Dans la jurisprudence de la CEDH (Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A n° 24), l'exigence de pluralisme sert de fondement à la nécessité de la protection des propos qui heurtent, choquent ou inquiètent.

La liberté d'expression garantit la clarté du débat démocratique. F. Sudre la définit comme un « droit hors du commun ».

- Comme le dit la Cour EDH (Müller et autres c. Suisse, arrêt du 24 mai 1988, série A n° 133) : « Ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une oeuvre d'art contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensables à une société démocratique.
- CC 28 février 2012 : *« la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ».*
- D'un point de vue historique (**pour nourrir le débat)** : La liberté d'expression est un acquis provenant du courant des Lumières (XVIIIe siècle). L'individualisme, couplé avec l'abolition des privilèges, particulièrement dans la France de 1789, ou, aux États-Unis, avec celle de toute forme de soumission à un pouvoir, a consacré le rôle central de l'homme dans l'organisation démocratique de la vie sociale et a développé, par là, la nécessité pour chacun de s'exprimer librement (auparavant, cette liberté était auparavant dévolue aux seules autorités royales et religieuses).

La liberté d'expression découle la liberté d'accès aux différents moyens d'expression. Cette liberté s'applique à toutes les formes et à tous les supports de l'information (Presse ; Audiovisuel ; Spectacles).

II. Une liberté non absolue

La liberté d'expression, aussi importante qu'elle soit dans la société, est assortie de <u>limites pour ne pas entraver d'autres libertés :</u>

- Ne pas porter atteinte à la vie privée et au droit à l'image d'autrui
- Ne pas tenir de propos diffamatoires : la diffamation se définit par toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne
- Ne pas tenir certains propos interdits par la loi : l'apologie du terrorisme, les propos discriminatoires à raison d'orientations sexuelles ou d'un handicap, l'incitation à l'usage de produits stupéfiants, le négationnisme
- Ne pas tenir de propos injurieux

Il existe des limites liées à certaines catégories de personnes :

- Contrôle des publications destinées à la jeunesse : Il s'agit d'un régime préventif souple avec l'intervention d'une commission auprès du ministre de la justice (loi du 16 juillet 1949 modifiée par la loi du 4 janvier 1967). En cas d'atteinte à la jeunesse, peut être pris un arrêté du ministre de la justice interdisant la vente aux mineurs.

2. **Sujet – Argumentation**

Soutenez que l'on ne peut pas tout dire

Présentation du sujet

Le sujet renvoie directement à la liberté d'expression

- la liberté est une absence de contrainte.
- L'expression est l'action d'exprimer quelque chose (opinion, etc) par le langage oral ou écrit, par le corps, l'art…
- La liberté d'opinion et d'expression implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
- La liberté d'expression est protégée au ttire de DLF **(droits et libertés fondamentaux)**. Ces derniers correspondent à un ensemble de prérogatives personnelles qu'une société donnée estime être fondamentales. À ce titre, elles leur confère la place la plus élevée dans la hiérarchie des normes. C'est un ensemble de droits considérés comme fondamentaux, proclamés comme tels dans les sources juridiques, et opposables à l'État et aux personnes publiques.

La liberté d'expression est reconnue depuis la Révolution française en droit français et connaître les fondements textuels :

- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789) :
    - Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ».
    - Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi
- Déclaration universelle des Droits de l'Homme :
    - « Article 18 - Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. »
    - « Article 10 - Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. »
- Chartes des droits fondamentaux de l'Union européenne :
    - Article 1 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
- Convention européenne des droits de l'homme :
    - Article 10. 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,

à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».

I. Une liberté non absolue

A- La nécessaire protection d'autres libertés

La liberté d'expression, aussi importante qu'elle soit dans la société, est assortie de <u>limites pour ne pas entraver d'autres libertés :</u>

- Ne pas porter atteinte à la vie privée et au droit à l'image d'autrui
- Ne pas tenir de propos diffamatoires : la diffamation se définit par toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne
- Ne pas tenir certains propos interdits par la loi : l'apologie du terrorisme, les propos discriminatoires à raison d'orientations sexuelles ou d'un handicap, l'incitation à l'usage de produits stupéfiants, le négationnisme
- Ne pas tenir de propos injurieux

B- La nécessaire protection de certaines personnes

Il existe des limites liées à certaines catégories de personnes :

- Contrôle des publications destinées à la jeunesse : Il s'agit d'un régime préventif souple avec l'intervention d'une commission auprès du ministre de la justice (loi du 16 juillet 1949 modifiée par la loi du 4 janvier 1967). En cas d'atteinte à la jeunesse, peut être pris un arrêté du ministre de la justice interdisant la vente aux mineurs.

II. Une limitation dangeureuse

La liberté d'expression ne doit pas être trop limitée.

A- L'expression de la liberté de penser

La liberté d'expression est une une condition de la liberté de la pensée et qu'elle exprime l'identité et l'autonomie intellectuelles des individus. Par là, elle conditionne leurs relations aux autres individus et à la société.

La liberté d'expression est une manifestation de la liberté de la pensée.

Dans la jurisprudence de la CEDH (Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A n° 24), l'exigence de pluralisme sert de fondement à la nécessité de la protection des propos qui heurtent, choquent ou inquiètent.

B- La garantie du débat démocratique

La liberté d'expression garantit la clarté du débat démocratique. F. Sudre la définit comme un « droit hors du commun ».

- Comme le dit la Cour EDH (Müller et autres c. Suisse, arrêt du 24 mai 1988, série A n° 133) : « Ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une oeuvre d'art contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensables à une société démocratique.
- CC 28 février 2012 : *« la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ».*
- D'un point de vue historique (**pour nourrir le débat)** : La liberté d'expression est un acquis provenant du courant des Lumières (XVIIIe siècle). L'individualisme, couplé avec l'abolition des privilèges, particulièrement dans la France de 1789, ou, aux États-Unis, avec celle de toute forme de soumission à un pouvoir, a consacré le rôle central de l'homme dans l'organisation démocratique de la vie sociale et

a développé, par là, la nécessité pour chacun de s'exprimer librement (auparavant, cette liberté était auparavant dévolue aux seules autorités royales et religieuses).

De la liberté d'expression découle la liberté d'accès aux différents moyens d'expression. Cette liberté s'applique à toutes les formes et à tous les supports de l'information (Presse ; Audiovisuel ; Spectacles).

---

3. Commentaire

Article 10 Convention européenne des droits de l'homme

« Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations ».

« L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».

Présentation du sujet

Source : La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, communément appelée Convention européenne des droits de l'homme, est un traité international signé par les États membres du Conseil de l'Europe le 4 novembre 1950 et entré en vigueur le 3 septembre 1953. Elle a pour but de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales en permettant un contrôle judiciaire du respect de ces droits individuels. La Convention se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Le respect des obligations par les États parties à la CEDH est contrôlé dans le cadre d'une procédure de plainte individuelle ou étatique.

Sujet : Le texte évoque la Liberté d'expression

- la liberté est une asbence de contrainte.
- L'expression est l'action d'exprimer quelque chose (opinion, etc) par le langage oral ou écrit, par le corps, l'art…
- La liberté d'opinion et d'expression implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
- La liberté d'expression est protégée au ttire de DLF **(droits et libertés fondamentaux)**. Ces derniers correspondent à un ensemble de prérogatives personnelles qu'une société donnée estime être fondamentales. À ce titre, elles leur confère la place la plus élevée dans la hiérarchie des normes. C'est un ensemble de droits considérés comme fondamentaux, proclamés comme tels dans les sources juridiques, et opposables à l'État et aux personnes publiques.

Éléments de réponse

Deux idées, clairement indiquées dans le texte, doivent être mises en lumière:

- la liberté d'expression doit être protégée comme DLF

- la liberté d'expression ne peut pas être absolue. Les Etats peuvent mettre en place des sytèmes de contrôle de la presse.

I. La reconnaissance de la liberté d'expression

La liberté d'expression est reconnue depuis la Révolution française en droit français et connaître les fondements textuels :

- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789) :
  - Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ».
  - Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi
- Déclaration universelle des Droits de l'Homme :
  - « Article 18 - Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. »
  - « Article 10 - Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. »
- Chartes des droits fondamentaux de l'Union européenne :
  - Article 1 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
- Convention européenne des droits de l'homme :
  - Article 10. 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».

II. La nécessité de la liberté d'expression

La liberté d'expression est une condition de la liberté de la pensée et qu'elle exprime l'identité et l'autonomie intellectuelles des individus. Par-là, elle conditionne leurs relations aux autres individus et à la société.

La liberté d'expression est une manifestation de la liberté de la pensée.

Dans la jurisprudence de la CEDH (Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A n° 24), l'exigence de pluralisme sert de fondement à la nécessité de la protection des propos qui heurtent, choquent ou inquiètent.

La liberté d'expression garantit la clarté du débat démocratique. F. Sudre la définit comme un « droit hors du commun ».

- Comme le dit la Cour EDH (Müller et autres c. Suisse, arrêt du 24 mai 1988, série A n° 133) : « Ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une oeuvre d'art contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensables à une société démocratique.

- CC 28 février 2012 : *« la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ».*
- D'un point de vue historique (**pour nourrir le débat)** : La liberté d'expression est un acquis provenant du courant des Lumières (XVIIIe siècle). L'individualisme, couplé avec l'abolition des privilèges, particulièrement dans la France de 1789, ou, aux États-Unis, avec celle de toute forme de soumission à un pouvoir, a consacré le rôle central de l'homme dans l'organisation démocratique de la vie sociale et a développé, par là, la nécessité pour chacun de s'exprimer librement (auparavant, cette liberté était auparavant dévolue aux seules autorités royales et religieuses).

La liberté d'expression découle la liberté d'accès aux différents moyens d'expression. Cette liberté s'applique à toutes les formes et à tous les supports de l'information (Presse ; Audiovisuel ; Spectacles).

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2023

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 2 – L'euthanasie

1. Dissertation
2. Argumentation
3. Commentaire

1. Sujet – Dissertation

L'interdiction de l'euthanasie

Présentation du sujet

L'euthanasie consiste à faire usage des procédés qui permettent de hâter ou de provoquer la mort de malades incurables qui souffrent et souhaitent mourir. Elle n'est pas reconnue par les DLF (droits et libertés fondamentaux).

Les DLF (droits et libertés fondamentaux) correspondent à un ensemble de prérogatives personnelles qu'une société donnée estime être fondamentales. À ce titre, elles leur confèrent la place la plus élevée dans la hiérarchie des normes. C'est un ensemble de droits considérés comme fondamentaux, proclamés comme tels dans les sources juridiques, et opposables à l'État et aux personnes publiques.
Contraire : qui ne s'accorde pas avec l'usage qu'on veut en faire, qui ne convient pas à la destination qu'on lui donne ; inapproprié.

Le droit français garantit un apaisement des souffrances dans l'accompagnement fin de vie :

- La loi du 2 février 2016 « créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie » renforce la libre disposition de sa vie. Si en apparence elle ne consacre pas un droit à mourir quand la personne le souhaite, elle autorise, en fin de vie, le recours à une sédation profonde et irréversible en même temps que l'arrêt de l'hydratation et de la nutrition qui entraînent la mort : « Toute personne a droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance ». (art. L. 1110-5, CSP).

I. L'interdiction, un principe

A. Un droit à la mort ?

En droit français, le suicide est toléré. Ni le suicide ni la tentative de suicide ne sont une infraction pénale. C'est une prérogative personnelle ajuridique (X. Bioy, Droits fondamentaux et libertés publiques, p. 363). Il n'existe pas un droit au suicide, droit subjectif dont l'individu serait titulaire et portant sur sa vie. B. Mathieu explique que le suicide doit être conçu comme une liberté autonome. La relation de la personne avec sa vie relève à tel point de son intimité, que la société ne peut s'y immiscer. L'État ne reconnaît aucun droit particulier, il n'intervient pas. En revanche, la provocation au suicide est punie depuis la loi du 31 décembre 1987. En effet, si le droit français n'incrimine pas le suicide, il punit tout agissement d'autrui en sa faveur. Par ailleurs, une question demeure largement débattue, notamment lors des débats parlementaires concernant la loi Claeys-Leonetti de 2016, il s'agit du suicide assisté.

Comme l'a souligné B. Beignier, il existe un droit de la mort qui va de la loi Leonetti du 22 avril 2005 sur la fin de vie jusqu'au droit relatif aux funérailles et aux sépultures. Il n'existe pas un droit à la mort, la Cour européenne des droits de l'homme (Décision Pretty, 29 avril 2002) et la Cour suprême des États-Unis (26 juin 1997) sont d'accord sur ce point. Le fait que le droit français ne se prononce pas sur le suicide ne signifie nullement qu'il en découle un droit subjectif ; le suicide n'est pas un droit, c'est une liberté civile. Plus exactement, selon la récente jurisprudence du Conseil d'État, c'est une liberté personnelle. Et en la matière, le droit s'abstient.

Il n'en est pas de même concernant l'euthanasie.

Il faut savoir que l'euthanasie implique l'assistance d'un tiers et qu'elle est rigoureusement interdite en France autant par la déontologie médicale que par la loi.

- Article R4127-38 du code de la santé publique : « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort »
- La Cour de Strasbourg, elle a jugé dans l'affaire Pretty c/R.U., le 29 Avril 2002 que le droit à la vie ne saurait être interprété comme conférant à une personne le droit symétrique de mourir avec l'assistance d'un tiers.

B. L'exemple de l'affaire Lambert

On peut évoquer l'affaire Vincent Lambert :

- En 2008, après un accident de voiture, Vincent Lambert est tétraplégique et est plongé dans un état végétatif.
- En avril 2013, avec l'accord de son épouse, les médecins, dans le cadre de la loi Leonetti, ont décidé d'arrêter son hydratation et son alimentation. Les parents avaient alors saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui le 10 mai a remis en cause la décision du corps médical. Les soins ont donc repris.
- Fin 2013, la procédure collégiale, dans le cadre de la loi Leonetti, est de nouveau engagée. Encore une fois, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne donne raison aux parents. Mais le CHU de Reims, ainsi que la femme et le neveu de Vincent Lambert, saisissent le Conseil d'État, plus haute instance du droit administratif français. Cette juridiction leur donne raison le 24 juin 2014
- Quelques heures plus tard, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), saisie par les parents et la famille de Vincent Lambert, ordonne à titre conservatoire la suspension provisoire du jugement du Conseil d'État. Il faudra attendre un an, le 5 juin 2015, pour que la CEDH valide la légalité de l'arrêt des soins. Un recours est déposé par la famille, il est refusé durant l'été.
- L'arrêt des soins aurait donc pu être enclenché, mais le 23 juillet, les médecins décident de ne pas stopper l'alimentation et l'hydratation, considérant que « les conditions de sérénité et de sécurité nécessaire à la poursuite de cette procédure, tant pour Vincent Lambert que pour l'équipe soignante, ne sont pas réunies ».
- Le 19 juillet 2017, le Conseil d'État confirme l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Nancy durant l'été 2016, qui explique que la procédure d'arrêt des soins doit être recommencée de zéro, le médecin responsable de Vincent Lambert n'étant plus le même.
- En avril 2018, le docteur Sanchez annonce sa décision « d'arrêter les traitements », à la suite d'une procédure collégiale. Il faudra attendre un an et la saisie de l'ensemble des juridictions jusqu'au Conseil d'État, qui estimera le 24 avril 2019 que la décision d'arrêt des soins prise le 9 avril 2018 par le CHU de Reims est légalement justifiée.
- Le 30 avril 2019, la Cour européenne des droits de l'Homme rejette le recours des parents de Vincent Lambert et confirme la décision prise par le Conseil d'État.
- Deux semaines après, le tribunal administratif de Paris rejette lui aussi un recours en urgence des parents de Vincent Lambert. L'arrêt des soins commence donc le 20 mai 2019, dans la matinée, après que la CEDH ait rejeté un énième recours des parents. Mais le soir même, la cour d'appel de Paris ordonne la reprise des traitements « afin de faire respecter les mesures provisoires demandées par le Comité international des droits des personnes handicapées le 3 mai 2019 tendant au maintien de l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert ».

Il faut rappeler que l'euthanasie pourrait très vite être assortie de dérives largement attentatoires aux droits, notamment au droit à la vie

- Cette forme d'assistance à la mort reste interdite dans la plupart des pays car trop dangereuse et particulièrement dans une période où le vieillissement de la population peut faire craindre que des esprits peu scrupuleux la préconisent pour des raisons économiques.

II. La primauté du droit à la vie

A. Le rejet d'un droit à l'euthanasie

Étymologiquement, euthanos signifie la bonne mort. L'euthanasie est le droit de décider de sa propre mort. Autrefois synonyme de mort calme et sans souffrance, ce terme est défini comme la pratique qui consiste à provoquer la mort d'un malade incurable, afin d'abréger ses souffrances (Dictionnaire de médecine, Flammarion). On distingue l'euthanasie active, qui consiste à agir pour donner la mort, et l'euthanasie passive selon laquelle l'arrêt des traitements entraîne le décès de l'individu. La prise en charge médicale de la fin de vie a progressivement été encadrée par le droit.

Après un grave accident de la route en 2000, V. Humbert, ne supportant plus sa vie sans espoir de guérison, entreprend de nombreuses démarches pour obtenir le droit d'être euthanasié. Il écrit au président de la République auquel il demande un « droit de mourir ». Ce jeune tétraplégique relance alors un débat ancien. Le médecin qui avait accepté de l'aider à mourir a été mis en examen pour empoisonnement avec préméditation, il bénéficiera d'un non-lieu en 2006. Ce type d'agissement n'est généralement pas poursuivi pénalement, en 1988, le professeur Schwartzenberg a reconnu avoir pratiqué l'euthanasie à plusieurs reprises. En 2015, le docteur Bonnemaison a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis par la Cour d'assise du Maine-et-Loire et radié de l'ordre des médecins par le Conseil de l'ordre pour avoir délibérément provoqué la mort de trois de ses patientes, décision confirmée par le Conseil d'État. Le 11 avril 2019, la CEDH a rejeté sa requête contre sa radiation de l'Ordre des médecins. Ces affaires ont contribué à relancer le débat sur l'euthanasie en France.

Un rapport rendu en 2004, « Vivre ou laisser mourir. Respecter la vie, accepter la mort », précède le vote de la loi Leonetti du 22 avril 2005 sur les droits des malades et la fin de vie. Elle s'inscrit dans le prolongement de la loi de 2002 sur les droits des malades qui autorisait la suspension des soins médicaux dès qu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Le médecin peut renoncer à l'acharnement thérapeutique en s'efforçant de développer les soins palliatifs et de ménager au mourant une fin qui sauvegarde sa dignité.

Cette loi comprend trois dispositions essentielles : l'interdiction de toute obstination déraisonnable, le renforcement des droits du patient et la mise en place d'un processus décisionnel en cas de patient inconscient ou d'arrêt des traitements qui repose sur la collégialité et la transparence. L'un des apports majeurs de la loi concerne l'expression des malades en fin de vie qui suppose que lorsqu'un malade en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable décide de limiter ou d'arrêter son traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informé des conséquences de son choix. Le texte précise que toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Le médecin en tiendra compte pour toute décision, à la seule condition qu'elles aient été rédigées moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne.

B. La prise en compte de la souffrance des malades en fin de vie

Les procédures de limitation et d'arrêt des traitements, instituées par la loi Leonetti, ont connu plusieurs améliorations. Ainsi en est-il du décret du 29 janvier 2010 relatif aux conditions de mise en œuvre des décisions de limitation ou d'arrêt de traitement, mais également du Programme national de développement des soins palliatifs 2008-2012 prolongé par un plan national 2015-2018, de la

création de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie par la loi du 2 mars 2010 ou encore de la mise en place de l'Observatoire national de la fin de vie par le décret du 19 février 2010. Par la suite, la loi n° 2016-87 Claeys Leonetti, du 2 février 2016, crée de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Cette loi met en place un « droit de dormir avant de mourir pour ne pas souffrir ». Si cette pratique sédative existait déjà dans les hôpitaux français, elle n'était ni générale ni homogène. Un médecin ne peut pas s'opposer à une demande de sédation profonde et continue de la part d'un patient atteint d'une « affection grave et incurable », dont le « pronostic vital est engagé à court terme » et qui présente une « souffrance réfractaire aux traitements ». Ou lorsque sa « décision d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable ».

Les directives anticipées, par lesquelles il est possible de faire connaître son refus d'un acharnement thérapeutique, jusque-là simplement indicatif, s'imposent désormais au médecin. Le soignant peut y déroger « en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation » et lorsqu'elles « apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale ».

Le refus de l'acharnement thérapeutique suppose, en vertu de l'article L.1110-5 du Code de la santé publique, que les actes de soin ne soient pas poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils sont inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le maintien artificiel de la vie, ils doivent être suspendus.

D'autres affaires ont médiatisé la problématique de la fin de vie, notamment pour les mineurs. L'arrêt du Conseil d'État du 8 mars 2017, APHP à propos d'une enfant âgée d'un an, maintenue artificiellement en vie et pour laquelle le médecin a considéré que la poursuite des traitements constituait une obstination déraisonnable. En 2018, le Conseil d'État s'est également prononcé sur le cas d'une jeune fille de 14 ans (Conseil d'État, 5 janv. 2018, Biddari) confirmant l'arrêt des soins, le traitement étant considéré comme une obstination déraisonnable.

Sans surprise, cette question est au cœur des États généraux de la bioéthique qui se sont déroulés en 2018. Dans son avis n° 129, rendu le 25 septembre 2018, le CCNE propose de ne pas modifier la loi existante sur la fin de vie Claeys-Leonetti et insiste sur l'impérieuse nécessité que cette loi soit mieux connue, mieux appliquée et mieux respectée.

2. Sujet - Commentaire

Cour EDH, Grande chambre, 5 juin 2015, Lanbert et autres contre France, n°46043/14:

> « La loi n'autorise ni l'euthanasie ni le suicide assisté. Elle ne permet au médecin d'interrompre un traitement que si sa poursuite manifeste une obstination déraisonnable (autrement dit, relève de l'acharnement thérapeutique) et selon une procédure réglementée. »

Présentation du sujet

Présentation de l'arrêt : L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) du 5 juin 2015 a pour particularité de déterminer si une personne peut subir un arrêt de ses traitements, alors qu'il est dans l'incapacité d'exprimer sa volonté clairement. Cette question soulevant celle de la violation de l'article 2 de la Conv. EDH, relatif au droit à la vie, a opposé les membres de la Grande Chambre, cinq juges ayant exprimé une opinion dissidente avec une grande fermeté, par rapport non seulement à l'arrêt, mais également à la protection offerte par la Convention. La Cour s'est largement appuyée sur le principe de subsidiarité pour conforter la solution du Conseil d'État du 24 juin 2014.

À l'origine des faits, il y a Vincent Lambert qui souffre d'un grave traumatisme crânien, victime d'un accident de moto. Il est alors tétraplégique et entièrement dépendant. Après des hospitalisations dans divers établissements, il est soigné au CHU de Reims. Il y bénéficie d'une hydratation et d'une alimentation artificielles par voie entérale au moyen d'une sonde gastrique. Son état est aujourd'hui qualifié de végétatif, cependant il respire sans appareillage et n'a pas d'autres soins. En 2013, après plusieurs semaines de réflexion et d'échanges entre le personnel médical, son épouse et une partie de la famille, le médecin en charge a décidé d'arrêter la nutrition et de réduire l'hydratation. Les parents de Vincent Lambert, qui n'avaient pas été consultés à l'époque ni informés de la décision prise par le corps médical, ont saisi le juge des référés afin que la décision cesse d'être appliquée. Ce juge a fait droit à leur demande. Une nouvelle décision fut prise d'arrêter les soins le 11 janvier 2014 par le médecin. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (16 janv. 2014, n° 1400029) puis le Conseil d'État ont été saisis. La décision du Conseil d'État est intervenue le 24 juin 2014.

Dans cette décision, les juges du Palais Royal ont jugé que la loi Leonetti du 22 avril 2005, relative au droit des malades et à la fin de vie était applicable et que l'hydratation et l'alimentation artificielles constituaient des traitements qui pouvaient être arrêtés en cas d'obstination déraisonnable. Après avoir en outre demandé une expertise médicale, le Conseil d'État s'est prononcé en faveur de la légalité de la décision, en insistant sur l'exigence de prendre en considération la volonté du patient. Il a jugé conforme à la loi et à la Convention européenne des droits de l'homme l'exécution de la décision médicale d'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation artificielles de Vincent Lambert.

C'est au regard de cette décision du Conseil d'État que les parents ont choisi de saisir la CEDH. Il a été sursis à l'exécution de cette mesure dans l'attente d'un examen de l'affaire par la Cour. La procédure de l'article 39 du règlement de la Cour EDH, permet de décider de mesures provisoires uniquement s'il y a « un risque imminent de dommage irréparable » dont la suspension de l'exécution d'un arrêt pour la durée de la procédure devant la Cour. La CEDH a également décidé que la procédure au fond sera traitée en priorité, en vertu de l'article 41 du règlement de la juridiction.

Avant de revenir sur le fond, la recevabilité de la requête doit être évoquée. En effet, les parents voulaient agir au nom et pour le compte de leur fils. La Cour leur a refusé au regard des critères de sa jurisprudence (notamment CEDH, 22 juill. 2003, Y. F. C/ Turquie, n° 24209/94). Pour la Cour, il n'existe pas de risque que Vincent Lambert soit privé d'une protection effective. En effet, les proches peuvent invoquer en leur nom le droit à la vie protégé par l'article 2 de la Convention. Ensuite, il n'y a selon la Cour aucune convergence d'intérêts entre les requérants et Vincent Lambert. Il est vrai que les parents semblent exprimer une position différente de celle que leur fils aurait pu choisir. Cependant, aucune directive anticipée ne permet d'affirmer clairement cette divergence. Dès lors les

parents de Vincent Lambert n'ont pu intervenir qu'en leur propre nom, position de la Cour qui a largement été contestée par les juges ayant une opinion dissidente.

Sur le fond, la Cour européenne se prononce sur le seul article 2 de la Convention, bien que les requérants aient invoqué également l'article 8 relatif au droit à la vie privée et l'article 3 sur les traitements inhumains et dégradants. Cependant la Cour intègre l'article 8 dans son raisonnement sur la violation de l'article 2, justifiant qu'elle ne se prononce pas spécifiquement sur sa violation.

Sous l'angle de l'article 2, la Cour écarte la question des obligations négatives, qui imposent aux États de s'abstenir de donner la mort intentionnellement. En effet, la loi Leonetti n'autorise pas l'euthanasie ou le suicide assisté. Cette loi permet uniquement d'arrêter un traitement si sa poursuite est la traduction d'une obstination déraisonnable. La Cour s'en tient en conséquence aux obligations positives issues de l'article 2 de la Convention qui impose aux États de prendre les mesures nécessaires de protection à la vie des personnes. À partir de cette approche, la Cour reprend son raisonnement traditionnel en déterminant si l'État dispose d'une marge d'appréciation. Les juges retiennent l'existence d'une marge d'appréciation étant donné qu'il n'existe pas de consensus sur l'arrêt des traitements artificiels. La Cour recherche alors si une violation existe tant par rapport à la clarté de la loi, au processus décisionnel et aux recours juridictionnels.

Sur le premier point, la Cour va rechercher au regard des moyens soulevés si la loi Leonetti présente une absence de clarté et de précision, notamment par rapport aux notions d'obstination déraisonnable et de traitement. En outre, les parents estimaient que la loi ne pouvait s'appliquer à leur fils, celui-ci n'étant pas en fin de vie ou malade, contrairement au champ d'application posé par la loi. Après examen, la Cour reconnaît que la loi peut s'appliquer à Vincent Lambert, puisqu'au regard de la décision du Conseil d'État et des travaux préparatoires de la loi, celle-ci s'adresse à tous les usagers et non simplement aux personnes malades ou en fin de vie. En outre il est jugé que la loi française répond aux exigences de la Convention, eu égard aux précisions apportées par le Conseil d'État et par les dispositions du code de la santé publique (art. L. 1110-5 sur l'obstination déraisonnable). Dès lors, le cadre législatif est suffisamment clair aux fins de l'article 2 de la Convention.

Dans un second point, la Cour s'attache aux conditions de la prise de décision, autrement dit, elle s'attarde sur la détermination de la volonté du malade telle que le Conseil d'État l'a retenue. La Cour remarque que les États font jouer un rôle primordial à la volonté du patient dans la prise de décision, mais que la décision finale peut être confiée à différentes personnes. En conséquence, les modalités sont multiples, notamment quand il y a absence de directive anticipée de la part du patient et que par ailleurs, l'article 2, comme la jurisprudence n'impose aucune obligation. Au regard de la marge d'appréciation laissée aux États membres, la Cour juge qu'en l'espèce, la procédure collégiale est conforme à l'article 2, d'autant plus que le CHU de Reims a été au-delà des préconisations de la loi. En effet plusieurs médecins ont été consultés, ainsi que l'équipe soignante, tout comme la famille. La décision du médecin a enfin été longuement motivée. La procédure a été ainsi longue et méticuleuse selon les mots de la Cour.

Dans un troisième point, la Cour revient sur l'effectivité des recours juridictionnels. La Cour note qu'ils sont réels au regard des pouvoirs du juge, y compris en référé. Des expertises ont pu être menées à bien et de manière complète. Le contrôle a également porté sur la volonté du patient. La Cour précise que cette volonté a été recherchée, le Conseil d'État ayant pris en considération des témoignages familiaux liés à la personnalité et à l'histoire de Vincent Lambert. La position de sa femme, elle-même infirmière comme Vincent Lambert, qui avait évoqué ensemble ce sujet des traitements artificiels, a été intégrée dans la décision du Conseil d'État. La Cour en conclut logiquement à l'absence de violation, rappelant la complexité éthique et juridique de l'affaire.

Thème du sujet : L'euthanasie consiste à faire usage des procédés qui permettent de hâter ou de provoquer la mort de malades incurables qui souffrent et souhaitent mourir. Elle n'est pas reconnue par les DLF (droits et libertés fondamentaux).

Les DLF (droits et libertés fondamentaux) correspondent à un ensemble de prérogatives personnelles qu'une société donnée estime être fondamentale. À ce titre, elles leur confèrent la place la plus élevée dans la hiérarchie des normes. C'est un ensemble de droits considérés comme

fondamentaux, proclamés comme tels dans les sources juridiques, et opposables à l'État et aux personnes publiques.
Contraire : qui ne s'accorde pas avec l'usage qu'on veut en faire, qui ne convient pas à la destination qu'on lui donne ; inapproprié.

Textes : Le droit français garantit un apaisement des souffrances dans l'accompagnement fin de vie :

- La loi du 2 février 2016 « créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie » renforce la libre disposition de sa vie. Si en apparence elle ne consacre pas un droit à mourir quand la personne le souhaite, elle autorise, en fin de vie, le recours à une sédation profonde et irréversible en même temps que l'arrêt de l'hydratation et de la nutrition qui entraînent la mort : « Toute personne a droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance ». (art. L. 1110-5, CSP).

I. L'interdiction, un principe

A. Un droit à la mort ?

En droit français, le suicide est toléré. Ni le suicide ni la tentative de suicide ne sont une infraction pénale. C'est une prérogative personnelle ajuridique (X. Bioy, Droits fondamentaux et libertés publiques, p. 363). Il n'existe pas un droit au suicide, droit subjectif dont l'individu serait titulaire et portant sur sa vie. B. Mathieu explique que le suicide doit être conçu comme une liberté autonome. La relation de la personne avec sa vie relève à tel point de son intimité, que la société ne peut s'y immiscer. L'État ne reconnaît aucun droit particulier, il n'intervient pas. En revanche, la provocation au suicide est punie depuis la loi du 31 décembre 1987. En effet, si le droit français n'incrimine pas le suicide, il punit tout agissement d'autrui en sa faveur. Par ailleurs, une question demeure largement débattue, notamment lors des débats parlementaires concernant la loi Claeys-Leonetti de 2016, il s'agit du suicide assisté.

Comme l'a souligné B. Beignier, il existe un droit de la mort qui va de la loi Leonetti du 22 avril 2005 sur la fin de vie jusqu'au droit relatif aux funérailles et aux sépultures. Il n'existe pas un droit à la mort, la Cour européenne des droits de l'homme (Décision Pretty, 29 avril 2002) et la Cour suprême des États-Unis (26 juin 1997) sont d'accord sur ce point. Le fait que le droit français ne se prononce pas sur le suicide ne signifie nullement qu'il en découle un droit subjectif ; le suicide n'est pas un droit, c'est une liberté civile. Plus exactement, selon la récente jurisprudence du Conseil d'État, c'est une liberté personnelle. Et en la matière, le droit s'abstient.

B. Le rejet de l'assistance du tiers

Il n'en est pas de même concernant l'euthanasie.

Il faut savoir que l'euthanasie implique l'assistance d'un tiers et qu'elle est rigoureusement interdite en France autant par la déontologie médicale que par la loi.

- Article R4127-38 du code de la santé publique : « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort »
- La Cour de Strasbourg, elle a jugé dans l'affaire Pretty c/R.U., le 29 Avril 2002 que le droit à la vie ne saurait être interprété comme conférant à une personne le droit symétrique de mourir avec l'assistance d'un tiers.

II. La primauté du droit à la vie

A. Le rejet d'un droit à l'euthanasie

Étymologiquement, euthanos signifie la bonne mort. L'euthanasie est le droit de décider de sa propre mort. Autrefois synonyme de mort calme et sans souffrance, ce terme est défini comme la pratique qui consiste à provoquer la mort d'un malade incurable, afin d'abréger ses souffrances (Dictionnaire de médecine, Flammarion). On distingue l'euthanasie active, qui consiste à agir pour donner la mort, et l'euthanasie passive selon laquelle l'arrêt des traitements entraîne le décès de l'individu. La prise en charge médicale de la fin de vie a progressivement été encadrée par le droit.

Après un grave accident de la route en 2000, V. Humbert, ne supportant plus sa vie sans espoir de guérison, entreprend de nombreuses démarches pour obtenir le droit d'être euthanasié. Il écrit au président de la République auquel il demande un « droit de mourir ». Ce jeune tétraplégique relance alors un débat ancien. Le médecin qui avait accepté de l'aider à mourir a été mis en examen pour empoisonnement avec préméditation, il bénéficiera d'un non-lieu en 2006. Ce type d'agissement n'est généralement pas poursuivi pénalement, en 1988, le professeur Schwartzenberg a reconnu avoir pratiqué l'euthanasie à plusieurs reprises. En 2015, le docteur Bonnemaison a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis par la Cour d'assise du Maine-et-Loire et radié de l'ordre des médecins par le Conseil de l'ordre pour avoir délibérément provoqué la mort de trois de ses patientes, décision confirmée par le Conseil d'État. Le 11 avril 2019, la CEDH a rejeté sa requête contre sa radiation de l'Ordre des médecins. Ces affaires ont contribué à relancer le débat sur l'euthanasie en France.

Un rapport rendu en 2004, « Vivre ou laisser mourir. Respecter la vie, accepter la mort », précède le vote de la loi Leonetti du 22 avril 2005 sur les droits des malades et la fin de vie. Elle s'inscrit dans le prolongement de la loi de 2002 sur les droits des malades qui autorisait la suspension des soins médicaux dès qu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Le médecin peut renoncer à l'acharnement thérapeutique en s'efforçant de développer les soins palliatifs et de ménager au mourant une fin qui sauvegarde sa dignité.

Cette loi comprend trois dispositions essentielles : l'interdiction de toute obstination déraisonnable, le renforcement des droits du patient et la mise en place d'un processus décisionnel en cas de patient inconscient ou d'arrêt des traitements qui reposent sur la collégialité et la transparence. L'un des apports majeurs de la loi concerne l'expression des malades en fin de vie qui suppose que lorsqu'un malade en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable décide de limiter ou d'arrêter son traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informé des conséquences de son choix. Le texte précise que toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Le médecin en tiendra compte pour toute décision, à la seule condition qu'elles aient été rédigées moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne.

B. La prise en compte de la souffrance des malades en fin de vie

Les procédures de limitation et d'arrêt des traitements, instituées par la loi Leonetti, ont connu plusieurs améliorations. Ainsi en est-il du décret du 29 janvier 2010 relatif aux conditions de mise en œuvre des décisions de limitation ou d'arrêt de traitement, mais également du Programme national de développement des soins palliatifs 2008-2012 prolongé par un plan national 2015-2018, de la création de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie par la loi du 2 mars 2010 ou encore de la mise en place de l'Observatoire national de la fin de vie par le décret du 19 février 2010. Par la suite, la loi n° 2016-87 Claeys Leonetti, du 2 février 2016, crée de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Cette loi met en place un « droit de dormir avant

de mourir pour ne pas souffrir ». Si cette pratique sédative existait déjà dans les hôpitaux français, elle n'était ni générale ni homogène. Un médecin ne peut pas s'opposer à une demande de sédation profonde et continue de la part d'un patient atteint d'une « affection grave et incurable », dont le « pronostic vital est engagé à court terme » et qui présente une « souffrance réfractaire aux traitements ». Ou lorsque sa « décision d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable ».

Les directives anticipées, par lesquelles il est possible de faire connaître son refus d'un acharnement thérapeutique, jusque-là simplement indicatif, s'imposent désormais au médecin. Le soignant peut y déroger « en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation » et lorsqu'elles « apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale ».

Le refus de l'acharnement thérapeutique suppose, en vertu de l'article L.1110-5 du Code de la santé publique, que les actes de soin ne soient pas poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils sont inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le maintien artificiel de la vie, ils doivent être suspendus.

D'autres affaires ont médiatisé la problématique de la fin de vie, notamment pour les mineurs. L'arrêt du Conseil d'État du 8 mars 2017, APHP à propos d'une enfant âgée d'un an, maintenue artificiellement en vie et pour laquelle le médecin a considéré que la poursuite des traitements constituait une obstination déraisonnable. En 2018, le Conseil d'État s'est également prononcé sur le cas d'une jeune fille de 14 ans (Conseil d'État, 5 janv. 2018, Biddari) confirmant l'arrêt des soins, le traitement étant considéré comme une obstination déraisonnable.

Sans surprise, cette question est au cœur des États généraux de la bioéthique qui se sont déroulés en 2018. Dans son avis n° 129, rendu le 25 septembre 2018, le CCNE propose de ne pas modifier la loi existante sur la fin de vie Claeys-Leonetti et insiste sur l'impérieuse nécessité que cette loi soit mieux connue, mieux appliquée et mieux respectée.

3. Sujet - Argumentation

Soutenez que l'euthanasie est contraire aux droits et libertés fondamentales

Présentation du sujet

L'euthanasie consiste à faire usage des procédés qui permettent de hâter ou de provoquer la mort de malades incurables qui souffrent et souhaitent mourir. Elle n'est pas reconnue par les DLF (droits et libertés fondamentaux).

Les DLF (droits et libertés fondamentaux) correspondent à un ensemble de prérogatives personnelles qu'une société donnée estime être fondamentales. À ce titre, elles leur confèrent la place la plus élevée dans la hiérarchie des normes. C'est un ensemble de droits considérés comme fondamentaux, proclamés comme tels dans les sources juridiques, et opposables à l'État et aux personnes publiques.
Contraire : qui ne s'accorde pas avec l'usage qu'on veut en faire, qui ne convient pas à la destination qu'on lui donne ; inapproprié.

Le droit français garantit un apaisement des souffrances dans l'accompagnement fin de vie :

- La loi du 2 février 2016 « créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie » renforce la libre disposition de sa vie. Si en apparence elle ne consacre pas un droit à mourir quand la personne le souhaite, elle autorise, en fin de vie, le recours à une sédation profonde et irréversible en même temps que l'arrêt de l'hydratation et de la nutrition qui entraînent la mort : « Toute personne a droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance ». (art. L. 1110-5, CSP).

I. Une interdiction nécessaire

A. Les limites du droit à la mort

En droit français, le suicide est toléré. Ni le suicide ni la tentative de suicide ne sont une infraction pénale. C'est une prérogative personnelle ajuridique (X. Bioy, Droits fondamentaux et libertés publiques, p. 363). Il n'existe pas un droit au suicide, droit subjectif dont l'individu serait titulaire et portant sur sa vie. B. Mathieu explique que le suicide doit être conçu comme une liberté autonome. La relation de la personne avec sa vie relève à tel point de son intimité, que la société ne peut s'y immiscer. L'État ne reconnaît aucun droit particulier, il n'intervient pas. En revanche, la provocation au suicide est punie depuis la loi du 31 décembre 1987. En effet, si le droit français n'incrimine pas le suicide, il punit tout agissement d'autrui en sa faveur. Par ailleurs, une question demeure largement débattue, notamment lors des débats parlementaires concernant la loi Claeys-Leonetti de 2016, il s'agit du suicide assisté.

Comme l'a souligné B. Beignier, il existe un droit de la mort qui va de la loi Leonetti du 22 avril 2005 sur la fin de vie jusqu'au droit relatif aux funérailles et aux sépultures. Il n'existe pas un droit à la mort, la Cour européenne des droits de l'homme (Décision Pretty, 29 avril 2002) et la Cour suprême des États-Unis (26 juin 1997) sont d'accord sur ce point. Le fait que le droit français ne se prononce pas sur le suicide ne signifie nullement qu'il en découle un droit subjectif ; le suicide n'est pas un droit, c'est une liberté civile. Plus exactement, selon la récente jurisprudence du Conseil d'État, c'est une liberté personnelle. Et en la matière, le droit s'abstient.

Il n'en est pas de même concernant l'euthanasie.

Il faut savoir que l'euthanasie implique l'assistance d'un tiers et qu'elle est rigoureusement interdite en France autant par la déontologie médicale que par la loi.

- Article R4127-38 du code de la santé publique : « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort »
- La Cour de Strasbourg, elle a jugé dans l'affaire Pretty c/R.U., le 29 Avril 2002 que le droit à la vie ne saurait être interprété comme conférant à une personne le droit symétrique de mourir avec l'assistance d'un tiers.

B. L'exemple de l'affaire Lambert

On peut évoquer l'affaire Vincent Lambert :

- En 2008, après un accident de voiture, Vincent Lambert est tétraplégique et est plongé dans un état végétatif.
- En avril 2013, avec l'accord de son épouse, les médecins, dans le cadre de la loi Leonetti, ont décidé d'arrêter son hydratation et son alimentation. Les parents avaient alors saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui le 10 mai a remis en cause la décision du corps médical. Les soins ont donc repris.
- Fin 2013, la procédure collégiale, dans le cadre de la loi Leonetti, est de nouveau engagée. Encore une fois, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne donne raison aux parents. Mais le CHU de Reims, ainsi que la femme et le neveu de Vincent Lambert, saisissent le Conseil d'État, plus haute instance du droit administratif français. Cette juridiction leur donne raison le 24 juin 2014
- Quelques heures plus tard, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), saisie par les parents et la famille de Vincent Lambert, ordonne à titre conservatoire la suspension provisoire du jugement du Conseil d'État. Il faudra attendre un an, le 5 juin 2015, pour que la CEDH valide la légalité de l'arrêt des soins. Un recours est déposé par la famille, il est refusé durant l'été.
- L'arrêt des soins aurait donc pu être enclenché, mais le 23 juillet, les médecins décident de ne pas stopper l'alimentation et l'hydratation, considérant que « les conditions de sérénité et de sécurité nécessaire à la poursuite de cette procédure, tant pour Vincent Lambert que pour l'équipe soignante, ne sont pas réunies ».
- Le 19 juillet 2017, le Conseil d'État confirme l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Nancy durant l'été 2016, qui explique que la procédure d'arrêt des soins doit être recommencée de zéro, le médecin responsable de Vincent Lambert n'étant plus le même.
- En avril 2018, le docteur Sanchez annonce sa décision « d'arrêter les traitements », à la suite d'une procédure collégiale. Il faudra attendre un an et la saisie de l'ensemble des juridictions jusqu'au Conseil d'État, qui estimera le 24 avril 2019 que la décision d'arrêt des soins prise le 9 avril 2018 par le CHU de Reims est légalement justifiée.
- Le 30 avril 2019, la Cour européenne des droits de l'Homme rejette le recours des parents de Vincent Lambert et confirme la décision prise par le Conseil d'État.
- Deux semaines après, le tribunal administratif de Paris rejette lui aussi un recours en urgence des parents de Vincent Lambert. L'arrêt des soins commence donc le 20 mai 2019, dans la matinée, après que la CEDH ait rejeté un énième recours des parents. Mais le soir même, la cour d'appel de Paris ordonne la reprise des traitements « afin de faire respecter les mesures provisoires demandées par le Comité international des droits des personnes handicapées le 3 mai 2019 tendant au maintien de l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert ».

Il faut rappeler que l'euthanasie pourrait très vite être assortie de dérives largement attentatoires aux droits, notamment au droit à la vie

- Cette forme d'assistance à la mort reste interdite dans la plupart des pays car trop dangereuse et particulièrement dans une période où le vieillissement de la population peut faire craindre que des esprits peu scrupuleux la préconisent pour des raisons économiques.

II. **La primauté du droit à la vie**

A. Les dangers de l'euthanasie

Étymologiquement, euthanos signifie la bonne mort. L'euthanasie est le droit de décider de sa propre mort. Autrefois synonyme de mort calme et sans souffrance, ce terme est défini comme la pratique qui consiste à provoquer la mort d'un malade incurable, afin d'abréger ses souffrances (Dictionnaire de médecine, Flammarion). On distingue l'euthanasie active, qui consiste à agir pour donner la mort, et l'euthanasie passive selon laquelle l'arrêt des traitements entraîne le décès de l'individu. La prise en charge médicale de la fin de vie a progressivement été encadrée par le droit.

Après un grave accident de la route en 2000, V. Humbert, ne supportant plus sa vie sans espoir de guérison, entreprend de nombreuses démarches pour obtenir le droit d'être euthanasié. Il écrit au président de la République auquel il demande un « droit de mourir ». Ce jeune tétraplégique relance alors un débat ancien. Le médecin qui avait accepté de l'aider à mourir a été mis en examen pour empoisonnement avec préméditation, il bénéficiera d'un non-lieu en 2006. Ce type d'agissement n'est généralement pas poursuivi pénalement, en 1988 le professeur Schwartzenberg a reconnu avoir pratiqué l'euthanasie à plusieurs reprises. En 2015, le docteur Bonnemaison a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis par la Cour d'assise du Maine-et-Loire et radié de l'ordre des médecins par le Conseil de l'ordre pour avoir délibérément provoqué la mort de trois de ses patientes, décision confirmée par le Conseil d'État. Le 11 avril 2019, la CEDH a rejeté sa requête contre sa radiation de l'Ordre des médecins. Ces affaires ont contribué à relancer le débat sur l'euthanasie en France.

Un rapport rendu en 2004, « Vivre ou laisser mourir. Respecter la vie, accepter la mort », précède le vote de la loi Leonetti du 22 avril 2005 sur les droits des malades et la fin de vie. Elle s'inscrit dans le prolongement de la loi de 2002 sur les droits des malades qui autorisait la suspension des soins médicaux dès qu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Le médecin peut renoncer à l'acharnement thérapeutique en s'efforçant de développer les soins palliatifs et de ménager au mourant une fin qui sauvegarde sa dignité.

Cette loi comprend trois dispositions essentielles : l'interdiction de toute obstination déraisonnable, le renforcement des droits du patient et la mise en place d'un processus décisionnel en cas de patient inconscient ou d'arrêt des traitements qui repose sur la collégialité et la transparence. L'un des apports majeurs de la loi concerne l'expression des malades en fin de vie qui suppose que lorsqu'un malade en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable décide de limiter ou d'arrêter son traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informé des conséquences de son choix. Le texte précise que toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Le médecin en tiendra compte pour toute décision, à la seule condition qu'elles aient été rédigées moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne.

B. La prise en compte de la souffrance des malades en fin de vie

Les procédures de limitation et d'arrêt des traitements, instituées par la loi Leonetti, ont connu plusieurs améliorations. Ainsi en est-il du décret du 29 janvier 2010 relatif aux conditions de mise en œuvre des décisions de limitation ou d'arrêt de traitement, mais également du Programme national

de développement des soins palliatifs 2008-2012 prolongé par un plan national 2015-2018, de la création de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie par la loi du 2 mars 2010 ou encore de la mise en place de l'Observatoire national de la fin de vie par le décret du 19 février 2010. Par la suite, la loi n° 2016-87 Claeys Leonetti, du 2 février 2016, crée de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Cette loi met en place un « droit de dormir avant de mourir pour ne pas souffrir ». Si cette pratique sédative existait déjà dans les hôpitaux français, elle n'était ni générale ni homogène. Un médecin ne peut pas s'opposer à une demande de sédation profonde et continue de la part d'un patient atteint d'une « affection grave et incurable », dont le « pronostic vital est engagé à court terme » et qui présente une « souffrance réfractaire aux traitements ». Ou lorsque sa « décision d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable ».

Les directives anticipées, par lesquelles il est possible de faire connaître son refus d'un acharnement thérapeutique, jusque-là simplement indicatives, s'imposent désormais au médecin. Le soignant peut y déroger « en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation » et lorsqu'elles « apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale ».

Le refus de l'acharnement thérapeutique suppose, en vertu de l'article L.1110-5 du Code de la santé publique, que les actes de soin ne soient pas poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils sont inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le maintien artificiel de la vie, ils doivent être suspendus.

D'autres affaires ont médiatisé la problématique de la fin de vie, notamment pour les mineurs. L'arrêt du Conseil d'État du 8 mars 2017, APHP à propos d'une enfant âgée d'un an, maintenue artificiellement en vie et pour laquelle le médecin a considéré que la poursuite des traitements constituait une obstination déraisonnable. En 2018, le Conseil d'État s'est également prononcé sur le cas d'une jeune fille de 14 ans (Conseil d'État, 5 janv. 2018, Biddari) confirmant l'arrêt des soins, le traitement étant considéré comme une obstination déraisonnable.

Sans surprise, cette question est au cœur des États généraux de la bioéthique qui se sont déroulés en 2018. Dans son avis n° 129, rendu le 25 septembre 2018, le CCNE propose de ne pas modifier la loi existante sur la fin de vie Claeys-Leonetti et insiste sur l'impérieuse nécessité que cette loi soit mieux connue, mieux appliquée et mieux respectée.

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2023

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 3 – La liberté de la presse

1. Dissertation
2. Argumentation
3. Commentaire

1. **Sujet – Dissertation**

Défendre la liberté de la presse

Présentation du sujet

- **Presse :** Ensemble des moyens de diffusion de l'information journalistique. Oral comme écrite.
- **liberté :** absence de limitation, sous entendue dans l'epxression. L'expression est l'action d'exprimer quelque chose (opinion, etc) par le langage oral ou écrit, par le corps, l'art… La liberté d'opinion et d'expression implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

I. La reconnaissance de la liberté de la presse

A) La longue marche vers la liberté de la presse

La liberté de la presse est protégée en droit français :

- Loi du 29 juillet 1881 : C'est incontestablement une grande loi républicaine, de celles qui créent les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Elle va réellement instaurer un régime juridique de liberté de la presse. Dans ce nouveau régime, il n'y a plus d'autorisation préalable, de censure ou de cautionnement. On assiste à la suppression du délit d'opinion. Les infractions qui sont établis permettent l'instauration de garde-fous, de limites à un usage excessif de la liberté de la presse. Il s'agit notamment de la diffamation ou de l'injure (allégation ou imputation d'influer qui portent atteinte à l'honneur ou la considération de la personne), qui entraîne une responsabilité en cascade : gérant, éditeur, auteur, imprimeur, vendeur peuvent tous être tenus pour responsable. Le jury de la cour d'assises est compétent pour les délits commis par voie de presse, ce qui constitue un élément de protection.
- L'entreprise de presses est libre. CC, 29 juillet 1986 : « la libre communication des pensées et des opinions ne serait pas effective si le public auquel s'adressent les quotidiens n'était pas à même de disposer d'un nombre suffisant de publication de tendance et de caractères différents ».
- Il existe une liberté d'accès à la profession de journaliste : Le journaliste bénéficie de la délivrance d'une carte d'identité professionnelle, permettant de se prévaloir de sa profession, par une commission paritaire (composée de 8 représentants des journalistes professionnels et de 8 représentants des directeurs de journaux, d'agences de presse et d'entreprises de communication). Le plus frappant en matière de liberté du journaliste, c'est la clause de conscience (loi du 29 mars 1835 à l'origine, mais figurant aujourd'hui dans l'article L. 761-7 du Code du travail).

La liberté de presse repose sur la liberté d'expression et en connaître la base juridique textuelle:

- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789) :
  - Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ».
  - Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi
- Déclaration universelle des Droits de l'Homme :
  - « Article 18 - Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté

de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. »
    - « Article 10 - Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. »
- Chartes des droits fondamentaux de l'Union européenne :
    - Article 1 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
- Convention européenne des droits de l'homme :
    - Article 10. 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».

B. La liberté de la presse, socle d'autres libertés

La liberté d'expression est une une condition de la liberté de la pensée et qu'elle exprime l'identité et l'autonomie intellectuelles des individus. Par là, elle conditionne leurs relations aux autres individus et à la société.
La liberté d'expression est une manifestation de la liberté de la pensée.
Dans la jurisprudence de la CEDH (Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A n° 24), l'exigence de pluralisme sert de fondement à la nécessité de la protection des propos qui heurtent, choquent ou inquiètent.

II. Une liberté à défendre

A. La clarté du débat démocratique

La liberté d'expression garantit la clarté du débat démocratique. F. Sudre la définit comme un « droit hors du commun ».

- Comme le dit la Cour EDH (Müller et autres c. Suisse, arrêt du 24 mai 1988, série A n° 133) : « Ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une oeuvre d'art contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensables à une société démocratique.
- CC 28 février 2012 : *« la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ».*
- D'un point de vue historique (**pour nourrir le débat)** : La liberté d'expression est un acquis provenant du courant des Lumières (XVIIIe siècle). L'individualisme, couplé avec l'abolition des

privilèges, particulièrement dans la France de 1789, ou, aux États-Unis, avec celle de toute forme de soumission à un pouvoir, a consacré le rôle central de l'homme dans l'organisation démocratique de la vie sociale et a développé, par là, la nécessité pour chacun de s'exprimer librement (auparavant, cette liberté était auparavant dévolue aux seules autorités royales et religieuses).

Il existe un droit de réponse accordée à toute personne qui ne serait pas d'accord avec ce qui a été publié à son encontre :
« Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service. » Article 6, alinéa IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

B. Une protection nécessaire

Il faut protéger cette liberté car il peut y avoir des atteintes :

- Entrave au métier de journaliste (assassinats, agressions, menaces, emprisonnement, enlèvement,…)
- Pressions sur le métier de journaliste (politique, financières, …).

Exemple : l'affaire Charlie Hebdo relative à la liberté de la presse :
Arrêt du 12 mars 2008 de la CA de Paris : « si elle peut choquer et susciter l'émoi (…), elle ne peut être comprise qu'à la lumière de l'ensemble du contenu du journal qui porte un regard critique non pas sur la communauté musulmane mais sur certains de ses membres qui, au nom de l'islam, pratiquent des actes terroristes à répétition ; en effet, dès la page de couverture, CHARLIE HEBDO donne le ton en stigmatisant les intégristes par son titre et par l'image de la désolation qu'ils provoquent chez le prophète de l'islam, puis, tout au long des nombreux articles de réflexion et des dessins ou caricatures qui traitent du prophète comme des « dieux juif, chrétien, et musulman », ce même journal souligne, avec son esprit satirique bien connu mais de manière argumentée, le danger des fanatismes religieux, de l'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques et des atteintes à la liberté d'expression ».

2. Sujet – Commentaire de texte ou d'arrêt

Article 11-2 Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne
« La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés »

I. La reconnaissance de la liberté de la presse

A. la liberté de la presse, héritage du XIXe siècle

La liberté de la presse est protégée en droit français :

- Loi du 29 juillet 1881 : C'est incontestablement une grande loi républicaine, de celles qui créent les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Elle va réellement instaurer un régime juridique de liberté de la presse. Dans ce nouveau régime, il n'y a plus d'autorisation préalable, de censure ou de cautionnement. On assiste à la suppression du délit d'opinion. Les infractions qui sont établis permettent l'instauration de garde-fous, de limites à un usage excessif de la liberté de la presse. Il s'agit notamment de la diffamation ou de l'injure (allégation ou imputation d'influer qui portent atteinte à l'honneur ou la considération de la personne), qui entraîne une responsabilité en cascade : gérant, éditeur, auteur, imprimeur, vendeur peuvent tous être tenus pour responsable. Le jury de la cour d'assises est compétent pour les délits commis par voie de presse, ce qui constitue un élément de protection.
- L'entreprise de presses est libre. CC, 29 juillet 1986 : « la libre communication des pensées et des opinions ne serait pas effective si le public auquel s'adressent les quotidiens n'était pas à même de disposer d'un nombre suffisant de publication de tendance et de caractères différents ».
- Il existe une liberté d'accès à la profession de journaliste : Le journaliste bénéficie de la délivrance d'une carte d'identité professionnelle, permettant de se prévaloir de sa profession, par une commission paritaire (composée de 8 représentants des journalistes professionnels et de 8 représentants des directeurs de journaux, d'agences de presse et d'entreprises de communication). Le plus frappant en matière de liberté du journaliste, c'est la clause de conscience (loi du 29 mars 1835 à l'origine, mais figurant aujourd'hui dans l'article L. 761-7 du Code du travail).

La liberté de presse repose sur la liberté d'expression et en connaître la base juridique textuelle:

- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789) :
    - Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ».
    - Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi
- Déclaration universelle des Droits de l'Homme :
    - « Article 18 - Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. »
    - « Article 10 - Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. »
- Chartes des droits fondamentaux de l'Union européenne :
    - Article 1 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa

religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

- Convention européenne des droits de l'homme :
    - Article 10. 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».

B. La liberté de la presse, socle d'autres libertés

La liberté d'expression est une une condition de la liberté de la pensée et qu'elle exprime l'identité et l'autonomie intellectuelles des individus. Par là, elle conditionne leurs relations aux autres individus et à la société.
La liberté d'expression est une manifestation de la liberté de la pensée.
Dans la jurisprudence de la CEDH (Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A n° 24), l'exigence de pluralisme sert de fondement à la nécessité de la protection des propos qui heurtent, choquent ou inquiètent.

II. Une liberté à défendre

A. La nécessité de défendre la clarté du débat démocratique

La liberté d'expression garantit la clarté du débat démocratique. F. Sudre la définit comme un « droit hors du commun ».

- Comme le dit la Cour EDH (Müller et autres c. Suisse, arrêt du 24 mai 1988, série A n° 133) : « Ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une oeuvre d'art contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensables à une société démocratique.
- CC 28 février 2012 : *« la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ».*
- D'un point de vue historique (**pour nourrir le débat)** : La liberté d'expression est un acquis provenant du courant des Lumières (XVIIIe siècle). L'individualisme, couplé avec l'abolition des privilèges, particulièrement dans la France de 1789, ou, aux États-Unis, avec celle de toute forme de soumission à un pouvoir, a consacré le rôle central de l'homme dans l'organisation démocratique de la vie sociale et a développé, par là, la nécessité pour chacun de s'exprimer librement (auparavant, cette liberté était auparavant dévolue aux seules autorités royales et religieuses).

Il existe un droit de réponse accordée à toute personne qui ne serait pas d'accord avec ce qui a été publié à son encontre :
« Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service. » Article 6, alinéa IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

B. Une liberté de plus en plus menacée en France

Il faut protéger cette liberté car il peut y avoir des atteintes :

- Entrave au métier de journaliste (assassinats, agressions, menaces, emprisonnement, enlèvement,…)
- Pressions sur le métier de journaliste (politique, financières, …).

Exemple : l'affaire Charlie Hebdo relative à la liberté de la presse :
Arrêt du 12 mars 2008 de la CA de Paris : « si elle peut choquer et susciter l'émoi (…), elle ne peut être comprise qu'à la lumière de l'ensemble du contenu du journal qui porte un regard critique non pas sur la communauté musulmane mais sur certains de ses membres qui, au nom de l'islam, pratiquent des actes terroristes à répétition ; en effet, dès la page de couverture, CHARLIE HEBDO donne le ton en stigmatisant les intégristes par son titre et par l'image de la désolation qu'ils provoquent chez le prophète de l'islam, puis, tout au long des nombreux articles de réflexion et des dessins ou caricatures qui traitent du prophète comme des « dieux juif, chrétien, et musulman », ce même journal souligne, avec son esprit satirique bien connu mais de manière argumentée, le danger des fanatismes religieux, de l'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques et des atteintes à la liberté d'expression ».

3. Sujet – Argumentation

Soutenez que la liberté de la presse ne soit pas être absolue

Présentation du sujet

- **Presse :** Ensemble des moyens de diffusion de l'information journalistique. Oral comme écrite.
- **liberté :** absence de limitation, sous entendue dans l'epxression. L'expression est l'action d'exprimer quelque chose (opinion, etc) par le langage oral ou écrit, par le corps, l'art… La liberté d'opinion et d'expression implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
- **Non absolue :** limitée

La liberté de la presse est protégée en droit français :

- Loi du 29 juillet 1881 : C'est incontestablement une grande loi républicaine, de celles qui créent les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Elle va réellement instaurer un régime juridique de liberté de la presse. Dans ce nouveau régime, il n'y a plus d'autorisation préalable, de censure ou de cautionnement. On assiste à la suppression du délit d'opinion. Les infractions qui sont établis permettent l'instauration de garde-fous, de limites à un usage excessif de la liberté de la presse. Il s'agit notamment de la diffamation ou de l'injure (allégation ou imputation d'influer qui portent atteinte à l'honneur ou la considération de la personne), qui entraîne une responsabilité en cascade : gérant, éditeur, auteur, imprimeur, vendeur peuvent tous être tenus pour responsable. Le jury de la cour d'assises est compétent pour les délits commis par voie de presse, ce qui constitue un élément de protection.
- L'entreprise de presses est libre. CC, 29 juillet 1986 : « la libre communication des pensées et des opinions ne serait pas effective si le public auquel s'adressent les quotidiens n'était pas à même de disposer d'un nombre suffisant de publication de tendance et de caractères différents ».
- Il existe une liberté d'accès à la profession de journaliste : Le journaliste bénéficie de la délivrance d'une carte d'identité professionnelle, permettant de se prévaloir de sa profession, par une commission paritaire (composée de 8 représentants des journalistes professionnels et de 8 représentants des directeurs de journaux, d'agences de presse et d'entreprises de communication). Le plus frappant en matière de liberté du journaliste, c'est la clause de

conscience (loi du 29 mars 1835 à l'origine, mais figurant aujourd'hui dans l'article L. 761-7 du Code du travail).

La liberté de presse repose sur la liberté d'expression et en connaître la base juridique textuelle:

- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789) :
    - Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ».
    - Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi
- Déclaration universelle des Droits de l'Homme :
    - « Article 18 - Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. »
    - « Article 10 - Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. »
- Chartes des droits fondamentaux de l'Union européenne :
    - Article 1 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
- Convention européenne des droits de l'homme :
    - Article 10. 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».

I. **Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la liberté de la presse**

A. Une liberté nécessaire

Certes, La liberté d'expression garantit la clarté du débat démocratique. F. Sudre la définit comme un « droit hors du commun ».

- Comme le dit la Cour EDH (Müller et autres c. Suisse, arrêt du 24 mai 1988, série A n° 133) : « Ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une oeuvre d'art contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensables à une société démocratique.
- CC 28 février 2012 : *« la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres*

droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ».

- D'un point de vue historique (**pour nourrir le débat)** : La liberté d'expression est un acquis provenant du courant des Lumières (XVIIIe siècle). L'individualisme, couplé avec l'abolition des privilèges, particulièrement dans la France de 1789, ou, aux États-Unis, avec celle de toute forme de soumission à un pouvoir, a consacré le rôle central de l'homme dans l'organisation démocratique de la vie sociale et a développé, par là, la nécessité pour chacun de s'exprimer librement (auparavant, cette liberté était auparavant dévolue aux seules autorités royales et religieuses).

Certes, il existe un droit de réponse accordée à toute personne qui ne serait pas d'accord avec ce qui a été publié à son encontre :
« Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service. » Article 6, alinéa IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

B. Une liberté difficile à a protéger

Il peut y avoir des atteintes à la liberté de la presse :

- Entrave au métier de journaliste (assassinats, agressions, menaces, emprisonnement, enlèvement,…)
- Pressions sur le métier de journaliste (politique, financières, …).

Exemple : l'affaire Charlie Hebdo relative à la liberté de la presse :
Arrêt du 12 mars 2008 de la CA de Paris : « si elle peut choquer et susciter l'émoi (…), elle ne peut être comprise qu'à la lumière de l'ensemble du contenu du journal qui porte un regard critique non pas sur la communauté musulmane mais sur certains de ses membres qui, au nom de l'islam, pratiquent des actes terroristes à répétition ; en effet, dès la page de couverture, CHARLIE HEBDO donne le ton en stigmatisant les intégristes par son titre et par l'image de la désolation qu'ils provoquent chez le prophète de l'islam, puis, tout au long des nombreux articles de réflexion et des dessins ou caricatures qui traitent du prophète comme des « dieux juif, chrétien, et musulman », ce même journal souligne, avec son esprit satirique bien connu mais de manière argumentée, le danger des fanatismes religieux, de l'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques et des atteintes à la liberté d'expression ».

II. Les limites nécessaires

A. Le respect d'autres libertés

La liberté d'expression, aussi importante qu'elle soit dans la société, est assortie de <u>limites pour ne pas entraver d'autres libertés :</u>

- Ne pas porter atteinte à la vie privée et au droit à l'image d'autrui
- Ne pas tenir de propos diffamatoires : la diffamation se définit par toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne
- Ne pas tenir certains propos interdits par la loi : l'apologie du terrorisme, les propos discriminatoires à raison d'orientations sexuelles ou d'un handicap, l'incitation à l'usage de produits stupéfiants, le négationnisme
- Ne pas tenir de propos injurieux

B. Le respect de catégories de personnes

Il existe des limites liées à certaines catégories de personnes :

- Contrôle des publications destinées à la jeunesse : Il s'agit d'un régime préventif souple avec l'intervention d'une commission auprès du ministre de la justice (loi du 16 juillet 1949 modifiée par la loi du 4 janvier 1967). En cas d'atteinte à la jeunesse, peut être pris un arrêté du ministre de la justice interdisant la vente aux mineurs.

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2023

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 4 – La déchéance de la nationalité

1. Dissertation
2. Argumentation
3. Commentaire

Sujet de type dissertation

La nécessité de la déchéance de nationalité

Corrigé

Présentation du sujet

La déchéance de nationalité est définie par le Professeur Paul Lagarde comme «la sanction qui consiste à retirer à un individu qui l'avait acquise la nationalité française, en raison de son indignité ou de son manque de loyalisme ». Elle est prévue par les articles 25 et 25-1 du Code civil. Le retrait de la nationalité française est possible si la personne possède une autre nationalité (sans cela, la déchéance rendrait la personne apatride) et s'il existe des motifs d'une particulière gravité (notamment pour acte de terrorisme).

La la déchéance est encadrée.
Elle peut être décidée uniquement si les conditions suivantes sont remplies :

- Acquisition de la NF (par exemple par naturalisation ou par déclaration de mariage). Une personne française d'origine ne peut pas perdre la nationalité française.
- Avoir une autre nationalité. Il n'est pas possible de rendre une personne apatride.
- Absence de rétroactivité.

I/ La sanction d'une faute particulièrement grave

A- Les cas reconnus

La déchéance de la nationalité sanctionne des faits d'une particulière gravité :

- Crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation
- Crime ou délit constituant un acte de terrorisme
- Crime ou délit constituant une atteinte à l'administration publique commis par une personne exerçant une fonction publique (par exemple, atteinte à une liberté individuelle, discrimination, etc.)
- Non-respect des obligations résultant du code du service national
- Actes accomplis au profit d'un État étranger, incompatibles avec la qualité de Français(e)

Art. 3-1 Constitution - Un Français qui a également une autre nationalité peut, dans les conditions fixées par la loi, être déchu de la nationalité française lorsqu'il est définitivement condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ».

B- La procédure

Quatre cas pouvant justifier la déchéance de la nationalité

- 1er cas : un individu condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (dans son principe, la déchéance de nationalité pour des motifs de terrorisme n'est pas incompatible avec les droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l'homme : CEDH 25 juin 2020, Ghoumid et a. c/ France, n° 52273/16) ;
- 2e cas : un individu condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du Code pénal (ex. : condamnation à une peine de 12 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire : CE 15 mars 1999, n° 171879 ; ou à une peine de 9 ans d'emprisonnement : CE 29 nov. 2000, n° 206754) ;
- 3e cas : un individu condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national (insoumission) ;

- 4e cas : un individu qui s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. Le quatrième cas ne vise pas une condamnation précise, mais des faits et comportements liés à un défaut grave de loyalisme ; faits laissés à l'appréciation du Gouvernement, sous contrôle du juge administratif.

■ Nature de la sanction

La déchéance de la nationalité constitue une sanction de nature administrative (CE 8 juin 2019, n° 394348).

■ Procédure de déchéance

** les délais*

Deux délais sont fixés par l'article 25-1 du Code civil.

Le premier délai concerne les faits reprochés. Ainsi, la déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits avant l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.

Le second délai est relatif au prononcé de la sanction administrative. La déchéance de la nationalité ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration des faits.

Toutefois, si les faits concernent le 1er cas de l'article 25 du Code civil (acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou crime ou un délit constituant un acte de terrorisme), les deux délais sont portés à quinze ans.

** la notification*

L'article 61 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 précise que lorsque le Gouvernement décide de prononcer la déchéance de la nationalité, il notifie les motifs de droit et de fait qui la justifient en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le domicile de l'individu n'est pas connu, un avis informatif est publié au Journal officiel. Puis la personne intéressée dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification ou de la publication de l'avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. Une fois ce délai expiré, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'État, que l'intéressé est déchu de la nationalité française.

II/ Une sanction nécessaire

A- Une sanction affirmée par la CEDH

Quelques affaires :

- Décision du 11 mai 2015 du Conseil d'État :

L'article 25 du Code civil permet de déchoir de la nationalité française les personnes qui ont acquis cette nationalité et qui ont également une autre nationalité, pour des motifs limitativement énumérés et dans un délai limité, fixé à l'article 25-1 du même code :

Le 1° de l'article 25 vise notamment les personnes qui ont été condamnées pour crime ou délit constituant un acte de terrorisme

L'article 25-1 ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu'à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu'ils aient été commis soit avant l'acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition. »

Ainsi, « eu égard à la gravité toute particulière des actes de terrorisme et aux conditions fixées par les articles 25 et 25-1 du Code civil, les dispositions de ces articles ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l'Union» et notamment les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (V. CJUE 2 mars 2010, Rottman).

- Par cinq arrêts du 8 juin 2016, le Conseil d'État a rejeté les recours contre des décrets du 7 octobre 2015 par lesquels le Premier ministre avait déchu de leur nationalité française cinq personnes – dont deux nées en France – qui avaient été condamnées pour des actes de terrorisme commis entre 1995 et 2004

Pour La Cour EDH, L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas méconnu lorsque l'État renvoie un individu vers un pays ayant pris des mesures générales pour prévenir les risques de mauvais traitements prohibés par cette disposition, et que le requérant ne présente aucun élément de preuve établissant que ses conditions de détention auraient dépassé le seuil de gravité nécessaire pour constituer une telle violation (CEDH 19 avr. 2018, A. S. c/ France, req. n° 46240/15)

B- Une sanction affirmée par les juridictions nationales

Les exemples récents de déchéance de la nationalité répondent essentiellement au 1er cas visé par l'article 25 du Code civil :

- Homme condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers pour des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Il avait rejoint un groupe terroriste et participé à des entraînements et aux opérations armées de ce groupe (CE 15 mars 2023, n° 460443) ;
- Homme condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Il avait assisté ses fils lors de leur départ en zone syro-irakienne pour rejoindre les rangs de l'organisation terroriste « État islamique », en leur apportant un soutien logistique et financier pendant leur engagement sur place et a facilité le départ de France de deux jeunes femmes afin qu'elles rejoignent ses fils (CE 10 févr. 2023, n° 458130) ;
- Homme condamné pour avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme une peine de six ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté de la moitié. Il avait rejoint en Syrie un groupe djihadiste affilié à Al-Qaida dont il adoptait l'idéologie djihadiste, suivi un entraînement au maniement des armes, possédé une arme automatique et été en contact avec des combattants djihadistes sur zone (CE 22 juin 2022, n° 455395).

Sujet de type commentaire (texte ou arrêt)

Art. 25 et 25-1 du Code civil

« L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :

1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;

2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du Code pénal ;

3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;

4° S'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.»

« La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans. »

Corrigé

Présentation du sujet

La déchéance de nationalité est définie par le Professeur Paul Lagarde comme «la sanction qui consiste à retirer à un individu qui l'avait acquise la nationalité française, en raison de son indignité ou de son manque de loyalisme ». Elle est prévue par les articles 25 et 25-1 du Code civil. Le retrait de la nationalité française est possible si la personne possède une autre nationalité (sans cela, la déchéance rendrait la personne apatride) et s'il existe des motifs d'une particulière gravité (notamment pour acte de terrorisme).

La la déchéance est encadrée.
Elle peut être décidée uniquement si les conditions suivantes sont remplies :

- Acquisition de la NF (par exemple par naturalisation ou par déclaration de mariage). Une personne française d'origine ne peut pas perdre la nationalité française.
- Avoir une autre nationalité. Il n'est pas possible de rendre une personne apatride.
- Absence de rétroactivité.

I/ Une déchéance de nationalité nécessaire

A-Les cas reconnus

La déchéance de la nationalité sanctionne des faits d'une particulière gravité :

- Crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation
- Crime ou délit constituant un acte de terrorisme
- Crime ou délit constituant une atteinte à l'administration publique commis par une personne exerçant une fonction publique (par exemple, atteinte à une liberté individuelle, discrimination, etc.)
- Non-respect des obligations résultant du code du service national
- Actes accomplis au profit d'un État étranger, incompatibles avec la qualité de Français(e)

Art. 3-1 Constitution - Un Français qui a également une autre nationalité peut, dans les conditions fixées par la loi, être déchu de la nationalité française lorsqu'il est définitivement condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ».

B-La procédure

Quatre cas pouvant justifier la déchéance de la nationalité

- 1er cas : un individu condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (dans son principe, la déchéance de nationalité pour des motifs de terrorisme n'est pas incompatible avec les droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l'homme : CEDH 25 juin 2020, Ghoumid et a. c/ France, n° 52273/16) ;
- 2e cas : un individu condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du Code pénal (ex. : condamnation à une peine de 12 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire : CE 15 mars 1999, n° 171879 ; ou à une peine de 9 ans d'emprisonnement : CE 29 nov. 2000, n° 206754) ;
- 3e cas : un individu condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national (insoumission) ;
- 4e cas : un individu qui s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. Le quatrième cas ne vise pas une condamnation

précise, mais des faits et comportements liés à un défaut grave de loyalisme ; faits laissés à l'appréciation du Gouvernement, sous contrôle du juge administratif.

■ Nature de la sanction

La déchéance de la nationalité constitue une sanction de nature administrative (CE 8 juin 2019, n° 394348).

■ Procédure de déchéance

** les délais*

Deux délais sont fixés par l'article 25-1 du Code civil.

Le premier délai concerne les faits reprochés. Ainsi, la déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits avant l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.

Le second délai est relatif au prononcé de la sanction administrative. La déchéance de la nationalité ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration des faits.

Toutefois, si les faits concernent le 1er cas de l'article 25 du Code civil (acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou crime ou un délit constituant un acte de terrorisme), les deux délais sont portés à quinze ans.

** la notification*

L'article 61 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 précise que lorsque le Gouvernement décide de prononcer la déchéance de la nationalité, il notifie les motifs de droit et de fait qui la justifient en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le domicile de l'individu n'est pas connu, un avis informatif est publié au Journal officiel. Puis la personne intéressée dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification ou de la publication de l'avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. Une fois ce délai expiré, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'État, que l'intéressé est déchu de la nationalité française.

II/ Une déchéance de nationalité conforme aux DLF

A-Une sanction affirmée par la CEDH

Quelques affaires :

- Décision du 11 mai 2015 du Conseil d'État :

L'article 25 du Code civil permet de déchoir de la nationalité française les personnes qui ont acquis cette nationalité et qui ont également une autre nationalité, pour des motifs limitativement énumérés et dans un délai limité, fixé à l'article 25-1 du même code :

Le 1° de l'article 25 vise notamment les personnes qui ont été condamnées pour crime ou délit constituant un acte de terrorisme

L'article 25-1 ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu'à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu'ils aient été commis soit avant l'acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition. »

Ainsi, « eu égard à la gravité toute particulière des actes de terrorisme et aux conditions fixées par les articles 25 et 25-1 du Code civil, les dispositions de ces articles ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l'Union» et notamment les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (V. CJUE 2 mars 2010, Rottman).

- Par cinq arrêts du 8 juin 2016, le Conseil d'État a rejeté les recours contre des décrets du 7 octobre 2015 par lesquels le Premier ministre avait déchu de leur nationalité française cinq personnes – dont deux nées en France – qui avaient été condamnées pour des actes de terrorisme commis entre 1995 et 2004

Pour La Cour EDH, L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas méconnu lorsque l'État renvoie un individu vers un pays ayant pris des mesures générales pour prévenir les risques de mauvais

traitements prohibés par cette disposition, et que le requérant ne présente aucun élément de preuve établissant que ses conditions de détention auraient dépassé le seuil de gravité nécessaire pour constituer une telle violation (CEDH 19 avr. 2018, A. S. c/ France, req. n° 46240/15)

B-Une sanction affirmée par les juridictions nationales

Les exemples récents de déchéance de la nationalité répondent essentiellement au 1er cas visé par l'article 25 du Code civil :

- Homme condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers pour des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Il avait rejoint un groupe terroriste et participé à des entraînements et aux opérations armées de ce groupe (CE 15 mars 2023, n° 460443) ;
- Homme condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Il avait assisté ses fils lors de leur départ en zone syro-irakienne pour rejoindre les rangs de l'organisation terroriste « État islamique », en leur apportant un soutien logistique et financier pendant leur engagement sur place et a facilité le départ de France de deux jeunes femmes afin qu'elles rejoignent ses fils (CE 10 févr. 2023, n° 458130) ;
- Homme condamné pour avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme une peine de six ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté de la moitié. Il avait rejoint en Syrie un groupe djihadiste affilié à Al-Qaida dont il adoptait l'idéologie djihadiste, suivi un entraînement au maniement des armes, possédé une arme automatique et été en contact avec des combattants djihadistes sur zone (CE 22 juin 2022, n° 455395).

Sujet de type argumentation

Soutenez que la déchéance de nationalité est conforme aux DLF

Corrigé

<u>Présentation du sujet</u>

La déchéance de nationalité est définie par le Professeur Paul Lagarde comme «la sanction qui consiste à retirer à un individu qui l'avait acquise la nationalité française, en raison de son indignité ou de son manque de loyalisme ». Elle est prévue par les articles 25 et 25-1 du Code civil. Le retrait de la nationalité française est possible si la personne possède une autre nationalité (sans cela, la déchéance rendrait la personne apatride) et s'il existe des motifs d'une particulière gravité (notamment pour acte de terrorisme).

La la déchéance est encadrée.
Elle peut être décidée uniquement si les conditions suivantes sont remplies :

- Acquisition de la NF (par exemple par naturalisation ou par déclaration de mariage). Une personne française d'origine ne peut pas perdre la nationalité française.
- Avoir une autre nationalité. Il n'est pas possible de rendre une personne apatride.
- Absence de rétroactivité.

I/ La sanction d'une faute particulièrement grave

C- Les cas reconnus

La déchéance de la nationalité sanctionne des faits d'une particulière gravité :

- Crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation
- Crime ou délit constituant un acte de terrorisme
- Crime ou délit constituant une atteinte à l'administration publique commis par une personne exerçant une fonction publique (par exemple, atteinte à une liberté individuelle, discrimination, etc.)
- Non-respect des obligations résultant du code du service national
- Actes accomplis au profit d'un État étranger, incompatibles avec la qualité de Français(e)

Art. 3-1 Constitution - Un Français qui a également une autre nationalité peut, dans les conditions fixées par la loi, être déchu de la nationalité française lorsqu'il est définitivement condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ».

D- La procédure

Quatre cas pouvant justifier la déchéance de la nationalité

- 1er cas : un individu condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (dans son principe, la déchéance de nationalité pour des motifs de terrorisme n'est pas incompatible avec les droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l'homme : CEDH 25 juin 2020, Ghoumid et a. c/ France, n° 52273/16) ;
- 2e cas : un individu condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du Code pénal (ex. : condamnation à une peine de 12 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire : CE 15 mars 1999, n° 171879 ; ou à une peine de 9 ans d'emprisonnement : CE 29 nov. 2000, n° 206754) ;

- 3e cas : un individu condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national (insoumission) ;
- 4e cas : un individu qui s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. Le quatrième cas ne vise pas une condamnation précise, mais des faits et comportements liés à un défaut grave de loyalisme ; faits laissés à l'appréciation du Gouvernement, sous contrôle du juge administratif.

■ Nature de la sanction

La déchéance de la nationalité constitue une sanction de nature administrative (CE 8 juin 2019, n° 394348).

■ Procédure de déchéance

** les délais*

Deux délais sont fixés par l'article 25-1 du Code civil.

Le premier délai concerne les faits reprochés. Ainsi, la déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits avant l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.

Le second délai est relatif au prononcé de la sanction administrative. La déchéance de la nationalité ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration des faits.

Toutefois, si les faits concernent le 1er cas de l'article 25 du Code civil (acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou crime ou un délit constituant un acte de terrorisme), les deux délais sont portés à quinze ans.

** la notification*

L'article 61 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 précise que lorsque le Gouvernement décide de prononcer la déchéance de la nationalité, il notifie les motifs de droit et de fait qui la justifient en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le domicile de l'individu n'est pas connu, un avis informatif est publié au Journal officiel. Puis la personne intéressée dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification ou de la publication de l'avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. Un fois ce délai expiré, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'État, que l'intéressé est déchu de la nationalité française.

II/ Une sanction nécessaire

C- Une sanction affirmée par la CEDH

Quelques affaires :

- Décision du 11 mai 2015 du Conseil d'État :

L'article 25 du Code civil permet de déchoir de la nationalité française les personnes qui ont acquis cette nationalité et qui ont également une autre nationalité, pour des motifs limitativement énumérés et dans un délai limité, fixé à l'article 25-1 du même code :

Le 1° de l'article 25 vise notamment les personnes qui ont été condamnées pour crime ou délit constituant un acte de terrorisme

L'article 25-1 ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu'à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu'ils aient été commis soit avant l'acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition. »

Ainsi, « eu égard à la gravité toute particulière des actes de terrorisme et aux conditions fixées par les articles 25 et 25-1 du Code civil, les dispositions de ces articles ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l'Union» et notamment les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (V. CJUE 2 mars 2010, Rottman).

- Par cinq arrêts du 8 juin 2016, le Conseil d'État a rejeté les recours contre des décrets du 7 octobre 2015 par lesquels le Premier ministre avait déchu de leur nationalité française cinq personnes – dont

deux nées en France – qui avaient été condamnées pour des actes de terrorisme commis entre 1995 et 2004

Pour La Cour EDH, L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas méconnu lorsque l'État renvoie un individu vers un pays ayant pris des mesures générales pour prévenir les risques de mauvais traitements prohibés par cette disposition, et que le requérant ne présente aucun élément de preuve établissant que ses conditions de détention auraient dépassé le seuil de gravité nécessaire pour constituer une telle violation (CEDH 19 avr. 2018, A. S. c/ France, req. n° 46240/15)

D- Une sanction affirmée par les juridictions nationales

Les exemples récents de déchéance de la nationalité répondent essentiellement au 1er cas visé par l'article 25 du Code civil :

- Homme condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers pour des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Il avait rejoint un groupe terroriste et participé à des entraînements et aux opérations armées de ce groupe (CE 15 mars 2023, n° 460443) ;
- Homme condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Il avait assisté ses fils lors de leur départ en zone syro-irakienne pour rejoindre les rangs de l'organisation terroriste « État islamique », en leur apportant un soutien logistique et financier pendant leur engagement sur place et a facilité le départ de France de deux jeunes femmes afin qu'elles rejoignent ses fils (CE 10 févr. 2023, n° 458130) ;
- Homme condamné pour avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme une peine de six ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté de la moitié. Il avait rejoint en Syrie un groupe djihadiste affilié à Al-Qaida dont il adoptait l'idéologie djihadiste, suivi un entraînement au maniement des armes, possédé une arme automatique et été en contact avec des combattants djihadistes sur zone (CE 22 juin 2022, n° 455395).

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2024

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 1 – La liberté religieuse (Corrigés)

1. Dissertation
2. Argumentation
3. Commentaire de texte
4. Commentaire d'arrêt

1. Dissertation: La liberté religieuse

Présentation du sujet :

- Liberté religieuse : composante de la liberté de conscience/pensée. Peut se définir comme le droit d'avoir ou ne pas avoir de croyances religieuses
- Absence de définition textuelle ou jurisprudentielle de la religion. Pourtant le caractère religieux peut déterminer un régime juridique (par ex : interdiction des signes religieux ostensibles à l'école ; statut d'association cultuelle)
- Double dimension de la liberté religieuse : dimension individuelle qui renvoie à la liberté de pensée (croire ou non) et à la liberté d'expression (expression des convictions religieuses) ; dimension collective qui renvoie à la liberté de manifestation et d'association (exercice du culte)
- Comment la liberté religieuse est-elle garantie aujourd'hui ?

I. La consécration de la liberté religieuse

A. Une liberté constitutionnelle

La liberté religieuse est protégée par des textes de droit interne et international :

- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789) :
  - Article 10 « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi »
- Constitution de 1958 :
  - Article 1er « La France est une République (…) laïque (…) Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances »
- Préambule Constitution 1946 :
  - Alinéa 5 : « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances »
- Loi du 9 décembre 1905 :
  - Article 1er : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. »

- Convention européenne des droits de l'homme :
  - Article 9 : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites »
- Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
  - Article 10 : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. »

- Déclaration universelle des droits de l'homme :
  - Article 18 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites »

La liberté religieuse est également protégée par la jurisprudence :
- PFRLR de la liberté de conscience : CC, 23 novembre 1977, *Loi relative à la liberté d'enseignement*
- Principe constitutionnel de liberté d'expression religieuse : CE, 27 juin 2008, *Mme M.*
- Liberté de culte est une liberté fondamentale au sens du référé-liberté : CE, 16 février 2004, *M. B.*

B. Une liberté garantie par le principe de laïcité

Le principe de laïcité est protégé par divers fondements textuels et jurisprudentiels :

- CC, 19 novembre 2004, *Traité établissant une Constitution pour l'Europe* : la laïcité interdit de « se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers »
- CC, QPC, 21 février 2013, *Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité* : la laïcité figure au nom des droits et libertés que garantit la Constitution au sens de l'article 61-1 (QPC)
- Loi du 9 décembre 1905 :
    - Article 1er : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. »
    - Article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte »

Double conséquence pour l'Etat :

- Obligation d'abstention à travers le principe de neutralité :
    - Neutralité des agents publics : interdiction de manifester leurs croyances religieuses dans le cadre du service (CE, 3 mai 2000, *Demoiselle Marteau*)
    - Financement des édifices cultuels : interdiction (article 2 loi 1905), sauf si intérêt public local et exclusion de toute libéralité (CE, 19 juillet 2011, *Fédération de la libre pensée et de l'action social du Rhône*)
    - Crèches de la nativité : leur présence dans un emplacement public est légale si elles ont un caractère culturel, artistique ou festif, et illégale si elle exprime la reconnaissance d'un culte ou marque une préférence religieuse (CE, 9 novembre 2016, *Fédération de la libre pensée de Vendée*)
- Obligation d'intervention à travers le libre exercice des cultes :
    - Cimetières : article 28 loi 1905 : « Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception (…) des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires » ; article L. 2223-12 code général des collectivités territoriales : « Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture »
    - Aumôneries : article R. 351-1 code pénitentiaire : « Chaque personne détenue peut exercer le culte de son choix, à titre individuel dans sa cellule ou collectivement dans les salles prévues à cet effet, en présence des intervenants d'aumônerie » ; article R. 1112-46 code de la santé publique : « Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l'administration de l'établissement, la visite du ministre du culte de leur choix »
    - Concordat en Alsace-Moselle : PFRLR : CC, QPC, 15 octobre 2021, *Pierre-Etienne R.*

II. Une liberté non absolue

A. Les atteintes justifiées par le maintien de l'ordre public

Au niveau textuel :

- Loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public
- Article L. 227-1-I du code de la sécurité intérieure : le préfet peut prononcer la fermeture d'un lieu de culte aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme

Contrôle de proportionnalité du juge :

- CE, 26 août 2016, *LDH* : illégalité de l'arrêté municipal interdisant le port du burkini sur la plage en l'absence de risque de trouble à l'ordre public

- CE, 26 avril 2022, *Asso Rassemblement des musulmans de Pessac* : illégalité de l'arrêté préfectoral de fermeture d'une mosquée en l'absence de lien avec un risque de commission d'actes de terrorisme ou une apologie de tels actes

B. Les atteintes justifiées par le bon fonctionnement du service public ou de l'entreprise privée

Au niveau textuel :

- Loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics
- Article L. 1121-1 code du travail. : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché »

Contrôle de proportionnalité du juge :

- CEDH, 4 décembre 2009, *Dogru c/ France* : conventionnalité d'une mesure d'expulsion d'un établissement scolaire prise sur le fondement de la loi du 15 mars 2004
- Ccass, 25 juin 2014, *Baby Loup* : légalité du règlement intérieur d'une crèche interdisant le port de signes religieux par ses agents
- CE, 21 juin 2022, *Commune de Grenoble* : illégalité du règlement intérieur d'une piscine municipale autorisant le port du burkini, dès lors que celle dérogation, qui ne vise qu'à satisfaire qu'une revendication religieuse, affecte le bon fonctionnement du service public et porte atteinte à l'égalité de traitement des usagers et donc à la neutralité du service public

2. Argumentation : soutenez que la liberté religieuse n'est pas absolue

Présentation du sujet :

- Liberté religieuse : composante de la liberté de conscience/pensée. Peut se définir comme le droit d'avoir ou ne pas avoir de croyances religieuses
- Absence de définition textuelle ou jurisprudentielle de la religion. Pourtant le caractère religieux peut déterminer un régime juridique (par ex : interdiction des signes religieux ostensibles à l'école ; statut d'association cultuelle)
- Double dimension de la liberté religieuse : dimension individuelle qui renvoie à la liberté de pensée (croire ou non) et à la liberté d'expression (expression des convictions religieuses) ; dimension collective qui renvoie à la liberté de manifestation et d'association (exercice du culte)

=> La liberté religieuse au sens de liberté de pensée est absolue. C'est son extériorisation qui ne l'est pas

La liberté religieuse est protégée par des textes de droit interne et international :

- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789) :
  - Article 10 « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi »
- Constitution de 1958 :
  - Article 1er « La France est une République (…) laïque (…) Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances »
- Préambule Constitution 1946 :
  - Alinéa 5 : « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances »
- Loi du 9 décembre 1905 :
  - Article 1er : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. »

- Convention européenne des droits de l'homme :
  - Article 9 : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites »
- Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
  - Article 10 : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. »

- Déclaration universelle des droits de l'homme :
  - Article 18 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites »

I. Les atteintes justifiées par le maintien de l'ordre public

A. Les atteintes fondées sur le droit commun

Au niveau textuel :

- Loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public
- Article L. 227-1-I du code de la sécurité intérieure : le préfet peut prononcer la fermeture d'un lieu de culte aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme

Contrôle de proportionnalité du juge :

- CE, 26 août 2016, *LDH* : illégalité de l'arrêté municipal interdisant le port du burkini sur la plage en l'absence de risque de trouble à l'ordre public
- CE, 26 avril 2022, *Asso Rassemblement des musulmans de Pessac* : illégalité de l'arrêté préfectoral de fermeture d'une mosquée en l'absence de lien avec un risque de commission d'actes de terrorisme ou une apologie de tels actes

B. Des atteintes accrues en temps de crise

- Etat d'urgence sanitaire : décret du 29 octobre 2020 – article 47 : « I. - Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes »
- CE, 18 mai 2020 : illégalité de l'interdiction de participer collectivement à des cérémonies dans les lieux de culte

II. Les atteintes justifiées par la vie en commun

A. Le principe de laïcité

Le principe de laïcité est protégé par divers fondements textuels et jurisprudentiels :

- CC, 19 novembre 2004, *Traité établissant une Constitution pour l'Europe* : la laïcité interdit de « se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers »
- CC, QPC, 21 février 2013, *Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité* : la laïcité figure au nom des droits et libertés que garantit la Constitution au sens de l'article 61-1 (QPC)
- Loi du 9 décembre 1905 :
    - Article 1er : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. »
    - Article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte »

⇨ Obligation d'abstention à travers le principe de neutralité :

- Neutralité des agents publics : interdiction de manifester leurs croyances religieuses dans le cadre du service (CE, 3 mai 2000, *Demoiselle Marteau*)
- Financement des édifices cultuels : interdiction (article 2 loi 1905), sauf si intérêt public local et exclusion de toute libéralité (CE, 19 juillet 2011, *Fédération de la libre pensée et de l'action social du Rhône*)
- Crèches de la nativité : leur présence dans un emplacement public est légale si elles ont un caractère culturel, artistique ou festif, et illégale si elle exprime la reconnaissance d'un culte ou marque une préférence religieuse (CE, 9 novembre 2016, *Fédération de la libre pensée de Vendée*)

B. Le bon fonctionnement du service public et de l'entreprise privée

Au niveau textuel :

- Loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics
- Article L. 1121-1 code du travail. : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché »

Contrôle de proportionnalité du juge :

- CEDH, 4 décembre 2009, *Dogru c/ France* : conventionnalité d'une mesure d'expulsion d'un établissement scolaire prise sur le fondement de la loi du 15 mars 2004
- Ccass, 25 juin 2014, *Baby Loup* : légalité du règlement intérieur d'une crèche interdisant le port de signes religieux par ses agents
- CE, 21 juin 2022, *Commune de Grenoble* : illégalité du règlement intérieur d'une piscine municipale autorisant le port du burkini, dès lors que celle dérogation, qui ne vise qu'à satisfaire qu'une revendication religieuse, affecte le bon fonctionnement du service public et porte atteinte à l'égalité de traitement des usagers et donc à la neutralité du service public

3. Commentaire : Article 1er loi 1905 : « *La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public* »

Présentation du sujet :

- Loi 1905 : texte fondateur sur la place de la religion en France. Toujours en vigueur aujourd'hui, reste un texte fondamental d'où son importance
- Loi qui détermine la place de l'Etat dans le domaine religieux, et qui aboutit à un équilibre entre absence et présence de l'Etat
- On se réfère à la loi 1905 quand on parle de laïcité, mais le terme n'apparaît pas dans la loi => c'est le contenu du principe de laïcité qui y est présent
- Article 1er : article fondamental :
    - Consacre la liberté de conscience, dont la liberté religieuse est une composante
    - Prévoit les atteintes possibles à cette liberté, au nom de la protection de l'ordre public
    - Détermine le rôle de l'Etat : assurer la liberté de conscience, garantir le libre exercice des cultes => obligation d'abstention, obligation d'intervention

I. La consécration de la liberté religieuse, composante de la liberté de conscience

A. Une liberté garantie par les textes de droit interne

- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789) :
    - Article 10 « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi »
- Constitution de 1958 :
    - Article 1er « La France est une République (…) laïque (…) Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances »
- Préambule Constitution 1946 :
    - Alinéa 5 : « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances »
- Loi du 9 décembre 1905 :
    - Article 1er : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. »

B. Une liberté garantie par les textes internationaux et la jurisprudence

- Convention européenne des droits de l'homme :
    - Article 9 : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites »
- Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
    - Article 10 : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. »
- Déclaration universelle des droits de l'homme :
    - Article 18 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites »

La liberté religieuse est également protégée par la jurisprudence :

- PFRLR de la liberté de conscience : CC, 23 novembre 1977, *Loi relative à la liberté d'enseignement*

- Principe constitutionnel de liberté d'expression religieuse : CE, 27 juin 2008, *Mme M.*
- Liberté de culte est une liberté fondamentale au sens du référé-liberté : CE, 16 février 2004, *M. B.*

II. Le principe de laïcité, garantie de la liberté de conscience

A. Un principe constitutionnel

Le principe de laïcité est protégé par divers fondements textuels et jurisprudentiels :

- CC, 19 novembre 2004, *Traité établissant une Constitution pour l'Europe* : la laïcité interdit de « se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers »
- CC, QPC, 21 février 2013, *Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité* : la laïcité figure au nom des droits et libertés que garantit la Constitution au sens de l'article 61-1 (QPC)
- Loi du 9 décembre 1905 :
    - Article 1er : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. »
    - Article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte »

B. Une double obligation d'abstention et d'intervention pour l'Etat

- Obligation d'abstention à travers le principe de neutralité :
    - Neutralité des agents publics : interdiction de manifester leurs croyances religieuses dans le cadre du service (CE, 3 mai 2000, *Demoiselle Marteau*)
    - Financement des édifices cultuels : interdiction (article 2 loi 1905), sauf si intérêt public local et exclusion de toute libéralité (CE, 19 juillet 2011, *Fédération de la libre pensée et de l'action social du Rhône*)
    - Crèches de la nativité : leur présence dans un emplacement public est légale si elles ont un caractère culturel, artistique ou festif, et illégale si elle exprime la reconnaissance d'un culte ou marque une préférence religieuse (CE, 9 novembre 2016, *Fédération de la libre pensée de Vendée*)
- Obligation d'intervention à travers le libre exercice des cultes :
    - Cimetières : article 28 loi 1905 : « Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception (…) des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires » ; article L. 2223-12 code général des collectivités territoriales : « Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture »
    - Aumôneries : article R. 351-1 code pénitentiaire : « Chaque personne détenue peut exercer le culte de son choix, à titre individuel dans sa cellule ou collectivement dans les salles prévues à cet effet, en présence des intervenants d'aumônerie » ; article R. 1112-46 code de la santé publique : « Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l'administration de l'établissement, la visite du ministre du culte de leur choix »
    - Concordat en Alsace-Moselle : PFRLR : CC, QPC, 15 octobre 2021, *Pierre-Etienne R.*

4. Commentaire d'arrêt : CE, 27 septembre 2024, *Association La Voix lycéenne et autres*

Présentation du sujet

Présentation de l'arrêt :

Le 31 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a adressé aux chefs d'établissements, inspecteurs de l'éducation nationale et directeurs d'établissements une note de service intitulée « Principe de laïcité à l'École – Respect des valeurs de la République ».

Cette note rappelle les modalités d'application de la loi du 15 mars 2004, codifiée notamment à l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, et qui interdit dans les établissements publics de l'enseignement primaire et secondaire « *le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse* ». Mais surtout, et c'est ce qui a donné lieu à la présente décision, dans son préambule, cette note énonce que « *dans certains établissements, la montée en puissance du port de tenues de type abaya ou qamis a fait naître un grand nombre de questions sur la conduite à tenir. Ces questionnements appellent une réponse claire et unifiée de l'institution scolaire sur l'ensemble du territoire. / En vertu de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, qui reprend la loi du 15 mars 2004, le port de telles tenues, qui manifeste ostensiblement en milieu scolaire une appartenance religieuse, ne peut y être toléré. En application de cet article, à l'issue d'un dialogue avec l'élève, si ce dernier refuse d'y renoncer au sein de l'établissement scolaire ou durant les activités scolaires, une procédure disciplinaire devra être engagée* ».

Trois associations et un syndicat ont formé un recours en annulation à l'encontre de cette note devant le Conseil d'État, et en demandent l'annulation en tant qu'elle prohibe le port de tenues de type abaya par les élèves dans les écoles, collèges et lycées publics.

Le Conseil d'Etat rejette le recours, au motif notamment que l'abaya peut être regardée comme manifestant ostensiblement une appartenance religieuse au sens de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, et dont le port est par conséquent prohibé.

Fondements juridiques :

- **Constitution 1958** : Art. 1er : « *La France est une République (…) laïque (…) Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances* »
- **Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales** : Art. 8 : respect de la vie privée et familiale
- **loi du 9 décembre 1905** concernant la séparation des Églises et de l'État : liberté de conscience, libre exercice des cultes
- **loi du 15 mars 2004** (article L. 141-5-1 code éducation) : interdiction de signes ou tenues manifestement ostensiblement une appartenance religieuse dans les établissements publics

Problèmes de droit :

- Le port de l'abaya manifeste-t-il ostensiblement une appartenance religieuse ?
- L'interdiction du port de l'abaya méconnaît-elle le respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) ?
- Plus globalement : comment concilier liberté religieuse et exercice du culte, et bon fonctionnement du service public ? Quelles limitations à la liberté religieuse/exercice du culte au nom du bon fonctionnement du service public ?

I. Une solution de continuité quant à la notion de signes religieux ostensibles

A. L'interdiction du port de signes religieux ostensibles dans les établissements publics

- Principe : usagers du service public peuvent exprimer les convictions religieuses ; ne sont pas soumis au principe de neutralité/laïcité ;
- Loi du 15 mars 2004 : interdiction des signes religieux manifestant ostensiblement une appartenance religieuse (donc les signes discrets sont tolérés) ; justification à l'interdiction : bon fonctionnement du service public ;
- Contexte de la note du ministre : multiplication des signalements de ports d'abayas ; nécessité d'une réponse de l'administration identique sur tout le territoire (principe d'égalité devant le service public)

B. Une décision conforme à la jurisprudence

- CEDH, 4 décembre 2009, *Dogru c/ France* : conformité de la sanction d'exclusion définitive d'une élève pour avoir porté un foulard islamique
- Nombreuses jurisprudences du CE sur les caractéristiques d'un signe religieux ostentatoire
- CE, 5 décembre 2012, *Singh* : sous-turban sikh manifeste ostensiblement une appartenance religieuse ; CE, 5 décembre 2012, *Ghazal* : bandana couvrant la chevelure d'une élève, et qu'elle avait refusé d'ôter, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse ;
- En l'espèce : abaya constitue un signe manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ; un vêtement peut constituer un signe religieux ostensible ; vêtement qui couvre tout le corps, donc n'est pas discret ;
- Conclusion : la note, en qualifiant l'abaya de signe manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, n'a pas méconnu la loi du 15 mars 2004.

II. Un contrôle de proportionnalité au regard de l'article 8 de la CEDH

A- La liberté de choix des vêtements, composante du droit à la vie privée

- Invocation de l'article 8 CEDH (et non l'article 9 – on peut être étonné)
- CEDH, 1er juillet 2014, *SAS c/ France* : loi du 11 octobre 2010 sur la dissimulation du visage dans l'espace public ne méconnaît pas l'article 8 CEDH (atteinte proportionnée à la vie privée)
- CEDH, 16 mai 2024, *Mikyas c/ Belgique* : conventionnalité de l'interdiction de port de signes religieux à l'école
- En l'espèce : « *à supposer que la liberté des élèves de choisir les vêtements qu'ils entendent porter en milieu scolaire relève du champ d'application de l'article 8* » : le CE n'est pas certain que cette liberté invoquée relève effectivement de l'article 8 CEDH. Le CE écarte néanmoins le moyen au fond : l'interdiction est proportionnée car elle ne concerne que les signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, et elle est justifiée au nom de « *la garantie pour les élèves de bénéficier d'un enseignement public exempt de toute forme d'exclusion et de pression, dans le respect du pluralisme et de la liberté d'autrui* » et du principe de laïcité => Contrôle de proportionnalité

B- Une solution justifiée au regard des faits de l'espèce

- Décision détaille beaucoup le contexte d'édiction de la note : forte augmentation des signalements d'atteintes à la laïcité, et notamment relatifs au port d'abayas
- Contrôle de proportionnalité de la mesure d'interdiction par rapport aux signalements

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2024

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 2 – La liberté d'association (Corrigés)

1. Dissertation
2. Argumentation
3. Commentaire de texte
4. Commentaire d'arrêt

1. Dissertation – *Les limites à la liberté d'association*

À caractère humanitaire, culturel, sportif, philosophique, politique, etc., employeuses ou non, d'utilité publique ou non, les associations sont multiples, plurielles et nombreuses sur le territoire français. Selon l'enquête de l'Institut national des statistiques et des études économiques (INSEE) sur la situation des associations en France, en 2018, on en dénombre 1,3 million : 25 % d'entre elles ont le sport pour activité principale, 20 % des activités artistiques et culturelles, 19 % entrent dans le champ du loisir, du divertissement et de la vie sociale, 15 % sont relatives à la défense de droits ou d'intérêts, 10 % développent des actions sociales et humanitaires ; enfin, 3 % sont vouées à l'enseignement, la recherche, la gestion des services économiques et locaux. Selon ce même rapport, 19 % des associations déclarent plusieurs activités, ce qui permet de saisir des combinaisons entre des champs d'actions différents : l'action sociale est ainsi reliée à la défense des droits ou à l'enseignement.

La liberté d'association a une place particulière dans le bloc de constitutionnalité. Elle ne se trouve pas dans la *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* de 1789, ni directement dans la Constitution de 1958. Elle est consacrée par une loi de 1901 et n'est finalement reconnue, en tant que norme constitutionnellement garantie, qu'en 1971, par une interprétation extensive du Conseil constitutionnel et sa célèbre décision CC, 16 juill. 1971, n° 71-44, *Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association*. Cette décision a profondément modifié l'ordonnancement juridique français et a pu être considérée comme traduisant le passage d'un État légal à un État de droit, dans le sens où le Conseil constitutionnel se saisit du pouvoir de contrôler les lois par rapport aux normes constitutionnelles.

Aujourd'hui, la loi définit la liberté d'association, en tant que convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Depuis 1901, l'association est libre même si pour obtenir la capacité juridique, elle doit être déclarée auprès d'un représentant de l'État. La puissance publique ne détient pas la liberté : si une déclaration est nécessaire, elle ne représente pas un contrôle *a priori* de la part de l'administration. Sur le fondement des articles 5 et 6 de la loi de 1901, les associations déclarées disposent d'une personnalité morale et donc d'une capacité juridique conférant des droits propres : exercer une action en justice, recevoir des dons manuels, subventions publiques et cotisations.

Aussi, dans le contexte politique français contemporain, la liberté d'association est soupçonnée de permettre des dérives dangereuses pour l'État de droit, en donnant un cadre juridique à un islamisme radical, ce que la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 entend combattre par le biais d'un arsenal juridique fortement contesté tant par la doctrine[1], que par les

[1] V. Revue des Droits de l'Homme / JusPoliticum / Droit et société

associations[2], le rapporteur public près le Conseil d'État[3] et, dans une certaine mesure le Conseil constitutionnel[4].

La liberté d'association n'est pas absolue. Sur le fondement de l'article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure, les associations peuvent être dissoutes en cas d'actes violents et d'actions discriminatoires. Il y a donc des limitations à l'exercice de cette liberté qui sont toutefois de plusieurs natures et qu'il convient de distinguer : certaines sont intrinsèques à la nature même de la liberté (I) et d'autres sont extérieures et proviennent des pouvoirs publics (II.)

I. Les limites intrinsèques de la liberté d'association

A. L'absence de but lucratif

- En France, la loi de 1901, reprise directement en tant que liberté fondamentale, exclut de son champ les sociétés commerciales et de manière générale le partage de bénéfices, ce qui est de jurisprudence constante depuis le début du XX^{ème} siècle : V. CCass., 11 mars 1914, *Caisse rurale de la commune de Manigod c/ Administration de l'enregistrement*.

- Le possibilité pour les associations de disposer de leurs bénéfices afin de distinguer une association d'une entreprise commerciale, établissant une distinction fondamentale entre ces deux entités. On peut ainsi considérer que l'association sans but lucratif est le sujet de la liberté d'association en tant que droit fondamental, dans le sens où il est consacré dans un texte à valeur constitutionnelle et donc supérieur à la loi.

B. Éviter les dérives sectaires

- Le droit d'association relève de la catégorie du contrat de groupement dans le sens où il s'agit d'une convention fonctionnant dans l'intérêt collectif de tous ses membres.

- La liberté est à la fois individuelle et collective, elle protège les membres et le groupe.

- Les membres conservent leur liberté individuelle : il existe un droit à s'associer et un droit à ne pas s'associer. V. la célèbre jurisprudence CEDH, 1999, *Chassagnou c. France.* Il s'agit ainsi d'interdire les régimes d'adhésion obligatoire et empêcher les

[2] Plus de 70 contributions extérieures ont été déposées auprès du Conseil constitutionnel par des associations et fédérations d'associations, dénonçant une atteinte disproportionnée aux droits et libertés fondamentales en général.
[3] V. Conclusions de L. Domingo ss CE, 30 juin 2023, nos 461962, 462013 et 462015. Domingo Laurent, Conclusions aff. n° 461962, 462013 et 462015, Séance du 19 juin 2023, décision du 30 juin 2023. Ce dernier souligne l'incompatibilité de la loi avec la jurisprudence de la CEDH.
[4] Le Conseil constitutionnel émet une réserve d'interprétation précisant que « l'obligation de restituer des subventions publiques déjà versées est susceptible d'affecter les conditions dans lesquelles une association exerce son activité » constituant ainsi « une atteinte disproportionnée à la liberté d'association ». V. CC, DC, 13 août 2021, n° 2021-823*, Loi confortant le respect des principes de la République.*

dérives sectaires dans le sens où un membre serait contrait à participer aux activités collectives des associations.

II. Les limites politiques de la liberté d'association

A. Une liberté pouvant subir les ingérences de l'État

- La loi de 1901 est d'inspiration libérale : la puissance publique ne détient pas la liberté. Pour obtenir une personnalité civile, une déclaration est nécessaire sans pour autant constituer un contrôle *a priori* de la part de l'Administration, qui se contente donc d'enregistrer la déclaration. On retrouve cet esprit libéral dans la nature contractuelle de l'association, laissant une large latitude aux citoyens. C'est pour cela que les régimes autoritaires présentent la nette tendance à la limiter. La liberté d'association doit donc être protégée des ingérences étatiques.

- Actualité : Par la loi n° 2021- 1109 du 24 août 2021, le gouvernement à l'origine du texte entend endiguer le problème des regroupements « séparatistes » d'avec les valeurs de la République. Pour ce faire, le chapitre II de la loi est constitué de « dispositions relatives aux associations » durcissant le contrôle des aides financières publiques et facilitant leur dissolution administrative. Pour ce faire, un contrat d'engagement républicain (CER) doit être signé par les représentants des associations bénéficiant de subventions publiques. Il s'agit d'un engagement « *1° À respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ; 2° À ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; 3° À s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.* ». En cas de non-respect, « *l'autorité ou l'organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée (…) et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.* » .

B. Des sursauts institutionnels et de la société civile pour protéger la liberté d'association

- Dans son contrôle de la loi séparatisme, le Conseil constitutionnel émet une réserve d'interprétation précisant que « *l'obligation de restituer des subventions publiques déjà versées est susceptible d'affecter les conditions dans lesquelles une association exerce son activité* », constituant ainsi « *une atteinte disproportionnée à la liberté d'association* ». Par ces mots, il réaffirme l'importance de la protection de la liberté d'association, tout en acceptant sa limitation partielle.

- Cette décision a été appuyée par le monde associatif recourant massivement aux contributions extérieures : plus de soixante-dix dénoncent les atteintes aux droits et libertés fondamentales et le caractère flou et imprécis du CER. Une vingtaine

d'associations ont d'ailleurs saisi le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir contre le décret d'application du 31 décembre 2021, requête rejetée par la décision n° 461962 du 30 juin 2023. Le Conseil n'a pas suivi les conclusions du rapporteur public qui soulignaient l'imprécision du décret en se fondant sur la jurisprudence de la CEDH.

- Les récentes applications de la loi dite Séparatisme ont ouvert un problème juridique relatif à la liberté d'expression. En cela, l'affaire Alternatiba Poitiers est particulièrement intéressante. Le préfet de la Vienne a demandé le retrait des subventions accordées à Alternatiba du fait de la tenue d'un atelier de désobéissance civile, estimé contraire au CER. Les collectivités territoriales concernées n'ont pas donné suite à la demande du préfet, ce dernier saisit alors le juge administratif par un déféré préfectoral le 28 octobre 2022. Le tribunal administratif rejette la demande du préfet par sa décision du 30 novembre 2023, estimant qu'en l'espèce l'association n'a pas incité à entreprendre des actions susceptibles d'entraîner des troubles à l'ordre public. Le juge resserre les critères du CER, sans en donner une portée générale.

2. Argumentation – *Soutenez au sens de Tocqueville que « dans les pays démocratiques, la science de l'association est la science mère ; le progrès de toutes les autres dépend des progrèsde celle-là ».*

De Tocqueville Alexis*, De la Démocratie en Amérique* [1840], t. II, 2002, in J.-M. Tremblay (dir.), Les Classiques des sciences sociales, p. 114.

Présentation du régime juridique de la liberté d'association : Loi de 1901 et Décision 1971 ouvrant son statut de PFRLR. V. *supra.* Il est intéressant de constater le régime juridique et l'histoire constitutionnelle originale qui entourent la liberté d'association. En effet, c'est par cette décision que le Conseil constitutionnel s'est saisi de sa compétence de juge de la constitutionnalité de la loi : il peut maintenant contrôler la loi, produit de la volonté générale au regard du bloc de constitutionnalité.

Aussi, les associations sont nombreuses et recoupent des champs très variés de l'activité sociale - V. *supra*. Elles caractérisent la réunion d'individus libres qui désirent s'organiser autour d'une cause commune allant de l'organisation d'un sport ou d'activités musicales à des actions directement politiques. Est-ce cela qui fait dire à Tocqueville que la liberté d'association permet le progrès de la démocratie et des autres droits fondamentaux ? Il nous semble en effet que les analyses comparatives de Tocqueville ont mis au jour une réalité que l'on peut toujours observer aujourd'hui en France. La liberté d'association est au cœur de la démocratie et permet son développement, de par son fonctionnement interne et de par sa nature à la fois individuelle et collective qui permet de saisir l'aspect dialectique d'une démocratie représentant les individus et la société civile organisée (I.). Qui plus, est sa structure matricielle lui permet de développer d'autres droits et libertés fondamentales nécessaires au fonctionnement d'une démocratie (II.)

I. Une liberté au fondement de la démocratie

A. Fonctionnement démocratique interne aux associations

- En France, la loi de 1901 n'impose pas directement un fonctionnement démocratique à l'intérieur de *toutes* les associations. Cependant, en pratique, de nombreux statuts reprennent un fonctionnement démocratique en introduisant le mécanisme de l'élection pour choisir les membres dirigeants.

- Les associations d'intérêt général, bénéficiant d'un régime fiscal particulier, *doivent nécessairement* fonctionner de manière démocratique ce qui implique l'organisation régulière d'assemblées générales, un droit de vote dévolu à chaque membre, des dirigeants élus et le respect d'un principe de transparence, impliquant de rendre compte de la gestion et des activités.

- En pratique, la plupart des associations proposent à leurs membres de voter pour le bureau de l'association et de prendre part collectivement aux décisions.

B. Une liberté individuelle et collective

- La liberté d'association est un droit fondamental constitutionnellement consacré ayant pour objectif de protéger concomitamment les droits individuels des membres et les droits de l'association.

- Il s'agit donc d'un droit à la fois individuel et collectif, ce qui permet de le saisir comme fondant la possibilité d'une autonomie collective infra-étatique, par la défense et la promotion d'un fonctionnement démocratique interne à l'association. Ainsi l'association permet la synthèse entre la liberté de chacun et l'égalité de tous, au fondement du principe démocratique.

II. Une liberté « matricielle » permettant un développement démocratique

A. La liberté d'association rendant effectifs les droits politiques

- La CEDH précise dans *CEDH, 2003, Parti socialiste turc c. Turquie* : « *il est de l'essence de la démocratie de permettre la proposition et la discussion de projets politiques divers, même ceux qui remettent en cause le mode d'organisation actuel d'un État, pourvu qu'ils ne visent pas à porter atteinte à la démocratie elle-même* ». Dans la même décision, la Cour rappelle qu'il n'y a pas de « *démocratie sans pluralisme* ». Les associations sont des lieux de débats d'idées et de développement de la liberté d'expression.

- Au sein des associations se développent la liberté d'expression, d'opinion et une culture démocratique par un exercice du droit de vote interne et d'élection. Les associations favorisent le pluralisme politique à l'échelle nationale.

- Le rapport de l'INSEE publié en 2016 analysant trente années de vie associative en France souligne que l'engagement associatif « *s'accompagne d'un engagement citoyen plus élevé* ». Les membres d'associations participent davantage aux élections nationales.

B. Un développement des droits fondamentaux en général

- La liberté d'association ouvre un espace de liberté de création du droit dans le but de faire vivre des droits : droit au sport ou à la culture, à la solidarité, à la dignité humaine. Pour ce faire, d'autres droits et libertés fondamentales sont activés : la liberté d'expression, d'opinions, les droits politiques, etc. En ce sens, le terme « faire vivre » peut-être interprété dans un sens socio-juridique de « rendre effectifs » les droits fondamentaux.

- Les associations déclarées disposent d'une capacité juridique permettant le recours en justice, notamment auprès du juge administratif et dans le cas où elles ont un intérêt à agir. Sous condition de permanence et de représentativité, les associations peuvent se saisir d'un droit d'action pour la défense d'intérêts collectifs : défense des droits des consommateurs, lutte contre le racisme et les violences, pour la protection de l'enfance ou de l'environnement, etc. Par le recours pour excès de pouvoir, les associations bénéficient d'une voie de droit leur permettant de défendre les intérêts qu'elles représentent. René Chapus, commentant le célèbre arrêt de principe CE 1906, *Syndicats des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli*.

- Par ce biais, les associations peuvent défendre d'autres droits fondamentaux, ce qui permet leur protection et enrichissement jurisprudentiel.

3. Commentaire d'arrêt : CE, 11 juillet 1956, *Amicale des Annamites de Paris*

(*11 juillet - Assemblée plénière - 26.638. Amicale des Annamites de Paris et sieur Nguyen-Duc-Frang - MM. Jacomet, rapp. ; Lasry, c du g ; Me Mayer, av.).*

Requête de l'Amicale des Annamites de Paris, association déclarée, représentée par ses président et secrétaire général en exercice, et du sieur Nguyen-Duc-Frang, agissant tant en son nom personnel que comme secrétaire général de ladite association, ladite requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrête du 30 avril 1953, par lequel le Ministre de l'Intérieur a constaté la nullité de l'Amicale des Annamites de Paris en application du décret du 12 avril 1939, relatifs aux associations étrangères ;

Vu la Constitution du 27 octobre 1946 ; la loi du 1er juillet 1901 ; les décrets des 12 avril 1939 et 1er septembre 1939 ; l'ordonnance du 19 octobre 1945 ; l'accord franco-vietnamien du 8 mars 1949 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article 81 de la Constitution de la République française : « Tous les nationaux français et les ressortissants de l'Union française ont la qualité de citoyens de l'Union française qui leur assure la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution » ; qu'il résulte de cette disposition que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et réaffirmés par le préambule de ladite Constitution sont applicables sur le territoire français aux ressortissants de l'Union française ; qu'au nombre de ces principes figure la liberté d'association ; que, dès lors, le Ministre de l'Intérieur n'a pu, sans excéder ses pouvoirs, constater par l'arrêté attaqué en date du 30 avril 1953 la nullité de l'association déclarée des Annamites de Paris, dont les dirigeants et les membres étaient des ressortissants vietnamiens ; ...

(Annulation)

L'arrêt du 11 juillet 1956 rendu par le Conseil d'État est moins célèbre que la décision du Conseil constitutionnel de 1971 qui proclame la liberté d'association en tant que faisant partie du bloc de constitutionnalité. Pourtant, dès 1956, le Conseil d'État a développé une argumentation similaire : il affirme l'illégalité de décisions de dissolution prises en l'absence de dispositions législatives l'autorisant, consacre pleinement la liberté d'association et la qualifie de « principe fondamental reconnu par les lois de la République », se fondant sur le préambule de la Constitution de 1946.

L'Amicale des Annamites (habitant.es du Vietnam) de Paris, par l'intermédiaire de son représentant, forme un recours en excès de pouvoir contre la décision du 30 avril 1953 du Ministre de l'Intérieur comme nulle l'association en application du décret du 12 avril 1939, relatifs aux associations étrangères. Le Ministre estime que cette association représentant la culture et la vie des Vietnamiens doit être considérée comme une association étrangère, possiblement nulle, alors même que le Vietnam fait alors partie de l'Union française. Le Conseil d'État annule l'acte sur le fondement de la liberté d'association par un raisonnement extensive.

Par quel raisonnement le juge administratif fonde-t-il sa décision d'annulation ? Pour annuler l'acte d'annulation dune association, la CE doit fonder l'existence de cette liberté fondamentale dans le bloc de constitutionalité par la reconnaissance d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République (I.)., ce qui aura une portée importante, modifiant l'ordonnancement juridique français, ouvrant des critiques doctrinales (II.).

I. La reconnaissance du PFRLR de la liberté d'association

A. Une liberté fondamentale de source légale

- Le préambule de la Constitution de 1946 réaffirme « solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Il ne cite pas ces fameux PFRLR. Le Conseil d'État va alors consacrer de lui-même la liberté d'association découlant de la loi du 1er juillet 1901 comme principe fondamental reconnu par les lois de la République. C'est l'une des rares et uniques fois que le Conseil d'État crée une norme à caractère constitutionnelle.

- Cela permet d'interpréter les textes « fondateurs » et les lois de la III^{ème} République, comme la loi de 1901, dans leur valeur constitutionnelle, permettant un contrôle de légalité. Proclamation d'une liberté et application directe.

B. Une liberté attachée à la citoyenneté

- La question qui se pose dans cet arrêt est aussi de savoir si les associations de ressortissant.es de pays de l'Union française peuvent être considérée comme étrangères.

- Le CE est clair et estime que les ressortissants vietnamiens font partie des citoyens frnaçais sur le fondement de l'article 81 de la Constitution de la République française de 1946, alors en *: « Tous les nationaux français et les ressortissants de l'Union française ont la qualité de citoyens de l'Union française qui leur assure la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution ».*

- Il s'agit d'attacher la liberté d'association à la citoyenneté et montrer ainsi la nécessité de participer à des associations pour exercer pleinement sa citoyenneté. Dès 1956, autrement dit, la première invocation jurisprudentielle du PFRLR, elle est pensée dans sa dimension démocratique et citoyenne.

II. Une interprétation extensive au fondement d'une modification profonde de l'ordonnancement juridique français, source de critiques

A. Une décision influençant la décision du CC de 1971, *Liberté d'association*

- Cette décision du CE a fortement influencé la décision du CC rendue en 1971. Sur le fondement de la Constitution de 1958 cette fois-ci, mais en reprenant le même raisonnement le CC fonde un PFRL qui ne s'impose plus qu'au pouvoir réglementaire comme en 1956 mais au pouvoir législatif désormais.

- Passage d'un État légal à un État de droit. Désormais, les lois sont soumises à la Constitution. En donnant une portée normative au Préambule de 1958 et à ses renvois, le CC vient modifier la Constitution. Son rôle change : il devient gardien de la constitution et des DF.

B. Le risque d'un gouvernement des juges

- De manière générale, la critique d'un gouvernement des juges a été avancé dès 1956.

- Dans le champ de la théorie du droit et des DLF, le Doyen Vedel estime que le CC est aussi le gardien de la transcendance des DLF par rapport à tout pouvoir politique. Pour le Doyen Favoreu, on peut observer le passage d'un droit constitutionnel à un droit constitutionnel jurisprudentiel.

4. Commentaire de texte – Extraits : *Dissolution de l'association « Les soulèvements de la Terre » : La liberté constitutionnelle d'association face à l'ordre public, un combat inégal*

Par Guillaume Drago, le 30 juin 2023, Le Club des juristes, en ligne : https://www.leclubdesjuristes.com/politique/dissolution-de-lassociation-les-soulevements-de-la-terre-la-liberte-constitutionnelle-dassociation-face-a-lordre-public-un-combat-inegal-par- guill-769/

« *Quelles interrogations juridiques ce décret de dissolution soulève-t-il ? Ce décret de dissolution du 23 juin 2023 interroge à plusieurs titres. Peut-on ainsi dissoudre un mouvement rassemblant de nombreuses personnes, une forme de collectif sans composition délimitée, revendiquant justement la représentation d'une partie de la population ? On touche d'abord ici à la liberté de manifestation qui permet le rassemblement de personnes se rapportant à un objet, un lieu, une revendication politique, écologique, sans nécessairement se rattacher à une organisation identifiée. Peut-on dissoudre une opinion, une tendance de pensée qui dépasse largement toute organisation ? Cette forme de dissolution des associations et groupement de fait est ensuite fortement marquée par son caractère politique en ce qu'elle est un acte du président de la République, pris en Conseil des ministres, deux institutions constitutionnelles mais agissant selon un mode d'action politique, au plus haut niveau de l'État. Le droit rejoint la politique, dans un acte d'autorité qui n'est pas l'expression d'un libéralisme affirmé… Enfin, la dissolution d'une association touche surtout à la liberté constitutionnelle d'association, reconnue par le Conseil constitutionnel dans sa décision fondatrice du 16 juillet 1971. La liberté d'association demeure l'une des libertés fondamentales les plus revendiquées avec plus d'un million d'associations dans notre pays. Au-delà du cas d'espèce, les agissements des « Soulèvements de la Terre » ne pouvant être approuvés, on constate que les motivations d'ordre public prennent ici le pas sur ces libertés constitutionnelles que sont la liberté d'expression et de manifestation ainsi que la liberté d'association. Ce n'est pas un bon signal pour nos libertés. Le juge saura-t-il vraiment les défendre ? On l'espère.* »

Guillaume Drago, Professeur en droit constitutionnel à l'Université d'Assas est ici interrogé dans les lignes du magazine juridique en ligne, *Le Club des juristes*, à propos du décret de dissolution de 2023 demandant la dissolution des Soulèvements de la Terre, mouvement

écologiste. Suite à un appel à manifestation massif contre les méga-bassines, le Ministre de l'intérieur dissout le groupe par décret, ce qui est fortement contesté par la doctrine car il ne s'agit pas d'une association déclarée mais une association de fait. Depuis la loi séparatisme de 2021, la loi permet de dissoudre une association ou un groupement de fait qui provoque à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens. Il est reproché aux Soulèvements de la Terre de légitimer publiquement des agissements graves.

Ce décret de dissolution soulève de nombreuses interrogations juridiques. Ainsi, peut-on dissoudre une association de fait, revendiquant la représentation d'une partie de la population ? Quels sont les fondements juridiques au cœur de la protection des groupements de faits et comment analyser le décret de dissolution ?
En premier lieu, le texte présente les fondements constitutionnels protégeant les groupements de fait (I.) qui ouvre alors à une critique de l'opportunité du décret de dissolution (II.)

I. Une association de fait protégée par plusieurs libertés fondamentales

A. Liberté d'association, protégeant les associations de fait

- *« Peut-on dissoudre une opinion, une tendance de pensée qui dépasse largement toute organisation ? ».* La liberté constitutionnelle d'association protège les groupements de fait.

- PFRLR reconnu comme pleinement constitutionnel en 1971. Jurisprudence fournie et constante du CC sur ce fondement.

B. La liberté de manifestation comme corollaire de la protection des associations de fait

- La liberté de manifestation permet le rassemblement de personnes « *se rapportant à un objet, un lieu, une revendication politique, écologique, sans nécessairement se rattacher à une organisation identifiée* ». Il s'agit donc d'un fondement alternatif pour protéger les groupements de fait réunis dans l'espace public.

- Le CC précise que l'on peut déduire la liberté de manifester de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. V CC, 2019, décision n°2019-780 QPC : il propose de considérer la liberté de manifester comme le « droit d'expression collective des idées et des opinions »

II. La contestation de la nature politique du décret

A. Ordre public et décision politique

- Ici l'auteur développe un questionnement sur la forme de la dissolution du groupement de fait : un acte du Président, pris en Conseil des ministres, c'est-à-dire*, « deux*

institutions constitutionnelles mais agissant selon un mode d'action politique, au plus haut niveau de l'État ». On peut donc observer ici que le droit rejoint la politique.

- Une décision de dissolution doit être motivée au regard des atteintes à l'ordre public et non uniquement sur des considérations politiques, ce qui est ici contesté par l'auteur. Le juge administratif sera ici amené à trancher.

B. Ordre public et libertés fondamentales

- L'auteur montre son inquiétude quant à la prépondérance de la préservation de l'ordre public au détriment des libertés fondamentales : « *on constate que les motivations d'ordre public prennent ici le pas sur ces libertés constitutionnelles que sont la liberté d'expression et de manifestation ainsi que la liberté d'association. Ce n'est pas un bon signal pour nos libertés. Le juge saura-t-il vraiment les défendre ? On l'espère.*

- Le juge est alors convoqué pour assurer l'équilibre entre les notions et à justement tranché en faveur des Soulèvements de la Terre.

- Décision du 11 septembre 2023, n° 476384, le CE précise : « *que les Soulèvements de la Terre se sont bien livrés à des provocations à des agissements violents à l'encontre des biens, qui entrent dans le champ du 1° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Cependant, il estime que la dissolution des Soulèvements de la Terre ne constituait pas une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles susceptibles d'être portés à l'ordre public au vu des effets réels qu'ont pu avoir leurs provocations à la violence contre des biens, à la date à laquelle a été pris le décret attaqué. »* V. https://www.conseil-etat.fr/actualites/soulevements-de-la-terre-gale-alvarium-cri-le-conseil-d-etat-precise-les-criteres-justifiant-la-dissolution-d-une-association-ou-d-un-groupement

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2024

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 3 – Le droit des générations futures (Corrigés)

1. Dissertation
2. Argumentation
3. Commentaire de texte
4. Commentaire d'arrêt

1. Dissertation – Les « générations futures » ont-elles un intérêt à agir en justice ?

Dès le XVIII^{ème} siècle, les jurisconsultes s'emparent de la notion de « générations futures » pour désigner le droit de modifier le droit, et plus spécifiquement les Constitutions, au regard de l'évolution de la société. V. Article 28 de la *Déclaration des droits* de la *Constitution de 1793* : « *Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures* ».

A mesure que l'humanité saisit la fragilité et la destruction de son environnement humain et naturel, les générations futures sont considérées comme nécessitant une protection juridique. C'est en substance ce qui est inscrit dans le *Préambule de la Charte des Nations Unies* : « *Nous, Peuples des Nations unies, sommes résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre* ». Ce même impératif est aujourd'hui inscrit dans la lutte contre le réchauffement climatique et l'effondrement des écosystèmes.

Une série de conférences internationales (Stockholm, 1972 ; Rio de Janeiro 1992), de rapports d'experts internationaux (Brundtland, Commission des Nations unies sur l'environnement et le développement, 1987) utilisent la notion et affirment la nécessité de la protéger en droit. En 2015, l'*Accord de Paris* engage les parties signataires à « *respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant (…) l'équité entre générations* » et devient un fondement juridique pour leur reconnaissance internationale.

Depuis quelques années, la notion se fraie un chemin normatif par la voie jurisprudentielle dans de nombreuses zones du globe et devient une question juridique de premier plan. Ce fut le cas en premier lieu dans la jurisprudence *Dejusticia* de la Cour suprême colombienne en 2018 et l'on voit aujourd'hui que le Conseil constitutionnel français a pu s'y référer (V. décision n°2022-843 DC du 12 août 2022, *infra*). Les actions en justice tendant à porter la voix des générations futures sont le plus souvent menées en relation avec les droits humains et on peut assister à une sorte de « fondamentalisation » du droit des générations futures. Ainsi, dans le champ du droit des libertés fondamentales et de son contentieux, le droit des générations futures devient une question de premier plan et sera amenée à se développer dans d'autres branches du droit.

Ce mouvement juridique international invite à discuter la possibilité de la construction juridique d'un réel droit des générations futures de source jurisprudentielle. En cela, la question de leur inexistence physique est centrale et implique de se demander dans quelle mesure elles peuvent avoir un intérêt à agir et si oui, comment le mettre en œuvre dans les procès qu'ils soient constitutionnels, administratif ou judiciaire.

Cette question épineuse, bien qu'au cœur du contentieux climatique contemporain, ne se présente que parcimonieusement dans les juridictions nationales. Les argumentations peuvent différer d'un État à l'autre. Toutefois, on peut observer des grandes tendances communes.

L'intérêt à agir est une condition de l'action en justice et constitue une règle processuelle précédant l'application du droit substantiel. Tant dans l'ordre administratif que judiciaire, il doit être né, direct, actuel et personnel pour être reconnu comme opérant dans le procès. On voit d'emblée que la question de l'intérêt à agir des générations futures est une contradiction entre les termes : le futur n'est, par essence, pas encore né, il n'est pas actuel.

Cette question entraîne d'elle-même la question de l'intérêt à agir de l'individu. En effet, chaque personne n'aurait-elle pas un intérêt à la survie de l'espèce humaine ou de ses enfants et cela par le biais de l'environnement, justifiant ainsi le caractère d'intérêt général d'un tel droit ? Cependant, il semble peu probable que tous les humains détiennent le pouvoir d'introduire une action en justice sur base d'un droit de l'Humanité ainsi accordé. Comme énoncé dans le concept même de ce droit, ce seraient les générations futures qui en seraient les titulaires, mais encore faut-il dégager une personnalité juridique à celles-ci. Dans tous les cas, elles n'ont pas la capacité d'agir en justice étant donné qu'elles n'ont pas encore intégré notre ordre juridique. Il faut donc, pour mettre en œuvre ce droit, qu'un représentant soit désigné.

Ainsi, on peut se demander dans quelle mesure les générations futures peuvent-être considérées comme disposant d'un intérêt à agir direct et personnel et ceci dans les deux ordres de juridictions, afin de permettre leur protection dans les procès contemporains. En premier lieu, l'intérêt à agir des générations futures doit être compris dans une dimension subsidiaire, dans le sens où il est porté « par ricochet » par d'autres sujets de droit disposant d'un intérêt à agir dans lequel est intégré celui des générations futures. Les générations futures ne sont donc pas directement des sujets de droit et disposent d'un intérêt à agir relatif (I.). Toutefois, dans le cas de certain procès en responsabilité – pour inaction climatique notamment – les juges peuvent reconnaître un principe de reconnaissance directe des intérêts lésés des générations futures (II.).

I. L'intérêt à agir subsidiaire des générations futures

L'intérêt à agir des générations futures peut être subsidiairement porté par l'action d'une personne individuelle (A.) ou par celui d'une personne collective (B.).

A. L'action individuelle prenant en compte les générations futures

- Les requérant.es agissent en leur nom afin d'obtenir réparation d'un préjudice et invoque « par ricochet » les intérêts des générations futures.

- CEDH, 2024, *Les Ainées c/Suisse*. Dans cette affaire, un groupe de femmes de plus de 65 ans ont intenté une action en justice contre l'État suisse afin de faire valoir le préjudice subi du fait du réchauffement climatique. En tant que séniors, elles estiment être particulièrement vulnérables à la hausse des températures. La question des générations est alors invoquée transversalement : elles mentionnent les générations futures qui elles aussi seront particulièrement touchées et dont elles portent la cause. L'intérêt à agir est indirect et porté par des actions associatives et individuelles, subsidiairement, dans le sens où porter la voix des générations futures n'est pas l'objet direct de l'association.

- Il en va de même dans les affaires : *Oposa vs. Factoran* aux Philippines ; *Andrea Lozano Barragan c. Colombie ; Juliana vs. USA.*

B. Les associations de défense des droits des générations futures

- Le cas d'une association ayant pour objet direct la défense des droits des générations futures. En France, les juges judiciaires et administratifs se montrent assez souples pour reconnaître leur intérêt à agir et donc indirectement celui des générations futures, tout comme il a pu le faire concernant les générations passées dans le cas du devoir de mémoire. V. Cour de cassation, *Le Pen et autres,* 14 janvier 197.

- Dans sa célèbre décision du 9 avril 202, *Verein KlimaSeniorinnen c. Suisse* (dite l'Affaire des

Ainées), la CEDH précise « *qu'en raison de la nature en partie collective et intergénérationnelle de la crise climatique et la complexité des questions qui sous-tendent les contentieux climatiques, les ONG sont mieux outillées que les individus (§ 489).* » Elle précise en sus dans quelle mesure les associations peuvent agir en justice. Elle doit : « *a) avoir été légalement constituée dans le pays concerné ou avoir la qualité pour agir dans ce pays, b) être en mesure de démontrer qu'elle poursuit un but statutaire correspondant au climat dans la défense des droits fondamentaux de ses adhérents ou d'autres individus, et c) être en mesure de démontrer qu'elle peut être considérée comme véritablement représentative et habilitée à agir pour le compte d'adhérents ou d'autres individus touchés dans le pays concerné se trouvent exposés à des menaces ou conséquences néfastes spécifiques liées au changement climatique.* » (§ 502).

II. La reconnaissance directe du principe de réparation pour le futur

Certaines juridictions reconnaissent l'intérêt à agir des générations futures dans celui des plus jeunes (A.). Toutefois, on observe que c'est le devoir de vigilance qui permet de fondamentaliser les générations futures, puisque c'est en leur nom qu'il est nécessaire d'agir avec précaution (B.).

A. Les générations futures représentées par les jeunes générations

- Pour la Cour constitutionnelle allemande le risque d'un dommage futur peut aussi constituer un dommage actuel pouvant affecter les droits fondamentaux et on le constate de plus en plus car certains processus s'avèrent irréversibles, comme c'est le cas du réchauffement climatique.

- Les droits des générations futures ne sont donc pas reconnus en tant que tels, ni leur intérêt à agir, mais celui-ci est enchâssé dans celui des jeunes générations qui agissent en leur nom propre et qui eux existent aujourd'hui.

- Il s'agit d'un argumentaire porté par les juges mais aussi dans la société civile, dans les mouvement *Youth for Climate* par exemple.

B. Un nécessaire développement du devoir de vigilance (ou due diligence)

- Le devoir de vigilance implique d'agir dans le présent en prenant en compte le futur. Les juges internationaux (not. Cour internationale de Justice) se sont notamment appuyés sur cette notion pour caractériser la responsabilité des États dans des situations diverses : dans le cadre du génocide en ex-Yougoslavie, dans le domaine des atteintes à l'équilibre écologique du fleuve Uruguay ou à l'intégrité des fonds marins des océans, et plus généralement dans le domaine des atteintes à l'équilibre des écosystèmes.

- Le devoir de vigilance permet d'adapter le contenu des obligations internationales, conventionnelles et coutumières, des États à la multiplication aussi bien des risques qui caractérisent la société contemporaine que des acteurs qui contribuent à leur émergence. Dans cette perspective, il n'est dès lors pas étonnant que la protection de l'environnement naturel soit devenue le champ privilégié de la *due diligence :* dans ce domaine, les atteintes dérivent assez rarement de l'action intentionnelle des États, mais d'un ensemble de négligences imputables à la fois aux acteurs privés (qui opèrent) et aux acteurs publics (qui auraient dû contrôler ces opérations).

La reconnaissance d'un devoir de vigilance autrement dit, d'un devoir de prise en compte des impacts futurs d'une action présente permet de reconnaître les générations futures au niveau des droits fondamentaux et de leur ouvrir un intérêt à agir, même s'il est porté par des représentants subsidiaires.

2. Argumentation – *Soutenez l'intérêt d'un droit des générations futures de source constitutionnelle*

Dans la célèbre affaire *Urgenda* aux Pays-Bas, l'État a été condamné pour son inaction face aux changements climatiques. Le juge souligne le lien direct entre ces changements et une atteinte aux droits et libertés fondamentales, en l'occurrence le droit à la vie et le droit au respect de la vie privée et familiale inscrits dans la Conv. EDH. La protection de l'environnement et du climat est directement reliée à une protection des droits fondamentaux des individus : l'un servant l'autre et inversement.

On observe dans les divers ordres juridiques, une volonté de créer de nouveaux droits fondamentaux englobant le respect de l'environnement. C'est le sens de la résolution 48/13 du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies reconnaissant qu'un environnement propre, sain et durable représente un droit humain fondamental. La résolution a été reprise par l'Assemblée générale, dans une résolution du 28 juillet 2022, précisant que « *dégradation de l'environnement, les changements climatiques, la perte de biodiversité, la désertification et le développement non durable font partie des menaces les plus urgentes qui pèsent sur la capacité des générations actuelles et futures d'exercer tous les droits humains de manière effective* ». S'il est clair que les humains sont directement lésés dans l'exercice de leurs droits fondamentaux par la catastrophe écologique, il semble bien que les générations futures le soient encore davantage. Si les humains vivant actuellement sur la terre, sont bien des sujets de droit, la question des générations futures en tant que sujet de droit n'est pas encore tranchée.

On peut ainsi se demander dans quelle mesure les générations futures devraient être expressément reconnues en tant que sujets de droit et inscrites dans le bloc de constitutionnalité français. Si les générations futures ne sont pas totalement absentes du bloc (I.), on peut tout de même interroger la possibilité d'une interprétation des textes constitutionnels vers une plus grande reconnaissance des générations futures, ce qui semble plus efficient qu'une révision constitutionnelle (II.).

I. Une considération déjà présente dans le bloc de constitutionnalité

A. Les générations futures évoquées dans la Charte de l'environnement

- L'Alinéa 7 du Préambule de la Charte précise qu'« *afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins* ».

- Cependant, cet alinéa n'a pas la valeur d'un droit garanti et dont on peut se prévaloir en procédure QPC selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel.

- Les générations futures sont certes évoquées mais on ne peut les considérer pleinement comme des sujets de droit et ceci alors même qu'elles ont – indirectement – la possibilité d'agir en justice.

B. **Le principe de précaution comme corollaire**

- On peut estimer que le droit des générations futures est indirectement contenu dans le principe de précaution selon la lettre de l'article 7 de la Charte de l'environnement : « *Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage*. »

- La jurisprudence récente du CC (V. Infra) reconnaît l'importance des intérêts des générations futures, qui font partie des intérêts supérieurs de la Nation. Le CC se fonde sur plusieurs article de la Charte et estime que l'économie générale du texte impose de prendre en compte le futur et les dommages nouveaux qui pourraient exister. Le principe de précaution est le moyen de respecter les générations futures et leurs droits fondamentaux.

Toutefois, face à la réalité de l'impact des politiques contemporaines sur le changement climatique future et par extension des besoins des générations futures, on ne peut se satisfaire de la fondamentalisation partielle de ces dernières.

II. La nécessité d'une évolution du droit constitutionnel pour renforcer le droit des générations futures

A. La jurisprudence constitutionnelle comme piste d'évolution de l'interprétation de la Charte

- Un mouvement juridique international montre que les évolutions majeures dans le sens d'une reconnaissante effective du droit des générations futures est de source jurisprudentielle. Par un travail d'interprétation et de combinaison des normes fondamentales de plusieurs ordres juridiques, le droit des générations futures est étendu, développé, ses contours sont de plus en plus précis.

- Un réel dialogue des juges s'est instauré.

- La CEDH précise aujourd'hui avec clarté que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme inclut le droit à une protection efficace contre les effets négatifs du réchauffement climatique sur la vie, la santé, le bien-être et la qualité de vie, ce qui implique la prise en compte des générations futures. V. CEDH 9 avr. 2024, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c/ Suisse*, n° 53600/20

B. Les débat sur l'opportunité d'une révision constitutionnelle

- Une révision constitutionnelle ouvrirait un débat politique permettant de consolider le Pacte social autour de la question écologique et des générations futures.

- Une révision constitutionnelle peut être longue et instrumentalisée pour d'autres fins politiques, ce qui pourrait entrainer une large division de la société sur le sujet.

- En guise d'ouverture, il est donc intéressant de discuter l'opportunité d'une révision.

3. Commentaire de décision – Décision n°2022-843 DC du 12 aout 2022 (extraits)

« Saisi des dispositions des articles 29 et 30 de la loi fixant le régime d'autorisation et de maintien en exploitation d'un terminal méthanier flottant et prévoyant les règles de procédure applicables au projet d'installation d'un terminal méthanier flottant sur le site portuaire du Havre, le Conseil juge qu'un terminal méthanier flottant est un navire servant d'installation de traitement de gaz naturel liquéfié, amarré dans un port où il est raccordé, par une canalisation, à un réseau de transport de gaz naturel. Au regard de son objet et de ses effets, l'installation et la mise en service d'un terminal méthanier flottant est susceptible de porter atteinte à l'environnement. Toutefois, en premier lieu, il résulte des travaux préparatoires que ces dispositions visent à répondre à des difficultés d'approvisionnement énergétique en gaz par l'augmentation des capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié. Ce faisant, elles mettent en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, au nombre desquels figurent l'indépendance de la Nation ainsi que les éléments essentiels de son potentiel économique. En deuxième lieu, les dispositions contestées prévoient que le maintien en exploitation d'un terminal méthanier flottant ainsi que l'installation d'un tel terminal sur le site portuaire du Havre est possible lorsqu'il est nécessaire d'augmenter les capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement. Il résulte cependant du préambule de la Charte de l'environnement que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation et que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Dès lors, sauf à méconnaître l'article 1er de la Charte de l'environnement, ces dispositions ne sauraient s'appliquer que dans le cas d'une menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz. En troisième lieu, les dispositions de l'article 29 prévoient que le terminal méthanier flottant désigné par arrêté est soumis aux règles et aux contrôles de sécurité internationalement reconnus applicables à la catégorie des navires, et en particulier à ceux prenant en charge du gaz naturel liquéfié, ainsi qu'à l'ensemble des prescriptions prises par le préfet sur proposition de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, afin notamment de prévenir les inconvénients ou dangers pour l'environnement. Ces prescriptions précisent les obligations liées au démantèlement ou à l'adaptation des installations et des équipements à l'issue de leur exploitation, incluant les éventuelles obligations de renaturation du site. En quatrième lieu, d'une part, les dispositions de l'article 30, qui prévoient des dérogations procédurales, ne s'appliquent que pour la réalisation d'un terminal méthanier flottant sur le site portuaire du Havre et pour une durée d'exploitation qui ne peut dépasser cinq ans. D'autre part, ces dérogations, qui sont limitativement énumérées, ne peuvent être mises en œuvre que si elles sont strictement proportionnées aux besoins de ce projet et jusqu'au 1er janvier 2025. Dans tous les cas, le public est informé sur les incidences notables du projet sur l'environnement et la santé humaine et l'exploitant doit se conformer aux mesures d'évitement et de réduction des atteintes à des espèces protégées et à leurs habitats. En outre, dans un délai de six mois à compter de la mise en service du terminal, l'exploitant est tenu de réaliser une étude, mise à la disposition du public, sur les impacts environnementaux associés à l'exploitation du terminal. Il doit également, six mois avant la fin de l'exploitation, remettre une étude, mise à disposition du public, sur les conditions de démantèlement de l'exploitation, les mesures de compensation mises en œuvre et l'état de la biodiversité et des sols. Par ailleurs, les décisions de l'autorité compétente prises en application de ces dérogations peuvent faire l'objet de recours devant le juge administratif, y compris par la voie du référé. Il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 12, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l'article 1er de la Charte de l'environnement ».

(2022-843 DC, 12 août 2022, cons. 10, 11, 12, 13, 14, 15, JORF n°0189 du 17 août 2022, texte n° 5)

Les articles 30 et 36 de la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat prévoyaient des dérogations procédurales applicables au projet d'installation d'un terminal méthanier flottant sur le site portuaire du Havre et de rehausser le plafond d'émission de gaz à effets de serre applicable à certaines installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles.

Saisi en contrôle *a priori* par les députés et sénateurs, le Conseil constitutionnel émet de fortes réserves d'interprétations et développe un argumentaire constitutionnel favorable à la reconnaissance d'un droit des générations futures dans l'ordre juridique français. La décision est tout à fait novatrice et illustre la place grandissante des juridictions dans la défense de la lutte contre le réchauffement climatique

Dans quelle mesure le Conseil constitutionnel permet-il une ouverture à la reconnaissance constitutionnelle des générations futures ? La décision est novatrice et permet en effet de penser que le droit constitutionnel peut reconnaître des sources constitutionnelles à un droit des générations futures (I.). Toutefois, la reconnaissance est en demi-teinte, puisqu'il ne s'agit d'une réserve d'interprétation

I. Une décision novatrice : la reconnaissance d'un droit des générations futures

A. Une reconnaissance certaine des besoins propres des générations futures

« Il résulte cependant du préambule de la Charte de l'environnement que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation et que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. »

- Le Conseil constitutionnel juge que, au regard de son objet et de ses effets, l'installation et la mise en service d'un terminal méthanier flottant est susceptible de porter atteinte à l'environnement.

- Cette atteinte à l'environnement compromet le droit des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Cette satisfaction des besoins ne doit pas être compromise par des actions actuelles.

- Le respect de l'environnement est pensé comme un respect des générations futures et peut être considéré comme un intérêt fondamental de la Nation.

B. La Charte de l'environnement, source d'un droit des générations futures

« *Dès lors, sauf à méconnaître l'article 1er de la Charte de l'environnement, ces dispositions ne sauraient s'appliquer que dans le cas d'une menace grave sur la sécurité »*

- Invocation directe des articles 1, 6 et 7 de la Charte

- Analyse de ces articles comme le fondement d'un droit des générations futures

- Ouverture à une reconnaissance les générations futures comme des sujets de droit constitutionnel, titulaires de droits fondamentaux.

II. Une application fragile dans la jurisprudence : la réserve d'interprétation

A. Une réserve d'interprétation plutôt qu'une censure de la loi

« Ces dérogations, qui sont limitativement énumérées, ne peuvent être mises en œuvre que si elles sont strictement proportionnées aux besoins de ce projet et jusqu'au 1er janvier 2025 »

- Le CC ne censure pas la loi mais propose une réserve d'interprétation. Il invite le gouvernement à analyser la loi dans le sens qu'il propose mais la contrainte qu'il peut exercer reste limitée.

- Le CC observe une série de dérogations possibles permettant de contourner le droit constitutionnel environnemental.

- La protection et les innovations sont en demi-teintes : il admet les dérogations possibles mais estime qu'elles doivent être limitée au maximum et strictement proportionnées. Il y a donc un balancement entre les intérêts économiques, énergétiques et écologiques.

B. La place du CC : juge de la constitutionnalité et non de l'opportunité politique

- L'impossibilité d'une censure effective et d'une réelle reconnaissance d'un droit des générations futures est inhérente à la fonction du juge constitutionnel qui ne peut décider à la place du Parlement, au regard du principe de la séparation des pouvoirs.

- Il répète cet argumentaire juridique dans une jurisprudence constante.

- Il y a une limite inhérente à la fonction des cours. La possibilité de reconnaître pleinement les générations futures et leurs droits fondamentaux revient au constituant originaire ou dérivé.

4. Commentaire de texte – *Le Rapport Brundtland, Notre avenir à tous*, 1987, Extrait

« *L'espoir que la Commission place en l'avenir est conditionné par la prise immédiate de mesures politiques décisives pour commencer à gérer les ressources de l'environnement de manière à assurer un progrès durable et à garantir la survie de l'humanité. Nous ne prédisons pas l'avenir : nous nous bornons à signifier à l'humanité – et ce, de toute urgence et à partir des données scientifiques les plus fiables et les plus récentes – qu'il est largement temps de prendre les décisions qui s'imposent pour s'assurer des ressources qui feront vivre cette génération et celles à venir. Nous n'avons pas de cadre strict à imposer ; nous nous contentons d'indiquer une voie qui permettrait aux peuples de la Terre de multiplier les sphères de coopération.* »

Le Rapport Brundtland est le nom usuel d'une publication de 1987 intitulée Notre avenir à tous. Il a été rédigé par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'ONU, alors présidée par Mme Gro Harlem Brundtland. Ce texte fait aujourd'hui partie des textes fondamentaux du droit de l'environnement et participe à la conceptualisation du terme « développement durable ». Ce terme a ensuite été médiatisé lors du Sommet de la Terre de 1992, se tenant à Rio.

Le rapport définit le développement durable et propose de saisir les moyens de le mettre en œuvre, de le rendre effectif dans les politiques publiques et le temps présent. L'extrait présenté montre

l'espoir en avenir meilleur qui ne sera permis que par la prise de conscience internationale de l'urgence environnementale, en s'appuyant sur l'expertise scientifique. Il s'agit ainsi dans cet extrait de questionner les moyens d'un développement durable et ses objectifs. La durabilité est alors affaire de lien entre les générations (I.) qui doit être pris en compte dans les politiques publiques (II.).

I. Un développement durable nécessairement intergénérationnel

A. La gestion durable des ressources pour la survie de l'humanité

- Le développement durable passe par une gestion décroissante des ressources.
- La décroissance remet en cause le mode productiviste d'extraction et devient un concept de droit mou international. Ce rapport signe la prise en compte d'une remise en cause de la gestion actuelle des ressources, propose un modèle alternatif et une prise de conscience internationale.
- La survie de l'humanité présente ne peut se faire que par une prise en compte réelle de la question écologique.

B. Des devoirs nouveaux envers les générations futures

- Le rapport montre la nécessaire prise en compte des générations futures et de devoirs de la génération présente envers elle
- Les ressources doivent être protégées en prenant en compte les besoins des générations futures
- Des sphères de coopérations sont nécessaires impliquant la prise en compte de l'humanité future
- Ce rapport de 1987 est tout à fait novateur et pose les bases du droit international de l'environnement actuel

II. L'objectif : interpeller les États

A. Une prise immédiate de mesures demandée

- Pour permettre un développement durable et garantir la vie aux générations futures, la Commission précise que les États doivent prendre des mesures. Les politiques publiques de tous les États sont interpellées pour qu'elles légifèrent.
- Ces mesures sont urgentes et s'imposent. La Commission demande un droit de l'environnement qui permet le développement durable actuel et pour l'avenir. La prise en compte de l'avenir est maintenant une nouvelle donne politique, même s'il n'est pas possible de le prévoir totalement.

B. Les limites et les faiblesses de l'ONU

- Ce rapport de 1987 n'a pas eu les effets escomptés, on peut aujourd'hui s'en rendre facilement compte.
- En effet, la Commission spéciale et l'ONU n'ont pas le pouvoir de contraindre les Etats, ni même de formuler des mesures précises. Il en va de la séparation des pouvoirs.
- La Commission est claire sur ce sujet : elle ne peut que se permettre « d'indiquer la voie » et ne peut formuler « un cadre strict ».
- En substance, cet extrait contient tous les enjeux du droit de l'environnement aujourd'hui : une affirmation de l'urgence, d'un besoin de politiques publiques décisives prenant en compte le lien intergénérationnel et les faiblesses des institutions qui alertent sur ce sujet.

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2024

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 4 – Solidarité (Corrigés)

1. Dissertation
2. Argumentation
3. Commentaire de texte
4. Commentaire d'arrêt

1. Dissertation – La solidarité est-elle un droit fondamental ?

En France, le Code civil de 1804, aux articles 1197 et suivants, se réfère à la solidarité comme un moyen purement technique de créer des obligations collectives, indépendamment des appartenances communautaires et sans « lien individuel entre créancier et débiteur. Il est à la base des dispositifs juridiques de propriété solidaire ou de répétition d'indu qui ne supposent pas l'existence préalable d'un acte de volonté.

Dès les années 1830, en France, les saint-simoniens et socialistes utopiques comme Pierre Leroux (1797-1871) ou Charles Fourier (1772-1837) s'y réfèrent abondamment. À partir des années 1850, ils sont suivis, entre autres, par Charles Gide (1847-1932) ou Émile Durkheim (1858-1917), qui distingue la solidarité mécanique (dans les sociétés inférieures où les membres du groupe sont peu différenciés) de la solidarité organique (dans les sociétés supérieures, où les individus sont différenciés mais aussi associés du fait de la division du travail social). L'un des plus importants théoriciens de la question est Alfred Fouillée (1838-1912) puis Léon Bourgeois (1851-1925) qui va intégrer ces évolutions fortes de la société française au XIXe siècle dans une théorie, le « solidarisme », s'écartant à la fois de l'individualisme libéral issu de la Révolution française et des différentes idéologies collectivistes en plein essor (Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865 et Karl Marx, 1818-1883 .).

Par l'étude de ces travaux, on peut saisir que la solidarité est un fait, dans le monde physique et biologique, comme dans le monde social. Tout, chez chaque être humain, dépend des autres : sa santé, en raison de la propagation des maladies ; sa condition matérielle, du fait de la division du travail ; ses idées, qui dépendent de la circulation des connaissances. Ensuite, très important, le fait même de vivre en société implique une dette à l'égard des autres, des vivants comme des morts. Il semble bien que la théorie politique souligne l'impérieuse nécessité de la solidarité pour garantir la vie en société et permettre ainsi à des droits fondamentaux d'exister effectivement : le droit à la vie, à la vie familiale normale, à la liberté générale, à l'égalité entre tous. Pourtant, le terme solidarité ne fait pas expressément partie du bloc de constitutionnalité, il n'est pas invoqué dans les textes classiques et ne fait pas non plus l'objet d'une consécration jurisprudentielle. Il est ainsi intéressant de se questionner sur la possible fondamentalité de la solidarité.

Le principe de solidarité se retrouve en substance dans d'autres droits et libertés fondamentales et apparaît ainsi comme une des fonctions de ces droits (I.). Plus récemment, le principe de fraternité a permis une reconnaissance plus directe de la solidarité (II.).

I. Un droit à la solidarité contenu dans d'autres droits fondamentaux

A. L'égalité comme moyen de reconnaissance de la solidarité

- En France, le principe d'égalité a pour particularité de se retrouver dans les textes du bloc de constitutionnalité provenant de plusieurs générations de droit. La Déclaration de 1789 dans son article 1er proclame « l'égalité en droit », l'article 6 « l'égalité de tous devant la loi et face aux emplois publics » et l'article 13 « l'égalité de tous devant l'impôt ». L'article 1er de la Constitution de 1958 et l'alinéa 3 du Préambule de 1946 interdisent les différenciations opérées sur les critères de l'origine, de la race, de la religion, des croyances et du sexe. C'est la norme de référence la plus invoquée dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

- La conception classique du principe revient à considérer l'égalité des citoyens devant la règle de droit, ce qui implique de ne pas créer de discrimination par le droit. Il s'agit ainsi dans cette conception majoritaire de ne pas prendre en compte les discriminations de fait selon le considérant de principe du CC : « si le principe d'égalité devant la loi implique qu'à situations semblables il soit fait application de solutions semblables, il n'en résulte pas que des situations différentes ne puissent faire l'objet de solutions différentes ». V. CC n°79-107 DC, 12 juillet 1979, *Ponts à péages.*

- Toutefois, la jurisprudence a ouvert l'interprétation du principe d'égalité. Progressivement, il affine son considérant de principe pour reconnaître des caractéristiques sociales particulières pouvant justifier une différence de traitement, notamment du fait de l'âge (CC n°89-257 DC, 25 juillet 1989, *Prévention des licenciements économiques*) mais aussi dans le cadre des recrutements et concours de la fonction publique. Ainsi, selon lui, le principe d'égalité « ne s'oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre l'appréciation des aptitudes et des qualités des candidats à l'entrée dans une école de formation ou dans un corps de fonctionnaires soient différenciées pour tenir compte tant de la variété des mérites à prendre en considération que de celle des besoins du service public » V. CC n°82-153 DC, 14 janvier 1983, *Troisième voie d'accès à l'ENA.*

- En prenant en compte des caractéristiques de fait, le CC montre que l'on peut interpréter le principe d'égalité en tant que moyen juridique pour assurer une solidarité entre les membres d'une même nation. Les inégalités de fait impose une certaine adaptation du droit pour assurer une solidarité réelle entre les membres.

B. Les principes particulièrement nécessaires à notre temps, une consécration dans le champ économique et social

- Les PPNT sont les droits-créance contenus dans le Préambule de la Constitution de 1946. Ils organisent les droits sociaux : la négociation collective, le droit de grève et de manière plus générale les droits permettant un État-Providence : la famille, comme l'individu, se voient assurer les conditions nécessaires à leur développement (alinéa 10) ; tout être humain dans l'incapacité de travailler se voit accorder le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence (alinéa 11), etc.

- On les retrouve dans la *Charte sociale européenne* et dans la *Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs*.

- La philosophie soutenant ces DLF dits de 2ème génération est l'organisation d'une solidarité à l'échelle nationale en fonction des niveaux de richesse économique des individus.

II. Une reconnaissance plus directe : la fraternité

A. Une fondamentalité formelle nouvelle

- Depuis la Décision du CC, en QPC , Cédric H (V. Commentaire d'arrêt *infra*): la devise de la France « Liberté, Égalité, Fraternité » a une valeur de liberté fondamentale et peut être invoquée au fondement d'une QPC.

- La jurisprudence consacre ainsi un droit fondamental à la solidarité, en la fondant dans le texte constitutionnel de 1958 directement. En substance, il s'agit d'un droit à agir dans un but humanitaire et ceci peut implique une aide apportée alors même qu'une personne se trouve dans une situation d'illégalité.

- La fondamentalité est donc formellement consacrée, sa source est constitutionnelle et donc supérieure aux lois.

B. Des précisions jurisprudentielles attendues

- La formule étant très largement ouverte à interprétation, il faut attendre les précisions des cours. Il n'y a pour l'heure que peu d'application jurisprudentielle.

- Cela montre la faiblesse du principe et le flou qui entoure la notion mais qui permet tout de même de développer une critique générale des DLF notamment concernant ses lacunes (qui est de manière générale, une méthode intéressante pour commenter les DLF). Le principe de solidarité semble manquant dans le champ des DLF consacrés dans le bloc de constitutionnalité. Il gagnerait à y être inscrit car il leur donnerait une cohérence d'ensemble. Car en effet, on peut, à bien des égards, estimer que le principe de solidarité est au fondement de tous les DLF, ces derniers existant dans le but de protéger et d'assurer une égalité entre tous et toutes.

2. Argumentation – Soutenez que la solidarité est une notion essentielle du droit de l'environnement

La préservation des ressources, du climat et de l'environnement est aujourd'hui le problème global par excellent et peut être bien le plus important défi de l'humanité. Il révèle l'interconnexion entre les États et les peuples et impose une gestion collective.

Aussi, la question environnementale révèle les injustices à l'échelle planétaire. Les pays du sud étant davantage impactés par les effets du réchauffement climatique, le principe de solidarité entre les État pour répartir les efforts et les responsabilités semble d'emblée au cœur d'un droit de l'environnement effectif.

Définition de la solidarité. V. *supra.*

Toutefois, c'est dans une double dimension que le principe de solidarité est le plus fréquemment invoqué en tant que fondement du droit de l'environnement. Il se décline en tant que solidarité entre les générations (I.) et entre les espèces (II.).

I. La solidarité entre les générations

A. Une consécration internationale

- Depuis le rapport Brundtland de 1987, la nécessité d'une solidarité entre les générations est définie dans le sens d'une solution au problème du réchauffement climatique et de la destruction de l'environnement.

- D'autres outils internationaux vont dans ce sens, comme c'est le cas de la Déclaration des droits de l'Humanité du 22 sept. 2016. L'article I précise : « *Le principe de responsabilité, d'équité et de solidarité, intragénérationnelles et intergénérationnelles, exige de la famille humaine et notamment des États d'œuvrer, de manière commune et différenciée, à la sauvegarde et à la préservation de l'humanité et de la terre. ».* La même déclaration précise en son article XI que la solidarité intergénérationnelle implique nécessairement es devoirs des générations actuelles envers les futures.

B. Une consécration nationale en demi-teinte

- Si le Conseil constitutionnel a déduit du Préambule de 1946, une nécessaire équité entre les générations (décision n° 97-388 DC du 20 mars 1997), la formule est beaucoup moins présente dans le droit national.

- On peut néanmoins observer un développement de la notion tant dans le doctrine que dans la jurisprudence (V. Sujet – Le droit des générations futures).

- Ceci est compréhensible dans le sens où la réduction des gaz à effet de serre et la lutte contre la dégradation environnementale est une action nécessairement globale.

II. La solidarité entre les espèces

A. Des sujets de droits non-humains

- La reconnaissance de sujets de droit non-humains est aujourd hui un phénomène important dans la justice environnementale des États.

- Déjà en 2011, la Cour provinciale de Loja en Équateur reconnaît la personnalité juridique du fleuve Vilcabamba : Cour provinciale de Loja Équateur, n°11121-2011-0010 du 30 mars 2011.

- En 2015 puis 2016, la Cour constitutionnelle colombienne reconnaît une personnalité juridique au fleuve Atrato alors très pollué : Sentencia T-080 2015 du 20 février 2015 et Sentencia T-622-16, 10 novembre 2016.

- Puis, en 2017, la Haute Cour de l'Uttarakhand en Inde reconnaît le Gange, la rivière Yamuna et les glaciers Gangotri et Yamunotri en tant que personnes juridiques vivantes.

- En 2018, la Cour suprême de Colombie reconnaît la personnalité juridique de l'Amazonie colombienne.

- Ces consécrations jurisprudentielles ne sont pas sans poser des problèmes juridique, notamment quand on cherche à les transposées en droit français : comment assurer la mise en œuvre des droits de ces nouveaux sujets ? Les fleuves ne pouvant physiquement ester en justice, ils sont nécessairement représentés par d'autres sujets, en l'occurrence des humains en collectifs ou individuellement, ce qui impose une solidarité juridique.

B. Des humains garants de ces nouveaux sujets de droits

- Les humains, la plupart du temps en association, sont les mieux à même à protéger et faire valoir les droits des autres espèces.

- Ce raisonnement fait valoir ce que la CEDH a récemment argumenté dans l'affaire des Ainées contre Suisse en précisant que les ONG ont un intérêt à agir plus direct en matière environnementale.

3. Commentaire de décision – Décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018, M. Cédric H. et autre [Délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger]

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 11 mai 2018 par la Cour de cassation (Chambre criminelle, arrêts nos 1163 et 1164 du 9 mai 2018), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été posées pour MM. Cédric H. et Pierre-Alain M. par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2018-717 QPC et 2018-718 QPC. Elles sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 622-1 et L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
(...)
- En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe de fraternité : Aux termes de l'article 2 de la Constitution : « La devise de la République est "Liberté, Égalité, Fraternité" ». La Constitution se réfère également, dans son préambule et dans son article 72-3, à l' « idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité ». Il en ressort que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle. Il découle du principe de fraternité la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Toutefois, aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « au séjour irrégulier » figurant au premier alinéa de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées, sont contraires à la Constitution.

I. La reconnaissance expresse de la valeur normative de la fraternité

A. La devise de la France en tant que principe à valeur constitutionnelle

- Le juge constitutionnel reconnaît expressément la valeur constitutionnelle de la fraternité et son opposabilité au sein d'une QPC. Elle est précisée dans les articles 2 et 72-13 de la Constitution mais n'avait jamais été interprétée comme ayant une valeur fondamentale pouvant annuler une loi y contrevenant. La décision du CC est en cela tout à fait novatrice.

- Désormais, la fraternité bénéficie d'une fondamentalité formelle. Selon ce point de vue, la fondamentalité d'un droit est consubstantiel au caractère constitutionnel de ce droit. La valeur constitutionnelle emporte la valeur fondamentale du droit. Cela consiste à postuler que, dans notre ordre juridique, le constitutionnel étant fondamental, les droits fondamentaux sont les droits constitutionnels.

B. La liberté d'aider dans un but humanitaire au cœur de la fraternité

- En l'espèce, la fraternité permet d'exercer une aide humanitaire, d'aider des individus se trouvant dans des situations de détresse et ceci même sils sont dans une situation illégale, comme c'est le cas en espèce.

- Le principe constitutionnel de fraternité permet de protéger les actions solidaires, l'entraide et les actions générales des ONG à but humanitaire.

II. Le droit au séjour des étrangers sur le sol français, en dehors du champ de la constitutionnalité

A. Un principe n'ouvrant pas de droit à la migration

- Le principe de fraternité ouvre un droit individuelle à apporter une aide et non un devoir des États : la fraternité n'est pas un droit-créance c'est un droit-liberté rattaché à la personne humaine. Il permet de protéger les individus des ingérences de l'État mais n'ouvre pas d'obligation d'agir à ce dernier.

- L'État n'est pas ici enjoint à prendre des mesures globales pour organiser la migration et les situations humanitaires qui en découlent. En cela, la jurisprudence du CC, bien que novatrice et permettant de garantir à des individus et ONG de continuer leurs actions humanitaires, demeure fortement limitée, notamment au regard de la *soft law* international qui impose une solidarité entre les États sur les questions migratoires. (V. *infra*).

B. Une application incertaine : un principe à concilier avec la préservation de l'ordre public

- Le juge des référés de Besançon a été saisi d'une demande de suspension d'un arrêté « anti-mendicité » pris par le maire. Après avoir fait référence à la décision du CC (« de ce principe découle la liberté fondamentale d'aider autrui dans un but humanitaire »), le

juge des référés rappelle que cette liberté n'a pas de caractère général et absolu et doit être conciliée avec notamment l'objectif de préservation de l'ordre public. Il n'est donc pas possible de se prévaloir de la liberté de mendier en se fondant sur le principe de fraternité.

- Le peu de références au principe suppose une utilisation encore marginale mais pourrait se développer face à de nouvelles questions de société.

4. Commentaire – Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (dit « Pacte de Marrakech »), 11 déc. 2018 (extrait)

Pour que notre action porte ses fruits, les États doivent faire preuve de confiance mutuelle, de détermination et de solidarité afin de concrétiser les objectifs et engagements énoncés dans le présent Pacte mondial. Nous unissons nos forces, dans un esprit de coopération profitable à tous, afin de relever les défis que posent les migrations sous tous leurs aspects et de tirer parti des possibilités qu'elles offrent en partageant les responsabilités et en mettant au point des solutions novatrices. C'est mus par cette ambition commune que nous prenons cette initiative historique, pleinement conscients du fait que le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières marque certes une étape importante, mais pas la fin de nos efforts.

En 2018, de nombreux chefs d'États et gouvernement se sont réunis au Maroc afin de trouver une entente internationale autour de la question de la migration et de ses conséquences politiques. Par-là, ils réaffirment la *Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants* de … et désirent fonder une réelle coopération internationale sur la question. Pour ce faire, ils adoptent le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières fondé sur un principe de solidarité entre les États.

L'extrait à commenter s'appuie sur la notion de solidarité pour fonder une méthode novatrice de régulation des migrations internationales et permet ainsi de poser une définition du principe (I.) et il apparaît alors que la solidarité peut être vue comme une méthode en droit international (II.)

I. Une définition de la solidarité internationale

A. Une coopération et une union des forces internationales

- L'extrait précise que la question de la migration implique une coopération internationale au fondement du principe de solidarité.

- Ainsi, la coopération, la confiance mutuelle et l'union des forces sont des éléments de définition de la solidarité et permettent de voir ce dernier comme un principe matriciel.

B. Un nécessaire partage des responsabilités

- La solidarité est aussi un partage des responsabilités face aux problèmes qui touchent tous les États.

- Cette méthode d'action est au cœur de problèmes internationaux tels celui qui concerne le présent Pacte, la migration, et il tend à se développer notamment dans le champ du droit international de l'environnement. La solidarité et le partage des responsabilités sont au cœur du droit international.

II. Une méthode d'action en droit international

A. Un moyen pour concrétiser des objectifs internationaux

- La solidarité n'est pas qu'un principe fondamental à appliquer par principe : c'est une méthode d'action internationale qui permet d'atteindre des objectifs généraux. En l'occurrence, il s'agit d'un moyen pour résoudre la question migratoire par solidarité et partage de responsabilités entre les États accueillants et les États de départ de migration.

- Cette méthode est au cœur des institutions internationales depuis la SDN à celles nous étant contemporaines. Il s'agit de reconnaître un lien de solidarité de fait entre les États. V. https://www.ungeneva.org/fr/about/league-of-nations

- Il en va de même de de l'ONU. En effet, le Pacte repose sur les buts et principes consacrés par la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte International relatif aux droits économiques sociaux et culturels.

B. Une solution novatrice

- Malgré une méthode d'action reconnue et développée dans le droit international, le Pacte estime qu'il s'agit d'une solution novatrice soulignant ainsi le manque de coopération internationale et le nécessaire développement d'une réelle solidarité entre les États.

- Le principe de solidarité est ainsi un moyen de critique des actions internationales et des politiques internes des États qui ne participent que peu à l'élaboration de politiques solidaires concernant la migration en particulier. Cette critique peut tout à fait s'étendre plus globalement.

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2024

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 5 – Environnement (Corrigés)

1. Dissertation
2. Argumentation
3. Commentaire de texte
4. Commentaire d'arrêt

1. Dissertation : le droit à un environnement sain

Présentation du sujet :

- Définition du droit à un environnement sain : Article 1er Charte de l'environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé »
- Droit 3ème génération : droits octroyés à un peuple (autres exemples : paix, développement…)
- Consécration tardive du droit à un environnement sain, en particulier en France
- Difficultés dans sa mise en œuvre
- Comment le droit à un environnement sain est-il garanti aujourd'hui ?

I. La consécration récente du droit à un environnement sain

A. Les sources internationales

- Droit international :
    - Déclaration de Stockholm 1972
    - Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 1992
    - Protocole de Kyoto 1997
    - Accord de Paris 2015
    - Absence de mention de l'environnement dans la CEDH
- Union européenne :
    - Article 191 TFUE
    - Article 37 Charte européenne des droits fondamentaux

B. Les sources nationales

- Charte de l'environnement : Article 3 : principe de prévention ; Article 4 : réparation des préjudices causés à l'environnement ; Article 5 : principe de précaution ; Article 7 : principe de participation du public
- Valeur constitutionnelle des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement : CC, 19 juin 2008, *Loi relative aux OGM* ; CE, 3 octobre 2008, *Commune d'Annecy*
- Article 1246 et s. code civil : préjudice écologique
- Article L. 110-1-II code de l'environnement : 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; 4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ; 5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ; 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et

réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment

II. Une mise en œuvre insuffisante

A. La garantie juridictionnelle du droit à un environnement sain

- CC, 27 octobre 2023, *Association Meuse nature environnement* : lorsqu'il adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à un environnement équilibré et respectueux de la santé, le législateur doit veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, en préservant leur liberté de choix à cet égard. Les limitations apportées par le législateur à l'exercice du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé doivent être liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi
- CE, 19 juillet 2010, *Association Les Hauts de Choiseul* : principe de précaution (article 5 Charte) s'impose aux pouvoirs publics aux autorités publiques, y compris en urbanisme
- Droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé : liberté fondamentale invocable en référé liberté : CE, 20 septembre 2022
- CE, 27 mars 2023, *Association Réseau Sortir du nucléaire* : le principe de non-régression s'impose au pouvoir réglementaire, sauf si le législateur en a écarté l'application
- CEDH, 9 avril 2024, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c/ Suisse* : violation de l'article 8 CEDH, qui consacre un droit pour les individus à une protection effective, par les autorités de l'État, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie

B. Les difficultés dans la garantie du droit à un environnement sain

- Absence de responsable identifié
- Pollution transcende les frontières
- Connaissances juridiques insuffisantes
- Difficulté à contraindre les pouvoirs publics : CE, arrêts *Commune de Grande Synthe*
- Équilibre entre le droit à un environnement sain et d'autres droits et libertés : avec la liberté d'entreprendre : CC, QPC du 31 janvier 2020, *Union des industries de la protection des plantes* : Il appartient au législateur d'assurer la conciliation des objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et de protection de la santé avec l'exercice de la liberté d'entreprendre
- Équilibre entre droit à un environnement sain et d'autres intérêts : industries, chasse, pêche, transports, constructions …

2. Argumentation : Soutenez que le droit à un environnement sain ne peut pas être atteint

Présentation du sujet :

- Définition du droit à un environnement sain : Article 1er Charte de l'environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé »
- Droit 3ème génération : droits octroyés à un peuple (autres exemples : paix, développement…)
- Droit à un environnement sain n'existe que parce qu'existent des atteintes à l'environnement
- Consécration tardive du droit à un environnement sain, en particulier en France
- Difficultés dans sa mise en œuvre, tant au niveau des textes que de leur application

I. Des textes insuffisants ou inadaptés

A. Les sources internationales : des déclarations à portée symbolique

- Principaux traités :
  - Déclaration de Stockholm 1972
  - Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 1992
  - Protocole de Kyoto 1997
  - Accord de Paris 2015
- Déclarations énoncent des objectifs, qui n'impliquent pas d'obligations précises pour les parties mais parfois seulement une obligation de moyens
- Difficultés dans leur mise en œuvre : absence de mécanismes contraignant les États, absence de sanctions
- Pourtant, le dérèglement climatique est un problème mondial, qui dépasse les frontières : l'échelon mondial est celui qui paraît le plus adapté

B. Les sources européennes et nationales : une meilleure efficacité

- Transposition des objectifs internationaux au niveau de l'UE : mécanismes permettant de contraindre les États membres
- Charte de l'environnement : tous les articles ne sont pas invocables devant le juge
- Loi prévoit des obligations précises : par exemple, pour les installations classées pour l'environnement, les émissions de gaz à effet de serre, la dépollution des sols… => Recours juridictionnels possibles si inexécution

II. Une mise en œuvre du droit à un environnement sain insuffisante

A. Des progrès dans la protection par le juge

- CC, 27 octobre 2023, *Association Meuse nature environnement* : lorsqu'il adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à un environnement

équilibré et respectueux de la santé, le législateur doit veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, en préservant leur liberté de choix à cet égard. Les limitations apportées par le législateur à l'exercice du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé doivent être liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi

- CE, 19 juillet 2010, *Association Les Hauts de Choiseul* : principe de précaution (article 5 Charte) s'impose aux pouvoirs publics aux autorités publiques, y compris en urbanisme
- Droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé : liberté fondamentale invocable en référé liberté : CE, 20 septembre 2022
- CE, 27 mars 2023, *Association Réseau Sortir du nucléaire* : le principe de non-régression s'impose au pouvoir réglementaire, sauf si le législateur en a écarté l'application
- CEDH, 9 avril 2024, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c/ Suisse* : violation de l'article 8 CEDH, qui consacre un droit pour les individus à une protection effective, par les autorités de l'État, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie

B. Des difficultés difficilement surmontables

- Absence de responsable identifié
- Pollution transcende les frontières
- Difficulté à contraindre les pouvoirs publics : CE, arrêts *Commune de Grande Synthe*
- Équilibre entre le droit à un environnement sain et d'autres droits et libertés : avec la liberté d'entreprendre : CC, QPC du 31 janvier 2020, *Union des industries de la protection des plantes* : Il appartient au législateur d'assurer la conciliation des objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et de protection de la santé avec l'exercice de la liberté d'entreprendre
- Équilibre entre droit à un environnement sain et d'autres intérêts : industries, chasse, pêche, transports, constructions …

3. Commentaire d'arrêt : CE, 3 octobre 2008, *Commune d'Annecy*

Présentation du sujet :

Un décret du 1er août 2006 relatif à la procédure d'élaboration des décisions de délimitation des zones de protection autour des grands lacs de montagne, avait été pris en application de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme. Cet article organise une procédure administrative (notamment la mise en œuvre d'une enquête publique) visant à la délimitation, autour des lacs de montagne, de secteurs d'application de la loi littoral.
Ce mécanisme est moins protecteur de l'environnement dès lors que la loi littoral ne s'applique plus sur l'ensemble du territoire de ces communes.
La commune d'Annecy a attaqué ce décret, en invoquant la méconnaissance du principe de participation et d'information du public, tel qu'énoncé par l'article 7 de la Charte de l'environnement, lors de l'élaboration des décisions de délimitation dans le domaine de la protection des grands lacs de montagne.

Le Conseil d'Etat consacre la valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement, ainsi que son invocabilité devant le juge administratif.
Il conclut à l'illégalité du décret pour incompétence de son auteur, au motif qu'il n'appartient qu'au législateur, et non au pouvoir réglementaire, de mettre en œuvre le principe de participation du public conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement.

Fondements juridiques :

- **Constitution 1958** : article 34 : « La loi détermine les principes fondamentaux : (…) de la préservation de l'environnement »
- **Charte de l'environnement** : article 7 : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement »

Problèmes de droit :

- La Charte de l'environnement a-t-elle valeur constitutionnelle ?
- La Charte est-elle invocable devant le juge administratif, à l'appui d'un recours contre un acte réglementaire ?
- Le pouvoir réglementaire pouvait-il prévoir la mise en œuvre d'une enquête publique, alors qu'elle n'était pas prévue par la loi ?

I. La répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire précisée par la Charte

A. Un renforcement de la compétence du pouvoir législatif

- Article 34 Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux : (…) de la préservation de l'environnement »
- Nouveau domaine de la loi avec loi constitutionnelle du 1er mars 2005
- 3 articles de la Charte renvoient à la loi : article 3 (devoir de prévention), article 4 (devoir de réparation des dommages causés à l'environnement) et article 7 (principe de participation du public)
- CE, 2008, *Cme d'Annecy* : l'article 7 Charte réserve au législateur le soin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de tout personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. A contrario, le pouvoir réglementaire se limite à mettre en œuvre ces limites et conditions

B. La sanction de l'incompétence du pouvoir réglementaire

- En l'espèce, le décret attaqué ne se limitait pas à prendre des mesures d'application de dispositions législatives
- L'article L. 145-1 code de l'environnement (antérieur à la Charte) ne précise pas les conditions et limites de l'information et la participation du public. Le décret attaqué du 1er août 2006 (postérieur à la Charte) institue une enquête publique => le pouvoir réglementaire a excédé sa compétence et a empiété sur celle du législateur

II. La valeur constitutionnelle et l'invocabilité de la Charte de l'environnement

A. La valeur constitutionnelle

- CC, 19 juin 2008, *Loi relative aux OGM* : Valeur constitutionnelle des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement
- Consécration constitutionnelle de principes garantis par la loi (article L. 110-1 code de l'environnement) : principe de précaution ; principe de prévention
- Insertion dans le bloc de constitutionnalité : DDHC (droits 1ère génération) ; Préambule Constitution 1946 (droits 2ème génération) ; Charte de l'environnement (droits 3ème génération)

B. L'invocabilité de l'article 7 devant le juge

- Invocabilité devant le juge administratif :
  - Invocabilité de la Charte à l'encontre d'un règlement
  - Sauf si théorie de la loi-écran : ce sont les dispositions législatives mettant en œuvre les dispositions de la Charte qui doivent être invoquées
- Invocabilité devant le juge constitutionnel :
  - Contrôle a priori de la loi – par ex, CC, 20 décembre 2019, *Loi d'orientation des mobilités* : le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé énoncé à l'article 1er de la Charte est une exigence constitutionnelle

- QPC – par ex, CC, 31 janvier 2020, *Union des industries de la protection des plantes* : la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle

4. Commentaire : Affaire du siècle : cinq questions pour comprendre la décision du tribunal administratif

Présentation du sujet :

- « Affaire du siècle » : recours porté par plusieurs associations de défense de l'environnement devant le tribunal administratif de Paris
- Recours indemnitaire, qui vise à reconnaître la carence fautive de l'Etat dans l'absence de diminution des émissions de gaz à effet de serre et à indemniser les préjudices écologique et moral
- Solution : satisfaction partielle. Le tribunal reconnaît la faute de l'Etat, mais rejette la réparation du préjudice écologique à hauteur d'un euro. Il condamne néanmoins l'administration à réparer le préjudice moral des associations à hauteur d'un euro. Il ordonne un supplément d'instruction pour statuer sur l'évaluation et les modalités de réparation de ce préjudice
- Portée de l'arrêt : première décision rendue par une juridiction administrative qui condamne l'Etat pour inaction climatique et à réparer un préjudice écologique
- Jugement du 14 octobre 2021 : le tribunal ordonne à l'Etat, en tant que réparation du préjudice écologique, de prendre toutes les mesures sectorielles utiles de nature à réparer le préjudice à hauteur de la part non compensée d'émissions de gaz à effet de serre au titre du premier budget carbone

I. La carence fautive de l'Etat en matière de lutte contre le dérèglement climatique

A. Les obligations pour l'Etat

- Charte de l'environnement : Article 3 : principe de prévention ; Article 4 : réparation des préjudices causés à l'environnement ; Article 5 : principe de précaution ; Article 7 : principe de participation du public
- Valeur constitutionnelle des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement : CC, 19 juin 2008, *Loi relative aux OGM* ; CE, 3 octobre 2008, *Commune d'Annecy*
- Article 1246 et s. code civil : préjudice écologique
- Article L. 110-1-II code de l'environnement : 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; 4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ; 5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ; 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une

amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment

B. La carence de l'Etat dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre

- Objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment issu de l'Accord de Paris
- Fondement juridique en droit interne : notamment article L. 100-4 code de l'énergie : « De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050 »
- L'inaction de l'Etat dans la lutte contre le dérèglement climatique a déjà été reconnue par le Conseil d'Etat (décision commune de Grande-Synthe)
- Reconnaissance d'une faute de l'Etat alors que l'obligation impose une réduction en 2030

II. La délicate réparation du préjudice écologique

A. Les spécificités du préjudice écologique

- Définition préjudice écologique : article 1247 du code civil : « atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement »
- Préjudice subi par l'environnement dans son ensemble
- Nécessité d'une faute : responsabilité extracontractuelle
- Requérant : article 1248 : « toute personne ayant qualité et intérêt à agir » => personne publique, privée, morale…

B. La réparation du préjudice écologique

- Réparation : article 1249 du code civil : « La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat » => Raisonnement en deux temps du juge : vérifier si la réparation en nature est possible. Si non, réparation financière
- Débiteur et lien de causalité : difficile à appréhender. L'Etat n'est pas le responsable direct des émissions de gaz à effet de serre, mais le responsable de l'absence de mise en œuvre de politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre
- Ici : juge rejette la réparation pécuniaire demandée (un euro symbolique) et ordonne un supplément d'instruction pour vérifier comment réparer en nature

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2025

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 1 – La représentation des manifestants

1. Dissertation
2. Argumentation
3. Commentaire de texte
4. Commentaire d'arrêt

1. Sujet – Dissertation

La répression des manifestants : entre exigences de sécurité et garanties des droits.

---

2. Sujet – Argumentation

Argumentez en faveur d'une meilleure reconnaissance de la liberté de manifester.

---

3. Sujet – Commentaire de texte

« *Ce n'est pas la rue qui gouverne, c'est la loi votée par le Parlement* »
Jean-Pierre Raffarin
2003

---

4. Sujet – Commentaire d'arrêt

Conseil d'État, ord. réf., 5 janvier 2007, Ministre de l'Intérieur c/ Association "Solidarité des Français"

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu le recours enregistré le 3 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'État :

1) d'annuler l'ordonnance du 2 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de police en date du 28 décembre 2006 interdisant les rassemblements envisagés par l'association « Solidarité des Français » les 2, 3, 4, 5 et 6 janvier 2007 ;

2) de rejeter les conclusions de l'association « Solidarité des Français » (SDF) tendant à la suspension de cet arrêté ;

le ministre soutient que le caractère discriminatoire de la distribution sur la voie publique des « soupes gauloises » est établie ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a statué au delà de sa saisine en suspendant la totalité de l'arrêté litigieux quand l'association « Solidarité des Français » ne demandait la suspension que de l'article 1er relatif à la distribution du 2 janvier 2007 ; que l'ordonnance attaquée a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il était demandé l'application de l'article L. 521-2 quand la demande se prévalait de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'elle est entachée de contradiction de motifs en reconnaissant que la manifestation est constitutive d'une forme de dégradation de la dignité humaine pour en déduire que son interdiction ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale ; que le juge des référés a commis une erreur de droit en se référant à des circonstances factuelles antérieures pour évaluer le risque d'un trouble futur ;

Vu enregistré le 5 janvier 2007 le mémoire présenté par l'association « Solidarité des français » qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'État la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; l'association fait valoir que la requête est devenue sans objet ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas statué au delà des conclusions qui lui étaient soumises ; que l'association s'est placée exclusivement sur le terrain du référé liberté de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative ; que l'interdiction est attentatoire à la liberté de rassemblement, d'expression et de réunion ; qu'il y a urgence à suspendre la décision préfectorale ; qu'en l'absence de troubles à l'ordre public la seule possibilité pour le préfet d'interdire la distribution de soupe était d'établir que l'objet de l'association était contraire aux lois et règlements ; que le préfet de police a commis un détournement de pouvoir alors que l'association n'a jamais refusé de servir ses soupes à qui que ce soit ; qu'aucune organisation juive ou musulmane n'a protesté contre les conditions de ces distributions de soupe ; qu'aucune discrimination d'aucune sorte n'est établie ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a pu, sans erreur de droit, tenir compte du passé pour apprécier la notion de troubles à l'ordre public ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE et d'autre part, l'association « Solidarité des français » ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 5 janvier 2007 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

-Me Boutet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat du MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ;

-Me Le Griel, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de l'association « Solidarité des français » ;

Considérant que l'arrêté préfectoral sur lequel le juge des référés du tribunal administratif de Paris était appelé à se prononcer porte non seulement sur le rassemblement du 2 janvier 2007 mais aussi sur ceux des 3, 4, 5 et 6 janvier 2007 ; que dès lors, d'une part il y avait lieu pour le juge des référés de se prononcer et d'autre part l'appel du MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... » ; que selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le Conseil d'État ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait, sans entacher son ordonnance de

contradiction de motifs, d'une part retenir le caractère discriminatoire de l'organisation sur la voie publique, par l'association « Solidarité des français » des distributions d'aliments contenant du porc et d'autre part estimer que l'arrêté portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 2 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'arrêté du préfet de police en date du 28 décembre 2006 au motif d'absence de risque de troubles plus grand que dans les précédentes occasions de telles opérations ;

Considérant qu'il y a lieu pour le juge des référés du Conseil d'État, statuant par la voie de l'évocation, de se prononcer sur le bien-fondé des conclusions de la demande ;

Considérant que l'arrêté contesté prend en considération les risques de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et de causer ainsi des troubles à l'ordre public ;

Considérant que le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l'ordre public ;

Considérant qu'en interdisant par l'arrêté contesté plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d'aliments contenant du porc, le préfet de police n'a pas, eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site internet de l'association, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association « Solidarité des français » n'est pas fondée à demander la suspension de l'arrêté contesté du préfet de police ;

Sur les conclusions de l'association « Solidarité des français » tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme réclamée par l'association « Solidarité des français » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2025

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 1 – La représentation des manifestants

1. Dissertation
2. Argumentation
3. Commentaire de texte
4. Commentaire d'arrêt

1. Sujet – Dissertation

La répression des manifestants : entre exigences de sécurité et garanties des droits.

---

2. Sujet – Argumentation

Argumentez en faveur d'une meilleure reconnaissance de la liberté de manifester.

---

3. Sujet – Commentaire de texte

« *Ce n'est pas la rue qui gouverne, c'est la loi votée par le Parlement* »
Jean-Pierre Raffarin
2003

---

4. Sujet – Commentaire d'arrêt

Conseil d'État, ord. réf., 5 janvier 2007, Ministre de l'Intérieur c/ Association "Solidarité des Français"

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu le recours enregistré le 3 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'État :

1) d'annuler l'ordonnance du 2 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de police en date du 28 décembre 2006 interdisant les rassemblements envisagés par l'association « Solidarité des Français » les 2, 3, 4, 5 et 6 janvier 2007 ;

2) de rejeter les conclusions de l'association « Solidarité des Français » (SDF) tendant à la suspension de cet arrêté ;

le ministre soutient que le caractère discriminatoire de la distribution sur la voie publique des « soupes gauloises » est établie ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a statué au delà de sa saisine en suspendant la totalité de l'arrêté litigieux quand l'association « Solidarité des Français » ne demandait la suspension que de l'article 1er relatif à la distribution du 2 janvier 2007 ; que l'ordonnance attaquée a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il était demandé l'application de l'article L. 521-2 quand la demande se prévalait de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'elle est entachée de contradiction de motifs en reconnaissant que la manifestation est constitutive d'une forme de dégradation de la dignité humaine pour en déduire que son interdiction ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale ; que le juge des référés a commis une erreur de droit en se référant à des circonstances factuelles antérieures pour évaluer le risque d'un trouble futur ;

Vu enregistré le 5 janvier 2007 le mémoire présenté par l'association « Solidarité des français » qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'État la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; l'association fait valoir que la requête est devenue sans objet ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas statué au delà des conclusions qui lui étaient soumises ; que l'association s'est placée exclusivement sur le terrain du référé liberté de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative ; que l'interdiction est attentatoire à la liberté de rassemblement, d'expression et de réunion ; qu'il y a urgence à suspendre la décision préfectorale ; qu'en l'absence de troubles à l'ordre public la seule possibilité pour le préfet d'interdire la distribution de soupe était d'établir que l'objet de l'association était contraire aux lois et règlements ; que le préfet de police a commis un détournement de pouvoir alors que l'association n'a jamais refusé de servir ses soupes à qui que ce soit ; qu'aucune organisation juive ou musulmane n'a protesté contre les conditions de ces distributions de soupe ; qu'aucune discrimination d'aucune sorte n'est établie ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a pu, sans erreur de droit, tenir compte du passé pour apprécier la notion de troubles à l'ordre public ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE et d'autre part, l'association « Solidarité des français » ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 5 janvier 2007 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

-Me Boutet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat du MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ;

-Me Le Griel, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de l'association « Solidarité des français » ;

Considérant que l'arrêté préfectoral sur lequel le juge des référés du tribunal administratif de Paris était appelé à se prononcer porte non seulement sur le rassemblement du 2 janvier 2007 mais aussi sur ceux des 3, 4, 5 et 6 janvier 2007 ; que dès lors, d'une part il y avait lieu pour le juge des référés de se prononcer et d'autre part l'appel du MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... » ; que selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le Conseil d'État ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait, sans entacher son ordonnance de

contradiction de motifs, d'une part retenir le caractère discriminatoire de l'organisation sur la voie publique, par l'association « Solidarité des français » des distributions d'aliments contenant du porc et d'autre part estimer que l'arrêté portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 2 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'arrêté du préfet de police en date du 28 décembre 2006 au motif d'absence de risque de troubles plus grand que dans les précédentes occasions de telles opérations ;

Considérant qu'il y a lieu pour le juge des référés du Conseil d'État, statuant par la voie de l'évocation, de se prononcer sur le bien-fondé des conclusions de la demande ;

Considérant que l'arrêté contesté prend en considération les risques de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et de causer ainsi des troubles à l'ordre public ;

Considérant que le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l'ordre public ;

Considérant qu'en interdisant par l'arrêté contesté plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d'aliments contenant du porc, le préfet de police n'a pas, eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site internet de l'association, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association « Solidarité des français » n'est pas fondée à demander la suspension de l'arrêté contesté du préfet de police ;

Sur les conclusions de l'association « Solidarité des français » tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme réclamée par l'association « Solidarité des français » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

1. Dissertation : « La répression des manifestants : entre exigences de sécurité et garanties des droits »

La liberté de manifester est un droit fondamental, reconnu en droit français par la Constitution à travers la liberté d'expression et de réunion telles qu'exprimées dans *La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* de 1789 (art. 11) et au regard de l'argumentation du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995.

Il en va de même dans le droit de la *Convention européenne des droits de l'homme* (CEDH) qui garantit la liberté de réunion pacifique. La CEDH condamne régulièrement les États qui restreignent abusivement ce droit (ex. CEDH, 1991, *Ezelin c. France*). En droit international, l'article 21 du *Pacte international relatif aux droits civils et politiques* (PIDCP) reconnaît également le droit de réunion pacifique, que seules des restrictions nécessaires et proportionnées peuvent limiter.

Cela oblige la France, signataire de ces traités, à accorder une protection renforcée aux manifestations. Le droit français ne peut restreindre la liberté de manifester qu'en respectant des exigences strictes de proportionnalité.

L'exercice de cette liberté se heurte régulièrement à des impératifs d'ordre public : les manifestations peuvent être source de troubles, de violences ou de dégradations. La liberté de manifester bénéficie d'une protection constitutionnelle et internationale, mais son effectivité exige que les restrictions soient strictement encadrées par le principe de proportionnalité, avec une présomption claire en faveur de la liberté. Tant le droit, tant privé que public, encadre les manifestations, pour sanctionner voire dissuader certains comportements individuels ; que pour autoriser ou interdire une manifestation.

La liberté de manifester se confronte ainsi à la limite du respect de l'ordre public et implique une conciliation entre garantie des droits fondamentaux et impératifs de sécurité intérieure. *Comment concilier la répression des manifestants par le droit pénal et la procédure pénale avec les garanties des droits fondamentaux ?*

Ceci invite à analyser, d'une part, le rôle de la répression pénale et procédurale comme instrument de protection de l'ordre public (I), et d'autre part, les limites et garanties qui doivent encadrer cette répression dans un État de droit (II).

I. La répression pénale et procédurale comme instrument de protection de l'ordre public

A. La détermination par le droit pénal de comportements illicites en manifestation

Par le régime juridique pénal entourant la liberté de manifester, l'objectif est ainsi de dissuader et sanctionner les comportements susceptibles de troubler gravement l'ordre public.

Le droit pénal incrimine principalement :

- la violence (art 222-1 et s.)
- la destruction de biens (art 322-1)
- la participation à un attroupement interdit (art. 431-3 et s.)
- le port ou usage d'armes (art 222-14 et s.)
- le non-respect des obligations légales des participants (art 431-9)
- le port de masques ou dissimulation du visage dans une manifestation interdite (art 431-9-1 depuis la *Loi sur la sécurité intérieure*)

B. L'efficacité de la procédure pénale comme outil de réponse rapide

Pour prévenir ou réprimer les troubles à l'ordre public que la manifestation pourrait causer, la procédure pénale est un instrument de réactivité, imposant des réponses judiciaires rapides. Au regard des incriminations pré-citées, il est possible de recourir tant à la garde à vue qu'aux comparutions immédiates, bien que cela puisse poser des problèmes de proportionnalité et de respect des droits de la défense.

- **Gardes à vue**. Le fondement des interpellations est souvent basé sur l'article 431-3 du Code pénal (participation à un attroupement après sommations), ou sur des infractions connexes (violences, dégradations, rébellion). Principe de proportionnalité : le recours à la GAV doit être justifié par les nécessités de l'enquête (prévenir des infractions, garantir la présentation devant la justice).

- **Recours aux comparutions immédiates**. Les articles 395 et suivants du Code de procédure pénale en sont le fondement. Concernant le cas particulier des manifestants, les infractions souvent retenues sont la participation à un attroupement après sommations, violences contre agents, dégradations, port ou transport d'armes par destination en manifestation. Lorsqu'il s'agit de manifestants interpellés lors de mouvements sociaux, le régime juridique reste le même que pour tout justiciable, mais il soulève des enjeux particuliers (libertés publiques, droit de manifester, pression politique). En pratique, cette procédure est souvent utilisée pour les interpellations massives lors de manifestations, afin d'apporter une réponse pénale rapide et visible.

(Transition) Il est donc nécessaire de saisir dans quelle mesure la liberté de manifester est une liberté fondamentale garantie afin d'empêcher les abus répressifs.

II. Les garanties des droits fondamentaux face au risque d'abus répressif

A. Le contrôle constitutionnel et européen

- Tant le CC que la CEDH rappellent que toute restriction doit être nécessaire, proportionnée et justifiée par la protection de l'ordre public. La protection de la liberté de manifester est une **obligation positive de l'État** : la CEDH impose aux États non seulement de ne pas entraver abusivement les manifestations, mais aussi de protéger les manifestants contre les violences de tiers (CEDH, 1988, *Plattform Ärzte für das Leben c. Autriche*).

- Le CE joue un rôle majeur. Il peut intervenir en **référé-liberté** (article L.521-2 du Code de justice administrative) pour contrôler la légalité des décisions d'interdiction de manifestations prises par les préfets ou le ministre de l'Intérieur.

- Exemple important **: CE, 10 juin 2021, n°444849 et autres**. Plusieurs syndicats et associations (dont la LDH, SNJ, CGT, SAF, Solidaires…) demandaient l'annulation du **Schéma national du maintien de l'ordre 16 septembre 2020** qui autorisait notamment l'encerclement des manifestants par les forces de l'ordre. Il censure plusieurs points du SNMO : annulation de la condition imposée aux journalistes de n'utiliser des équipements de protection que si leur identification est confirmée et leur comportement irréprochable ; annulation de la mention imposant une accréditation auprès des autorités pour accéder au canal d'échanges avec la police ; annulation de la règle obligeant journalistes et observateurs à quitter un attroupement après sommations, alors qu'ils peuvent rester pour témoigner ; **annulation de la doctrine d'« encerclement » (nasse), jugée trop imprécise et portant une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester.**

- La CCass elle aussi protège la liberté de manifester. Dans la décision **Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 23-80.226**, ***Extinction Rebellion***, la Cour a confirmé leur condamnation pour intrusion, mais a aussi rappelé que les juges doivent concilier la répression des infractions avec le respect de la liberté de manifester. Il y a une obligation de mise en balance.

B. La procédure pénale comme garantie des libertés individuelles

De ce point de vue, la procédure pénale dans le cadre de la répression des manifestants présente encore des points d'ombre dénoncés par les avocats et les ONG.

- **Concernant la GAV**. L'utiliser de manière préventive contre des manifestants pacifiques pose un problème de légalité et de proportionnalité. Des associations et certains magistrats dénoncent l'usage

de la GAV comme outil de gestion de l'ordre public, parfois sans véritable perspective de poursuite (nombreux manifestants sont relâchés sans suite).

- **Concernant la comparution immédiate**. Il y a des risques d'atteinte aux droits de la défense : préparation de la défense difficile en quelques heures, alors que les poursuites peuvent avoir de lourdes conséquences (prison ferme, casier judiciaire) ; les avocats dénoncent souvent une justice « expéditive » ; non-respect de l'art 6 CEDH. C'est une procédure légale mais controversée, car elle conjugue rapidité répressive et risques d'atteinte aux droits de la défense, particulièrement dans le contexte sensible du droit de manifester.

La répression pénale et procédurale des manifestants illustre la tension entre liberté et sécurité inhérente aux démocraties contemporaines. Si le droit pénal et la procédure pénale permettent de prévenir et sanctionner les débordements liés aux manifestations, leur usage ne peut se faire au détriment des droits fondamentaux. L'équilibre recherché repose sur la proportionnalité des mesures répressives et sur le rôle de gardien des libertés joué par le juge, qu'il soit judiciaire, constitutionnel ou européen. Ainsi, la répression des manifestants ne peut être légitime que si elle demeure un instrument de protection de l'ordre public respectueux de l'État de droit.

---

2. Argumentez en faveur d'une meilleure reconnaissance de la liberté de manifester

Intro = intro de la dissertation

I. Un droit fondamental démocratique

A. Une modalité de la liberté d'expression

- La liberté de manifester est l'un des piliers de la démocratie. Elle découle directement de la liberté d'expression et de réunion pacifique, garanties par de nombreux textes (Déclaration universelle des droits de l'homme, Convention européenne des droits de l'homme, Constitution française). Restreindre ce droit revient à limiter la possibilité pour les citoyens de participer activement à la vie publique.

- Obligation positive de l'État : la CEDH impose aux États non seulement de ne pas entraver abusivement les manifestations, mais aussi de protéger les manifestants contre les violences de tiers (CEDH, 1988, *Plattform Ärzte für das Leben c. Autriche*).

- Article 11 CEDH proclame aussi le droit à la liberté de réunion pacifique. La Cour estime qu'elle est l'un des « fondements essentiels d'une société démocratique » (*Ezelin c. France*, 1991). Dans *Oya Ataman c. Turquie* de 2006, elle précise même que les manifestations non autorisées bénéficient d'une protection si elles sont pacifiques.

B. Un moyen de contre-pouvoir

- Les manifestations permettent de mettre en lumière des revendications que les institutions politiques ou les médias dominants peuvent négliger. C'est un outil de contre-pouvoir essentiel qui équilibre le rapport entre gouvernants et gouvernés et évite que la décision publique ne soit monopolisée par une élite.
-
- La liberté de manifester concoure à l'effectivité du pluralisme politique, principe lui-aussi à valeur constitutionnelle. Dans une décision de 1994, le Conseil constitutionnel consacre un « droit d'expression collective des idées et des opinions » qui s'inscrit dans la liberté de manifester (CC, déc. n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, *Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité*, cons. 16.)

- Les manifestations permettent l'expression de courants minoritaires ou non représentés au Parlement. Elles participent ainsi à la réalisation du pluralisme et à la correction des déséquilibres du système représentatif.

- La jurisprudence européenne reconnaît explicitement la fonction démocratique et contestataire de la manifestation comme un outil de participation citoyenne et de contrôle des pouvoirs publics

- Une meilleure reconnaissance juridique de la liberté de manifester devrait donc renforcer l'obligation pour l'État d'assurer la sécurité des participants, au lieu de privilégier la logique d'interdiction préventive.

II. Un moyen d'évolution des politiques sociales et de maintien de la paix sociale

A. Un espace de solidarité et de visibilité

- Les manifestations rassemblent des individus autour d'une cause commune, renforçant le sentiment d'appartenance et la solidarité sociale. Elles offrent aussi une visibilité médiatique et publique à des problématiques souvent marginalisées (droits sociaux, discriminations, environnement…).

- L'histoire montre que de nombreux progrès sociaux (droit de vote, égalité femmes-hommes, droits syndicaux, lutte contre les discriminations) ont été obtenus grâce aux mobilisations citoyennes. Restreindre la liberté de manifester, c'est ralentir le progrès social et figer le débat public.

B. Un moyen pacifique pour prévenir les tensions

- Lorsque la liberté de manifester est trop encadrée ou restreinte, l'expression des colères et des revendications peut se déplacer vers des formes plus radicales, voire violentes. Reconnaître pleinement ce droit, c'est aussi favoriser des expressions pacifiques et organisées du mécontentement.

- La liberté est le principe, la restriction l'exception : c'est un principe constant du droit français et européen. Le droit de manifester devrait donc être présumé légitime et autorisé, les autorités devant démontrer concrètement en quoi une restriction est nécessaire (CE, ord. 5 janv. 2007*, Ministre de l'Intérieur c/ Association solidarité des Français*)

---

3. Commentaire de texte.

« *Ce n'est pas la rue qui gouverne, c'est la loi votée par le Parlement* »
Jean-Pierre Raffarin
2003

En 2003, le gouvernement Raffarin engage une réforme importante des retraites (alignement de la durée de cotisation des fonctionnaires sur celle du secteur privé). Cette réforme provoque de très fortes mobilisations syndicales et manifestations, notamment en mai-juin 2003, avec des millions de personnes dans les rues. Face à cette pression sociale, Raffarin défend la légitimité des institutions représentatives (Parlement et Gouvernement) face à la contestation populaire et prononce cette phrase restée célèbre et souvent reprise dans le champ journalistique.

Ce bon mot médiatique soulève au final une question fondamentale : celle de la légitimité politique. En effet, *si une grande partie de la population conteste une loi, peut-on encore parler de démocratie pleinement représentative ? Quelle est la place de la manifestation dans la représentativité démocratique ?*

[Annonce]

I. La réaffirmation du principe représentatif classique

- Cette phrase illustre une conception classique de la démocratie représentative : la souveraineté est avant tout nationale, elle s'exprime avant par les élections et le Parlement et non par les manifestations ou d'autres procédés politiques.

- Raffarin insiste sur la primauté des institutions : la loi adoptée par le Parlement, représentant du peuple souverain, a une valeur supérieure aux revendications exprimées dans la rue.

- Il sous-entend alors que seules les élections sont le moyen d'expression démocratique des citoyens. Il ignore le principe de l'État de droit en France, construit sur un équilibre entre souverainetés nationale et populaire, encadré par le respect des libertés fondamentales dont la liberté de manifester mais aussi le droit de résistance à l'oppression.

II. Le mépris de l'importance de la manifestation pour la démocratie

- En France, la « rue » a souvent joué un rôle historique majeur (Révolution française, Front populaire, Mai 68, etc.). Dire qu'elle « ne gouverne pas » ignore l'histoire des luttes sociales et politiques qui ont permis l'inscription dans le droit de la majeure partie des DLF.

- La liberté de manifester est reconnue comme fondamentale et le Premier Ministre, au nom du principe de l'État de droit doit concourir à leur protection. Les lois elles-mêmes sont soumises au respect des DLF.

4. Commentaire d'arrêt : Conseil d'État, ord. réf., 5 janvier 2007, Ministre de l'Intérieur c/ Association "Solidarité des Français"

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours enregistré le 3 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 2 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de police en date du 28 décembre 2006 interdisant les rassemblements envisagés par l'association « Solidarité des français » les 2, 3, 4, 5 et 6 janvier 2007 ;

2) de rejeter les conclusions de l'association « Solidarité des français » (SDF) tendant à la suspension de cet arrêté ;

le ministre soutient que le caractère discriminatoire de la distribution sur la voie publique des « soupes gauloises » est établie ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a statué au delà de sa saisine en suspendant la totalité de l'arrêté litigieux quand l'association « Solidarité des français » ne demandait la suspension que de l'article 1er relatif à la distribution du 2 janvier 2007 ; que l'ordonnance attaquée a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il était demandé l'application de l'article L. 521-2 quand la demande se prévalait de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'elle est entachée de contradiction de motifs en reconnaissant que la manifestation est constitutive d'une forme de dégradation de la dignité humaine pour en déduire que son interdiction ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale ; que le juge des référés a commis une erreur de droit en se référant à des circonstances factuelles antérieures pour évaluer le risque d'un trouble futur ;

Vu enregistré le 5 janvier 2007 le mémoire présenté par l'association « Solidarité des français » qui conclut au

rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; l'association fait valoir que la requête est devenue sans objet ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas statué au delà des conclusions qui lui étaient soumises ; que l'association s'est placée exclusivement sur le terrain du référé liberté de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative ; que l'interdiction est attentatoire à la liberté de rassemblement, d'expression et de réunion ; qu'il y a urgence à suspendre la décision préfectorale ; qu'en l'absence de troubles à l'ordre public la seule possibilité pour le préfet d'interdire la distribution de soupe était d'établir que l'objet de l'association était contraire aux lois et règlements ; que le préfet de police a commis un détournement de pouvoir alors que l'association n'a jamais refusé de servir ses soupes à qui que ce soit ; qu'aucune organisation juive ou musulmane n'a protesté contre les conditions de ces distributions de soupe ; qu'aucune discrimination d'aucune sorte n'est établie ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a pu, sans erreur de droit, tenir compte du passé pour apprécier la notion de troubles à l'ordre public ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et d'autre part, l'association « Solidarité des français » ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 5 janvier 2007 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

-Me Boutet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

-Me Le Griel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association « Solidarité des français » ;

Considérant que l'arrêté préfectoral sur lequel le juge des référés du tribunal administratif de Paris était appelé à se prononcer porte non seulement sur le rassemblement du 2 janvier 2007 mais aussi sur ceux des 3, 4, 5 et 6 janvier 2007 ; que dès lors, d'une part il y avait lieu pour le juge des référés de se prononcer et d'autre part l'appel du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... » ; que selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait, sans entacher son ordonnance de contradiction de motifs, d'une part retenir le caractère discriminatoire de l'organisation sur la voie publique, par l'association « Solidarité des français » des distributions d'aliments contenant du porc et d'autre part estimer que l'arrêté portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 2 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'arrêté du préfet de police en date du 28 décembre 2006 au motif d'absence de risque de troubles plus grand que dans les précédentes occasions de telles opérations ;

Considérant qu'il y a lieu pour le juge des référés du Conseil d'État, statuant par la voie de l'évocation, de se prononcer sur le bien-fondé des conclusions de la demande ;

Considérant que l'arrêté contesté prend en considération les risques de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et de causer ainsi des troubles à l'ordre public ;

Considérant que le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l'ordre public ;

Considérant qu'en interdisant par l'arrêté contesté plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d'aliments contenant du porc, le préfet de police n'a pas, eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site internet de l'association, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association « Solidarité des français » n'est pas fondée à demander la suspension de l'arrêté contesté du préfet de police ;

Sur les conclusions de l'association « Solidarité des français » tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme réclamée par l'association « Solidarité des français » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

***

Faits de l'espèce

L'association « Solidarité des Français » organise des distributions de soupes au porc, lesdites « soupes gauloises » à des personnes sans-abri à Paris. Le préfet de police de Paris, par arrêté du 28 décembre 2006, interdit les rassemblements liés à ces distributions les 2, 3, 4, 5 et 6 janvier 2007 au motif qu'il existe un risque de trouble à l'ordre public, car ces distributions sont perçues comme discriminatoires (exclusion implicite des juifs et musulmans) et portent ainsi atteinte à la dignité humaine.

Procédure

L'association saisit le juge des référés du TA de Paris selon l'art. L. 521-2 CJA, (référé-liberté). Par l'ordonnance du 2 janvier 2007, le TA suspend l'arrêté préfectoral car le juge estime qu'il y a une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Le Ministre de l'Intérieur fait appel devant le Conseil d'État.

Prétentions des parties

Le Ministre de l'Intérieur soutient :

- Le caractère discriminatoire des soupes est établi.
- que le juge de 1ère instance a commis une contradiction de motifs et une erreur de droit.
- qu'il fallait prévenir les risques de trouble à l'ordre public.

L'Association SDF soutient :

- que son activité est protégée par la liberté de réunion et d'expression.
- l'absence tout trouble à l'ordre public.
- l'interdiction préfectorale constitue un détournement de pouvoir.

Problème de droit

L'autorité de police peut-elle interdire une manifestation au motif qu'elle comporte un caractère discriminatoire et porte atteinte à la dignité humaine, même en l'absence de troubles effectifs constatés ?

Le Conseil d'État annule l'ordonnance du TA car il considère que :

- L'arrêté préfectoral prend légitimement en compte les risques de réactions liés à une manifestation portant atteinte à la dignité des personnes et susceptible de causer un trouble à l'ordre public .

- La liberté de manifester ne s'oppose pas à ce que le préfet interdise une activité lorsque c'est la seule mesure permettant de prévenir un tel trouble.

- En l'espèce, l'interdiction des rassemblements ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester.

Portée

- Confirmation de la jurisprudence classique : le préfet peut interdire une manifestation si c'est la seule manière de prévenir un trouble à l'ordre public (CE, 1933*, Benjamin*) et ceci de manière proportionnée.

- Reconnaissance de la dignité de la personne humaine comme composante de l'ordre public, même sans troubles matériels immédiats (lignée CE, 1995, *Commune de Morsang-sur-Orge*).

- Le Conseil d'État réaffirme l'équilibre entre liberté de manifester et ordre public : la liberté n'est pas absolue, mais sa restriction doit être strictement justifiée.

La liberté de manifestation est une liberté fondamentale, protégée par l'article 11 de la CEDH et par la Constitution française (via la DDHC de 1789). Cependant, elle peut être limitée par les autorités de police pour des motifs d'ordre public, conformément à la jurisprudence classique (CE, Benjamin, 1933). Dans cette affaire, l'association « Solidarité des Français » organisait des distributions de soupe contenant du porc, présentées comme une « soupe identitaire », excluant implicitement certains groupes religieux. Le préfet de police de Paris interdit ces rassemblements au nom de la prévention des troubles à l'ordre public. Le juge des référés du TA de Paris suspend l'arrêté. Saisi en appel, le Conseil d'État annule cette décision.

On peut ainsi se demander dans quelle mesure l'autorité de police peut-elle limiter la liberté de manifester lorsqu'une manifestation présente un caractère discriminatoire portant atteinte à la dignité de la personne humaine ?

I. L'équilibre entre liberté fondamentale et maintien de l'ordre public

A. La liberté de manifester, une liberté fondamentale protégée

- Le juge des référés doit sauvegarder les libertés fondamentales (art. L. 521-2 CJA) dont la liberté de manifestation fait partie.

- La liberté de manifestation, reconnue comme dérivant de la liberté d'expression et de réunion, bénéficie donc d'une protection particulière.

- *V. le régime juridique générale dans la dissertation*

B. Le contrôle de proportionnalité et ses limites

- Le Conseil d'État opère un contrôle de proportionnalité : il vérifie que l'interdiction était la seule manière de prévenir le trouble à l'ordre public. Toutefois, le contrôle est parfois restreint, car il consacre une large marge d'appréciation au préfet, au risque d'un usage politique du pouvoir de police.

- Cette décision illustre ainsi les tensions entre l'effectivité de la liberté de manifester et les impératifs de sécurité publique, accentuées dans des contextes sensibles (identité, discrimination).

- La liberté de manifester si elle doit être protégée et garantie en tant qu'obligation positive de l'État se confronte au respect des autres DLF, dont certain, telle la dignité humaine, font partie de l'ordre public.

II. La consécration du pouvoir de police au nom de la dignité humaine

A. La dignité humaine comme composante de l'ordre public

- Le Conseil d'État reprend l'approche inaugurée par CE, Morsang-sur-Orge en 1995 : la dignité de la personne humaine fait partie intégrante de l'ordre public, indépendamment de troubles matériels constatés. C'est au nom du respect de la dignité que d'autres libertés fondamentales peuvent être restreintes.

- En l'espèce, la distribution de soupes contenant du porc, présentée comme une « soupe identitaire », pouvait être perçue comme discriminatoire envers certaines communautés et donc attentatoire à la dignité. Ce message ayant clairement été communiqué par les organisateurs de cette manifestation l'atteinte à la dignité de certains groupes est volontaire et risque ainsi d'entrainer des troubles à l'OP dans son sens général.

B. La possibilité d'interdiction préventive

- Le Conseil d'État rappelle que le respect de la liberté de manifester n'empêche pas l'autorité de police d'interdire une manifestation si c'est la seule mesure propre à prévenir un trouble. Il conserve la faculté d'interdire préventivement une manifestation.

- L'arrêté préfectoral apparaît proportionné au regard du but poursuivi : éviter des tensions et atteintes à l'ordre public liées à une démarche perçue comme stigmatisante.

Par cette décision, le Conseil d'État confirme la possibilité d'interdire une manifestation lorsque son objet ou ses modalités portent atteinte à la dignité de la personne humaine et risquent de troubler l'ordre public. L'arrêt illustre l'articulation délicate entre la liberté de manifester, liberté fondamentale, et la préservation de l'ordre public, au sein duquel la dignité, autre liberté fondamentale est intégrée. Il s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence Benjamin et Morsang-sur-Orge, mais révèle aussi une tendance à accorder une large latitude aux autorités de police, ce qui pose la question du risque de restriction excessive des libertés publiques sous couvert de maintien de l'ordre.

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2025

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 2 – La diversité culturelle

1. Dissertation
2. Argumentation
3. Commentaire de texte
4. Commentaire d'arrêt

1. <u>Dissertation</u> : La protection de la diversité culturelle.

---

2. <u>Argumentation</u> : Pensez-vous que [ou, *soutenez que*] le droit français devrait davantage reconnaître l'autonomie collective.

---

3. <u>Commentaire de texte</u> : « *Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune* ». Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

---

4. <u>Commentaire d'arrêt</u> : Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999.

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 mai 1999, par le Président de la République, sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, de la question de savoir si la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, signée à Budapest le 7 mai 1999, doit être précédée, compte tenu de la déclaration interprétative faite par la France et des engagements qu'elle entend souscrire dans la partie III de cette convention, d'une révision de la Constitution ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 18, alinéa 2, 19 et 20 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LE CONTENU DE L'ENGAGEMENT INTERNATIONAL SOUMIS A L'EXAMEN DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET SUR L'ÉTENDUE DU CONTRÔLE EXERCÉ :

1. Considérant que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires soumise à l'examen du Conseil constitutionnel se compose, outre un préambule, d'une partie I, intitulée : « dispositions générales » ; d'une partie II relative aux « objectifs et principes » que chaque État contractant s'engage à appliquer ; d'une partie III comportant quatre-vingt-dix-huit mesures en faveur de l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique, classées par domaine d'application, au sein desquelles chaque État contractant est libre de faire un choix dans les limites précisées à l'article 2 (§ 2) de la Charte, les mesures ainsi retenues ne s'appliquant qu'aux langues indiquées dans son instrument de ratification ; d'une partie IV contenant des dispositions d'application ; d'une partie V fixant des dispositions finales ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 2 (§ 1) de la Charte, « chaque Partie s'engage à appliquer les dispositions de la partie II », comportant le seul article 7, « à l'ensemble des langues régionales ou minoritaires pratiquées sur son territoire, qui répondent aux définitions de l'article 1 » ; qu'il résulte de ces termes mêmes que la partie II a une portée normative propre et qu'elle s'applique non seulement aux langues qui seront indiquées par la France au titre des engagements de la partie III, mais à toutes les langues régionales ou minoritaires pratiquées en France au sens de la Charte ;

3. Considérant que l'article 2 (§ 2) précité de la Charte fait obligation à chaque État contractant de s'engager à appliquer un minimum de trente-cinq paragraphes ou alinéas choisis parmi les dispositions de la partie III, dont au moins trois choisis dans les articles 8 : « enseignement » et 12 : « activités et équipements culturels », et un dans chacun des articles 9 : « justice », 10 : « autorités administratives et services publics », 11 : « médias » et 13 : « vie économique et sociale » ; que, lors de la signature de la Charte, la France a indiqué une liste de trente-neuf alinéas ou paragraphes, sur les quatre-vingt-dix-huit que comporte la partie III de cette convention, qu'elle s'engage à appliquer et qui sera jointe à son instrument de ratification ; que onze d'entre eux concernent l'enseignement, neuf les médias, huit les activités et équipements culturels, cinq la vie économique et sociale, trois les autorités administratives et services publics, deux les échanges transfrontaliers et un la justice ; que le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel sur la partie III doit porter sur les seuls engagements ainsi retenus ;

4. Considérant, par ailleurs, que le Gouvernement français a accompagné sa signature d'une déclaration interprétative dans laquelle il précise le sens et la portée qu'il entend donner à la Charte ou à certaines de ses dispositions au regard de la Constitution ; qu'une telle déclaration unilatérale n'a d'autre force normative que de constituer un instrument en rapport avec le traité et concourant, en cas de litige, à son interprétation ; qu'il appartient donc au Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, de procéder au contrôle de la constitutionnalité des engagements souscrits par la France indépendamment de cette déclaration ;

- SUR LES NORMES DE RÉFÉRENCE APPLICABLES :

5. Considérant, d'une part, qu'ainsi que le proclame l'article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » ; que le principe d'unicité du peuple français, dont aucune section ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale, a également valeur constitutionnelle ;

6. Considérant que ces principes fondamentaux s'opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance ;

7. Considérant, d'autre part, que la liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi », doit être conciliée avec le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution selon lequel « La langue de la République est le français » ;

8. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage ; que l'article 2 de la Constitution n'interdit pas l'utilisation de traductions ; que son application ne doit pas conduire à méconnaître l'importance que revêt, en matière d'enseignement, de recherche et de communication audiovisuelle, la liberté d'expression et de communication ;

- SUR LA CONFORMITÉ DE LA CHARTE À LA CONSTITUTION :

9. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de son préambule, la Charte reconnaît à chaque personne « un droit imprescriptible » de « pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique » ; qu'aux termes de l'article 1 (a) de la partie I : « par l'expression » langues régionales ou minoritaires ", on entend les langues : i) pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l'État ; et ii) différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet État", exception faite des dialectes de la langue officielle et des langues des migrants ; que, par « territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée », il convient d'entendre, aux termes de l'article 1 (b), « l'aire géographique dans

laquelle cette langue est le mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant l'adoption des différentes mesures de protection et de promotion » prévues par la Charte ; qu'en vertu de l'article 7 (§ 1) : « les Parties fondent leur politique, leur législation et leur pratique sur les objectifs et principes » que cet article énumère ; qu'au nombre de ces objectifs et principes figurent notamment « le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue », ainsi que « la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée » ; que, de surcroît, en application de l'article 7 (§ 4), « les Parties s'engagent à prendre en considération les besoins et les vœux exprimés par les groupes pratiquant ces langues » en créant, si nécessaire, des « organes chargés de conseiller les autorités » sur ces questions ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, en ce qu'elle confère des droits spécifiques à des « groupes » de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l'intérieur de « territoires » dans lesquels ces langues sont pratiquées, porte atteinte aux principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français ;

11. Considérant que ces dispositions sont également contraires au premier alinéa de l'article 2 de la Constitution en ce qu'elles tendent à reconnaître un droit à pratiquer une langue autre que le français non seulement dans la « vie privée » mais également dans la « vie publique », à laquelle la Charte rattache la justice et les autorités administratives et services publics ;

12. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions précitées de la Charte sont contraires à la Constitution ;

13. Considérant que n'est contraire à la Constitution, eu égard à leur nature, aucun des autres engagements souscrits par la France, dont la plupart, au demeurant, se bornent à reconnaître des pratiques déjà mises en œuvre par la France en faveur des langues régionales ;

D É C I D E :

Article premier :
La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires comporte des clauses contraires à la Constitution.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 juin 1999, présidée par M Yves GUÉNA, et où siégeaient : MM Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
Le président,
Yves GUÉNA

Journal officiel du 18 juin 1999, page 8964
Recueil, p. 71
ECLI : FR : CC : 1999 : 99.412.DC

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2025

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 2 – La diversité culturelle

1. Dissertation
2. Argumentation
3. Commentaire de texte
4. Commentaire d'arrêt

La diversité culturelle

1. Dissertation : La protection de la diversité culturelle.

2. Argumentez : Le droit français devrait davantage reconnaître l'autonomie collective

3. Commentaire de texte : « *Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune* ». Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

4. Commentaire d'arrêt : Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999.

Dissertation : La protection de la diversité culturelle

La diversité culturelle, entendue comme la coexistence et la valorisation des différentes expressions culturelles, artistiques et linguistiques, est aujourd'hui perçue comme un patrimoine commun de l'humanité. Dans un contexte de mondialisation marquée par l'uniformisation des modes de vie et la domination des industries culturelles globalisées, la protection de la diversité culturelle est devenue un enjeu majeur, à la fois politique, économique et juridique.

La diversité culturelle est à la fois un enjeu identitaire et un enjeu démocratique : elle renvoie à la coexistence des traditions, langues et modes de vie des communautés humaines. Par ce terme, il s'agit d'affirmer la reconnaissance d'un droit à la diversité culturelle. Le droit international est volontariste sur ce point et se confronte à d'autres logiques juridiques, notamment celui du droit français. Là où les droits international et européen reconnaissent explicitement des droits collectifs des peuples et minorités, le droit français reste attaché à une logique universaliste et individualiste, privilégiant l'unité républicaine sur les revendications communautaires.

Ainsi, *comment le droit, dans ses différentes dimensions, protège-t-il la diversité culturelle, et en quoi le modèle français se distingue-t-il de la logique internationale ?*

Les droits international et européen consacrent la diversité culturelle comme un droit collectif des peuples et minorités (I), tandis que le droit français en offre une protection plus limitée, fondée sur l'individu et l'unité nationale (II).

I. La reconnaissance internationale et européenne de la diversité culturelle comme droit collectif pour la protection des minorités

A. La consécration par le droit international

- **Le Pacte international pour les droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU de 1966** reconnaît, en son article 15, le droit de participer à la vie culturelle. Il est analysé en tant que droit reconnu à des collectifs et non uniquement aux individus. La logique sous-jacente est ainsi de reconnaître et de protéger la spécificité des communautés face aux risques d'assimilation. D'autres textes internationaux suivent cette logique :

- **La Convention de l'UNESCO de 2005** : diversité des expressions culturelles comme patrimoine commun de l'humanité.

- **La Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones de 2007** : reconnaissance d'un droit collectif à préserver langues, traditions, institutions.

B. L'approche européenne de la protection des minorités (UE et CEDH)

- Déjà en 1995, **la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales** du Conseil de l'Europe pose l'obligation positive pour les États de préserver les langues et les cultures minoritaires.

- La CEDH protège les droits collectifs minoritaires. **La JP de la CEDH** s'appuie sur les articles 8, 9, 10, 11 et parfois 14 sur la non-discrimination.

- Elle protège la diversité linguistique et culturelle. Ex. CEDH, GC, 17 février 2004, *Gorzelik et autres c. Pologne*: refus des autorités polonaises d'enregistrer une association d'une minorité silésienne. La CEDH rappelle que la liberté d'association (art. 11) protège aussi les minorités souhaitant préserver leur identité culturelle.

- Elle protège aussi la diversité religieuse des minorités. Ex. CEDH, 26 octobre 2000, *Hasan et Chaush c. Bulgarie* : ingérence de l'État dans la désignation du chef religieux musulman. La Cour affirme que l'autonomie des communautés religieuses est protégée par l'art. 9 (liberté de religion).

- La protection se situe aussi au niveau associatif et politique. CEDH, 30 janvier 1998, *Parti communiste unifié de Turquie c. Turquie* : Dissolution d'un parti politique minoritaire. La CEDH sanctionne : les partis politiques représentent une expression essentielle du pluralisme démocratique, y compris pour les minorités.

- Logique reprise dans la **Charte des droits fondamentaux de l'UE de 2000** en son art. 22 : respect de la diversité culturelle, religieuse et linguistique.

II. La protection française de la diversité culturelle en opposition avec le droit européen et international

A. Un régime juridique universaliste et individualiste

- Si la logique internationale et européenne est celle de la reconnaissance non seulement des particularismes et des droits collectifs, la logique française, elle, se fonde sur l'indifférenciation culturelle et les droits individuels.

- La DDHC est sous-tendue par une **logique universaliste de reconnaissance d'une égalité en droit et non en fait**. Le principe d'égalité « à la française » entraine un impératif d'égalité dans la loi, **empêchant les différences de traitements, telles les discriminations positives** : la loi doit être la même pour tous. V. CC, 1979, *Ponts à péage* ; CE, 1974, *Denoyez et Chorques*.

- Dans le *Préambule de la Constitution de 1946* : égal accès à l'instruction et à la culture (droit individuel).

- **Les principes constitutionnels de l'indivisibilité du peuple et du territoire** empêchent la reconnaissance des groupes minoritaires. Art 2 de la Constitution « *La langue de la République est le français* », ce qui représente un obstacle à une reconnaissance juridique des langues régionales et a justifié le refus de la France de ratifier la *Charte européenne des langues régionales ou minoritaires*, une convention du Conseil de l'Europe adoptée en 1992 pour protéger et promouvoir les langues historiques et celles des minorités en Europe.

B. Une évolution en demi-teinte

- Le principe d'égalité à la française est **universaliste et individualiste** : il garantit une égalité de traitement entre tous les citoyens, refuse la reconnaissance juridique de groupes minoritaires et privilégie l'indivisibilité de la République. Cela contraste avec le droit international, qui admet des droits collectifs pour protéger les minorités.

- Toutefois, on peut reconnaître une légère évolution en reconnaissant des politiques de discrimination positive, si elles poursuivent un objectif légitime : corriger des inégalités existantes.

- La **discrimination positive doit être proportionnée et temporaire**. Ex. : CC 1982, *Loi sur l'éducation* dans laquelle le CC précise que les mesures visant à réduire les inégalités sociales sont conformes à la Constitution. Mais, elles ne peuvent pas créer de privilèges permanents pour certains groupes, au détriment d'autres citoyens.

- Le droit français admet la discrimination positive dans une logique de correction d'inégalités individuelles, mais toujours encadrée pour rester compatible avec le principe d'égalité constitutionnel. Elle ne vise pas les droits collectifs des minorités.

Le droit protège la diversité culturelle, mais selon des logiques différentes. À l'échelle internationale et européenne, elle est envisagée comme un droit collectif, attaché aux peuples, minorités et communautés, impliquant des obligations positives des États. En France, elle est garantie dans une perspective universaliste et individualiste, centrée sur le pluralisme et l'accès à la culture, mais limitée par le principe constitutionnel d'unité et d'égalité qui ne permet pas de faire des régimes juridiques différenciés.

---

2. Argumentez : Le droit français devrait davantage reconnaître l'autonomie collective

Le droit français reconnaît traditionnellement l'autonomie individuelle, fondée sur la liberté et l'égalité des personnes. Selon la pensée des Lumières, principalement dans la philosophie kantienne, l'autonomie individuelle implique que chaque individu soit sujet de droit. Il peut se donner à lui-même sa propre loi (*auto* soi-même, *nomos* loi), ou au moins concourir à sa formation.

Si cette affirmation était largement nécessaire dans le contexte de lutte contre les privilèges structurant l'Ancien Régime, il apparaît aujourd'hui que l'égalité formelle proclamée par la DDHC se heurte à la question minoritaire : des groupes (communautés, associations, peuples autochtones, collectivités locales) ont des intérêts propres, qui ne peuvent pas se réduire à la somme des intérêts individuels et se retrouvent dans des situations de domination qui les empêchent de participer pleinement à la vie politique et à la préservation de leur identité collective. La reconnaissance de l'autonomie collective revient à reconnaître la possibilité pour les groupes minoritaires de participer à la prise de décision collective sur un pied d'égalité, dans une perspective qui dépasse l'égalité juridique formelle, mais qui cherche à la rendre effective dans la réalité politique et sociale.

La logique juridique française se confronte à celle du droit international et européen sur ce point précis et nous invite alors à argumenter en faveur d'une plus grande reconnaissance de l'autonomie collective en droit national.

I. L'autonomie collective, un moyen de protection et de reconnaissance des groupes

A. Préserver les droits collectifs et la diversité

- Certaines communautés (ethniques, culturelles ou linguistiques) ont des besoins spécifiques que le droit individuel ne peut garantir. Exemple : protection des langues régionales, droits des peuples autochtones, gestion collective des ressources naturelles.

- La reconnaissance de droits collectifs permettrait la survie de certaines langues minoritaires.

B. Renforcer la décentralisation

- Renforcer la démocratie locale et la participation collective à la création du droit. Au niveau territorial, la France est un État fortement centralisé qui ne reconnaît que peu d'autonomie aux collectivités territoriales. Une ouverture de la décentralisation vers un régionalisme ou un fédéralisme permettrait une plus grande autonomie des citoyens et des localités. Cela favorise la participation citoyenne et la responsabilisation des groupes.

II. L'autonomie collective, compatible avec les principes du droit français et international

A. Complémentarité avec les droits individuels

- **L'autonomie collective n'exclut pas les droits individuels**, mais les complète : un groupe peut agir pour le bien commun de ses membres sans violer la liberté individuelle.

- Le droit peut reconnaître l'autonomie collective **tout en fixant des limites pour éviter les abus** (ex. : respect de l'ordre public, égalité devant la loi, liberté individuelle).

B. Conformité avec les standards internationaux

- Par ce biais, la France alignerait son droit interne sur les standards internationaux, pour une plus grande **cohérence entre les ordres juridiques** et une plus grande **sécurité juridique**.

- Les instruments internationaux, tels la *Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones* et le *PIDESC* reconnaissent l'importance de l'autonomie collective et sont une source d'inspiration pour les législateurs nationaux. Il y a donc une **possibilité de réformation du droit français et des outils clairs à sa disposition.**

Reconnaître l'autonomie collective en droit français permettrait de concilier diversité et unité, protéger les droits spécifiques des groupes et renforcer la démocratie locale. Cette approche n'affaiblit pas l'individu, mais garantit que les communautés disposent de marges d'action pour gérer leurs affaires et préserver leur identité.

---

3. Commentaire de texte :

« *Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune* ».

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 – Art 1.

Ce célèbre article de la DDHC pose la logique générale du texte : tous les citoyens sont égaux devant la loi et l'on ne peut reconnaître des privilèges à certains. L'État ne reconnaît que des sujets individuels, selon une logique reprise dans l'article 1er de la Constitution de 1958.

Au fondement du principe d'égalité à la française (V. *Dissertation*), l'article 1er de la DDHC peut être à la fois lu dans son contexte d'écriture pour en saisir la nécessité historique et son importance dans le système juridique français. Toutefois, il se confronte aujourd'hui à d'autres logiques juridiques répondant à la préoccupation contemporaine de protection des minorités.

On peut alors *interroger quelles sont les forces et les faiblesses du texte dans un système juridique global contemporain*.

[Annonce]

I. L'universalisme comme rupture avec l'Ancien Régime : la nécessité d'endiguer les privilèges de certains contre tous

A. La consécration de la liberté et de l'égalité universelles

- À la fin du XVIII^{ème} siècle, cet article affirme un principe radical : tous les hommes, quelle que soit leur naissance, sont libres et égaux en droits. L'objectif est ainsi de **supprimer les privilèges héréditaires, l'aristocratie et les corporations de l'Ancien Régime**.

- Fortement influencés par la pensée de Lumières, les rédacteurs de la Déclaration entérinent dans le droit et la philosophie politique la reconnaissance de l'égalité de chaque être humain : nous sommes tous et toutes également pourvus de raison et nous devons jouir des mêmes droits.

- L'égalité est à la fois pensée dans une dimension formelle et individuelle : l'État s'adresse à des individus et non à des groupes.

B. Une logique unitaire et individualiste

- La DDHC postule que tous les hommes forment **une unité morale et juridique** : chaque individu appartient à la même communauté humaine et politique. En affirmant que tous les hommes « naissent et demeurent libres et égaux en droits », elle pose une norme universelle : **il n'y a pas de droit spécial pour certaines classes ou groupes** au départ.

- **L'idée unitariste** : la société est pensée comme un tout, un « corps-citoyen » cohérent, où les règles s'appliquent à tous de manière uniforme. L'article met l'accent sur l'individu en tant que titulaire de droits naturels : liberté, égalité, propriété, sûreté, résistance à l'oppression (listés dans les autres articles de la DDHC).

- Chaque personne est reconnue comme sujet autonome, dont les droits existent indépendamment de sa place sociale ou de son groupe. La protection des droits individuels prime sur toute hiérarchie sociale arbitraire. C'est la base de **la conception libérale des droits** : chaque individu compte en tant qu'entité indépendante.

II. La désuétude relative face aux exigences contemporaines de protection des minorités

A. L'opposition contemporaine entre une logique universaliste et collective

- Aujourd'hui, le droit international reconnaît l'existence de **minorités culturelles, linguistiques et autochtones** : ONU, UNESCO, Conseil de l'Europe – V. *Dissertation*.

- **Ces droits sont collectifs** : ils visent à la préservation d'identités minoritaires. L'universalisme français peut entrer en tension avec la protection spécifique de communautés, peuples autochtones ou minorités linguistiques. V. *Dissertation*.

B. Tension entre égalité formelle et pluralisme culturel

- **L'article 1er privilégie l'égalité stricte entre individus, refusant la reconnaissance de différences de traitement selon l'appartenance à un groupe**. Or, la protection des minorités nécessite souvent des mesures différenciées pour assurer une égalité réelle (ex. quotas, reconnaissance des langues régionales, politiques de discrimination positive). La reconnaissance de l'égalité en droit ne suffit pas à assurer son effectivité dans la réalité politique et sociale.

- Cette tension se manifeste dans la jurisprudence française. Par exemple, on retient la censure partielle de *la loi Molac sur l'enseignement immersif en langues régionales* : l'État protège l'égalité universelle, mais peut négliger la diversité culturelle.

Au XVIII^{ème} siècle, l'article 1er établit un universalisme nécessaire : il détruit les privilèges et fonde une égalité juridique entre individus. Aujourd'hui, cet universalisme montre ses limites face à la reconnaissance des droits collectifs des minorités tels qu'ils sont protégés par le droit international : il reflète une logique individualiste, parfois en tension avec les standards internationaux.

---

4. Commentaire d'arrêt : Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999

-

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 mai 1999, par le Président de la République, sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, de la question de savoir si la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, signée à Budapest le 7 mai 1999, doit être précédée, compte tenu de la déclaration interprétative faite par la France et des engagements qu'elle entend souscrire dans la partie III de cette convention, d'une révision de la Constitution ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 18, alinéa 2, 19 et 20 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LE CONTENU DE L'ENGAGEMENT INTERNATIONAL SOUMIS A L'EXAMEN DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET SUR L'ÉTENDUE DU CONTRÔLE EXERCÉ :

1. Considérant que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires soumise à l'examen du Conseil constitutionnel se compose, outre un préambule, d'une partie I, intitulée : « dispositions générales » ; d'une partie II relative aux « objectifs et principes » que chaque État contractant s'engage à appliquer ; d'une partie III comportant quatre-vingt-dix-huit mesures en faveur de l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique, classées par domaine d'application, au sein desquelles chaque État contractant est libre de faire un choix dans les limites précisées à l'article 2 (§ 2) de la Charte, les mesures ainsi retenues ne s'appliquant qu'aux langues indiquées dans son instrument de ratification ; d'une partie IV contenant des dispositions d'application ; d'une partie V fixant des dispositions finales ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 2 (§ 1) de la Charte, « chaque Partie s'engage à appliquer les dispositions de la partie II », comportant le seul article 7, « à l'ensemble des langues régionales ou minoritaires pratiquées sur son territoire, qui répondent aux définitions de l'article 1 » ; qu'il résulte de ces termes mêmes que la partie II a une portée normative propre et qu'elle s'applique non seulement aux langues qui seront indiquées par la France au titre des engagements de la partie III, mais à toutes les langues régionales ou minoritaires pratiquées en France au sens de la Charte ;

3. Considérant que l'article 2 (§ 2) précité de la Charte fait obligation à chaque État contractant de s'engager à appliquer un minimum de trente-cinq paragraphes ou alinéas choisis parmi les dispositions de la partie III, dont au moins trois choisis dans les articles 8 : « enseignement » et 12 : « activités et équipements culturels », et un dans chacun des articles 9 : « justice », 10 : « autorités administratives et services publics », 11 : « médias » et 13 : « vie économique et sociale » ; que, lors de la signature de la Charte, la France a indiqué une liste de trente-neuf alinéas ou paragraphes, sur les quatre-vingt-dix-huit que comporte la partie III de cette convention, qu'elle s'engage à appliquer et qui sera jointe à son instrument de ratification ; que onze d'entre eux concernent l'enseignement, neuf les médias, huit les activités et

équipements culturels, cinq la vie économique et sociale, trois les autorités administratives et services publics, deux les échanges transfrontaliers et un la justice ; que le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel sur la partie III doit porter sur les seuls engagements ainsi retenus ;

4. Considérant, par ailleurs, que le Gouvernement français a accompagné sa signature d'une déclaration interprétative dans laquelle il précise le sens et la portée qu'il entend donner à la Charte ou à certaines de ses dispositions au regard de la Constitution ; qu'une telle déclaration unilatérale n'a d'autre force normative que de constituer un instrument en rapport avec le traité et concourant, en cas de litige, à son interprétation ; qu'il appartient donc au Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, de procéder au contrôle de la constitutionnalité des engagements souscrits par la France indépendamment de cette déclaration ;

- SUR LES NORMES DE RÉFÉRENCE APPLICABLES :

5. Considérant, d'une part, qu'ainsi que le proclame l'article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » ; que le principe d'unicité du peuple français, dont aucune section ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale, a également valeur constitutionnelle ;

6. Considérant que ces principes fondamentaux s'opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance ;

7. Considérant, d'autre part, que la liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi », doit être conciliée avec le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution selon lequel « La langue de la République est le français » ;

8. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage ; que l'article 2 de la Constitution n'interdit pas l'utilisation de traductions ; que son application ne doit pas conduire à méconnaître l'importance que revêt, en matière d'enseignement, de recherche et de communication audiovisuelle, la liberté d'expression et de communication ;

- SUR LA CONFORMITÉ DE LA CHARTE À LA CONSTITUTION :

9. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de son préambule, la Charte reconnaît à chaque personne « un droit imprescriptible » de « pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique » ; qu'aux termes de l'article 1 (a) de la partie I : « par l'expression » langues régionales ou minoritaires ", on entend les langues : i) pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l'État ; et ii) différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet État", exception faite des dialectes de la langue officielle et des langues des migrants ; que, par « territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée », il convient d'entendre, aux termes de l'article 1 (b), « l'aire géographique dans laquelle cette langue est le mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant l'adoption des différentes mesures de protection et de promotion » prévues par la Charte ; qu'en vertu de l'article 7 (§ 1) : « les Parties fondent leur politique, leur législation et leur pratique sur les objectifs et principes » que cet article énumère ; qu'au nombre de ces objectifs et principes figurent notamment « le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue », ainsi que « la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée » ; que, de surcroît, en application de l'article 7 (§ 4),

« les Parties s'engagent à prendre en considération les besoins et les vœux exprimés par les groupes pratiquant ces langues » en créant, si nécessaire, des « organes chargés de conseiller les autorités » sur ces questions ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, en ce qu'elle confère des droits spécifiques à des « groupes » de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l'intérieur de « territoires » dans lesquels ces langues sont pratiquées, porte atteinte aux principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français ;

11. Considérant que ces dispositions sont également contraires au premier alinéa de l'article 2 de la Constitution en ce qu'elles tendent à reconnaître un droit à pratiquer une langue autre que le français non seulement dans la « vie privée », mais également dans la « vie publique », à laquelle la Charte rattache la justice et les autorités administratives et services publics ;

12. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions précitées de la Charte sont contraires à la Constitution ;

13. Considérant que n'est contraire à la Constitution, eu égard à leur nature, aucun des autres engagements souscrits par la France, dont la plupart, au demeurant, se bornent à reconnaître des pratiques déjà mises en œuvre par la France en faveur des langues régionales ;

D É C I D E :

Article premier :
La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires comporte des clauses contraires à la Constitution.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 juin 1999, présidée par M Yves GUÉNA, et où siégeaient : MM Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
Le président,
Yves GUÉNA

Journal officiel du 18 juin 1999, page 8964
Recueil, p. 71
ECLI : FR : CC : 1999 : 99.412.DC

Le 20 mai 1999, le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 54 de la Constitution pour savoir si la ratification de la *Charte européenne des langues régionales ou minoritaires,* signée à Budapest le 7 mai 1999, devait être précédée d'une révision constitutionnelle. Le Conseil a conclu que certaines dispositions de la Charte étaient contraires à la Constitution, notamment celles qui conféraient des droits spécifiques à des groupes linguistiques au sein de la République.

Cette décision illustre la tension entre les engagements internationaux et les principes fondamentaux de la Constitution française ; entre deux logiques juridiques plus ou moins contradictoires : la reconnaissance de droits collectifs et l'indifférenciation en droit.

La question de droit posée au Conseil constitutionnel dans cette affaire est en premier lieu celle de savoir si la ratification par la France de la *Charte européenne des langues régionales ou minoritaires* est compatible avec la Constitution, ou si elle exige une révision constitutionnelle préalable ?

Autrement dit, il s'agissait de savoir si les engagements internationaux pouvaient être respectés sans violer les principes constitutionnels français, plus spécifiquement : l'indivisibilité de la République ; l'égalité devant la loi ; l'unicité du peuple français et la primauté du français dans la vie publique.

[Annonce]

I. La protection de la Constitution et des principes fondamentaux de la République

A. Le respect de l'indivisibilité et de l'égalité de la République

- Le Conseil constitutionnel affirme que la France est « *une République indivisible* » et que « ***le principe d'unicité du peuple français*** » **interdit la reconnaissance de droits collectifs** à des groupes déterminés.

- La *Charte européenne des langues régionales ou minoritaires* attribue des droits spécifiques à certains groupes linguistiques sur des territoires définis. Cela **contredit le principe constitutionnel d'égalité devant la loi**, en favorisant certains citoyens sur la base de leur langue ou culture.

B. La primauté de la langue française dans la vie publique

- Le Conseil souligne que l'article 2 de la Constitution impose le français comme langue de la République.

- La Charte reconnaît le droit d'utiliser une langue régionale ou minoritaire dans la « vie publique », y compris dans la justice et l'administration. Cette reconnaissance serait incompatible avec l'exigence constitutionnelle que le français soit la langue obligatoire pour les actes officiels et les relations avec l'administration.

La France ne peut donc pas ratifier ce Traité sans une modification substantielle de sa Constitution ;

II. L'articulation entre engagements internationaux et normes constitutionnelles

A. Le contrôle de conformité des engagements internationaux

- Le Conseil rappelle que sa mission, sur le fondement de l'article 54, est de vérifier si les engagements internationaux sont compatibles avec la Constitution.

- La partie III de la Charte, qui comporte les mesures concrètes de promotion des langues régionales, a été examinée pour les seuls engagements pris par la France.

- Le Conseil distingue donc les dispositions de la Charte **selon qu'elles dépassent ou respectent les engagements français existants.**

B. Limites et portée de la décision

Le Conseil n'a pas rejeté tous les engagements de la France :

- Les mesures qui reconnaissent simplement des pratiques déjà mises en œuvre pour les langues régionales sont jugées conformes.

- Cette décision montre que le Conseil n'empêche pas toute action en faveur des langues régionales, mais encadre ces dernières dans une dimension compatible avec l'indivisibilité du territoire, le principe d'égalité en droit et la logique universaliste des textes constitutionnels nationaux.

Cette décision du Conseil constitutionnel illustre la primauté de la Constitution sur les engagements internationaux lorsque ceux-ci créent des droits spécifiques à des groupes au sein de la République. Elle met en lumière la tension entre le respect des normes internationales et la protection des principes fondamentaux français, en particulier l'indivisibilité, l'égalité devant la loi et la primauté du français. En pratique, elle laisse cependant une marge pour promouvoir les langues régionales tant que cela ne crée pas de discrimination constitutionnelle.

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2025

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 3 – Droits fondamentaux et démocratie

Droits fondamentaux et démocratie

---

1. <u>Dissertation</u> : Les droits fondamentaux limitent-ils la démocratie ?

---

2. <u>Argumentation</u> : Soutenez que l'État de droit est aujourd'hui en danger.

---

3. <u>Commentaire de texte</u> : Préambule de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14
Rome, 4.XI.1950

---

4. <u>Commentaire d'arrêt</u> : Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6 RIP du 11 avril 2024 *Proposition de loi visant à réformer l'accès aux prestations sociales des étrangers*

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La proposition de loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale, en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution.

2. Aux termes des premier, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution : « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. « Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. « Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique. « Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin ».

3. Aux termes de l'article 45-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus : « Le Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la proposition de loi : « 1 ° Que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction ; « 2 ° Que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution, les délais qui y sont mentionnés étant calculés à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel ; « 3 ° Et qu'aucune disposition de la proposition de loi n'est contraire à la Constitution ».

4. En premier lieu, conformément au 1 ° de l'article 45-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la proposition de loi a été présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement à la date d'enregistrement de la saisine du Conseil constitutionnel.

5. En deuxième lieu, il résulte du 2 ° du même article 45-2 qu'il appartient au Conseil constitutionnel, ainsi qu'il l'a relevé par sa décision du 9 mai 2019 mentionnée ci-dessus, de vérifier que, à la date d'enregistrement de la saisine, l'objet de la proposition de loi respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution. Ainsi qu'il l'a jugé tant par sa décision du 9 mai 2019 que par sa décision du 25 octobre 2022 mentionnée ci-dessus, il s'assure, en particulier, que la proposition porte sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tend à autoriser la ratification d'un traité qui aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

6. En l'espèce, la proposition de loi soumise au Conseil constitutionnel comporte cinq articles. Son article 1er instaure une condition de durée minimale de résidence en France ou d'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle que doivent remplir les étrangers non ressortissants de l'Union européenne en situation régulière pour bénéficier de certaines prestations sociales. Son article 2 remplace l'aide médicale de l'État bénéficiant à certains étrangers en situation irrégulière par une aide médicale d'urgence. Son article 3 exclut les étrangers en situation irrégulière du bénéfice de la réduction tarifaire accordée pour certains titres de transport. Son article 4 prévoit que certains hébergements destinés aux demandeurs d'asile sont pris en compte au titre des obligations des communes tenant à la proportion de logements locatifs sociaux sur leur territoire. Son article 5 modifie les conditions auxquelles les demandeurs d'asile peuvent se maintenir dans un lieu d'hébergement ainsi que celles relatives à l'évacuation de ses occupants.

7. Au regard des modifications que cette proposition de loi apporte à certains dispositifs de prestations sociales, d'aide à la mobilité et d'hébergement susceptibles de bénéficier à des étrangers, elle porte, au sens de l'article 11 de la Constitution, sur une réforme relative à la politique sociale de la nation.

8. Par ailleurs, à la date d'enregistrement de la saisine, la proposition de loi n'avait pas pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. Aucune proposition de loi portant sur le même sujet n'avait été soumise au référendum depuis deux ans.

9. Toutefois, en dernier lieu, aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». En vertu de son onzième alinéa : « Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ». Les exigences constitutionnelles résultant des dispositions précitées impliquent la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées.

10. Si le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques, il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Ils doivent cependant être conciliés avec la sauvegarde de l'ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. En outre, les étrangers jouissent des droits à la protection sociale, dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français.

11. L'article 1er de la proposition de loi modifie les articles L. 300-1 et L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, l'article L. 512-2 du code de la Sécurité sociale ainsi que l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles afin de prévoir que les étrangers non ressortissants de l'Union européenne ne bénéficient du droit au logement, de l'aide personnelle au logement, des prestations familiales et de l'allocation personnalisée d'autonomie que s'ils justifient d'une durée minimale de résidence stable et régulière en France ou d'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle en France.

12. Si les exigences constitutionnelles précitées ne s'opposent pas à ce que le bénéfice de certaines prestations sociales dont jouissent les étrangers en situation régulière sur le territoire français soit soumis à une condition de durée de résidence ou d'activité, cette durée ne saurait être telle qu'elle prive de garanties légales ces exigences.

13. En subordonnant le bénéfice de prestations sociales, dont certaines sont au demeurant susceptibles de présenter un caractère contributif, pour l'étranger en situation régulière non ressortissant de l'Union européenne, à une condition de résidence en France d'une durée d'au moins cinq ans ou d'affiliation au titre d'une activité professionnelle d'une durée d'au moins trente mois, les dispositions de l'article 1er portent une atteinte disproportionnée à ces exigences. Elles sont donc contraires à la Constitution.

14. Il résulte de ce qui précède, et sans que le Conseil constitutionnel n'ait à se prononcer sur la conformité à la Constitution de ses autres dispositions, que la proposition de loi ne remplit pas la condition prévue au 3 ° de l'article 45-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La proposition de loi visant à réformer l'accès aux prestations sociales des étrangers ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 11 de la Constitution et par l'article 45-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 avril 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 11 avril 2024.

JORF n°0086 du 12 avril 2024, texte n° 65
ECLI : FR : CC : 2024 : 2024.6.RIP

Le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre de la procédure de référendum d'initiative partagée, a rendu une décision importante le 11 avril 2024 relative à une proposition de loi concernant l'accès des étrangers aux prestations sociales. Ce contrôle s'inscrivait dans le cadre de l'article 11 de la Constitution, qui fixe les objets pouvant faire l'objet d'un référendum, et de l'article 45-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, qui encadre le rôle du Conseil en la matière.

Si la proposition respectait les conditions formelles et matérielles de recevabilité posées par ces textes, la haute juridiction a néanmoins jugé que certaines de ses dispositions, notamment l'article 1er, portaient une atteinte disproportionnée aux droits sociaux garantis par le Préambule de 1946. Cette décision illustre ainsi la tension entre, d'une part, la possibilité pour le législateur d'adopter des règles spécifiques concernant les étrangers et, d'autre part, l'exigence de respecter les droits fondamentaux à valeur constitutionnelle.

I. La recevabilité de la proposition de loi référendaire

A. Les conditions procédurales de dépôt et d'examen

- Le Conseil constitutionnel commence par rappeler **le cadre juridique applicable** (articles 11 de la Constitution et 45-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958). La proposition a bien été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale en application du troisième alinéa de l'article 11, et elle a

été soutenue par au moins un cinquième des membres du Parlement. **Ces conditions formelles de recevabilité sont donc respectées**.

B. Le respect des conditions matérielles de l'article 11 de la Constitution

- Le Conseil vérifie ensuite que la proposition relève bien de l'un des objets autorisés par l'article 11. En l'espèce, elle porte sur une réforme relative à la politique sociale de la Nation, ce qui la rattache bien aux matières énumérées.

- En outre, elle ne constitue ni l'abrogation d'une loi promulguée depuis moins d'un an, ni la réitération d'une proposition déjà rejetée par référendum depuis moins de deux ans. **Ces conditions sont également respectées**.

II. Le contrôle de constitutionnalité de la proposition de loi

A. Le rappel des exigences constitutionnelles de solidarité nationale

- Le Conseil mobilise le Préambule de 1946, qui garantit à toute personne des droits fondamentaux : protection de la santé, sécurité matérielle et moyens convenables d'existence.

- Ces droits doivent bénéficier aux personnes résidant sur le territoire français, y compris les étrangers en situation régulière, sous réserve de la sauvegarde de l'ordre public.

B. La censure de l'atteinte disproportionnée aux droits sociaux des étrangers

- L'article 1er de la proposition subordonnait l'accès à plusieurs prestations sociales (logement, prestations familiales, allocation personnalisée d'autonomie, etc.) à une durée de résidence d'au moins cinq ans ou à une affiliation de trente mois.

- Pour le Conseil, une telle exigence prive de garanties légales les droits constitutionnels, en instaurant une restriction excessive à l'accès des étrangers réguliers aux droits sociaux. Cette atteinte disproportionnée conduit à la censure de la proposition**, qui ne satisfait donc pas aux conditions fixées par l'article 45-2 de l'ordonnance de 1958**.

En l'espèce, le Conseil constitutionnel a ainsi confirmé que, même lorsqu'une proposition de loi relève d'une réforme sociale susceptible d'être soumise à référendum, elle doit respecter les exigences constitutionnelles en matière de droits fondamentaux et de solidarité nationale. La censure de l'article 1er montre que le législateur ne peut subordonner l'accès aux prestations sociales des étrangers à des conditions de durée de résidence ou d'activité disproportionnées. Cette décision illustre la fonction essentielle du Conseil constitutionnel : concilier l'initiative parlementaire et populaire avec le respect des droits garantis par la Constitution, et protéger les individus, y compris les étrangers en situation régulière, contre des mesures qui porteraient atteinte à leur dignité et à leur protection sociale.

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2025

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 2 – Droits fondamentaux et démocratie

Droits fondamentaux et démocratie

1. Dissertation : Les droits fondamentaux limitent-ils la démocratie ?

2. Argumentez : Soutenez que l'État de droit est aujourd'hui en danger.

3. Commentaire de texte : Préambule de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14
Rome, 4.XI.1950

4. Commentaire d'arrêt : Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6 RIP du 11 avril 2024 *Proposition de loi visant à réformer l'accès aux prestations sociales des étrangers*

Dissertation : Les droits fondamentaux limitent-ils la démocratie ?

La démocratie est fondée sur le principe de la souveraineté du peuple et sur la règle de la majorité. La démocratie est ainsi *le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple*. Toutefois, le principe de l'État de droit implique que les lois, votées par les représentants du peuple en son nom, soient-elles aussi soumises au respect de valeurs supérieures : les droits et libertés fondamentales. Autrement dit, la souveraineté du peuple n'est pas absolue : elle doit être conciliée avec le respect des droits fondamentaux, qui protègent les individus et les minorités contre les abus de la majorité ou du pouvoir.

Dès lors, *on peut se demander si ces droits fondamentaux, en imposant des limites aux décisions démocratiquement adoptées, ne restreignent pas la démocratie elle-même. Cette question appelle à analyser le rôle des droits fondamentaux dans l'organisation de la démocratie et les tensions qu'ils peuvent engendrer*.

Les droits fondamentaux limitent certes le principe démocratique, mais dans l'unique but d'encadrer ses abus (I.). Qui plus est, les droits politiques, protégés au niveau fondamental, concourent à la protection du principe démocratique (II.)

I. Les droits fondamentaux comme une limitation nécessaire de la démocratie

A. La protection des individus contre la tyrannie de la majorité

- **La démocratie purement majoritaire peut conduire à l'oppression des minorités**. Exemple : interdiction de discriminer des minorités religieuses ou linguistiques, protection des droits civiques.

- Le principe démocratique ne représente pas en lui-même un rempart suffisant contre la négation des DLF et l'autoritarisme. En témoigne notamment l'histoire de l'accession des nazis au pouvoir en Allemagne dans les années 1930 qui s'est établi par des voies démocratiques.

B. Une contrainte pour les gouvernants et les législateurs

- Les droits fondamentaux limitent le pouvoir des élus et empêchent des décisions arbitraires. Ils imposent l'indépendance des juridictions pour appliquer les DLF.

- Les gouvernants doivent respecter ces droits, ce qui peut apparaître comme une restriction de l'action démocratique. Exemple : la Constitution française impose le respect de l'égalité et de la

laïcité, ce qui limite certaines lois locales ou internationales (comme la ratification de la Charte des langues régionales).

- Il y a certes une limitation de l'action des États démocratiques au regard des DLF, mais le principe de l'État n'est pas non plus la négation de la démocratie : il s'agit plutôt d'un renforcement mutuel.

II. Les droits fondamentaux comme un moyen de renforcer la démocratie

A. Garantir une démocratie équilibrée et juste

- En protégeant les libertés individuelles et les minorités, les droits fondamentaux assurent que la démocratie **ne se transforme pas en dictature de la majorité**.

- Les DLF créent un cadre de respect et de légitimité, où chacun peut participer librement à la vie politique. Ils concourent à la démocratie en donnant le droit à chacun d'y participer pleinement grâce à **la liberté d'expression, d'opinion, aux droits civils et politiques en général**, au droit à l'association libre, etc.

- Le contrôle de constitutionnalité en France assure que les lois respectent les droits fondamentaux. Toutefois, le Conseil accepte qu'il ne puisse pas tout juger et s'incline devant la volonté démocratique par un considérant de principe répété, au sein duquel il précise qu'il ne dispose pas d'un pouvoir de décision similaire à celui du Parlement.

B. Les droits fondamentaux et la légitimité de l'action politique

- Une démocratie qui respecte les droits fondamentaux est plus légitime et plus stable. Les citoyens acceptent davantage les décisions de l'État lorsqu'ils savent que leurs droits sont protégés, ce qui renforce la participation et la confiance dans le système démocratique.

- La démocratie et le respect des DLF fonctionnent ensemble en un équilibre toujours en construction. Les institutions internationales et régionales, avec en premier lieu la CEDH, concourt à rendre réel cet équilibre. **DLF et démocratie fonctionnent ensemble et se renforce.**

- C'est aussi la ligne jurisprudentielle suivie par le CJUE, notamment en ce qu'elle contrôle le respect de l'État de droit dans les États membres. V. *Infra, les cas de la Pologne et de la Hongrie*.

Les droits fondamentaux peuvent sembler limiter la démocratie en imposant des contraintes aux décisions de la majorité. Cependant, cette limitation est nécessaire pour garantir que la démocratie ne se transforme pas en tyrannie de la majorité et pour assurer le respect des libertés individuelles et des minorités. Plutôt que de restreindre la démocratie, les droits fondamentaux en sont la condition de stabilité et de légitimité, permettant une démocratie réellement juste et durable. Ainsi, ils ne limitent pas la démocratie : ils la protègent et la renforcent.

2. Argumentez : L'État de droit est aujourd'hui en danger

En septembre-octobre 2024, le ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau déclare dans une interview au JDD que « l'État de droit n'est pas intangible, ni sacré ». Il ajoute que l'État de droit est « un ensemble de règles, une hiérarchie des normes, un contrôle juridictionnel, une séparation des pouvoirs », mais affirme que sa source est « la démocratie, c'est le peuple souverain ».

Ces propos provoquent une vive polémique : des personnalités politiques de divers bords estiment que ces déclarations suggèrent un affaiblissement potentiel des principes fondamentaux, comme l'indépendance de la justice, de la sécurité juridique et du respect des DLF par les institutions étatiques.

Le principe de l'État de droit repose sur l'idée que le pouvoir politique est limité par des normes supérieures (droits de l'homme, conventions internationales, les DLF de manière générale) et ne peut agir de manière arbitraire. Ce principe est au fondement non seulement du droit de l'Union européenne, mais aussi du droit de la Conv. EDH qui pose, dès son préambule, un lien consubstantiel entre principe démocratique et respect des DLF, l'un ne pouvant exister sans l'autre pour éviter l'arbitraire.

Ces propos soulignent-ils seulement un débat rhétorique, ou révèlent-ils une fragilité plus profonde de l'État de droit en France et en Europe ? En d'autres termes, dans quelles mesures l'État de droit est-il réellement en danger aujourd'hui, et comment les institutions du droit européen (CEDH, UE) tentent-elles ou peuvent-elles le protéger ?

[Annonce]

II. L'État de droit : un corps de principes menacé en France

A. Les dérives possibles : atteintes à l'indépendance judiciaire, pressions sur les libertés publiques

-
-
- Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) alerte dans son rapport annuel sur la nécessité de « défendre l'État de droit », notamment face aux **attaques politiques répétées visant le pouvoir des juges**, à la critique du « gouvernement des juges ».

- Le phénomène de **stigmatisation ou de criminalisation** de certaines catégories ou d'acteurs (défenseurs des droits humains, migrants, etc.) peut limiter l'égalité devant la loi ou le droit à un procès équitable protégé par la CEDH (articles 6, 14).

B. Les enjeux institutionnels, juridiques : sécurité juridique, hiérarchie des normes, séparation des pouvoirs

- Les propos de Retailleau suggèrent une tension entre la démocratie (la volonté de la majorité) et le respect des principes de l'État de droit – ce qui pose le risque que les décisions fondées sur une demande sociale ou populaire puissent contourner les gardes-fous du droit.

- En France, des réformes ou propositions (lois sur l'immigration, sur le pouvoir exécutif, sur la détention administrative) sont parfois perçues comme risquant de réduire les droits procéduraux ou d'affaiblir le contrôle juridictionnel.

- Le Conseil constitutionnel ou d'autres juridictions nationales ainsi que la CEDH constituent des **contrepoids**, mais le processus de mise en conformité, d'exécution des arrêts, ou d'adaptation législative peut être lent ou contourné.

III. L'État de droit en Europe : risques et résistances institutionnelles

A. Les cas emblématiques : Pologne, Hongrie, mais au-delà

- La Pologne et la Hongrie font l'objet de critiques répétées de **la Commission européenne** et de la **CJUE pour des entraves à l'indépendance des juges, la primauté du droit de l'UE, ou des réformes qui affaiblissent les contrôles judiciaires**.

- La CJUE, dans les arrêts de 16 février 2022 (affaires C-156/21 et C-157/21), a validé le mécanisme de conditionnalité institué par le règlement sur l'État de droit, qui permet de **suspendre des fonds européens à États qui violent les principes fondamentaux** (État de droit, indépendance judiciaire, séparation des pouvoirs, accès à la justice).

- Ceci montre un certain sursaut institutionnel pour protéger le principe de l'État de droit qui se trouve menacé par plusieurs gouvernements d'Europe.

B. Les dispositifs de protection : CEDH, CJUE, rapport de la Commission, conditionnalité

- **CEDH** : par ses arrêts, elle garantit les droits fondamentaux, le procès équitable, l'interdiction des traitements inhumains, l'impartialité judiciaire, etc.

- **CJUE et UE** : l'État de droit est une valeur fondamentale inscrite dans l'article 2 du TUE (Traité sur l'Union européenne). Le mécanisme de conditionnalité, contrôlé par la CJUE, est un instrument concret rendu nécessaire par des atteintes répétées aux fondements de l'État de droit.

- V. *Rapport annuel de la Commission sur l'État de droit dans l'Union européenne* 2025 : souligne que, dans plusieurs États membres, persistent des pressions sur les médias, les institutions judiciaires, et que certaines libertés sont en recul. Le rapport encourage la prévention et le dialogue, mais indique que dans certains pays « la situation est grave ».

L'État de droit est fragilisé par des discours politiques comme ceux de Retailleau, mais aussi par des phénomènes structurels : indépendance judiciaire mise à l'épreuve, pouvoir exécutif tentant de limiter le contrôle judiciaire, populisme, tentations autoritaires.

Les menaces majeures sont ainsi clairement identifiées :
- Affaiblissement du contrôle juridictionnel, remise en cause de la primauté du droit international ou du droit de l'UE.
- Réductions des libertés publiques ou limitations excessives de procédure pour répondre à des urgences (sécurité, immigration).
- Politisation des institutions de contrôle (justice, médias, etc.).

3. Commentaire de texte :

Préambule de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14
Rome, 4.XI.1950

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe, Considérant la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948; Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés; Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se réclament; Résolus, en tant que gouvernements d'États européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle.

Le préambule de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 sous l'égide du Conseil de l'Europe, s'inscrit dans un contexte historique marqué par l'après-guerre. Les États européens, profondément marqués par les crimes nazis et les atteintes massives aux droits humains, souhaitent garantir la paix et la stabilité par la mise en place d'un ordre fondé sur la démocratie et la protection des droits fondamentaux. Inspirés par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, ils affirment que les libertés fondamentales ne peuvent se maintenir que dans un régime démocratique et qu'elles constituent, à leur tour, le socle de la

paix et de la justice. Ce préambule, en même temps qu'il s'ancre dans l'universalité des droits, établit un lien organique entre droits fondamentaux et démocratie, en posant les bases d'une garantie collective et juridictionnelle inédite en Europe.

Comment le préambule de la CEDH articule-t-il la reconnaissance universelle des droits fondamentaux et la spécificité d'une mise en œuvre collective au sein des démocraties européennes ?

En premier lieu, le préambule affirme la valeur universelle des droits fondamentaux (I), avant de souligner qu'il les lie étroitement au cadre politique démocratique propre à l'Europe et en organise la protection collective (II).

I. L'affirmation de la valeur universelle des droits fondamentaux

A. Les droits fondamentaux comme condition de la paix et de la justice

- Le texte s'ouvre sur une référence directe à la **DUDH**, proclamée par l'ONU en 1948, dans le contexte de la fin de la guerre et de créations juridiques permettant d'endiguer les crimes contre l'humanité, les génocides et de manière générale, le négation des droits fondamentaux des humains. L'objectif du Préambule de la Conv. EDH est le même.

- Les États européens se rattachent à un socle commun à toute l'humanité : la **reconnaissance et l'application effective des droits énoncés**. Cela inscrit la CEDH dans une logique d'universalité et d'uniformité des droits.

- Les libertés fondamentales sont présentées comme des assises essentielles de l'ordre international. Leur respect dépasse le cadre purement national : il conditionne la stabilité du monde.

- On voit émerger l'idée que la protection des droits n'est pas une affaire intérieure, mais un **enjeu international légitimant une action collective**.

B. Une recherche d'effectivité des DLF

- Dans la lignée de la DUDH, l'objectif du Conseil de l'Europe est aussi d'assurer non seulement la reconnaissance des DLF, mais aussi leur **effectivité, au sens d'une application concrète par les États membres**, pour que ces dernières se réalisent dans la réalité politique et sociale

- Ces éléments préfigurent la création d'une cour dédiée qui permettra de sanctionner les atteintes aux DLF et de potentiellement condamner les États qui ne les respecteraient pas.

- L'effectivité des DLF passe ainsi par la création d'une cour internationale, mais aussi par la réalisation et la protection du système démocratique dans les États signataires.

II. La démocratie comme cadre et garantie des droits fondamentaux en Europe

A. Le Conseil de l'Europe, union de démocraties autour d'un patrimoine commun

- Le Préambule rappelle que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres. L'un des moyens essentiels de cette union est la sauvegarde et le développement des droits humains, ce qui **place les droits au cœur de la coopération européenne** : affirmation d'une identité européenne commune fondée sur la **démocratie**.

- Le fort lien établi entre respect des DLF et principes démocratiques s'inscrit dans le **principe de l'État de droit** : l'idée que le pouvoir politique est limité par des normes supérieures (droits de l'homme, conventions internationales, les DLF de manière générale) et ne peut agir de manière arbitraire.

B. Le lien organique entre démocratie et droits fondamentaux

- Les libertés fondamentales reposent « sur un régime politique véritablement démocratique » : **la démocratie est donc présentée comme condition de possibilité des droits.**

- En retour, **ces droits constituent le contenu et la finalité de la démocratie** : la protection des droits donne sens au régime démocratique.

- Cette interdépendance justifie la mise en place d'une garantie collective , au moyen de la CEDH pour éviter toute dérive autoritaire.

Le préambule de *la Convention européenne des droits de l'homme* établit ainsi une double articulation : il rattache l'Europe à l'universalité des droits proclamés en 1948, tout en affirmant une spécificité européenne fondée sur la démocratie et la prééminence des DLF, donnant ainsi, en creux une définition de l'État de droit. Cette complémentarité entre droits fondamentaux et démocratie fonde la légitimité du Conseil de l'Europe et justifie la création d'un système inédit de garantie collective : un contrôle juridictionnel supranational par la Cour européenne des droits de l'homme. L'originalité de ce Préambule réside donc dans sa capacité à inscrire l'Europe dans l'universel tout en la dotant d'un mécanisme concret de protection, conçu pour prévenir toute rechute dans l'autoritarisme et assurer la stabilité du continent.

4. Commentaire d'arrêt : Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6 RIP du 11 avril 2024 *Proposition de loi visant à réformer l'accès aux prestations sociales des étrangers*

[…]

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La proposition de loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale, en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution.

2. Aux termes des premier, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution : « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. « Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. « Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique. « Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin ».

3. Aux termes de l'article 45-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus : « Le Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la proposition de loi : « 1 ° Que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction ; « 2 ° Que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution, les délais qui y sont mentionnés étant calculés à la date d'enregistrement de la saisine par le

Conseil constitutionnel ;
« 3 ° Et qu'aucune disposition de la proposition de loi n'est contraire à la Constitution ».

4. En premier lieu, conformément au 1 ° de l'article 45-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la proposition de loi a été présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement à la date d'enregistrement de la saisine du Conseil constitutionnel.

5. En deuxième lieu, il résulte du 2 ° du même article 45-2 qu'il appartient au Conseil constitutionnel, ainsi qu'il l'a relevé par sa décision du 9 mai 2019 mentionnée ci-dessus, de vérifier que, à la date d'enregistrement de la saisine, l'objet de la proposition de loi respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution. Ainsi qu'il l'a jugé tant par sa décision du 9 mai 2019 que par sa décision du 25 octobre 2022 mentionnée ci-dessus, il s'assure, en particulier, que la proposition porte sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tend à autoriser la ratification d'un traité qui aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

6. En l'espèce, la proposition de loi soumise au Conseil constitutionnel comporte cinq articles. Son article 1er instaure une condition de durée minimale de résidence en France ou d'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle que doivent remplir les étrangers non ressortissants de l'Union européenne en situation régulière pour bénéficier de certaines prestations sociales. Son article 2 remplace l'aide médicale de l'État bénéficiant à certains étrangers en situation irrégulière par une aide médicale d'urgence. Son article 3 exclut les étrangers en situation irrégulière du bénéfice de la réduction tarifaire accordée pour certains titres de transport. Son article 4 prévoit que certains hébergements destinés aux demandeurs d'asile sont pris en compte au titre des obligations des communes tenant à la proportion de logements locatifs sociaux sur leur territoire. Son article 5 modifie les conditions auxquelles les demandeurs d'asile peuvent se maintenir dans un lieu d'hébergement ainsi que celles relatives à l'évacuation de ses occupants.

7. Au regard des modifications que cette proposition de loi apporte à certains dispositifs de prestations sociales, d'aide à la mobilité et d'hébergement susceptibles de bénéficier à des étrangers, elle porte, au sens de l'article 11 de la Constitution, sur une réforme relative à la politique sociale de la nation.

8. Par ailleurs, à la date d'enregistrement de la saisine, la proposition de loi n'avait pas pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. Aucune proposition de loi portant sur le même sujet n'avait été soumise au référendum depuis deux ans.

9. Toutefois, en dernier lieu, aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». En vertu de son onzième alinéa : « Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ». Les exigences constitutionnelles résultant des dispositions précitées impliquent la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées.

10. Si le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques, il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Ils doivent cependant être conciliés avec la sauvegarde de l'ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. En outre, les étrangers jouissent des droits à la protection sociale, dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français.

11. L'article 1er de la proposition de loi modifie les articles L. 300-1 et L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, l'article L. 512-2 du code de la Sécurité sociale ainsi que l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles afin de prévoir que les étrangers non ressortissants de l'Union européenne ne bénéficient du droit au logement, de l'aide personnelle au logement, des prestations familiales et de

l'allocation personnalisée d'autonomie que s'ils justifient d'une durée minimale de résidence stable et régulière en France ou d'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle en France.

12. Si les exigences constitutionnelles précitées ne s'opposent pas à ce que le bénéfice de certaines prestations sociales dont jouissent les étrangers en situation régulière sur le territoire français soit soumis à une condition de durée de résidence ou d'activité, cette durée ne saurait être telle qu'elle prive de garanties légales ces exigences.

13. En subordonnant le bénéfice de prestations sociales, dont certaines sont au demeurant susceptibles de présenter un caractère contributif, pour l'étranger en situation régulière non ressortissant de l'Union européenne, à une condition de résidence en France d'une durée d'au moins cinq ans ou d'affiliation au titre d'une activité professionnelle d'une durée d'au moins trente mois, les dispositions de l'article 1er portent une atteinte disproportionnée à ces exigences. Elles sont donc contraires à la Constitution.

14. Il résulte de ce qui précède, et sans que le Conseil constitutionnel n'ait à se prononcer sur la conformité à la Constitution de ses autres dispositions, que la proposition de loi ne remplit pas la condition prévue au 3 ° de l'article 45-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La proposition de loi visant à réformer l'accès aux prestations sociales des étrangers ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 11 de la Constitution et par l'article 45-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 avril 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 11 avril 2024.

JORF n°0086 du 12 avril 2024, texte n° 65
ECLI : FR : CC : 2024 : 2024.6.RIP

Le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre de la procédure de référendum d'initiative partagée, a rendu une décision importante le 11 avril 2024 relative à une proposition de loi concernant l'accès des étrangers aux prestations sociales. Ce contrôle s'inscrivait dans le cadre de l'article 11 de la Constitution, qui fixe les objets pouvant faire l'objet d'un référendum, et de l'article 45-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, qui encadre le rôle du Conseil en la matière.

Si la proposition respectait les conditions formelles et matérielles de recevabilité posées par ces textes, la haute juridiction a néanmoins jugé que certaines de ses dispositions, notamment l'article 1er, portaient une atteinte disproportionnée aux droits sociaux garantis par le Préambule de 1946. Cette décision illustre ainsi la tension entre, d'une part, la possibilité pour le législateur d'adopter des règles spécifiques concernant les étrangers et, d'autre part, l'exigence de respecter les droits fondamentaux à valeur constitutionnelle.

I. La recevabilité de la proposition de loi référendaire

A. Les conditions procédurales de dépôt et d'examen

- Le Conseil constitutionnel commence par rappeler **le cadre juridique applicable** (articles 11 de la Constitution et 45-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958). La proposition a bien été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale en application du troisième alinéa de l'article 11, et elle a été soutenue par au moins un cinquième des membres du Parlement. **Ces conditions formelles de recevabilité sont donc respectées**.

B. Le respect des conditions matérielles de l'article 11 de la Constitution

- Le Conseil vérifie ensuite que la proposition relève bien de l'un des objets autorisés par l'article 11. En l'espèce, elle porte sur une réforme relative à la politique sociale de la Nation, ce qui la rattache bien aux matières énumérées.

- En outre, elle ne constitue ni l'abrogation d'une loi promulguée depuis moins d'un an, ni la réitération d'une proposition déjà rejetée par référendum depuis moins de deux ans. **Ces conditions sont également respectées**.

II. Le contrôle de constitutionnalité de la proposition de loi

A. Le rappel des exigences constitutionnelles de solidarité nationale

- Le Conseil mobilise le Préambule de 1946, qui garantit à toute personne des droits fondamentaux : protection de la santé, sécurité matérielle et moyens convenables d'existence.

- Ces droits doivent bénéficier aux personnes résidant sur le territoire français, y compris les étrangers en situation régulière, sous réserve de la sauvegarde de l'ordre public.

B. La censure de l'atteinte disproportionnée aux droits sociaux des étrangers

- L'article 1er de la proposition subordonnait l'accès à plusieurs prestations sociales (logement, prestations familiales, allocation personnalisée d'autonomie, etc.) à une durée de résidence d'au moins cinq ans ou à une affiliation de trente mois.

- Pour le Conseil, une telle exigence prive de garanties légales les droits constitutionnels, en instaurant une restriction excessive à l'accès des étrangers réguliers aux droits sociaux. Cette atteinte disproportionnée conduit à la censure de la proposition**, qui ne satisfait donc pas aux conditions fixées par l'article 45-2 de l'ordonnance de 1958**.

En l'espèce, le Conseil constitutionnel a ainsi confirmé que, même lorsqu'une proposition de loi relève d'une réforme sociale susceptible d'être soumise à référendum, elle doit respecter les exigences constitutionnelles en matière de droits fondamentaux et de solidarité nationale. La censure de l'article 1er montre que le législateur ne peut subordonner l'accès aux prestations sociales des étrangers à des conditions de durée de résidence ou d'activité disproportionnées. Cette décision illustre la fonction essentielle du Conseil constitutionnel : concilier l'initiative parlementaire et populaire avec le respect des droits garantis par la Constitution, et protéger les individus, y compris les étrangers en situation régulière, contre des mesures qui porteraient atteinte à leur dignité et à leur protection sociale.

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2025

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 4 – La liberté d'expression

1. Dissertation
2. Argumentation
3. Commentaire de texte
4. Commentaire d'arrêt

1. Sujet – Dissertation

Peut-on tout dire librement ?

---

2. Sujet – Argumentation

Soutenez que l'on ne peut pas tout dire librement.

---

3. Sujet – Commentaire de texte

Article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Article 10 – Liberté d'expression
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

---

4. Sujet – Commentaire d'arrêt

CEDH, 3 juillet 2025, *Ludes c/ France*

1. Les requêtes concernent, sous l'angle de l'article 10 de la Convention, la condamnation pénale des requérants, militants écologistes, pour des faits de vols en réunion consistant dans le décrochage et la non-restitution du portrait du président de la République dans plusieurs mairies aux fins de dénoncer l'insuffisance des mesures mises en œuvre par l'État pour respecter ses engagements pris lors de la Conférence internationale sur le climat (COP21) et de lutter contre le dérèglement climatique.

(…)

4. Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par les parties, se présentent de la manière suivante.

5. Les requêtes s'inscrivent dans le cadre d'une action d'ampleur nationale intitulée « #DécrochonsMacron ». Cette action fut lancée en février 2019 par le mouvement citoyen « Action non-violente COP21 » (ANV-COP21), à la suite des déclarations du président de la République consécutives à l'introduction par des associations de défense de l'environnement de requêtes devant le tribunal administratif de Paris afin de voir reconnaître la carence de l'État français dans la lutte contre le changement climatique (voir, sur l'affaire dite « du siècle », *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse* ([GC], no 53600/20, §§ 236 à 253 et suivants, 9 avril 2024). Au jour de l'introduction des requêtes, environ 150 portraits du président de la République avaient été décrochés dans les mairies de France. Ces actions furent systématiquement photographiées et filmées en temps

réel, avec diffusion des photos et vidéos sur les réseaux sociaux ainsi qu'un message selon lequel le « vide symbolique » résultant du décrochage des portraits représentait le vide politique en matière de lutte contre le changement climatique. Il s'agissait, selon leurs auteurs, de « réquisitions temporaires » appelées à durer jusqu'à ce que des mesures soient prises par l'État en matière d'environnement.

6. Les requérantes et les requérants sont membres ou sympathisants du mouvement « ANV-COP21 » qui se présente, comme « un mouvement de citoyennes et de citoyens qui ne se résignent pas face au dérèglement climatique et aux injustices sociales qu'il engendre » ayant fait le choix, pour traiter de cet « enjeu majeur », d'une stratégie non-violente susceptible d'aller jusqu'à la « désobéissance civile ». Ils participèrent à des actions de décrochage qui ont donné lieu à des enquêtes de police comprenant des mesures de perquisition à leur domicile, de saisies de leur téléphone et matériel informatique ainsi que de prélèvements d'empreintes génétiques. Ils furent tous par la suite condamnés pour vol en réunion.

(…)

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

61. Les requérants soutiennent que leurs condamnations pour vol en réunion constituent une ingérence disproportionnée dans l'exercice de leur droit à la liberté d'expression protégé par l'article 10 de la Convention, aux termes duquel :

« *1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)*

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »

2. Appréciation de la Cour

87. À titre liminaire, la Cour rappelle que la protection offerte par l'article 10 de la Convention ne se limite pas aux paroles ou écrits, les idées ou les opinions d'une personne pouvant s'exprimer au travers de conduites ou de comportements (…).

88. Dans la présente affaire, la Cour considère, à l'instar des parties, et comme l'ont expressément reconnu les juridictions internes, que la soustraction du portrait du président de la République par les requérants s'inscrivait dans le cadre d'une démarche politique et militante relevant de la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention (*a contrario*, *Kotlyar c. Russie*, nos 38825/16 et 2 autres, §§ 39 à 44, 12 juillet 2022). Elle note que les requérants ont délibérément commis une infraction de droit commun en vue d'exprimer leurs opinions et convictions en matière de lutte contre le changement climatique.

89. À cet égard, la Cour relève qu'il ressort des pièces des dossiers que les actions litigieuses visaient à dénoncer l'inaction alléguée de l'État face au dérèglement climatique et à attirer l'attention du public sur la nécessité de changements face à la réalité du réchauffement climatique. Elle souligne qu'elles ont été conduites sans violence ouvertement en présence de journalistes, et relayées par la diffusion de tracts, la publication de communiqués de presse ou de messages sur les réseaux sociaux, le cas échéant, après la commission de l'infraction (dans l'affaire *Chancelier et autres*).

90. La Cour en conclut que les condamnations des requérants pour vol en réunion ont constitué une ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté d'expression protégé par l'article 10 § 1 de la Convention. Pareille ingérence méconnait cette disposition sauf si « prévue par la loi », elle poursuit un ou des « buts légitimes » au regard du second paragraphe de cette disposition et si elle « est « nécessaire dans un société démocratique » pour les atteindre.

a) « Prévue par la loi »

91. La Cour relève que les requérants ne contestent pas que les ingérences avaient pour base légale les articles 311-1 et 311-4-1 du code pénal. Relevant que les ingérences litigieuses résultent de sanctions pénales réprimant

les infractions de vol, elle considère qu'elles doivent être regardées comme « prévues par la loi » au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.

b) « But légitime »

92. La Cour considère que l'ingérence litigieuse poursuivait l'un au moins des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l'article 10, à savoir la « défense de l'ordre et de la prévention du crime ».

c) « Nécessaire dans une société démocratique »

i. Principes généraux

93. Les principes généraux à suivre pour déterminer si une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression est « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l'article 10 § 2 de la Convention, sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour. Ils ont été notamment rappelés dans l'arrêt *Sanchez c. France* [GC], no 45581/15, § 145, 15 mai 2023) :

« i. La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...)

ii. L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10.

iii. La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...) »

94. Pour évaluer la pertinence et la suffisance des conclusions retenues par les juridictions nationales, la Cour, conformément au principe de subsidiarité, prend en considération la manière dont ces dernières ont effectué la mise en balance des intérêts contradictoires en jeu à la lumière de sa jurisprudence bien établie en la matière (voir *Erla Hlynsdottir c. Islande (no 2)*, no 54125/10, § 54, 21 octobre 2014, et *Ergündoğan c. Turquie*, no 48979/10, § 24, 17 avril 2018). La Cour rappelle que la qualité de l'examen judiciaire de la nécessité de la mesure revêt une importance particulière dans le contexte de l'évaluation de proportionnalité sous l'angle de l'article 10 de la Convention (voir *Animal Defenders International c. Royaume-Uni* [GC], no 48876/08, § 108, CEDH 2013 (extraits)). Ainsi, l'absence d'un contrôle juridictionnel effectif de la mesure litigieuse peut justifier un constat de violation de l'article 10 (*Matúz c. Hongrie*, no 73571/10, § 35, 21 octobre 2014, *Ergündoğan*, précité, *ibidem*).

95. Enfin, la Cour souligne que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence. À cet égard, elle a maintes fois eu l'occasion de souligner, dans le contexte des affaires relatives à l'article 10 de la Convention, que le prononcé d'une condamnation pénale constituait l'une des formes les plus graves d'ingérence dans le droit à la liberté d'expression. Les instances nationales doivent faire preuve de retenue dans l'usage de la voie pénale, tout spécialement s'agissant du prononcé d'une peine d'emprisonnement qui revêt un effet particulièrement dissuasif quant à l'exercice de la liberté d'expression (*Mariya Alekhina et autres*, précité, § 227, *Bouton*, précité, §§ 46 et 53). Le caractère relativement modéré d'une amende ne suffit pas, à lui-seul, à faire disparaître le risque d'un effet dissuasif sur l'exercice de la liberté d'expression (*Mor c. France*, no 28198/09, § 61, 15 décembre 2011, avec les références qui y sont citées).

96. S'agissant plus particulièrement de la protection du débat politique, la Cour rappelle que l'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique. Il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique et la

Cour accorde la plus grande importance à la liberté dans le contexte du débat politique. Il en résulte que la marge d'appréciation dont disposent les autorités pour juger de la « nécessité » d'une mesure litigieuse dans ce contexte est donc « particulièrement restreinte » (*Sanchez c. France*, précité § 146 et les références citées, *Glukhin*, précité, § 51).

97. À cet égard, la protection de l'environnement constitue un sujet d'intérêt général (*Mamère c. France*, no 12697/03, § 20, CEDH 2006-XIII, *Association Burestop 55 et autres c. France*, nos 56176/18 et 5 autres, § 87, 1er juillet 2021, *Bumbeș*, précité, § 92) qui bénéficie en principe d'un niveau élevé de protection (*Mamère*, précité, § 20, *Animal Defenders International c. Royaume-Uni* [GC], no 48876/08, § 102, CEDH 2013 (extraits)). Ainsi, la Cour a déclaré, dans l'Avis consultatif « P16-2021-002 », que :
« (...) La protection de l'environnement, au sens large, et, dans ce cadre, la protection, plus spécifique, de la nature et des forêts, des espèces menacées, des ressources biologiques, du patrimoine ou de la santé publique, comptent (...) parmi les objectifs considérés, à ce jour, comme relevant de l'« intérêt général » au titre de la Convention. (...) même si aucune disposition de la Convention n'est spécialement destinée à assurer une protection générale de l'environnement en tant que tel (...), la responsabilité des pouvoirs publics en la matière devrait se concrétiser par leur intervention au moment opportun, afin de ne pas priver de tout effet utile les dispositions protectrices de l'environnement qu'ils ont décidé de mettre en œuvre (...) » (*Avis consultatif relatif à la différence de traitement entre les associations de propriétaires « ayant une existence reconnue à la date de la création d'une association communale de chasse agrée » et les associations de propriétaires créées ultérieurement, § 80, 13 juillet 2022*). »
98. En particulier, la Cour a jugé que la question du changement climatique constitue « l'une des plus préoccupantes de notre époque » (*Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres*, précité, § 410).

ii. Application en l'espèce

99. La Cour relève en premier lieu que la condamnation des requérants est fondée sur la caractérisation du délit de vol, avec la circonstance aggravante qu'il a été commis en réunion.

100. En deuxième lieu, la Cour souligne, comme elle l'a dit plus haut, que l'action de décrochage et de soustraction des portraits du président de la République, dans la ligne des positions du mouvement ANV-COP21 et à l'occasion d'une mobilisation nationale pour le climat à laquelle ce dernier, entre autres, avait appelé, s'inscrivait dans une démarche politique et militante. Cette démarche visait la commission délibérée d'infractions de droit commun à éveiller l'opinion et à sensibiliser la population sur les conséquences néfastes du dérèglement climatique, à dénoncer les carences alléguées de l'action de l'État en la matière et à inciter les pouvoirs publics à adopter des mesures nouvelles.

101. Il s'ensuit qu'alors même qu'elle a été exercée au moyen de la commission d'une infraction pénale, eu égard tant à l'objet du message qui relevait d'un sujet d'intérêt général (*mutatis mutandis*, *Bouton*, précité, § 49) qu'au caractère non violent des actions le véhiculant, la liberté d'expression des requérants devait bénéficier d'un niveau suffisant de protection allant de pair avec une marge d'appréciation des autorités nationales restreinte.

(…)

105. En l'espèce, la Cour relève tout d'abord qu'afin d'apprécier la nécessité de l'ingérence dans la liberté d'expression des requérants et de déterminer si leur comportement justifiait une sanction pénale, les juridictions internes se sont référées, ainsi que cela ressort des motifs de leurs décisions, à certains principes dégagés dans sa jurisprudence relative à l'article 10 de la Convention. En particulier, la Cour de cassation, dans ses trois arrêts du 18 mai 2022, a rappelé sa jurisprudence bien établie selon laquelle l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause avant de préciser qu'il appartient au juge, après s'être assuré, dans l'affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la condamnation au terme d'un examen d'ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé.

106. La Cour doit, ensuite, vérifier si, dans le cadre du contrôle qu'ils devaient opérer au titre du paragraphe 2 de l'article 10, les juges internes ont dûment effectué la mise en balance entre, d'une part, le droit des requérants

de communiquer au public, au moyen des actions litigieuses, leurs idées sur la lutte contre le dérèglement climatique, et, d'autre part, la défense de l'ordre et la prévention du crime.

107. À cet égard, la Cour constate que les tribunaux correctionnels de Strasbourg et de Valence ont prononcé la relaxe des requérants au nom de la défense de leur liberté d'expression tandis que celui de Paris les a déclarés coupables de vol en réunion en rejetant leur argumentation fondée sur l'état de nécessité en droit pénal. Elle note ensuite que les cours d'appels de Colmar, de Paris et de Grenoble, pour entrer en voie de condamnation, ont retenu des motivations variées mais toutes fondées sur la réunion des éléments matériel et intentionnel de l'infraction de vol en réunion, peu important la valeur marchande du portrait, l'absence de restitution de celui-ci, ainsi que, pour celles qui ont reconnu le dessein politique et militant de l'action litigieuse, l'absence de disproportion des poursuites engagées du fait des éléments qui viennent d'être cités.

108. La Cour note que, tout en reconnaissant le caractère militant de l'action des requérants, marquée notamment par son expression collective, publique et pacifique, les cours d'appel, dont les solutions n'ont pas été remises en cause par la Cour de cassation, se sont fondées pour entrer en voie de condamnation, d'une part, sur la commission du vol du portrait du président de la République en réunion et l'absence de restitution de celui-ci, et d'autre part, sur l'atteinte portée à un bien « dans un lieu public qui a une valeur symbolique ». Elles ont ainsi invoqué « la circonstance de réunion [...] constituée sur le plan matériel, les faits ayant été commis par plusieurs personnes dont les prévenus » ou la circonstance que « les faits ne sont pas seulement constitutifs d'un décrochage irrégulier du portrait présidentiel mais de la soustraction frauduleuse de ce portrait constituant le délit de vol avec la circonstance aggravante de réunion » (paragraphes 13 et 27 ci-dessus). Elles ont par ailleurs pris en compte le refus de restituer les portraits, « malgré une demande du maire » qui aurait permis « aux prévenus [d'être] épargnés sinon des poursuites pénales du moins (...) une opération de perquisition à domicile », étant observé qu'il était encore possible de le restituer après la manifestation du 25 août 2019 » (paragraphe 15 ci-dessus), ce qui a pu « créée[r] une incertitude quant à la portée de leur action, laquelle ne peut s'analyser comme tendant à seulement provoquer ou stimuler le débat d'intérêt général dans une société démocratique ».

109. Dans ses trois arrêts du 18 mai 2022, la Cour de cassation a confirmé les condamnations prononcées en appel après avoir relevé qu'elle était en mesure de s'assurer que, bien que l'action menée par les prévenus se soit inscrite dans le cadre d'une démarche militante et puisse être considérée comme une expression au sens de l'article 10 précité, ces condamnations n'étaient pas disproportionnées au regard de la valeur symbolique du portrait du Président de la République et du refus de le restituer tant que leurs revendications ne seraient pas satisfaites, ainsi que de la circonstance que le vol a été commis en réunion.

110. De l'ensemble des considérations qui précèdent, la Cour en déduit que le contrôle des juridictions internes a été effectué au moyen d'une analyse de l'ensemble des éléments en litige portant sur le contexte dans lequel se situaient les actions litigieuses ainsi que sur les mobiles des requérants.

111. Certes, la prise en compte de la circonstance que les vols ont été commis en réunion, pertinente pour l'application du droit pénal interne fait fi de la portée, au regard de l'article 10 de la Convention, du mode d'expression collectif utilisé par les requérants pour livrer leur message dans le cadre d'une action concertée.

112. S'agissant de la prise en considération de la « valeur symbolique du portrait » du président de la République, la Cour souligne qu'elle est au fondement de la démarche militante des requérants qui s'en sont précisément pris à ce symbole, sans porter aucune attaque personnelle contre la personne du Président de la République, pour dénoncer et protester contre l'inaction, selon eux, de l'État en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Le tract laissé par les requérants de la requête no 40899/22 à la place du portrait, expliquait ainsi que : « le vide laissé au mur symbolise l'inaction du gouvernement en matière sociale et climatique » (paragraphe 7 ci-dessus). La Cour considère que les juridictions internes ont pu valablement tenir compte de la portée symbolique des actions litigieuses à la fois pour établir l'existence d'un lien entre les actes incriminés et l'exercice par les requérants de leur liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général et pour apprécier la réelle portée des décrochages commis, au-delà de la faible valeur matérielle des biens soustraits. La Cour note au demeurant que, dans une décision postérieure à celles des espèces, une telle prise en compte de la « valeur symbolique du portrait » décroché, parmi les différents critères dégagés par sa jurisprudence, a conduit la Cour de cassation à adopter une solution différente confirmant la relaxe des prévenus.

113. En ce qui concerne la non-restitution des tableaux décrochés, la Cour note que les requérants, dans les requêtes nos 40899/22 et 42956/22, avaient expressément qualifié leur action de réquisition temporaire à laquelle ils ne mettraient fin que lorsque leurs revendications seraient satisfaites. Elle relève que les juridictions internes ont considéré que la conservation des tableaux, après leur décrochage, était de nature à rendre ambigüe la portée de l'action des requérants et à semer un doute sur le caractère réversible ou non du dommage causé. La Cour considère qu'en distinguant, ce faisant, entre, d'une part, le décrochage des portraits qui suffisait par lui-même à la claire expression du message porté par les requérants et qui n'aurait pu à lui seul faire l'objet d'une sanction pénale sans méconnaître les exigences attachées au respect de l'article 10, et, d'autre part, l'appropriation ultérieure des tableaux constitutive du délit de vol, les juridictions internes ont retenu, pour fonder la condamnation des requérants, des motifs qui apparaissent, dans les circonstances spécifiques des présentes affaires, à la fois « pertinents » et « suffisants ».

114. Par ailleurs, la Cour relève qu'en dénonçant l'effet dissuasif des actes effectués à la suite des poursuites engagées à leur encontre tels les auditions, perquisitions ou relevés d'empreinte, les requérants l'invitent à étendre le bénéfice de la protection attachée à l'article 10 de la Convention au point que la liberté d'expression devrait être regardée comme faisant obstacle dans les circonstances de l'espèce à l'incrimination de vol ou à tout le moins à l'engagement des poursuites de ce chef et à la réalisation des actes subséquents.

115. S'il est vrai que la nécessité d'une ingérence dans la liberté d'expression doit en principe s'apprécier au regard de l'ensemble des conséquences attachées à l'incrimination pénale, la Cour constate que la démarche militante des requérants s'est fondée sur la commission délibérée d'une infraction de droit commun et que, dès lors, les mesures de poursuite et d'enquête dénoncées doivent être regardées, dans les présentes affaires, non comme revêtant un effet dissuasif à l'expression de leur message mais au contraire comme faisant partie intégrante de leur stratégie de communication.

116. Dans ces conditions, après avoir relevé le soin mis par les juridictions internes à évaluer la proportionnalité sous l'angle de l'article 10 de la Convention et noté l'évolution postérieure de la jurisprudence de la Cour de cassation, la Cour ne voit pas de raison sérieuse de se départir de leur appréciation, dans les circonstances des espèces, qui n'apparaît ni arbitraire ni manifestement déraisonnable.

117. En cinquième lieu, il reste à la Cour à prendre en considération la nature et la lourdeur des peines infligées afin de mesurer la proportionnalité des atteintes portées au droit à la liberté d'expression des requérants. Elle rappelle que, dans les présentes affaires, les requérants n'ont pas été condamnés à des peines privatives de liberté (*a contrario*, *Rouillan c. France*, no 28000/19, § 75, 23 juin 2022) mais à des amendes respectivement de 200, 400 et 500 EUR avec sursis. Pour ce faire, les juges internes ont pris en considération le contexte de l'infraction ainsi que le mobile des requérants qui avaient agi dans un cadre politique et militant en dehors de tout intérêt personnel et financier (paragraphes 15, 26 et 35 ci-dessus).

118. Tout en rappelant que les instances nationales doivent faire preuve de retenue dans l'usage de la voie pénale lorsque la liberté d'expression est en jeu, la Cour considère que les juridictions internes ont fait le choix de peines particulièrement modérées, guidé par le souci de prendre en considération la nature et le contexte des agissements en cause. Tenant compte à la fois du faible montant des amendes prononcées et du sursis dont ces peines furent assorties, la Cour est d'avis que les condamnations prononcées à l'encontre des requérants, qui sont au nombre des sanctions les plus modérées possible, n'étaient pas disproportionnées au regard du but légitime poursuivi.

(…)
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
(…) Dit, par cinq voix contre deux, qu'il y n'a pas eu violation de l'article 10 de la Convention.

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2025

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 4 – La liberté d'expression

1. Dissertation
2. Argumentation
3. Commentaire de texte
4. Commentaire d'arrêt

1. Sujet – Dissertation

Peut-on tout dire librement ?

Présentation du sujet :

- Définition liberté d'expression : pouvoir communiquer ses opinions, quelle que soit la forme (écrite, orale, artistique…)
- Composantes de la liberté d'expression : dimension personnelle ; dimension sociale
- Consécration constitutionnelle : article 11 DDHC ; CC, 11 octobre 1984, *Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse* : la liberté d'expression est « *une liberté fondamentale, d'autant plus précieuse que son exercice est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés de la souveraineté nationale* »
- Consécration conventionnelle : article 10 CEDH ; article 11 de la Charte des Droits fondamentaux de l'UE
- Toutefois, la liberté d'expression n'est pas sans limites : elle doit être conciliée avec l'ordre public et l'exercices d'autres libertés fondamentales

I. La liberté d'expression, principe fondamental dans une démocratie

A. Les fondements textuels de la liberté d'expression

- Articles 10 & 11 DDHC
- Article 4 de la Constitution de 1958 (depuis la révision constitutionnelle de 2008)
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
- Article 10 CEDH
- Article 11 Charte européenne des droits fondamentaux

B. La garantie juridictionnelle de la liberté d'expression

- Conseil constitutionnel : de la liberté d'expression découlent d'autres libertés : liberté de communication, droit d'expression collective des idées et des opinions, pluralisme des courants de pensée et d'opinion, pluralisme et indépendance des médias
- Conseil d'État : la liberté d'expression est une liberté fondamentale au sens du référé-liberté
- CEDH : conception extensive de la liberté d'expression : droit d'accès à l'information, droit de s'exprimer par d'autres moyens que par la parole

II. La liberté d'expression, liberté limitée pour protéger la société

Nombreux exemples de limitation ou sanction de la liberté d'expression, au nom de la protection de l'ordre public ou des droits des tiers

A. Les limites à la liberté d'expression pour protéger l'ordre public

- Provocation aux crimes et délits : Loi 29 juillet 1881 (articles 23 et 24)
- Livraison d'informations à une puissance étrangère (articles L. 411-6 à 411-8 du code pénal)
- Manipulation de l'information : prohibition de la publication de fausses nouvelles ou pièces ayant susceptible de troubler la paix publique (article 27 loi du 29 juillet 1881) ; lutte contre la manipulation de l'information (loi du 22 décembre 2018)
- Secret de l'instruction : (article 38 loi du 29 juillet 1881)

B. Les limites à la liberté d'expression pour protéger les droits des tiers

- Protection de la vie privée : article 8 CEDH ; article 9 code civil
- Protection de l'honneur et de la réputation : sanction de la diffamation et de l'injure (article 29 loi du 29 juillet 1881)
- Droits d'auteur et protection intellectuelle

---

2. Sujet – Argumentation

Soutenez que l'on ne peut pas tout dire librement.

Présentation du sujet :

- Définition liberté d'expression : pouvoir communiquer ses opinions, quelle que soit la forme (écrite, orale, artistique…)
- Composantes de la liberté d'expression : dimension personnelle ; dimension sociale
- Consécration constitutionnelle : article 11 DDHC ; CC, 11 octobre 1984, *Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse* : la liberté d'expression est « *une liberté fondamentale, d'autant plus précieuse que son exercice est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés de la souveraineté nationale* »
- Consécration conventionnelle : article 10 CEDH ; article 11 de la Charte des Droits fondamentaux de l'UE
- Toutefois, la liberté d'expression n'est pas sans limites : l'article 10 CEDH prévoit, en son paragraphe 2, les limites à la liberté d'expression ; l'article 11 de la DDHC prévoit la compétence du législateur pour sanctionner les abus
- Comment justifier les limites à la liberté d'expression, alors qu'il s'agit d'une liberté essentielle dans une démocratie ?
- En réponse à l'énoncé : on ne peut pas tout dire, mais ce que l'on ne peut pas dire est très limité/encadré

I. Les limites à la liberté d'expression strictement encadrées

A. Une liberté fondamentale mais encadrée par les textes qui la consacrent

- Particularité de la liberté d'expression : les textes qui la consacrent mentionnent aussi les limites possibles
- Compétence du législateur pour limiter la liberté d'expression (article 34 Constitution)
- Régime de limitation à la liberté d'expression largement répressif (donc le moins attentatoire aux libertés) : article 1er loi du 29 juillet 1881
- Mais des régimes préventifs perdurent : publications destinées à la jeunesse (loi 16 juillet 1949) ; visa d'exploitation cinématographique (article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée)

B. Un contrôle de proportionnalité de l'atteinte ou de la sanction

- CEDH, 26 novembre 1991, *Sunday Times c/ Royaume-Uni* : l'atteinte à la liberté d'expression doit correspondre à un besoin social impérieux, elle doit être proportionnée au but légitime poursuivi, et les motifs fournis par les autorités nationales doivent être pertinents et suffisants
- CC, 10 juin 2009, *Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet* : il appartient au juge de contrôler que les mesures portant atteinte à la liberté d'expression sont strictement nécessaires

II. La liberté d'expression, liberté limitée pour protéger la société

A. Les limites à la liberté d'expression pour protéger l'ordre public

- Provocation aux crimes et délits : Loi 29 juillet 1881 (articles 23 et 24)
- Livraison d'informations à une puissance étrangère (articles L. 411-6 à 411-8 du code pénal)
- Manipulation de l'information : prohibition de la publication de fausses nouvelles ou pièces ayant susceptible de troubler la paix publique (article 27 loi du 29 juillet 1881) ; lutte contre la manipulation de l'information (loi du 22 décembre 2018)
- Secret de l'instruction : (article 38 loi du 29 juillet 1881)

B. Les limites à la liberté d'expression pour protéger les droits des tiers

- Protection de la vie privée : article 8 CEDH ; article 9 code civil
- Protection de l'honneur et de la réputation : sanction de la diffamation et de l'injure (article 29 loi du 29 juillet 1881)
- Droits d'auteur et protection intellectuelle

---

3. Sujet – Commentaire de texte

Article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Article 10 – Liberté d'expression
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

Présentation du sujet :

- Définition liberté d'expression : pouvoir communiquer ses opinions, quelle que soit la forme (écrite, orale, artistique…)
- Liberté qui constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique (CEDH, 7 décembre 1976, *Handyside c/ Royaume-Uni*)
- Liberté d'expression inclut la liberté d'informer et de recevoir des informations
- Liberté à la fois individuelle et sociale, sert de fondement à d'autres libertés : pensée, presse, manifestation…
- Comme toute liberté, elle peut être restreinte pour des motifs d'ordre public ou pour préserver les droits des tiers, mais toujours sous le contrôle du juge

I. La liberté d'expression, liberté fondamentale à large portée

A. Les composantes de la liberté d'expression

- Liberté d'expression vaut pour les informations et idées inoffensives mais aussi pour celles qui heurtent ou choquent (CEDH, 7 décembre 1976, *Handyside c/ Royaume-Uni*)
- Liberté d'expression englobe des formes diverses : symbole sur un vêtement (CEDH, 8 juillet 2008, *Vajnai c/ Hongrie*), appel au boycott (CEDH, 11 juin 2020, *Baldassi c/ France*), performance artistique (CEDH, 17 juillet 2018, *Mariya Alekhina et autres c. Russie*) ou militante (CEDH, 13 octobre 2022, *Bouton c/ France*)
- Liberté d'information : inclut toute forme d'information, y compris de nature commerciale ou publicitaire (CEDH, 5 mars 2009, *Hachette Filipacchi Presse c/ France*)
- Article 10 instaure une double obligation pour les États : doivent s'abstenir de toute ingérence, mais aussi prendre des mesures positives de protection (CEDH, 16 mars 2000, *Ozgur Gundem c/ Turquie*)

B. Les bénéficiaires de la liberté d'expression

- La liberté d'expression est garantie à « toute personne », physique ou morale (CEDH, 22 mai 1990, *Autronic AG c/ Suisse*)
- Certaines personnes bénéficient d'une liberté d'expression élargie dans le cadre de leurs fonctions :
    - Parlementaires : bénéficient d'une immunité juridictionnelle au sein de leur assemblée
    - Avocats dans le prétoire
    - Professeurs d'université
- Les agents publics bénéficient aussi de la liberté d'expression, même si les États peuvent leur imposer une obligation de réserve (CEDH, 14 mars 2002, *De Diego Nafria c/ Espagne*)

II. La liberté d'expression, une liberté soumise à des restrictions

A. Les conditions pour restreindre la liberté d'expression

- Les atteintes à la liberté d'expression doivent s'interpréter de manière restreinte (CEDH, 7 décembre 1976, *Handyside c/ Royaume-Uni*)
- Les limites doivent être prévues par une loi
- L'adjectif « nécessaire » prévu par le § 2 de l'article renvoie à un besoin social impérieux
- S'agissant de la presse, les restrictions préalables doivent s'inscrire dans un cadre légal particulièrement strict quant à la délimitation de l'interdiction et efficace quant au contrôle juridictionnel contre les abus éventuels (CEDH, 29 mars 2011, *RTBF c/ Belgique*)

B. Les motifs justifiant une restriction à la liberté d'expression

- Protection de l'ordre public
- Droits d'autrui : liberté d'expression doit être combinée avec les autres droits garantis par la convention tels que le droit à la vie privée (CEDH, 23 juillet 2009, Hachette Filipacchi c/ France), la liberté de religion (CEDH, 13 septembre 2005, *I. A. c/ Turquie*) ou le droit à un procès équitable (CEDH, 29 août 1997, *Worm c/ Autriche*)
- Confidentialité de certaines informations (CEDH, 10 décembre 2007, *Stoll c/ Suisse*)
- Lanceurs d'alerte (CEDH, 12 décembre 2008, *Guja c/ Moldavie*)

4. Sujet – Commentaire d'arrêt

CEDH, 3 juillet 2025, *Ludes c/ France*

1. Les requêtes concernent, sous l'angle de l'article 10 de la Convention, la condamnation pénale des requérants, militants écologistes, pour des faits de vols en réunion consistant dans le décrochage et la non-restitution du portrait du président de la République dans plusieurs mairies aux fins de dénoncer l'insuffisance des mesures mises en œuvre par l'État pour respecter ses engagements pris lors de la Conférence internationale sur le climat (COP21) et de lutter contre le dérèglement climatique.

(…)

4. Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par les parties, se présentent de la manière suivante.

5. Les requêtes s'inscrivent dans le cadre d'une action d'ampleur nationale intitulée « #DécrochonsMacron ». Cette action fut lancée en février 2019 par le mouvement citoyen « Action non-violente COP21 » (ANV-COP21), à la suite des déclarations du président de la République consécutives à l'introduction par des associations de défense de l'environnement de requêtes devant le tribunal administratif de Paris afin de voir reconnaître la carence de l'État français dans la lutte contre le changement climatique (voir, sur l'affaire dite « du siècle », *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse* ([GC], no 53600/20, §§ 236 à 253 et suivants, 9 avril 2024). Au jour de l'introduction des requêtes, environ 150 portraits du président de la République avaient été décrochés dans les mairies de France. Ces actions furent systématiquement photographiées et filmées en temps réel, avec diffusion des photos et vidéos sur les réseaux sociaux ainsi qu'un message selon lequel le « vide symbolique » résultant du décrochage des portraits représentait le vide politique en matière de lutte contre le changement climatique. Il s'agissait, selon leurs auteurs, de « réquisitions temporaires » appelées à durer jusqu'à ce que des mesures soient prises par l'État en matière d'environnement.

6. Les requérantes et les requérants sont membres ou sympathisants du mouvement « ANV-COP21 » qui se présente, comme « un mouvement de citoyennes et de citoyens qui ne se résignent pas face au dérèglement climatique et aux injustices sociales qu'il engendre » ayant fait le choix, pour traiter de cet « enjeu majeur », d'une stratégie non-violente susceptible d'aller jusqu'à la « désobéissance civile ». Ils participèrent à des actions de décrochage qui ont donné lieu à des enquêtes de police comprenant des mesures de perquisition à leur domicile, de saisies de leur téléphone et matériel informatique ainsi que de prélèvements d'empreintes génétiques. Ils furent tous par la suite condamnés pour vol en réunion.

(…)

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

61. Les requérants soutiennent que leurs condamnations pour vol en réunion constituent une ingérence disproportionnée dans l'exercice de leur droit à la liberté d'expression protégé par l'article 10 de la Convention, aux termes duquel :

« *1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)*

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »

2. Appréciation de la Cour

87. À titre liminaire, la Cour rappelle que la protection offerte par l'article 10 de la Convention ne se limite pas aux paroles ou écrits, les idées ou les opinions d'une personne pouvant s'exprimer au travers de conduites ou de comportements (…).

88. Dans la présente affaire, la Cour considère, à l'instar des parties, et comme l'ont expressément reconnu les juridictions internes, que la soustraction du portrait du président de la République par les requérants s'inscrivait dans le cadre d'une démarche politique et militante relevant de la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention (*a contrario*, *Kotlyar c. Russie*, nos 38825/16 et 2 autres, §§ 39 à 44, 12 juillet 2022). Elle note que les requérants ont délibérément commis une infraction de droit commun en vue d'exprimer leurs opinions et convictions en matière de lutte contre le changement climatique.

89. À cet égard, la Cour relève qu'il ressort des pièces des dossiers que les actions litigieuses visaient à dénoncer l'inaction alléguée de l'État face au dérèglement climatique et à attirer l'attention du public sur la nécessité de changements face à la réalité du réchauffement climatique. Elle souligne qu'elles ont été conduites sans violence ouvertement en présence de journalistes, et relayées par la diffusion de tracts, la publication de communiqués de presse ou de messages sur les réseaux sociaux, le cas échéant, après la commission de l'infraction (dans l'affaire *Chancelier et autres*).

90. La Cour en conclut que les condamnations des requérants pour vol en réunion ont constitué une ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté d'expression protégé par l'article 10 § 1 de la Convention. Pareille ingérence méconnait cette disposition sauf si « prévue par la loi », elle poursuit un ou des « buts légitimes » au regard du second paragraphe de cette disposition et si elle « est « nécessaire dans un société démocratique » pour les atteindre.

a) « Prévue par la loi »

91. La Cour relève que les requérants ne contestent pas que les ingérences avaient pour base légale les articles 311-1 et 311-4-1 du code pénal. Relevant que les ingérences litigieuses résultent de sanctions pénales réprimant les infractions de vol, elle considère qu'elles doivent être regardées comme « prévues par la loi » au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.

b) « But légitime »

92. La Cour considère que l'ingérence litigieuse poursuivait l'un au moins des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l'article 10, à savoir la « défense de l'ordre et de la prévention du crime ».

c) « Nécessaire dans une société démocratique »

i. Principes généraux

93. Les principes généraux à suivre pour déterminer si une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression est « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l'article 10 § 2 de la Convention, sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour. Ils ont été notamment rappelés dans l'arrêt *Sanchez c. France* [GC], no 45581/15, § 145, 15 mai 2023) :

« i. La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...)

ii. L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10.

iii. La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...) »

94. Pour évaluer la pertinence et la suffisance des conclusions retenues par les juridictions nationales, la Cour, conformément au principe de subsidiarité, prend en considération la manière dont ces dernières ont effectué la mise en balance des intérêts contradictoires en jeu à la lumière de sa jurisprudence bien établie en la matière

(voir *Erla Hlynsdottir c. Islande (no 2)*, no 54125/10, § 54, 21 octobre 2014, et *Ergündoğan c. Turquie*, no 48979/10, § 24, 17 avril 2018). La Cour rappelle que la qualité de l'examen judiciaire de la nécessité de la mesure revêt une importance particulière dans le contexte de l'évaluation de proportionnalité sous l'angle de l'article 10 de la Convention (voir *Animal Defenders International c. Royaume-Uni* [GC], no 48876/08, § 108, CEDH 2013 (extraits)). Ainsi, l'absence d'un contrôle juridictionnel effectif de la mesure litigieuse peut justifier un constat de violation de l'article 10 (*Matúz c. Hongrie*, no 73571/10, § 35, 21 octobre 2014, *Ergündoğan*, précité, *ibidem*).

95. Enfin, la Cour souligne que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence. À cet égard, elle a maintes fois eu l'occasion de souligner, dans le contexte des affaires relatives à l'article 10 de la Convention, que le prononcé d'une condamnation pénale constituait l'une des formes les plus graves d'ingérence dans le droit à la liberté d'expression. Les instances nationales doivent faire preuve de retenue dans l'usage de la voie pénale, tout spécialement s'agissant du prononcé d'une peine d'emprisonnement qui revêt un effet particulièrement dissuasif quant à l'exercice de la liberté d'expression (*Mariya Alekhina et autres*, précité, § 227, *Bouton*, précité, §§ 46 et 53). Le caractère relativement modéré d'une amende ne suffit pas, à lui-seul, à faire disparaître le risque d'un effet dissuasif sur l'exercice de la liberté d'expression (*Mor c. France*, no 28198/09, § 61, 15 décembre 2011, avec les références qui y sont citées).

96. S'agissant plus particulièrement de la protection du débat politique, la Cour rappelle que l'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique. Il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique et la Cour accorde la plus grande importance à la liberté dans le contexte du débat politique. Il en résulte que la marge d'appréciation dont disposent les autorités pour juger de la « nécessité » d'une mesure litigieuse dans ce contexte est donc « particulièrement restreinte » (*Sanchez c. France*, précité § 146 et les références citées, *Glukhin*, précité, § 51).

97. À cet égard, la protection de l'environnement constitue un sujet d'intérêt général (*Mamère c. France*, no 12697/03, § 20, CEDH 2006-XIII, *Association Burestop 55 et autres c. France*, nos 56176/18 et 5 autres, § 87, 1er juillet 2021, *Bumbeș*, précité, § 92) qui bénéficie en principe d'un niveau élevé de protection (*Mamère*, précité, § 20, *Animal Defenders International c. Royaume-Uni* [GC], no 48876/08, § 102, CEDH 2013 (extraits)). Ainsi, la Cour a déclaré, dans l'Avis consultatif « P16-2021-002 », que :
« (...) La protection de l'environnement, au sens large, et, dans ce cadre, la protection, plus spécifique, de la nature et des forêts, des espèces menacées, des ressources biologiques, du patrimoine ou de la santé publique, comptent (...) parmi les objectifs considérés, à ce jour, comme relevant de l'« intérêt général » au titre de la Convention. (...) même si aucune disposition de la Convention n'est spécialement destinée à assurer une protection générale de l'environnement en tant que tel (...), la responsabilité des pouvoirs publics en la matière devrait se concrétiser par leur intervention au moment opportun, afin de ne pas priver de tout effet utile les dispositions protectrices de l'environnement qu'ils ont décidé de mettre en œuvre (...) » (*Avis consultatif relatif à la différence de traitement entre les associations de propriétaires « ayant une existence reconnue à la date de la création d'une association communale de chasse agrée » et les associations de propriétaires créées ultérieurement, § 80, 13 juillet 2022*). »
98. En particulier, la Cour a jugé que la question du changement climatique constitue « l'une des plus préoccupantes de notre époque » (*Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres*, précité, § 410).

ii. Application en l'espèce

99. La Cour relève en premier lieu que la condamnation des requérants est fondée sur la caractérisation du délit de vol, avec la circonstance aggravante qu'il a été commis en réunion.

100. En deuxième lieu, la Cour souligne, comme elle l'a dit plus haut, que l'action de décrochage et de soustraction des portraits du président de la République, dans la ligne des positions du mouvement ANV-COP21 et à l'occasion d'une mobilisation nationale pour le climat à laquelle ce dernier, entre autres, avait appelé, s'inscrivait dans une démarche politique et militante. Cette démarche visait la commission délibérée d'infractions de droit commun à éveiller l'opinion et à sensibiliser la population sur les conséquences néfastes du dérèglement climatique, à dénoncer les carences alléguées de l'action de l'État en la matière et à inciter les pouvoirs publics à adopter des mesures nouvelles.

101. Il s'ensuit qu'alors même qu'elle a été exercée au moyen de la commission d'une infraction pénale, eu égard tant à l'objet du message qui relevait d'un sujet d'intérêt général (*mutatis mutandis*, *Bouton*, précité, § 49) qu'au caractère non violent des actions le véhiculant, la liberté d'expression des requérants devait bénéficier d'un niveau suffisant de protection allant de pair avec une marge d'appréciation des autorités nationales restreinte.

(…)

105. En l'espèce, la Cour relève tout d'abord qu'afin d'apprécier la nécessité de l'ingérence dans la liberté d'expression des requérants et de déterminer si leur comportement justifiait une sanction pénale, les juridictions internes se sont référées, ainsi que cela ressort des motifs de leurs décisions, à certains principes dégagés dans sa jurisprudence relative à l'article 10 de la Convention. En particulier, la Cour de cassation, dans ses trois arrêts du 18 mai 2022, a rappelé sa jurisprudence bien établie selon laquelle l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause avant de préciser qu'il appartient au juge, après s'être assuré, dans l'affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la condamnation au terme d'un examen d'ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé.

106. La Cour doit, ensuite, vérifier si, dans le cadre du contrôle qu'ils devaient opérer au titre du paragraphe 2 de l'article 10, les juges internes ont dûment effectué la mise en balance entre, d'une part, le droit des requérants de communiquer au public, au moyen des actions litigieuses, leurs idées sur la lutte contre le dérèglement climatique, et, d'autre part, la défense de l'ordre et la prévention du crime.

107. À cet égard, la Cour constate que les tribunaux correctionnels de Strasbourg et de Valence ont prononcé la relaxe des requérants au nom de la défense de leur liberté d'expression tandis que celui de Paris les a déclarés coupables de vol en réunion en rejetant leur argumentation fondée sur l'état de nécessité en droit pénal. Elle note ensuite que les cours d'appels de Colmar, de Paris et de Grenoble, pour entrer en voie de condamnation, ont retenu des motivations variées mais toutes fondées sur la réunion des éléments matériel et intentionnel de l'infraction de vol en réunion, peu important la valeur marchande du portrait, l'absence de restitution de celui-ci, ainsi que, pour celles qui ont reconnu le dessein politique et militant de l'action litigieuse, l'absence de disproportion des poursuites engagées du fait des éléments qui viennent d'être cités.

108. La Cour note que, tout en reconnaissant le caractère militant de l'action des requérants, marquée notamment par son expression collective, publique et pacifique, les cours d'appel, dont les solutions n'ont pas été remises en cause par la Cour de cassation, se sont fondées pour entrer en voie de condamnation, d'une part, sur la commission du vol du portrait du président de la République en réunion et l'absence de restitution de celui-ci, et d'autre part, sur l'atteinte portée à un bien « dans un lieu public qui a une valeur symbolique ». Elles ont ainsi invoqué « la circonstance de réunion [...] constituée sur le plan matériel, les faits ayant été commis par plusieurs personnes dont les prévenus » ou la circonstance que « les faits ne sont pas seulement constitutifs d'un décrochage irrégulier du portrait présidentiel mais de la soustraction frauduleuse de ce portrait constituant le délit de vol avec la circonstance aggravante de réunion » (paragraphes 13 et 27 ci-dessus). Elles ont par ailleurs pris en compte le refus de restituer les portraits, « malgré une demande du maire » qui aurait permis « aux prévenus [d'être] épargnés sinon des poursuites pénales du moins (...) une opération de perquisition à domicile », étant observé qu'il était encore possible de le restituer après la manifestation du 25 août 2019 » (paragraphe 15 ci-dessus), ce qui a pu « créée[r] une incertitude quant à la portée de leur action, laquelle ne peut s'analyser comme tendant à seulement provoquer ou stimuler le débat d'intérêt général dans une société démocratique ».

109. Dans ses trois arrêts du 18 mai 2022, la Cour de cassation a confirmé les condamnations prononcées en appel après avoir relevé qu'elle était en mesure de s'assurer que, bien que l'action menée par les prévenus se soit inscrite dans le cadre d'une démarche militante et puisse être considérée comme une expression au sens de l'article 10 précité, ces condamnations n'étaient pas disproportionnées au regard de la valeur symbolique du portrait du Président de la République et du refus de le restituer tant que leurs revendications ne seraient pas satisfaites, ainsi que de la circonstance que le vol a été commis en réunion.

110. De l'ensemble des considérations qui précèdent, la Cour en déduit que le contrôle des juridictions internes a été effectué au moyen d'une analyse de l'ensemble des éléments en litige portant sur le contexte dans lequel se situaient les actions litigieuses ainsi que sur les mobiles des requérants.

111. Certes, la prise en compte de la circonstance que les vols ont été commis en réunion, pertinente pour l'application du droit pénal interne fait fi de la portée, au regard de l'article 10 de la Convention, du mode d'expression collectif utilisé par les requérants pour livrer leur message dans le cadre d'une action concertée.

112. S'agissant de la prise en considération de la « valeur symbolique du portrait » du président de la République, la Cour souligne qu'elle est au fondement de la démarche militante des requérants qui s'en sont précisément pris à ce symbole, sans porter aucune attaque personnelle contre la personne du Président de la République, pour dénoncer et protester contre l'inaction, selon eux, de l'État en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Le tract laissé par les requérants de la requête no 40899/22 à la place du portrait, expliquait ainsi que : « le vide laissé au mur symbolise l'inaction du gouvernement en matière sociale et climatique » (paragraphe 7 ci-dessus). La Cour considère que les juridictions internes ont pu valablement tenir compte de la portée symbolique des actions litigieuses à la fois pour établir l'existence d'un lien entre les actes incriminés et l'exercice par les requérants de leur liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général et pour apprécier la réelle portée des décrochages commis, au-delà de la faible valeur matérielle des biens soustraits. La Cour note au demeurant que, dans une décision postérieure à celles des espèces, une telle prise en compte de la « valeur symbolique du portrait » décroché, parmi les différents critères dégagés par sa jurisprudence, a conduit la Cour de cassation à adopter une solution différente confirmant la relaxe des prévenus.

113. En ce qui concerne la non-restitution des tableaux décrochés, la Cour note que les requérants, dans les requêtes nos 40899/22 et 42956/22, avaient expressément qualifié leur action de réquisition temporaire à laquelle ils ne mettraient fin que lorsque leurs revendications seraient satisfaites. Elle relève que les juridictions internes ont considéré que la conservation des tableaux, après leur décrochage, était de nature à rendre ambigüe la portée de l'action des requérants et à semer un doute sur le caractère réversible ou non du dommage causé. La Cour considère qu'en distinguant, ce faisant, entre, d'une part, le décrochage des portraits qui suffisait par lui-même à la claire expression du message porté par les requérants et qui n'aurait pu à lui seul faire l'objet d'une sanction pénale sans méconnaître les exigences attachées au respect de l'article 10, et, d'autre part, l'appropriation ultérieure des tableaux constitutive du délit de vol, les juridictions internes ont retenu, pour fonder la condamnation des requérants, des motifs qui apparaissent, dans les circonstances spécifiques des présentes affaires, à la fois « pertinents » et « suffisants ».

114. Par ailleurs, la Cour relève qu'en dénonçant l'effet dissuasif des actes effectués à la suite des poursuites engagées à leur encontre tels les auditions, perquisitions ou relevés d'empreinte, les requérants l'invitent à étendre le bénéfice de la protection attachée à l'article 10 de la Convention au point que la liberté d'expression devrait être regardée comme faisant obstacle dans les circonstances de l'espèce à l'incrimination de vol ou à tout le moins à l'engagement des poursuites de ce chef et à la réalisation des actes subséquents.

115. S'il est vrai que la nécessité d'une ingérence dans la liberté d'expression doit en principe s'apprécier au regard de l'ensemble des conséquences attachées à l'incrimination pénale, la Cour constate que la démarche militante des requérants s'est fondée sur la commission délibérée d'une infraction de droit commun et que, dès lors, les mesures de poursuite et d'enquête dénoncées doivent être regardées, dans les présentes affaires, non comme revêtant un effet dissuasif à l'expression de leur message mais au contraire comme faisant partie intégrante de leur stratégie de communication.

116. Dans ces conditions, après avoir relevé le soin mis par les juridictions internes à évaluer la proportionnalité sous l'angle de l'article 10 de la Convention et noté l'évolution postérieure de la jurisprudence de la Cour de cassation, la Cour ne voit pas de raison sérieuse de se départir de leur appréciation, dans les circonstances des espèces, qui n'apparaît ni arbitraire ni manifestement déraisonnable.

117. En cinquième lieu, il reste à la Cour à prendre en considération la nature et la lourdeur des peines infligées afin de mesurer la proportionnalité des atteintes portées au droit à la liberté d'expression des requérants. Elle rappelle que, dans les présentes affaires, les requérants n'ont pas été condamnés à des peines privatives de liberté (*a contrario*, *Rouillan c. France*, no 28000/19, § 75, 23 juin 2022) mais à des amendes respectivement de

200, 400 et 500 EUR avec sursis. Pour ce faire, les juges internes ont pris en considération le contexte de l'infraction ainsi que le mobile des requérants qui avaient agi dans un cadre politique et militant en dehors de tout intérêt personnel et financier (paragraphes 15, 26 et 35 ci-dessus).

118. Tout en rappelant que les instances nationales doivent faire preuve de retenue dans l'usage de la voie pénale lorsque la liberté d'expression est en jeu, la Cour considère que les juridictions internes ont fait le choix de peines particulièrement modérées, guidé par le souci de prendre en considération la nature et le contexte des agissements en cause. Tenant compte à la fois du faible montant des amendes prononcées et du sursis dont ces peines furent assorties, la Cour est d'avis que les condamnations prononcées à l'encontre des requérants, qui sont au nombre des sanctions les plus modérées possible, n'étaient pas disproportionnées au regard du but légitime poursuivi.

(…)
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
(…) Dit, par cinq voix contre deux, qu'il y n'a pas eu violation de l'article 10 de la Convention.

Présentation du sujet :

Présentation de l'arrêt :
Les requérants sont membres d'un groupe qui lutte contre le dérèglement climatique et les injustices sociales. Ils ont participé à un mouvement de décrochage et non-restitution du portrait du Président de la République dans des mairies, et ont fait l'objet de condamnations pour vol en réunion.
Ils ont saisi la CEDH en faisant valoir que ces condamnations étaient contraires à l'article 10 de la Convention. La Cour a estimé que la France n'a pas méconnu ces stipulations.

Fondements juridiques :

- Article 10 CEDH : liberté d'expression
- Contrôle de proportionnalité de la sanction pénale au regard de la liberté d'expression

Problèmes de droit :

- Comment concilier le droit pour les requérants d'exprimer leurs idées avec la défense de l'ordre et la protection du crime ?
- La sanction pénale, qui constitue une ingérence dans la liberté d'expression, est-elle nécessaire et proportionnée au but poursuivi par l'autorité nationale ?

I. L'existence d'une ingérence légale

A. La protection de la liberté d'expression par l'article 10 CEDH

- Champ d'application large de la liberté d'expression : idées inoffensives, mais aussi celles qui heurtent ou inquiètent (CEDH, 7 décembre 1976, *Handyside c/ Royaume-Uni*) ; formes d'expression variées : symbole sur un vêtement (CEDH, 8 juillet 2008, *Vajnai c/ Hongrie*), mise à disposition d'une application mobile par un parti politique pendant une campagne (CEDH, 20 janvier 2020, *MKKP c/ Hongrie*) ; appel au boycott (CEDH, 11 juin 2020, *Baldassi c/ France*)
- Seuls sont exclus de la protection de l'article 10 les propos dirigés contre les valeurs qui sous-tendent la Convention (CEDH, 12 mai 1988, *Kuhnen c/ Allemagne*)
- Les motifs pour lesquels les autorités publiques peuvent restreindre la liberté d'expression sont limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 10 CEDH (sécurité nationale, sûreté publique…)

B. La sanction du décrochage du portrait constitue une ingérence dans la liberté d'expression

- Les condamnations sont fondées sur les articles 311-1 (vol) et 311-4-1 (vol en réunion) du code pénal => fondement légal
- Les sanctions pénales se fondent sur un motif prévu par le paragraphe 2 de l'article 10 soit la défense de l'ordre et la prévention du crime
- Le décrochage du portrait du Président s'inscrit dans une démarche politique et militante de protection de l'environnement, sujet d'intérêt général (et aussi protégé par la CEDH), et l'action est pacifique
- Par conséquent, l'action menée par les requérants devait bénéficier d'un niveau suffisant de protection face à une marge d'appréciation restreinte des autorités nationales

II. Une sanction proportionnée

A. Une ingérence nécessaire

- Contrôle *in concreto* des conséquences de l'action : gravité du dommage, trouble causé
- En l'espèce : vol commis en réunion, refus de restituer le portrait, action commise dans un lieu public et visant un symbole
- A contrario, on pourrait estimer que la protection de l'ordre ne justifiait pas une condamnation pénale au regard de l'absence de troubles effectifs à l'ordre public, et que le vol n'était pas caractérisé dès lors que le retrait du portait n'était que temporaire et qu'il devait être restitué

B. Des peines adaptées

- Prise en compte de l'intention des requérants, qui avaient conscience de commettre une infraction et ont refusé de restituer le portrait, ce qui excède la revendication portée à savoir la dénonciation de l'inaction des autorités et la sensibilisation du public
- Mais prise en compte également de l'absence d'intérêt financier des requérants (faible valeur matérielle du portrait)
- Peines modérées : absence de peines privatives de liberté, amendes de faibles montants

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2025

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 5 – Le droit à la vie privée

1. Dissertation
2. Argumentation
3. Commentaire de texte
4. Commentaire d'arrêt

1. Dissertation : Droit à la vie privée et réseaux sociaux

NB : il ne s'agit que d'une proposition de corrigé. Le sujet est extrêmement vaste, et une autre approche est tout à fait envisageable selon les connaissances et la spécialité du candidat.

Présentation du sujet :

- Vie privée : absence de définition précise, notion très évolutive selon les périodes. Absence de définition exhaustive (CEDH, 25 mars 1993, *Costello-Roberts c/ Royaume-Uni*). A la fois sphère intime mais aussi relations avec les tiers.
- Réseaux sociaux : absence de définition juridique. Dans le langage commun, renvoie à une plateforme accessible par internet qui permet aux utilisateurs de créer un compte et de partager du contenu (photos, vidéos…)
- Consécration constitutionnelle de la protection de la vie privée : CC, 23 juillet 1999, *Loi portant création d'une couverture maladie universelle* : rattachement à l'article 2 DDHC
- Consécration conventionnelle : article 8 CEDH ; article 7 de la Charte des Droits fondamentaux de l'UE
- Multiplication rapide et exponentielle des réseaux sociaux et de leur utilisation ces dernières années. Mais ce développement ne s'est pas accompagné d'un encadrement juridique
- Comment concilier l'usage des réseaux sociaux avec le droit au respect de sa vie privée ?

I. Le développement des réseaux sociaux fragilise le droit au respect de la vie privée

A. Le consentement au traitement des données à caractère personnel

- Inscription sur un réseau social nécessite la communication de données personnelles (nom, sexe, âge etc…)
- Définition des données à caractère personnel (RGPD) : *toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée») ; est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale*
- Définition d'un traitement des données personnelles (RGPD) : *toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à*

disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction

- Traitement des données à caractère personnel seulement si la personne a donné son consentement, soit une volonté libre, spécifique et informée (CJUE, 1er octobre 2019, *Planet49 GmbH*)
- Dans la pratique : le consentement est-il réellement effectif ?

B. L'utilisation des données personnelles

- Collecte, monétisation et profilage des données personnelles par les plateformes
- CJUE, 16 juillet 2020, *Schrems II* : invalidation du transfert de données personnelles depuis l'Europe vers les Etats-Unis (*Privacy Shield*) en raison notamment de l'accès aux données des opérateurs par les services de renseignements américains
- Utilisation des données personnelles par les autorités publiques (renseignement, administration fiscale…)

II. Un encadrement légal des réseaux sociaux renforcé mais qui reste limité

A. Un cadre législatif sous le contrôle du juge

- Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : création CNIL ; protection des données personnelles ; encadrement des traitements de fichiers informatiques
- RGPD :
    - Droits pour les personnes : droit de rectification (article 16) ; droit à l'oubli (article 17) ; droit d'opposition (article 21)
    - Obligations pour les entreprises : principe d'*accountability* (article 5 = mise en place de procédures internes permettant de démontrer le respect des règles) ; désignation d'un délégué à la protection des données (articles 37 et s.)
- Règlement sur les marchés numériques (*Digital markets act* – DMA) : prévention des abus de position dominante des géants du numérique (GAFAM)
- Règlement sur les services numériques (*Digital services act* – DSA) : lutte contre les contenus et produits illégaux en ligne (haine, désinformation, contrefaçons...)
- CEDH : protection des données personnelles par l'article 8 ; confrontation avec la protection de l'ordre public (24 avril 1990, *Kruslin c/ France* : écoutes téléphoniques) ; confrontation avec la liberté d'expression (10 novembre 2015, *Hachette Filipacchi Associés c/ France* : droit du public à l'information)

B. Une mise en œuvre insuffisante

- Absence de réel contrôle des autorités sur les plateformes (extraterritorialité)
- Contrôle de l'âge des utilisateurs
- Complexité du droit, manque de connaissance des dangers et de leurs droits par les utilisateurs
- Lenteur et manque de moyens des autorités de contrôle

2. Argumentation : Soutenez que le droit à la vie privée est menacé

Présentation du sujet :

- Vie privée : absence de définition précise, notion très évolutive selon les périodes. Absence de définition exhaustive (CEDH, 25 mars 1993, *Costello-Roberts c/ Royaume-Uni*). A la fois sphère intime mais aussi relations avec les tiers.
- Consécration constitutionnelle du droit à la vie privée : CC, 23 juillet 1999, *Loi portant création d'une couverture maladie universelle* : rattachement à l'article 2 DDHC
- Consécration conventionnelle : article 8 CEDH ; article 7 de la Charte des Droits fondamentaux de l'UE
- Bien que consacré par plusieurs textes nationaux et internationaux, le droit à la vie privée est confronté à des évolutions qui semblent le mettre en péril : évolutions technologiques, impératifs de sécurité publique

I. Le droit à la vie privée, un droit fondamental mais encadré

A. Une consécration élargie…

- Niveau national : article 9 code civil ; article 2 DDHC (CC, 23 juillet 1999, *Loi portant création d'une couverture maladie universelle*)
- Niveau international : article 8 CEDH ; article 7 Charte des Droits fondamentaux de l'UE ; article 12 DUDH
- Large champ d'application : intégrité physique et morale (protection contre les mauvais traitements, en matière de santé), atteinte à la réputation, identité sexuelle, protection des données personnelles, euthanasie, protection contre les effets néfastes du changement climatique, droits des étrangers…

B. … mais un droit limité

- Restrictions pour préserver l'ordre public
- Conciliation avec d'autres libertés : liberté d'expression, liberté de la presse, liberté d'aller et venir

II. Le droit à la vie privée menacé par les évolutions contemporaines

A. Les atteintes causées par le numérique

- Réseaux sociaux : exposition de la vie privée ; consentement peut être vicié ; absence de contrôle effectif des mineurs
- Utilisation des données personnelles : profilage des données à des fins commerciales ; transferts de données vers des pays tiers dont la législation est insuffisante (CJUE, 16 juillet 2020, *Schrems II*)

B. Les atteintes justifiées par la sécurité intérieure

- Vidéosurveillance : traitement d'images filmées par drones à des fins de maintien de l'ordre (CE, 30 décembre 2024, *Ligue des droits de l'homme*)
- Surveillance numérique généralisée : loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement ; CE, 21 avril 2021, *Quadrature du Net* : légalité de la conservation généralisée pour lutter contre la criminalité grave en raison des menaces pour la sécurité intérieure (en contradiction avec la position de la CJUE, 6 octobre 2020, *Quadrature du Net*)

3. Commentaire d'arrêt : CE, 31 juillet 2025, *Association MOUSSE*

Présentation du sujet :

Présentation de l'arrêt :

L'association MOUSSE avait saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) car elle estimait que l'obligation pour les clients de mentionner leur civilité pour l'achat d'un billet de train était contraire au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD). La CNIL ayant estimé qu'aucun manquement n'avait été constaté, l'association a saisi le Conseil d'État.
Par une décision du 21 juin 2023, le Conseil d'État a sursis à statuer et a posé une question préjudicielle à la CJUE sur l'interprétation des articles 5-1 c) et d) et 6-1 du RGPD. La Cour s'est prononcée le 9 janvier 2025, et a notamment considéré que « *le traitement de données à caractère personnel relatives à la civilité des clients d'une entreprise de transport, ayant pour finalité une personnalisation de la communication commerciale fondée sur leur identité de genre, ne paraît ni objectivement indispensable ni essentiel afin de permettre l'exécution correcte d'un contrat et, partant, ne peut pas être considéré comme étant nécessaire à l'exécution de ce contrat* ».
Par une décision du 31 juillet 2025, le Conseil d'État a jugé que l'obligation pour les clients de communiquer leur civilité était contraire au RGPD, dès lors qu'elle n'est pas obligatoire pour la vente de billets ou le contrôle d'identité pendant le voyage.

Fondements juridiques :

- **Loi 6 janvier 1978** : article 8 : missions de la CNIL
- **RGPD** : article 5 : principes relatifs au traitement des données à caractère personnel : c) principe de minimisation des données ; d) principe d'exactitude. Article 6 : licéité du traitement

Problèmes de droit :

- L'obligation pour les clients de la SNCF de communiquer leur civilité (Monsieur/Madame) est-elle contraire au RGPD ?
  Plus précisément :
- La collecte des civilités est-elle nécessaire à l'exécution d'un contrat, ou nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par la SNCF ?

I. La protection des données personnelles consacrée au niveau européen et garantie au niveau national

A. Les États membres garants du respect du droit de l'UE

- Principe de primauté du droit du l'UE sur le droit national : CJCE, 1964, *Costa c/ ENEL*

- Règlement UE : directement applicable dans les États membres (absence de transposition en droit interne)
- RGPD : entré en vigueur le 25 mai 2018. Vise à renforcer la protection des données personnelles des citoyens de l'UE, notamment en règlementant leurs modalités de collecte et de traitement. Plusieurs principes : transparence, consentement, droits des personnes (accès, rectification, oubli…) et obligations pour les responsables des traitements
- CNIL : AAI créée en 1978, a notamment pour mission de contrôler les traitements de données. Dispose d'un pouvoir de sanction. Peut être saisie par une personne privée qui s'estime victime. Décisions de la CNIL peuvent être contestées devant le Conseil d'État

B. Les principes de licéité et de minimisation des données personnelles

- Art. 6 RGPD : un traitement est licite si au moins une des conditions est remplie :
    - Consentement de la personne
    - Exécution d'un contrat
    - Obligation légale à laquelle est soumis le responsable du traitement
    - Sauvegarde des intérêts vitaux de la personne
    - Exécution d'une mission d'intérêt public
    - Intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement
- Art. 21 RGPD : Possibilité de s'opposer à un traitement fondé sur les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement
- Art. 5-1 c : principe de minimisation des données personnelles = traitement doit être strictement proportionné et limité à ce qui est nécessaire

II. La collecte des civilités des clients de la SNCF est contraire au RGPD

- Civilité Monsieur/Madame = identité de genre masculine ou féminine ; donnée personnelle lorsqu'elle se rapporte à une personne identifiée au sens de l'art. 4-1 RGPD
- Communication de la civilité = traitement au sens de l'art. 4-2 RGPD car collecte et enregistrement automatisés
    ⇨ Mention de la civilité pour l'achat de billets de train entre dans le champ d'application du RGPD

A. L'absence de nécessité pour la réalisation d'un contrat

- Position de la CNIL (§ 7) : le fondement juridique du traitement des données est le contrat de vente d'un billet de train ; la mention de la civilité était nécessaire à l'exécution d'un contrat sur le fondement de l'article 6-1 b du RGPD ; le principe de minimisation des données personnelles a été respecté (article 5-1 c du RGPD) ; le traitement des données est licite (article 6-1 f du RGPD)
- Position de la CJUE (§ 8) : la mention de la civilité, qui vise notamment une personnalisation de la communication commerciale fondée sur une identité de genre, n'est pas nécessaire à l'exécution du contrat

- Position du CE (§ 9 et 10) : l'absence de mention de la civilité ne rend pas plus difficile le contrôle des titres de transport ; si la mention de la civilité peut être nécessaire pour la réservation de compartiments pour femmes seules, elle n'a pas à être recueillie pour l'ensemble des prestations de transport
  ⇨ Méconnaissance de l'article 6-1 b du RGPD

B. L'absence de nécessité aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou un tiers

- Position de la CJUE (§ 11) : le traitement des données relatives à la civilité, qui vise à personnaliser une communication commerciale selon le genre, n'est pas nécessaire aux intérêts légitimes poursuivis par la SNCF lorsque les clients n'ont pas été informés, que le traitement n'est pas limité au strict nécessaire, ou que les droits fondamentaux des clients prévalent sur les intérêts poursuivis (en l'espèce un risque de discrimination fondée sur le genre)
- Position du CE (§ 12) : un recueil optionnel de la civilité aurait été conforme au RGPD
  ⇨ Méconnaissance de l'article 6-1 f du RGPD

4. Commentaire : article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Article 8 Droit au respect de la vie privée et familiale

1. *Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.*
2. *Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui*

Présentation du sujet :

- Vie privée : absence de définition précise, notion très évolutive selon les périodes. Absence de définition exhaustive (CEDH, 25 mars 1993, *Costello-Roberts c/ Royaume-Uni*). A la fois sphère intime mais aussi relations avec les tiers
- Cour retient une extension très large du champ d'application de la vie privée et familiale
- Obligation d'abstention d'ingérence des États, mais aussi obligations positives pour garantir le respect de la vie privée (CEDH, 13 juin 1979, *Marckx c/ Belgique*)
- Possibilité de restreindre la vie privée

I. L'article 8, fondement d'une notion extensive et évolutive de la vie privée

A. Un large champ d'application

- Vie privée : intégrité physique et morale, protection du nom, sexualité, droit à l'image, protection des données personnelles, protection contre les effets néfastes du changement climatique…
- Vie familiale : lien de parenté, protection pour les étrangers, protection des enfants…
- Protection du domicile : large appréciation de la notion de domicile (résidence secondaire, mode de vie des Tsiganes, locaux professionnels)
- Protection de la correspondance : inclus les correspondances professionnelles, des détenus

B. Les obligations mises à la charge des États

- L'obligation de mettre en place un cadre normatif permettant de protéger la vie privée :
    - Obligation d'adopter des dispositions pénales sanctionnant le viol et les appliquer effectivement (CEDH, 4 décembre 2003, *M.C. c/ Bulgarie*)
    - Obligation de prendre des mesures pour interdire le harcèlement scolaire et garantir l'absence d'impunité (CEDH, 22 avril 2021, *F.O. c/ Croatie*)

    - Obligation d'adopter une réglementation apte à atténuer les effets actuels et futurs du changement climatique (CEDH, 9 avril 2024, *Verein Klimaseniorinnen Schweiz ea c/ Suisse*)
- L'obligation d'intervenir pour empêcher les atteintes à la vie privée causées par les tiers :
    - S'agissant du droit à l'image, toute personne, même connue, doit pouvoir bénéficier d'une espérance légitime de protection de sa vie privée (CEDH, 24 juin 2004, *Von Hannover c/ Allemagne*)
    - Obligation pour les États d'empêcher que les éléments issus d'écoutes téléphoniques ne se retrouvent pas dans la presse (CEDH, 17 juillet 2003, *Craxi c/ Italie*)

II. Les restrictions au droit à la vie privée

A. Les restrictions fondées sur la protection de l'ordre public

- S'agissant des détenus, le refus d'autoriser les détenus à avoir des relations intimes avec leur conjoint est justifié (CEDH, 22 octobre 1997, *E.L.H. et P.H.B. c/ Royaume-Uni*)
- S'agissant des étrangers, la convention ne leur garantit aucun droit d'entrer ou de résider, ni aucun regroupement familial (CEDH, 2 août 2001, *Boultif c/ Suisse*)
- S'agissant de la protection des données personnelles, la loi peut autoriser l'interception en masse de communications internationales (CEDH, 25 mai 2021, *Big Brother Watch c/ Royaume-Uni*)

B. La conciliation entre la protection de la vie privée et d'autres libertés garanties par la convention

- Conciliation avec la liberté d'expression (CEDH, 10 novembre 2015, *Couderc et Hachette Filipacchi associés c/ France*)
- Conciliation avec l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (CEDH, 10 mai 2001, Z. c/ Royaume-Uni)

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2025

' ĬNJŬĽĂŢĬÔŇÄĂŬÄĜŖĂŇĎÄÔŖĂĽ

' ęŗĭěŠĂÄĽěÄŗôĭţŠĄåĂĩěÄŗĭvęě

1. Ďĭ' ' ěŗţăţĭôňĂ
2. Ăŗĝŭń ěňţăţĭôň
3. Çôń ń ěňţăĭŗěÄďěĄěýţě
4. Çôń ń ěňţăĭŗěÄď’ăŗŗêţĂ

1. Dissertation : Droit à la vie privée et réseaux sociaux

NB : il ne s'agit que d'une proposition de corrigé. Le sujet est extrêmement vaste, et une autre approche est tout à fait envisageable selon les connaissances et la spécialité du candidat.

Présentation du sujet :

- Vie privée : absence de définition précise, notion très évolutive selon les périodes. Absence de définition exhaustive (CEDH, 25 mars 1993, *Costello-Roberts c/ Royaume-Uni*). A la fois sphère intime mais aussi relations avec les tiers.
- Réseaux sociaux : absence de définition juridique. Dans le langage commun, renvoie à une plateforme accessible par internet qui permet aux utilisateurs de créer un compte et de partager du contenu (photos, vidéos…)
- Consécration constitutionnelle de la protection de la vie privée : CC, 23 juillet 1999, *Loi portant création d'une couverture maladie universelle* : rattachement à l'article 2 DDHC
- Consécration conventionnelle : article 8 CEDH ; article 7 de la Charte des Droits fondamentaux de l'UE
- Multiplication rapide et exponentielle des réseaux sociaux et de leur utilisation ces dernières années. Mais ce développement ne s'est pas accompagné d'un encadrement juridique
- Comment concilier l'usage des réseaux sociaux avec le droit au respect de sa vie privée ?

I. Le développement des réseaux sociaux fragilise le droit au respect de la vie privée

A. Le consentement au traitement des données à caractère personnel

- Inscription sur un réseau social nécessite la communication de données personnelles (nom, sexe, âge etc…)
- Définition des données à caractère personnel (RGPD) : *toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée») ; est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale*
- Définition d'un traitement des données personnelles (RGPD) : *toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à*

disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction

- Traitement des données à caractère personnel seulement si la personne a donné son consentement, soit une volonté libre, spécifique et informée (CJUE, 1er octobre 2019, *Planet49 GmbH*)
- Dans la pratique : le consentement est-il réellement effectif ?

B. L'utilisation des données personnelles

- Collecte, monétisation et profilage des données personnelles par les plateformes
- CJUE, 16 juillet 2020, *Schrems II* : invalidation du transfert de données personnelles depuis l'Europe vers les Etats-Unis (*Privacy Shield*) en raison notamment de l'accès aux données des opérateurs par les services de renseignements américains
- Utilisation des données personnelles par les autorités publiques (renseignement, administration fiscale…)

II. Un encadrement légal des réseaux sociaux renforcé mais qui reste limité

A. Un cadre législatif sous le contrôle du juge

- Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : création CNIL ; protection des données personnelles ; encadrement des traitements de fichiers informatiques
- RGPD :
    - Droits pour les personnes : droit de rectification (article 16) ; droit à l'oubli (article 17) ; droit d'opposition (article 21)
    - Obligations pour les entreprises : principe d'*accountability* (article 5 = mise en place de procédures internes permettant de démontrer le respect des règles) ; désignation d'un délégué à la protection des données (articles 37 et s.)
- Règlement sur les marchés numériques (*Digital markets act* – DMA) : prévention des abus de position dominante des géants du numérique (GAFAM)
- Règlement sur les services numériques (*Digital services act* – DSA) : lutte contre les contenus et produits illégaux en ligne (haine, désinformation, contrefaçons...)
- CEDH : protection des données personnelles par l'article 8 ; confrontation avec la protection de l'ordre public (24 avril 1990, *Kruslin c/ France* : écoutes téléphoniques) ; confrontation avec la liberté d'expression (10 novembre 2015, *Hachette Filipacchi Associés c/ France* : droit du public à l'information)

B. Une mise en œuvre insuffisante

- Absence de réel contrôle des autorités sur les plateformes (extraterritorialité)
- Contrôle de l'âge des utilisateurs
- Complexité du droit, manque de connaissance des dangers et de leurs droits par les utilisateurs
- Lenteur et manque de moyens des autorités de contrôle

2. Argumentation : Soutenez que le droit à la vie privée est menacé

Présentation du sujet :

- Vie privée : absence de définition précise, notion très évolutive selon les périodes. Absence de définition exhaustive (CEDH, 25 mars 1993, *Costello-Roberts c/ Royaume-Uni*). A la fois sphère intime mais aussi relations avec les tiers.
- Consécration constitutionnelle du droit à la vie privée : CC, 23 juillet 1999, *Loi portant création d'une couverture maladie universelle* : rattachement à l'article 2 DDHC
- Consécration conventionnelle : article 8 CEDH ; article 7 de la Charte des Droits fondamentaux de l'UE
- Bien que consacré par plusieurs textes nationaux et internationaux, le droit à la vie privée est confronté à des évolutions qui semblent le mettre en péril : évolutions technologiques, impératifs de sécurité publique

I. Le droit à la vie privée, un droit fondamental mais encadré

A. Une consécration élargie…

- Niveau national : article 9 code civil ; article 2 DDHC (CC, 23 juillet 1999, *Loi portant création d'une couverture maladie universelle*)
- Niveau international : article 8 CEDH ; article 7 Charte des Droits fondamentaux de l'UE ; article 12 DUDH
- Large champ d'application : intégrité physique et morale (protection contre les mauvais traitements, en matière de santé), atteinte à la réputation, identité sexuelle, protection des données personnelles, euthanasie, protection contre les effets néfastes du changement climatique, droits des étrangers…

B. … mais un droit limité

- Restrictions pour préserver l'ordre public
- Conciliation avec d'autres libertés : liberté d'expression, liberté de la presse, liberté d'aller et venir

II. Le droit à la vie privée menacé par les évolutions contemporaines

A. Les atteintes causées par le numérique

- Réseaux sociaux : exposition de la vie privée ; consentement peut être vicié ; absence de contrôle effectif des mineurs
- Utilisation des données personnelles : profilage des données à des fins commerciales ; transferts de données vers des pays tiers dont la législation est insuffisante (CJUE, 16 juillet 2020, *Schrems II*)

B. Les atteintes justifiées par la sécurité intérieure

- Vidéosurveillance : traitement d'images filmées par drones à des fins de maintien de l'ordre (CE, 30 décembre 2024, *Ligue des droits de l'homme*)
- Surveillance numérique généralisée : loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement ; CE, 21 avril 2021, *Quadrature du Net* : légalité de la conservation généralisée pour lutter contre la criminalité grave en raison des menaces pour la sécurité intérieure (en contradiction avec la position de la CJUE, 6 octobre 2020, *Quadrature du Net*)

3. Commentaire d'arrêt : CE, 31 juillet 2025, *Association MOUSSE*

Présentation du sujet :

Présentation de l'arrêt :

L'association MOUSSE avait saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) car elle estimait que l'obligation pour les clients de mentionner leur civilité pour l'achat d'un billet de train était contraire au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD). La CNIL ayant estimé qu'aucun manquement n'avait été constaté, l'association a saisi le Conseil d'État.
Par une décision du 21 juin 2023, le Conseil d'État a sursis à statuer et a posé une question préjudicielle à la CJUE sur l'interprétation des articles 5-1 c) et d) et 6-1 du RGPD. La Cour s'est prononcée le 9 janvier 2025, et a notamment considéré que « *le traitement de données à caractère personnel relatives à la civilité des clients d'une entreprise de transport, ayant pour finalité une personnalisation de la communication commerciale fondée sur leur identité de genre, ne paraît ni objectivement indispensable ni essentiel afin de permettre l'exécution correcte d'un contrat et, partant, ne peut pas être considéré comme étant nécessaire à l'exécution de ce contrat* ».
Par une décision du 31 juillet 2025, le Conseil d'État a jugé que l'obligation pour les clients de communiquer leur civilité était contraire au RGPD, dès lors qu'elle n'est pas obligatoire pour la vente de billets ou le contrôle d'identité pendant le voyage.

Fondements juridiques :

- **Loi 6 janvier 1978** : article 8 : missions de la CNIL
- **RGPD** : article 5 : principes relatifs au traitement des données à caractère personnel : c) principe de minimisation des données ; d) principe d'exactitude. Article 6 : licéité du traitement

Problèmes de droit :

- L'obligation pour les clients de la SNCF de communiquer leur civilité (Monsieur/Madame) est-elle contraire au RGPD ?
  Plus précisément :
- La collecte des civilités est-elle nécessaire à l'exécution d'un contrat, ou nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par la SNCF ?

I. La protection des données personnelles consacrée au niveau européen et garantie au niveau national

A. Les États membres garants du respect du droit de l'UE

- Principe de primauté du droit du l'UE sur le droit national : CJCE, 1964, *Costa c/ ENEL*

- Règlement UE : directement applicable dans les États membres (absence de transposition en droit interne)
- RGPD : entré en vigueur le 25 mai 2018. Vise à renforcer la protection des données personnelles des citoyens de l'UE, notamment en règlementant leurs modalités de collecte et de traitement. Plusieurs principes : transparence, consentement, droits des personnes (accès, rectification, oubli…) et obligations pour les responsables des traitements
- CNIL : AAI créée en 1978, a notamment pour mission de contrôler les traitements de données. Dispose d'un pouvoir de sanction. Peut être saisie par une personne privée qui s'estime victime. Décisions de la CNIL peuvent être contestées devant le Conseil d'État

B. Les principes de licéité et de minimisation des données personnelles

- Art. 6 RGPD : un traitement est licite si au moins une des conditions est remplie :
  - Consentement de la personne
  - Exécution d'un contrat
  - Obligation légale à laquelle est soumis le responsable du traitement
  - Sauvegarde des intérêts vitaux de la personne
  - Exécution d'une mission d'intérêt public
  - Intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement
- Art. 21 RGPD : Possibilité de s'opposer à un traitement fondé sur les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement
- Art. 5-1 c : principe de minimisation des données personnelles = traitement doit être strictement proportionné et limité à ce qui est nécessaire

II. La collecte des civilités des clients de la SNCF est contraire au RGPD

- Civilité Monsieur/Madame = identité de genre masculine ou féminine ; donnée personnelle lorsqu'elle se rapporte à une personne identifiée au sens de l'art. 4-1 RGPD
- Communication de la civilité = traitement au sens de l'art. 4-2 RGPD car collecte et enregistrement automatisés
  ⇨ Mention de la civilité pour l'achat de billets de train entre dans le champ d'application du RGPD

A. L'absence de nécessité pour la réalisation d'un contrat

- Position de la CNIL (§ 7) : le fondement juridique du traitement des données est le contrat de vente d'un billet de train ; la mention de la civilité était nécessaire à l'exécution d'un contrat sur le fondement de l'article 6-1 b du RGPD ; le principe de minimisation des données personnelles a été respecté (article 5-1 c du RGPD) ; le traitement des données est licite (article 6-1 f du RGPD)
- Position de la CJUE (§ 8) : la mention de la civilité, qui vise notamment une personnalisation de la communication commerciale fondée sur une identité de genre, n'est pas nécessaire à l'exécution du contrat

- Position du CE (§ 9 et 10) : l'absence de mention de la civilité ne rend pas plus difficile le contrôle des titres de transport ; si la mention de la civilité peut être nécessaire pour la réservation de compartiments pour femmes seules, elle n'a pas à être recueillie pour l'ensemble des prestations de transport
  ⇨ Méconnaissance de l'article 6-1 b du RGPD

B. L'absence de nécessité aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou un tiers

- Position de la CJUE (§ 11) : le traitement des données relatives à la civilité, qui vise à personnaliser une communication commerciale selon le genre, n'est pas nécessaire aux intérêts légitimes poursuivis par la SNCF lorsque les clients n'ont pas été informés, que le traitement n'est pas limité au strict nécessaire, ou que les droits fondamentaux des clients prévalent sur les intérêts poursuivis (en l'espèce un risque de discrimination fondée sur le genre)
- Position du CE (§ 12) : un recueil optionnel de la civilité aurait été conforme au RGPD
  ⇨ Méconnaissance de l'article 6-1 f du RGPD

4. Commentaire : article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Article 8 Droit au respect de la vie privée et familiale

1. *Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.*
2. *Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui*

Présentation du sujet :

- Vie privée : absence de définition précise, notion très évolutive selon les périodes. Absence de définition exhaustive (CEDH, 25 mars 1993, *Costello-Roberts c/ Royaume-Uni*). A la fois sphère intime mais aussi relations avec les tiers
- Cour retient une extension très large du champ d'application de la vie privée et familiale
- Obligation d'abstention d'ingérence des États, mais aussi obligations positives pour garantir le respect de la vie privée (CEDH, 13 juin 1979, *Marckx c/ Belgique*)
- Possibilité de restreindre la vie privée

I. L'article 8, fondement d'une notion extensive et évolutive de la vie privée

A. Un large champ d'application

- Vie privée : intégrité physique et morale, protection du nom, sexualité, droit à l'image, protection des données personnelles, protection contre les effets néfastes du changement climatique…
- Vie familiale : lien de parenté, protection pour les étrangers, protection des enfants…
- Protection du domicile : large appréciation de la notion de domicile (résidence secondaire, mode de vie des Tsiganes, locaux professionnels)
- Protection de la correspondance : inclus les correspondances professionnelles, des détenus

B. Les obligations mises à la charge des États

- L'obligation de mettre en place un cadre normatif permettant de protéger la vie privée :
    - Obligation d'adopter des dispositions pénales sanctionnant le viol et les appliquer effectivement (CEDH, 4 décembre 2003, *M.C. c/ Bulgarie*)
    - Obligation de prendre des mesures pour interdire le harcèlement scolaire et garantir l'absence d'impunité (CEDH, 22 avril 2021, *F.O. c/ Croatie*)

    - Obligation d'adopter une réglementation apte à atténuer les effets actuels et futurs du changement climatique (CEDH, 9 avril 2024, *Verein Klimaseniorinnen Schweiz ea c/ Suisse*)
- L'obligation d'intervenir pour empêcher les atteintes à la vie privée causées par les tiers :
    - S'agissant du droit à l'image, toute personne, même connue, doit pouvoir bénéficier d'une espérance légitime de protection de sa vie privée (CEDH, 24 juin 2004, *Von Hannover c/ Allemagne*)
    - Obligation pour les États d'empêcher que les éléments issus d'écoutes téléphoniques ne se retrouvent pas dans la presse (CEDH, 17 juillet 2003, *Craxi c/ Italie*)

II. Les restrictions au droit à la vie privée

A. Les restrictions fondées sur la protection de l'ordre public

- S'agissant des détenus, le refus d'autoriser les détenus à avoir des relations intimes avec leur conjoint est justifié (CEDH, 22 octobre 1997, *E.L.H. et P.H.B. c/ Royaume-Uni*)
- S'agissant des étrangers, la convention ne leur garantit aucun droit d'entrer ou de résider, ni aucun regroupement familial (CEDH, 2 août 2001, *Boultif c/ Suisse*)
- S'agissant de la protection des données personnelles, la loi peut autoriser l'interception en masse de communications internationales (CEDH, 25 mai 2021, *Big Brother Watch c/ Royaume-Uni*)

B. La conciliation entre la protection de la vie privée et d'autres libertés garanties par la convention

- Conciliation avec la liberté d'expression (CEDH, 10 novembre 2015, *Couderc et Hachette Filipacchi associés c/ France*)
- Conciliation avec l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (CEDH, 10 mai 2001, Z. c/ Royaume-Uni)

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2025

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 6 – La protection juridictionnelle des libertés en droit interne

1. Dissertation
2. Argumentation
3. Commentaire de texte
4. Commentaire d'arrêt

1. Sujet – Dissertation

La protection juridictionnelle des libertés en droit interne

---

2. Sujet – Argumentation

Soutenez que le juge est le garant essentiel de la protection des libertés fondamentales

---

3. Sujet – Commentaire de texte

« *Qu'aurait pensé Montesquieu de la condamnation de Nicolas Sarkozy ? Retour sur trois siècles de défiance du juge* », L'Express, 5 octobre 2025

Idées. La sévérité du jugement prononcé à l'encontre de l'ancien président de la République ravive les soupçons de partialité des juges. Une défiance qui traverse les siècles.

L'Express
Par Ambre Xerri
Publié le 05/10/2025 à 08:00

Symbole de l'égalité des citoyens devant la loi pour les uns, la condamnation de Nicolas Sarkozy à cinq ans de prison avec exécution provisoire, dans l'affaire libyenne, nourrit, pour les autres, les suspicions d'une justice partiale. Partout, des pénalistes et d'autres éminents spécialistes du droit jusqu'à l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel Jean-Éric Schoettl, interrogent : ce verdict serait-il politique ? Les magistrats auraient-ils jugé à l'aune de leurs convictions idéologiques ? Ou prendraient-ils simplement leur revanche sur un ancien président qui ne s'est pas toujours montré tendre à leur endroit ?

Des soupçons qui ressurgissent quasi systématiquement lors de procès visant des personnalités publiques – Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, François Fillon, et 2 400 ans avant eux, Socrate. Mais aussi, lorsque des juridictions suprêmes appelées à se prononcer sur une loi - Conseil d'État ou Conseil constitutionnel par exemple – enjoignent le législateur à revoir sa copie - et souvent, ses ambitions. Cette situation a d'ailleurs favorisé la démocratisation de l'expression de "gouvernement des juges", amenée au milieu du XXe siècle par le juriste Édouard Lambert pour décrire le droit de vie ou de mort exercé par la Cour suprême américaine sur les textes votés par le Congrès.

Le bras de fer de Roosevelt avec la très politisée Cour suprême

Au début des années 30, la possibilité laissée aux juges de donner un avis sur les lois votées par les représentants du peuple provoque des crises d'urticaire au président Franklin Delano Roosevelt. Le démocrate, pris d'un feu réformiste, s'engage dans une croisade avec la Cour suprême qui vient de retoquer plusieurs mesures de son New Deal. Pour tordre le cou à cette institution qui agit selon lui "non pas comme un organe judiciaire, mais comme un organe politique", Roosevelt dégaine début février 1937 son fameux *Court packing plan*.

Alors qu'il est d'usage que neuf juges siègent à la Cour suprême, le projet de loi prévoit la possibilité d'aller au-delà. Le président pourrait ainsi nommer de nouveaux juges - favorables à sa politique - à chaque fois qu'un des membres aurait atteint l'âge de 70 ans. Pour justifier ce pied de nez fait à la sacro-sainte Cour suprême, "FDR" prend à témoin le peuple américain dans une causerie radiophonique - ses très populaires

fireside chat - le 9 mars 1937 : "Notre difficulté avec la Cour ne vient pas de l'institution en tant que telle, mais des êtres humains qui la composent", ose-t-il.

Avant d'abonder avec gravité : "Nous ne pouvons pas livrer notre destin constitutionnel au jugement personnel de quelques hommes qui, par peur de l'avenir, nous refuseraient les moyens nécessaires pour affronter le présent." Près d'un siècle plus tard, en France, Gabriel Attal, député, met en garde contre le risque de voir la Ve République basculer dans une "vétocratie", après la censure d'une partie de sa loi sur la justice des mineurs. Mais le pays n'a pas attendu son plus jeune Premier ministre pour s'interroger sur la place et les pouvoirs accordés aux magistrats.

Mettre les juges au pas, une priorité pour les révolutionnaires

Sous l'Ancien Régime déjà, les juges n'avaient pas bonne presse. Les accusations de corruption, légion, reposaient en grande partie sur l'existence du système dit des "épices", ces sommes versées par les parties d'un procès aux magistrats. Sortes de pots-de-vin légaux, elles garantissaient néanmoins une certaine autonomie aux juges qui, ne dépendant pas financièrement du roi, pouvaient faire fonctionner à plein régime leur droit de remontrances. Après la révolution, cette liberté d'action horrifie les Marat, Robespierre, Barnave, Desmoulins et consorts, inquiets que les juges, réputés très conservateurs, n'entravent leurs réformes. Le lecteur ne sera donc pas surpris d'apprendre que "les premiers débats au sein de l'Assemblée nationale constituante portaient précisément sur la justice et les moyens de la limiter", raconte le juriste Matthieu Bertozzo.

Pour mettre les juges au pas, la pratique des épices, héritée du Moyen-Âge est supprimée dès le 11 août 1789. Les "arrêts de règlement" qui permettent aux magistrats de créer une norme à partir d'un jugement, sont également interdits. Les Parlements de l'Ancien Régime commencent par être suspendus avant d'être "supprimés dans une relative indifférence, voire une certaine satisfaction", souligne le constitutionnaliste Benjamin Morel. Et de résumer : "La révolution s'est construite contre les Parlements de l'Ancien Régime, et tout est pensé pour se prémunir de l'appréciation de ces juges politisés qui pourraient dénaturer les grands textes votés par l'Assemblée." De quoi expliquer ces mots de Robespierre : "Si la loi peut être interprétée, augmentée ou appliquée au gré d'une volonté particulière, l'homme n'est plus sous la sauvegarde de la loi mais sous la puissance de celui qui l'interprète, l'augmente ou l'applique."

Montesquieu, le rêve d'un juge sans pouvoir d'interprétation

Cette conception resserrée du juge découle directement de la pensée montesquienne des Lumières. L'auteur *De l'esprit des lois* estime que le juge est une institution dangereuse en ce qu'il dispose d'un pouvoir discrétionnaire. Raison pour laquelle, celui-ci doit être réduit à n'être que "la bouche de la loi". Passée dans la postérité, la formule signifie que les prérogatives du juge doivent être circonscrites à l'application de syllogismes. Dès lors, aucun pouvoir d'interprétation, même le plus infinitésimal, ne doit lui être confié. C'est d'ailleurs en ce sens que l'on peut imaginer un Montesquieu révolté à l'annonce de la condamnation de Nicolas Sarkozy qui repose, et les juges le reconnaissent d'eux-mêmes, sur un faisceau d'indices.

Si elle n'est plus d'actualité, la théorie de Montesquieu irrigue les lois des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, qui fixent des garde-fous très stricts. Les juges se voient interdire toute immixtion dans l'action publique. Il leur est par exemple défendu, sous peine de forfaiture, de troubler en quoi que ce soit les opérations des corps administratifs. La carte judiciaire est en outre profondément réorganisée : tribunaux de district, élection de juges de paix par les citoyens actifs, et mise en place d'un tribunal de cassation destiné à veiller à l'uniformité des jugements. Une transfiguration de l'ordre judiciaire qui conduit la justice à perdre "considérablement en crédibilité", explique le juriste Matthieu Bertozzo dans *Le 3 novembre 1790, la mise au pas des juges sous la Révolution*.

Au discrédit de la justice de l'Ancien Régime s'ajoute par la suite le traumatisme du Tribunal révolutionnaire, de sorte que le désaveu fut encore plus profond à la sortie de la Terreur. L'homme du XIX^{e} siècle n'imagine d'ailleurs pas une seconde que ses droits et libertés puissent être garantis par l'institution judiciaire. À L'Express, le professeur de droit public à l'université Paris-Panthéon-Assas Benjamin Morel

explique qu'"après la Révolution, la conception de Montesquieu selon laquelle seul le Parlement agit dans l'intérêt général, prévaut".

Il faut attendre les années 1830 pour que les tribunaux recouvrent leur marge d'interprétation, puis le début de la IIIe République pour que, par la pratique jurisprudentielle, le juge s'impose comme véritable fabriquant de normes aux côtés du pouvoir législatif. Une évolution importée des modèles anglais et américain, qui, aujourd'hui encore, interroge, et qui, à n'en pas douter, ferait horreur à Montesquieu.

---

4. Sujet – Commentaire d'arrêt

CC, 16 juillet 1971, *Liberté d'association*

Décision 71-44 DC - 16 juillet 1971

Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 1er juillet 1971 par le Président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, du texte de la loi, délibérée par l'Assemblée nationale et le Sénat et adoptée par l'Assemblée nationale, complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la Constitution et notamment son préambule ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, modifiée ;
Vu la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées ;

1. Considérant que la loi déférée à l'examen du Conseil constitutionnel a été soumise au vote des deux assemblées, dans le respect d'une des procédures prévues par la Constitution, au cours de la session du Parlement ouverte le 2 avril 1971 ;

2. Considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d'association ; que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; qu'en vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable ; qu'ainsi, à l'exception des mesures susceptibles d'être prises à l'égard de catégories particulières d'associations, la constitution d'associations, alors même qu'elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire ;

3. Considérant que, si rien n'est changé en ce qui concerne la constitution même des associations non

déclarées, les dispositions de l'article 3 de la loi dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, ont pour objet d'instituer une procédure d'après laquelle l'acquisition de la capacité juridique des associations déclarées pourra être subordonnée à un contrôle préalable par l'autorité judiciaire de leur conformité à la loi ;

4. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 3 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complétant l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901, ainsi, par voie de conséquence, que la disposition de la dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi soumise au Conseil constitutionnel leur faisant référence ;

5. Considérant qu'il ne résulte ni du texte dont il s'agit, tel qu'il a été rédigé et adopté, ni des débats auxquels la discussion du projet de loi a donné lieu devant le Parlement, que les dispositions précitées soient inséparables de l'ensemble du texte de la loi soumise au Conseil ;

6. Considérant, enfin, que les autres dispositions de ce texte ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ;

Décide :

Article premier : Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 3 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complétant les dispositions de l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901 ainsi que les dispositions de l'article 1er de la loi soumise au Conseil leur faisant référence.

Article 2 : Les autres dispositions dudit texte de loi sont déclarées conformes à la Constitution.

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2025

SIMULATION AU GRAND ORAL

Série 6 – La protection juridictionnelle des libertés en droit interne

1. Dissertation
2. Argumentation
3. Commentaire de texte
4. Commentaire d'arrêt

1. Sujet – Dissertation

La protection juridictionnelle des libertés en droit interne

Présentation du sujet :

- Protection juridictionnelle : intervention des juges pour garantir l'effectivité de libertés consacrées par des textes, voire même consécration de libertés directement par le juge
- Juges en droit interne : Conseil constitutionnel, juge judiciaire, juge administratif
- Rôle du CC : contrôle de la conformité des lois au bloc de constitutionnalité, qui comprend les libertés fondamentales ; rôle renforcé par la création de la QPC
- Rôle du juge judiciaire : gardien de la liberté individuelle (article 66 de la Constitution) ; rôle diminué concomitamment à la restriction de la notion de liberté individuelle
- Rôle du juge administratif : contrôle les atteintes aux libertés commises par l'administration ; rôle renforcé ces dernières décennies
- Aujourd'hui, protection des libertés est principalement garantie par le juge administratif

I. La protection limitée des libertés par le juge judiciaire et le Conseil constitutionnel

A. Le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle

- Article 66 Constitution : autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle
- CC, 12 janvier 1977, *Fouille des véhicules* : liberté individuelle est un PFRLR
- CC retient d'abord une conception extensive de la liberté individuelle : inclut la liberté d'aller et venir (12 juillet 1979, *Ponts à péage*), la liberté de mariage (13 août 1993, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration*), ou encore le droit au respect de la vie privée (18 janvier 1995, *Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité*)
- Par la suite, CC réduit la liberté individuelle à la sûreté. Ne sont plus incluses dans la liberté individuelle le droit au respect de la vie privée (29 décembre 1998, *Loi de finances pour 1999*), la liberté d'aller et venir (16 juin 1999, *Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière*), et enfin la liberté de mariage (20 novembre 2003, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration*)
- Compétence du juge judiciaire si voie de fait, dont la définition a été largement réduite (TC, 17 juin 2013, *Bergoend c/ ERDF Annecy Léman*) : atteinte à la liberté individuelle ou extinction du droit de propriété

B. Le Conseil constitutionnel, gardien limité des libertés

- Contrôle de constitutionnalité notamment au bloc de constitutionnalité (Préambule Constitution 1946, DDHC, Charte de l'environnement, PFRLR)
- Contrôle de constitutionnalité a priori des lois : obligatoire pour les lois organiques, facultatif pour les lois ordinaires (article 61 Constitution)
- Contrôle de constitutionnalité a priori des traités internationaux (article 54 Constitution)
- QPC (article 61-1 Constitution) : contrôle de constitutionnalité a posteriori, si méconnaissance d'un droit ou une liberté garanti par la Constitution

II. L'affirmation du rôle du juge administratif comme protecteur des libertés

A. Le respect des libertés par l'administration garanti par le contrôle de légalité du juge administratif

- Contrôle de légalité : conformité d'un acte administratif à la loi ou au règlement ; contrôle de conformité d'un acte administratif à un PFRLR (CE, 11 juillet 1956, *Amicale des anamites de Paris*) ou à la DDHC (CE, 12 février 1960, *Société Eky*)
- Contrôle de conventionnalité d'un acte administratif : CE, 20 octobre 1989, *Nicolo*
- Référé liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative) : atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

B. La consécration de droits subjectifs par le juge administratif

- CE a dégagé les principes généraux du droit : droits de la défense (5 mai 1944, *Dame veuve Trompier-Gravier*), principe d'égalité (CE, 9 mars 1951, *Société des concerts du conservatoire*), droit de mener une vie familiale normale (CE, 8 décembre 1978, *GISTI*)
- Nouvelles libertés fondamentales consacrées par le référé-liberté : droit pour un parti politique légalement constitué de tenir des réunions (19 août 2002, *Front national*), droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (20 septembre 2022)

---

2. Sujet – Argumentation

Soutenez que le juge est le garant essentiel de la protection des libertés fondamentales

Présentation du sujet :

- Garant : protecteur, garantit les libertés qui auxquelles il est porté atteinte
- Essentiel : le plus important, indispensable
- Juge : renvoie à plusieurs juges = nationaux/internationaux, constitutionnel/administratif/judiciaire
- L'inscription de libertés dans un texte est insuffisante : le juge vient garantir leur respect
- Les juges ont parfois aussi pallié aux insuffisances des textes en dégageant des nouveaux droits
- Le juge a été institué comme un protecteur des libertés (I), et il est devenu un acteur dynamique de la protection de ces libertés (II)

I. Le juge, protecteur institutionnel des libertés

A. La consécration des juges au plus haut niveau de la hiérarchie des normes

- Niveau national : Constitution instaure les 3 juges, leur composition et leurs compétences :
  - Conseil constitutionnel : Titre VII Constitution
  - Autorité judiciaire : Titre VIII Constitution
  - Juge administratif : pas de consécration en tant que tel, CE mentionné articles 39, 61-1 et 65 Constitution
- Niveau international :
  - CEDH et Convention européenne des droits de l'homme
  - CJUE chargée notamment de la Charte européenne des droits fondamentaux
  - Juges nationaux aussi chargés de faire respecter les traités internationaux

B. Des mécanismes permettant de garantir les libertés

- Impartialité des juges :
  - Nomination
  - Inamovibilité
  - Discipline
- Procédures de garantie des libertés :
  - QPC
  - Référé-liberté
  - Action de groupe
- Contrôle de la mise en œuvre de régimes d'exception :
  - État d'urgence

    - Circonstances exceptionnelles
- Élargissement des normes de référence :
    - Bloc de constitutionnalité
    - Traités internationaux : CCass, 24 mai 1975, *Jacques Vabre* ; CE, 20 octobre 1989, *Nicolo*

II. Le juge, acteur dynamique de la protection des libertés

A. De nouvelles libertés reconnues par les juges

- Libertés contemporaines dégagées de textes anciens
- Jurisprudence peut reconnaître des droits qui seront ensuite consacrés à un niveau supérieur : Charte de l'environnement
- Protection des données personnelles : article 2 DDHC (CC, 22 mars 2012, *Loi relative à la protection de l'identité*) ; article 8 CEDH (CEDH, 28 mars 1996, 4 décembre 2008, *S. et Marper c/ Royaume-Uni*)
- Environnement : article 8 CEDH (CEDH, 9 avril 2024, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c/ Suisse*)
- Identité de genre : article 8 CEDH (CEDH, 6 avril 2017, *A.P., Garçon et Nicot c/ France*)

B. Des droits inédits créés par le juge

- Les juges peuvent consacrer des droits sans les rattacher à un texte
- Dignité de la personne humaine (CE, 27 octobre 1995, *Morsang-sur-Orge*)
- Droit de solliciter le statut de réfugié et de demeurer en France le temps nécessaire à l'examen de la demande (CE, 2 mai 2001, *Ministre de l'intérieur*)
- Liberté d'exercice de la profession d'expert en automobile (CE, 15 décembre 2002)

---

3. Sujet – Commentaire de texte

« *Qu'aurait pensé Montesquieu de la condamnation de Nicolas Sarkozy ? Retour sur trois siècles de défiance du juge* », L'Express, 5 octobre 2025

Idées. La sévérité du jugement prononcé à l'encontre de l'ancien président de la République ravive les soupçons de partialité des juges. Une défiance qui traverse les siècles.

L'Express
Par Ambre Xerri
Publié le 05/10/2025 à 08:00

Symbole de l'égalité des citoyens devant la loi pour les uns, la condamnation de Nicolas Sarkozy à cinq ans de prison avec exécution provisoire, dans l'affaire libyenne, nourrit, pour les autres, les suspicions d'une justice partiale. Partout, des pénalistes et d'autres éminents spécialistes du droit jusqu'à l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel Jean-Éric Schoettl, interrogent : ce verdict serait-il politique ? Les magistrats auraient-ils jugé à l'aune de leurs convictions idéologiques ? Ou prendraient-ils simplement leur revanche sur un ancien président qui ne s'est pas toujours montré tendre à leur endroit ?

Des soupçons qui ressurgissent quasi systématiquement lors de procès visant des personnalités publiques – Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, François Fillon, et 2 400 ans avant eux, Socrate. Mais aussi, lorsque des juridictions suprêmes appelées à se prononcer sur une loi - Conseil d'État ou Conseil

constitutionnel par exemple – enjoignent le législateur à revoir sa copie - et souvent, ses ambitions. Cette situation a d'ailleurs favorisé la démocratisation de l'expression de "gouvernement des juges", amenée au milieu du XXe siècle par le juriste Édouard Lambert pour décrire le droit de vie ou de mort exercé par la Cour suprême américaine sur les textes votés par le Congrès.

Le bras de fer de Roosevelt avec la très politisée Cour suprême

Au début des années 30, la possibilité laissée aux juges de donner un avis sur les lois votées par les représentants du peuple provoque des crises d'urticaire au président Franklin Delano Roosevelt. Le démocrate, pris d'un feu réformiste, s'engage dans une croisade avec la Cour suprême qui vient de retoquer plusieurs mesures de son New Deal. Pour tordre le cou à cette institution qui agit selon lui "non pas comme un organe judiciaire, mais comme un organe politique", Roosevelt dégaine début février 1937 son fameux *Court packing plan*.

Alors qu'il est d'usage que neuf juges siègent à la Cour suprême, le projet de loi prévoit la possibilité d'aller au-delà. Le président pourrait ainsi nommer de nouveaux juges - favorables à sa politique - à chaque fois qu'un des membres aurait atteint l'âge de 70 ans. Pour justifier ce pied de nez fait à la sacro-sainte Cour suprême, "FDR" prend à témoin le peuple américain dans une causerie radiophonique - ses très populaires *fireside chat* - le 9 mars 1937 : "Notre difficulté avec la Cour ne vient pas de l'institution en tant que telle, mais des êtres humains qui la composent", ose-t-il.

Avant d'abonder avec gravité : "Nous ne pouvons pas livrer notre destin constitutionnel au jugement personnel de quelques hommes qui, par peur de l'avenir, nous refuseraient les moyens nécessaires pour affronter le présent." Près d'un siècle plus tard, en France, Gabriel Attal, député, met en garde contre le risque de voir la Ve République basculer dans une "vétocratie", après la censure d'une partie de sa loi sur la justice des mineurs. Mais le pays n'a pas attendu son plus jeune Premier ministre pour s'interroger sur la place et les pouvoirs accordés aux magistrats.

Mettre les juges au pas, une priorité pour les révolutionnaires

Sous l'Ancien Régime déjà, les juges n'avaient pas bonne presse. Les accusations de corruption, légion, reposaient en grande partie sur l'existence du système dit des "épices", ces sommes versées par les parties d'un procès aux magistrats. Sortes de pots-de-vin légaux, elles garantissaient néanmoins une certaine autonomie aux juges qui, ne dépendant pas financièrement du roi, pouvaient faire fonctionner à plein régime leur droit de remontrances. Après la révolution, cette liberté d'action horrifie les Marat, Robespierre, Barnave, Desmoulins et consorts, inquiets que les juges, réputés très conservateurs, n'entravent leurs réformes. Le lecteur ne sera donc pas surpris d'apprendre que "les premiers débats au sein de l'Assemblée nationale constituante portaient précisément sur la justice et les moyens de la limiter", raconte le juriste Matthieu Bertozzo.

Pour mettre les juges au pas, la pratique des épices, héritée du Moyen-Âge est supprimée dès le 11 août 1789. Les "arrêts de règlement" qui permettent aux magistrats de créer une norme à partir d'un jugement, sont également interdits. Les Parlements de l'Ancien Régime commencent par être suspendus avant d'être "supprimés dans une relative indifférence, voire une certaine satisfaction", souligne le constitutionnaliste Benjamin Morel. Et de résumer : "La révolution s'est construite contre les Parlements de l'Ancien Régime, et tout est pensé pour se prémunir de l'appréciation de ces juges politisés qui pourraient dénaturer les grands textes votés par l'Assemblée." De quoi expliquer ces mots de Robespierre : "Si la loi peut être interprétée, augmentée ou appliquée au gré d'une volonté particulière, l'homme n'est plus sous la sauvegarde de la loi mais sous la puissance de celui qui l'interprète, l'augmente ou l'applique."

Montesquieu, le rêve d'un juge sans pouvoir d'interprétation

Cette conception resserrée du juge découle directement de la pensée montesquienne des Lumières. L'auteur *De l'esprit des lois* estime que le juge est une institution dangereuse en ce qu'il dispose d'un pouvoir discrétionnaire. Raison pour laquelle, celui-ci doit être réduit à n'être que "la bouche de la loi". Passée dans la postérité, la formule signifie que les prérogatives du juge doivent être circonscrites à

l'application de syllogismes. Dès lors, aucun pouvoir d'interprétation, même le plus infinitésimal, ne doit lui être confié. C'est d'ailleurs en ce sens que l'on peut imaginer un Montesquieu révolté à l'annonce de la condamnation de Nicolas Sarkozy qui repose, et les juges le reconnaissent d'eux-mêmes, sur un faisceau d'indices.

Si elle n'est plus d'actualité, la théorie de Montesquieu irrigue les lois des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, qui fixent des garde-fous très stricts. Les juges se voient interdire toute immixtion dans l'action publique. Il leur est par exemple défendu, sous peine de forfaiture, de troubler en quoi que ce soit les opérations des corps administratifs. La carte judiciaire est en outre profondément réorganisée : tribunaux de district, élection de juges de paix par les citoyens actifs, et mise en place d'un tribunal de cassation destiné à veiller à l'uniformité des jugements. Une transfiguration de l'ordre judiciaire qui conduit la justice à perdre "considérablement en crédibilité", explique le juriste Matthieu Bertozzo dans *Le 3 novembre 1790, la mise au pas des juges sous la Révolution*.

Au discrédit de la justice de l'Ancien Régime s'ajoute par la suite le traumatisme du Tribunal révolutionnaire, de sorte que le désaveu fut encore plus profond à la sortie de la Terreur. L'homme du XIX^{e} siècle n'imagine d'ailleurs pas une seconde que ses droits et libertés puissent être garantis par l'institution judiciaire. À L'Express, le professeur de droit public à l'université Paris-Panthéon-Assas Benjamin Morel explique qu'"après la Révolution, la conception de Montesquieu selon laquelle seul le Parlement agit dans l'intérêt général, prévaut".

Il faut attendre les années 1830 pour que les tribunaux recouvrent leur marge d'interprétation, puis le début de la III^{e} République pour que, par la pratique jurisprudentielle, le juge s'impose comme véritable fabriquant de normes aux côtés du pouvoir législatif. Une évolution importée des modèles anglais et américain, qui, aujourd'hui encore, interroge, et qui, à n'en pas douter, ferait horreur à Montesquieu.

Présentation du sujet :

- Condamnation de N. Sarkozy le 25 septembre 2025 à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans le cadre du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Critiques virulentes du verdict, au motif notamment d'une partialité des juges
- Montesquieu, *De l'Esprit des Lois* : ouvrage du XVIII^{ème} siècle, qui traite notamment de la théorie de la séparation des pouvoirs comme fondement d'une démocratie
- Séparation des pouvoirs : fonctions distinctes entre exécutif/législatif/judiciaire, mais contrôle mutuel (« le pouvoir arrête le pouvoir »). L'autorité judiciaire (qui n'est pas désignée en tant que pouvoir dans la Constitution), doit se limiter à appliquer la loi selon Montesquieu : « *les juges ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi : des êtres inanimés qui ne peuvent en modérer ni la force ni la vigueur* »
- « Gouvernement des juges » : antinomie car le juge n'est pas censé gouverner mais sanctionner la méconnaissance de la loi => atteinte à la séparation des pouvoirs. Ici, critique de la condamnation de N. Sarkozy car les juges auraient jugé non pas en conformité avec la loi, mais selon d'autres considérations (politiques, etc)

I. Une séparation des pouvoirs garantie dans un État de droit

A. Le juge, un professionnel du droit qui juge au nom du peuple

- Garanties d'indépendance de la magistrature
- Procédures de garantie de l'impartialité : déport, récusation
- Loi des 16 et 24 août 1790 : interdiction au juge judiciaire de juger l'administration

B. L'autorité judiciaire est encadrée par les autres pouvoirs

- Nomination et sanction par l'exécutif (article 13 de la Constitution, Conseil supérieur de la magistrature)
- Encadrement de l'autorité judiciaire par la loi : article 34 de la Constitution « *la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats* »
- Soumission du judiciaire à la loi
- Codifications de jurisprudences : code des relations entre le public et l'administration, code général des la fonction publique
- Lois de validation : neutralisation d'une décision juridictionnelle par le législateur

II. Une autorité judiciaire amenée à interpréter voire créer le droit

A. La consécration de droits et libertés par le juge

- Marge d'interprétation importante du juge dans la protection des libertés, en l'absence de consécration textuelle : bloc de constitutionnalité qui vient compenser le silence de la Constitution en matière de libertés
- Consécration de nouveaux droits et libertés, qui semblent parfois éloignés des textes auxquels ils se rattachent : protection des données personnelles et article 2 DDHC ; lutte contre le changement climatique et article 8 CEDH
- A l'inverse, marge d'appréciation étroite du juge pénal

B. Des juridictions teintées de politique

- Composition politique de certaines juridictions : Conseil constitutionnel, Cour de Justice de la République
- Décisions critiquables de ces juridictions : CJR accusée de prononcer des condamnations trop faibles
- Juridictions supranationales qui échappent à la séparation des pouvoirs en droit interne : CEDH, CJUE

---

4. Sujet – Commentaire d'arrêt

CC, 16 juillet 1971, *Liberté d'association*

Décision 71-44 DC - 16 juillet 1971

Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 1er juillet 1971 par le Président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, du texte de la loi, délibérée par l'Assemblée nationale et le Sénat et adoptée par l'Assemblée nationale, complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la Constitution et notamment son préambule ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, modifiée ;
Vu la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées ;

1. Considérant que la loi déférée à l'examen du Conseil constitutionnel a été soumise au vote des deux assemblées, dans le respect d'une des procédures prévues par la Constitution, au cours de la session du Parlement ouverte le 2 avril 1971 ;

2. Considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d'association ; que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; qu'en vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable ; qu'ainsi, à l'exception des mesures susceptibles d'être prises à l'égard de catégories particulières d'associations, la constitution d'associations, alors même qu'elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire ;

3. Considérant que, si rien n'est changé en ce qui concerne la constitution même des associations non déclarées, les dispositions de l'article 3 de la loi dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, ont pour objet d'instituer une procédure d'après laquelle l'acquisition de la capacité juridique des associations déclarées pourra être subordonnée à un contrôle préalable par l'autorité judiciaire de leur conformité à la loi ;

4. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 3 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complétant l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901, ainsi, par voie de conséquence, que la disposition de la dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi soumise au Conseil constitutionnel leur faisant référence ;

5. Considérant qu'il ne résulte ni du texte dont il s'agit, tel qu'il a été rédigé et adopté, ni des débats auxquels la discussion du projet de loi a donné lieu devant le Parlement, que les dispositions précitées soient inséparables de l'ensemble du texte de la loi soumise au Conseil ;

6. Considérant, enfin, que les autres dispositions de ce texte ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ;

Décide :

Article premier : Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 3 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complétant les dispositions de l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901 ainsi que les dispositions de l'article 1er de la loi soumise au Conseil leur faisant référence.

Article 2 : Les autres dispositions dudit texte de loi sont déclarées conformes à la Constitution.

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Présentation de l'arrêt :

- CC saisi par le président du Sénat d'un contrôle de la constitutionnalité de la loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901
- Loi contrôlée vise à instaurer un régime d'autorisation préalable pour les associations au lieu d'un régime de déclaration
- Apport décision : 1er PFRLR = liberté d'association ; création du bloc de constitutionnalité
- Solution : non-conformité du régime d'autorisation préalable au PFRLR de la liberté d'association
- Problème de droit : en quoi la création du bloc de constitutionnalité a permis la garantie de la liberté d'association ?

I. La consécration du bloc de constitutionnalité comme norme de référence de contrôle

A. La reconnaissance du Préambule de la Constitution de 1946

- Alinéa 1er Préambule : PFRLR
- 1er PFRLR reconnu par le CC, mais le CE l'avait déjà dégagé (CE, 1956, *Amicale des annamites de Paris*)
- 3 conditions :
    - Règle suffisamment générale et importante, et relative à des droits et libertés fondamentaux, la souveraineté nationale ou l'organisation des pouvoirs publics
    - Base textuelle dans une loi antérieure à 1946 sous un régime républicain
    - Règle appliquée de manière continue

B. La censure du législateur au nom de la protection d'une liberté

- Consécration du bloc de constitutionnalité : DDHC, Préambule C 1946, Constitution 1958, Charte de l'environnement, PFRLR, PPNNT, principes à valeur constitutionnelle
- Bloc de constitutionnalité vient pallier l'absence de droits fondamentaux dans la Constitution, et consacre des droits et libertés au niveau constitutionnel
- Censure du législateur qui porterait excessivement atteinte aux libertés

II. La garantie de la liberté d'association par le bloc de constitutionnalité

A. Le renforcement de la protection juridictionnelle des libertés fondamentales

- Avant 1971 : CC contrôlait les rapports entre les pouvoirs publics mais non les libertés fondamentales
- CC s'affirme comme protecteur des libertés fondamentales, aux côtés du Conseil d'État et de la Cour de cassation
- Ici : liberté d'association érigée au niveau constitutionnel alors qu'elle n'était consacrée qu'au niveau législatif

B. Le renouveau du Conseil constitutionnel

- Le CC va s'imposer comme véritable gardien des libertés fondamentales
- Autres PFRLR consacrés par la suite : enseignement, interdiction d'extrader pour un motif politique, indépendance de la juridiction administrative…
- Révision constitutionnelle 2008 : création de la QPC